Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

Derecho Civil

Introducción y Parte General

Del derecho y la codificación a la persona, el patrimonio, los actos jurídicos y la extinción de las relaciones jurídicas

Apuntes integrados de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

Buenos Aires, Argentina

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de «Derecho Civil — Parte General» y no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

Introducción general **1**

I El derecho, la justicia y el derecho civil 4

1. La noción de derecho y de justicia 5

1.1. Origen etimológico de la palabra derecho 5
1.2. La justicia como dar a cada uno lo suyo 5
1.2.1. Tipos de justicia 6
1.3. Opción metodológica: el iusnaturalismo 6
1.4. Dignidad de la persona y bien común 7
1.5. Cuadro Cornell: la noción de derecho y de justicia 7

2. Derecho objetivo, subjetivo y normativo 9

2.1. Las tres dimensiones de la palabra derecho 9
2.2. Teorías clásicas del derecho subjetivo 9
2.3. Críticas colectivista y positivista al derecho subjetivo 10
2.4. La teoría de John Finnis 11
2.5. Cuadro Cornell: sentidos del derecho y derecho subjetivo 11

3. Las grandes divisiones del derecho 13

3.1. Derecho natural y derecho positivo 13
3.2. Derecho público y derecho privado 14

4. El derecho civil, la relación jurídica y su Parte General 15

4.1. El derecho civil como rama madre del derecho privado 15
4.2. La relación jurídica: sujeto, objeto y causa 15
4.2.1. Sujetos (elemento personal) 16
4.2.2. Objeto (elemento real) 16

4.2.3. Causa (elemento normativo) 16
4.3. La Parte General en el Código Civil y Comercial 17
4.4. Cuadro Cornell: el derecho civil y su Parte General 18

II La codificación del derecho civil 19

5. La codificación: concepto, caracteres y orígenes 20
5.1. Concepto y caracteres de la codificación 20
5.2. Ventajas e inconvenientes de la codificación 20
5.3. Orígenes históricos de la codificación moderna 21
5.4. Cuadro Cornell: la codificación 21

6. El Código de Vélez Sarsfield y la reforma de la Ley 17.711 23
6.1. Contexto constitucional y elaboración del Código de Vélez 23
6.2. Fuentes del Código de Vélez 23
6.3. Método del Código de Vélez 24
6.4. Proyectos de reforma anteriores a 1968 25
6.5. La Ley 17.711 (1968): primera reforma integral 25
6.5.1. Institutos incorporados 25
6.5.2. Reformas posteriores y proyectos de unificación 26
6.6. Cuadro Cornell: el Código de Vélez y la Ley 17.711 27

7. El Código Civil y Comercial de la Nación 28
7.1. Comisión redactora y elaboración del anteproyecto 28
7.2. Trámite parlamentario 28
7.3. Método del Código Civil y Comercial frente al Código de Vélez 29
7.4. Grandes líneas del Código Civil y Comercial 29
7.4.1. En materia de persona y familia 29
7.4.2. En materia de derecho privado patrimonial 31
7.5. Cuadro Cornell: el Código Civil y Comercial 32

III La Constitución y el Título Preliminar del Código Civil y Comercial 33

8. La constitucionalización del derecho privado 34

8.1. Qué significa constitucionalizar el derecho privado . . . 34
8.2. Las tres vías de constitucionalización . . . 34
8.2.1. La vía reformadora . . . 34
8.2.2. La vía hermenéutica . . . 35
8.2.3. La vía de aplicación directa . . . 35
8.3. Ventajas y riesgos de la constitucionalización . . . 35
8.3.1. Ventajas . . . 35
8.3.2. Riesgos . . . 36
8.4. Cuadro Cornell: la constitucionalización del derecho privado . . . 37

9. El Título Preliminar y la unificación civil y comercial 38

9.1. Importancia y estructura del Título Preliminar . . . 38
9.2. La distinción entre derecho y ley . . . 39
9.3. Unificación de la materia civil y comercial . . . 39
9.3.1. Materias que permanecen fuera del código . . . 39
9.3.2. Contenido comercial incorporado . . . 39

IV Las fuentes del derecho y la aplicación de la ley 41

10. Concepto y clasificación de las fuentes del derecho 42

10.1. Concepto de fuentes del derecho . . . 42
10.2. Fuentes formales y fuentes materiales . . . 42
10.2.1. Fuentes formales en el derecho argentino . . . 43
10.2.2. Fuentes materiales en el derecho argentino . . . 43
10.3. El desborde de las fuentes . . . 44
10.4. Cuadro Cornell: concepto y clasificación de las fuentes . . . 44

11. Arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial 46

11.1. Artículo 1: fuentes y aplicación . . . 46
11.1.1. Tratados que no son de derechos humanos . . . 46

11.2. La jurisprudencia en el artículo 1: el debate legislativo 47
11.3. Artículo 2: interpretación de la ley 47
11.4. Cuadro Cornell: artículos 1 y 2 del Código 48

12. La ley como fuente formal **50**
12.1. Concepto de ley: definición iusnaturalista 50
12.2. Ley en sentido formal y ley en sentido material 50
12.3. Caracteres de la ley como fuente formal 52
12.4. Procedimiento de formación de las leyes 53
12.5. Clasificación de las leyes 54
12.5.1. Ejemplo problemático: el artículo 765 CCyC 55
12.6. Orden jerárquico de las leyes en el derecho argentino 55
12.7. Cuadro Cornell: la ley como fuente formal 56

13. Vigencia temporal de la ley y cómputo de plazos **58**
13.1. Vigencia temporal de la ley 58
13.1.1. Modos de derogación 59
13.2. Modo de contar los intervalos del derecho (art. 6 CCyC) 59
13.3. Cuadro Cornell: vigencia de la ley y cómputo de plazos 60

14. Los efectos de la ley con relación al tiempo **62**
14.1. Planteamiento del problema 62
14.1.1. Tres modos de aplicación de la ley en el tiempo 62
14.2. El sistema del Código de Vélez (1871) 63
14.2.1. El derecho en expectativa (art. 4044) 63
14.2.2. La mera facultad (art. 4045) 64
14.2.3. Las excepciones del sistema 64
14.2.4. Crítica al sistema de Vélez 65
14.3. La reforma de la Ley 17.711 (1968) 66
14.3.1. Primer principio: efecto inmediato de la nueva ley imperativa 66
14.3.2. Segundo principio: irretroactividad de la ley 67
14.3.3. Tercer principio: efecto diferido de la nueva ley supletoria 67
14.4. El régimen vigente: artículo 7 del CCyC 68

14.5. Cuadro Cornell: efectos de la ley en el tiempo 69

15.La costumbre como fuente formal **71**

15.1. Concepto y elementos 71

15.2. Importancia histórica de la costumbre 71

15.3. Tipos de costumbre 72

15.4. La costumbre en el Código Civil y Comercial 73

15.4.1. Presencia de la costumbre en materia de contratos 73

15.5. Cuadro Cornell: la costumbre jurídica 75

16.Jurisprudencia, fallos plenarios y doctrina **76**

16.1. La jurisprudencia como fuente material 76

16.2. Los fallos plenarios como fuente formal 76

16.3. Difusión de la jurisprudencia 78

16.4. La doctrina como fuente material 78

16.5. Otras fuentes materiales: derecho comparado y principios jurídicos 79

16.6. Cuadro Cornell: jurisprudencia, plenarios y doctrina 79

16.7. Síntesis de las fuentes del derecho 80

V Límites al ejercicio de los derechos: orden público, buena fe y abuso **82**

17.El orden público **83**

17.1. Punto de partida: la libertad de contratar 83

17.2. Teorías sobre el orden público 84

17.2.1. Leyes imperativas y leyes supletorias 84

17.2.2. Género y especie: la crítica a la teoría de Bordas 85

17.2.3. Definición mayoritaria y caracteres del orden público 85

17.3. Tres grandes supuestos de aplicación 85

17.3.1. Orden público y autonomía de la voluntad 86

17.3.2. El fraude a la ley 87

17.3.3. La renuncia general a las leyes 88

17.3.4. Orden público y ley extranjera 88

17.3.5. Orden público y efectos de la ley en el tiempo . . . 89
17.4. Cuestiones frecuentes sobre el orden público . . . 89
17.5. Cuadro Cornell: el orden público . . . 90

18. Principios del derecho civil: buena fe y equidad **91**
18.1. El principio de buena fe . . . 91
18.2. El principio de equidad . . . 91
18.3. Cuadro Cornell: título Preliminar, unificación y principios . . . 92

19. El problema conceptual del abuso del derecho **93**
19.1. Introducción . . . 93
19.2. El dilema del abuso del derecho . . . 94
19.2.1. La noción de derecho subjetivo como punto de partida . . . 94
19.3. Caso práctico: propiedad horizontal . . . 94
19.4. Críticas a la noción de abuso del derecho . . . 94
19.5. Terminología técnica correcta . . . 95
19.6. Cuadro Cornell: el problema conceptual del abuso . . . 95

20. Criterios teóricos para determinar el abuso **96**
20.1. Criterios subjetivos . . . 96
20.2. Criterios objetivos . . . 96
20.3. Criterio mixto . . . 97
20.4. Cuadro Cornell: criterios para determinar el abuso . . . 97

21. El abuso del derecho en el derecho argentino **99**
21.1. El Código Civil de Vélez Sarsfield (1871) . . . 99
21.2. La jurisprudencia anterior a la reforma de 1968 . . . 99
21.3. La Constitución de 1949 . . . 99
21.4. El fallo Reina (Corte Suprema, 1956) . . . 100
21.5. La Ley 17.711 (1968): reforma del artículo 1071 . . . 100
21.5.1. Tres cambios fundamentales . . . 101
21.6. El Código Civil y Comercial de la Nación (2015) . . . 101
21.6.1. Tres cambios respecto de la Ley 17.711 . . . 102
21.7. Otros artículos relacionados del Código Civil y Comercial . . . 102

21.8. Cuadro Cornell: el abuso del derecho en el derecho argentino 104

VI La persona humana: reconocimiento, existencia y dignidad 106

22. La persona humana: fundamento y reconocimiento jurídico 107

22.1. Fundamentos filosóficos y etimológicos 107

22.1.1. El origen etimológico de *persona* 107

22.1.2. La definición filosófica de Boecio 107

22.1.3. El ser humano como ser en relación 108

22.1.4. Todo ser humano es persona 108

22.2. La persona en los tratados internacionales de derechos humanos 109

22.2.1. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 109

22.2.2. El Pacto de San José de Costa Rica 109

22.2.3. La dignidad humana: concepto y dimensiones 109

22.3. La persona humana en el Código Civil y Comercial 110

22.3.1. Los textos derogados de Vélez 111

22.3.2. El artículo 51 vigente 112

22.4. Cuestiones frecuentes sobre el concepto de persona 112

22.5. Cuadro Cornell: la persona humana 112

23. El comienzo de la existencia: la persona por nacer 114

23.1. La tradición romana 114

23.2. El Código de Vélez (1871) 114

23.3. La reforma constitucional de 1994 y los tratados 115

23.4. El Código Civil y Comercial 115

23.4.1. El debate de elaboración y el texto del artículo 19 115

23.4.2. Concepción: ¿fecundación o implantación? 116

23.4.3. Otras cuestiones sobre embriones 117

23.5. La época de la concepción (art. 20 CCyC) 117

23.6. El nacimiento con vida (art. 21 CCyC) 118

23.6.1. Qué significa nacer con vida 118

23.7. El régimen jurídico de la persona por nacer 119

23.8. Evolución del reconocimiento de la persona por nacer 120
23.9. Cuadro Cornell: el comienzo de la existencia 120

24. Derechos personalísimos: noción, caracteres y régimen 122
24.1. Introducción 122
24.2. Alcance y orden de exposición 122
24.3. Noción de derechos personalísimos 123
24.4. Importancia y contexto actual 123
24.4.1. Datos personales y privacidad digital 124
24.5. Antecedentes en Argentina 124
24.5.1. El Código de Vélez 124
24.5.2. Evolución legislativa en Argentina 125
24.5.3. La Constitución Nacional de 1994 125
24.6. Caracteres de los derechos personalísimos 126
24.7. Clasificación tripartita 126
24.8. Regulación en el Código Civil y Comercial 127
24.8.1. Disposiciones generales: artículo 51 127
24.8.2. Medios de protección: prevención y reparación 127
24.8.3. Disponibilidad relativa: artículo 55 128
24.9. Derecho a la libertad 129
24.10 Cuadro Cornell: derechos personalísimos 130

VII Los atributos de la persona humana 132

25. Los atributos de la persona humana 133
25.1. Enumeración de los atributos 133

26. El nombre 134
26.1. Concepto y caracteres 134
26.2. Régimen legal: evolución legislativa 134
26.3. El nombre como derecho y como deber (art. 62) 135
26.4. El prenombre (art. 63) 135
26.4.1. Adquisición y orden de elección 135

26.4.2. Reglas y límites . . . 136
26.5. El apellido . . . 136
26.5.1. Filiación matrimonial (art. 64) . . . 136
26.5.2. Filiación extramatrimonial . . . 137
26.5.3. Persona sin filiación determinada (art. 66) . . . 137
26.5.4. Apellido de los cónyuges, viudez y adopción . . . 137
26.6. Cambio de nombre y acciones de protección . . . 138
26.6.1. Vía judicial: justos motivos (art. 69) . . . 138
26.6.2. Vía administrativa . . . 139
26.6.3. Procedimiento y acciones de protección . . . 139
26.7. La filiación y el nombre . . . 139
26.8. Cuadro Cornell: el nombre . . . 141

27. El domicilio **142**
27.1. Concepto, finalidad y ubicación normativa . . . 142
27.1.1. Domicilio civil y domicilio constitucional . . . 142
27.1.2. Domicilio y residencia . . . 143
27.2. Clasificación: domicilio general y especial . . . 143
27.3. El domicilio real (art. 73) . . . 144
27.4. El domicilio legal (art. 74) . . . 145
27.5. El domicilio especial . . . 146
27.5.1. Domicilio convencional o de elección . . . 146
27.5.2. Domicilio procesal . . . 146
27.5.3. Domicilio profesional (art. 73, segundo párrafo) . . . 147
27.6. Domicilio desconocido (art. 76) . . . 147
27.7. Efectos jurídicos del domicilio (art. 78) . . . 148
27.8. Precisiones adicionales . . . 148
27.9. Cuadro Cornell: el domicilio . . . 148

28. El estado civil **150**
28.1. Concepto de estado civil . . . 150
28.1.1. Antecedentes en el derecho romano . . . 150
28.1.2. El estado en la era de los derechos humanos . . . 151

28.1.3. Importancia e incidencia del estado civil . . . 151
28.2. Las acciones de estado . . . 152
28.3. La posesión de estado . . . 152
28.3.1. Elementos históricos: *nomen*, *tractatus* y *fama* . . . 153
28.3.2. Las cuatro aplicaciones en el CCyC . . . 153
28.4. La prueba del estado civil . . . 155
28.4.1. Las partidas . . . 155
28.4.2. La prueba supletoria . . . 156
28.4.3. Fallecimiento sin hallazgo o identificación del cadáver (art. 98) . . . 156
28.5. Cuadro Cornell: el estado civil . . . 156

VIII La capacidad de la persona humana 158

29.La capacidad jurídica 159
29.1. Concepto de capacidad jurídica . . . 159
29.1.1. Capacidad de derecho . . . 159
29.1.2. Capacidad de ejercicio . . . 160
29.2. Incapacidades de derecho: el artículo 1002 . . . 160
29.3. Incapaces de ejercicio . . . 161
29.4. Capacidad restringida y sistemas de apoyo . . . 162
29.4.1. Personas inhabilitadas (pródigos) . . . 163
29.4.2. Representantes legales (art. 101) . . . 163
29.5. El Ministerio Público (art. 103) . . . 163

30.El régimen de capacidad de las personas menores de edad 165
30.1. Régimen general . . . 165
30.1.1. Menor de edad y adolescente . . . 165
30.1.2. La incapacidad de ejercicio como medida de protección . . . 165
30.1.3. La mayoría de edad a través del tiempo . . . 166
30.1.4. ¿Regla de capacidad o de incapacidad? . . . 166
30.2. Principios rectores (arts. 26 y 639) . . . 167
30.2.1. Representación de los menores . . . 167

30.2.2. Grado de madurez suficiente . . . 168
30.3. Actos que la ley autoriza realizar según la edad . . . 168
30.3.1. Tratamientos médicos (art. 26) . . . 168
30.3.2. Resumen de actos permitidos . . . 168
30.3.3. El título habilitante (art. 30) . . . 169
30.3.4. El matrimonio de personas menores de edad . . . 169
30.4. Consecuencias jurídicas y fin de la incapacidad . . . 170
30.4.1. Nulidad relativa de los actos celebrados sin representación . . . 170
30.4.2. Responsabilidad civil por daños causados por menores . . . 170
30.4.3. Fin de la incapacidad: la mayoría de edad . . . 170
30.4.4. Fin de la incapacidad: la emancipación por matrimonio . . . 170
30.4.5. Restricciones a la capacidad del emancipado (arts. 28 y 29) . . . 171
30.4.6. Mayoría de edad anticipada para egresados de institutos (Ley 27.364) 171
30.5. Cuadro Cornell: la capacidad jurídica y el régimen de los menores . . . 172

31. El marco convencional y los antecedentes del régimen de capacidad 174
31.1. Presentación del tema . . . 174
31.2. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 175
31.2.1. El artículo 12 de la CDPD: igual reconocimiento como persona ante la ley . . . 175
31.2.2. El Comité de la CDPD y el modelo de apoyo a la decisión . . . 178
31.3. El régimen del Código Civil derogado: incapaces e inhabilitados . . . 178
31.3.1. Figura 1: los incapaces de hecho declarados judicialmente . . . 178
31.3.2. Figura 2: los inhabilitados (artículo 152 bis) . . . 178
31.4. La Ley de Salud Mental 26.657 y el artículo 152 ter . . . 179
31.5. Cuadro Cornell: el marco convencional y los antecedentes del régimen de capacidad . . . 180

32. Tipos de restricciones a la capacidad en el Código Civil y Comercial 181
32.1. Reglas generales del artículo 31 . . . 181
32.2. Personas con capacidad restringida (artículo 32, primer párrafo) . . . 182
32.2.1. Requisitos del artículo 32 . . . 182
32.2.2. Régimen de las personas con capacidad restringida . . . 182

32.3. Personas incapaces (artículo 32, último párrafo) . . . 183
32.3.1. Régimen de las personas incapaces . . . 183
32.4. Inhabilitados por prodigalidad (artículo 48) . . . 184
32.4.1. Régimen de los inhabilitados . . . 184
32.5. Cuadro Cornell: tipos de restricciones a la capacidad en el Código Civil y Comercial . . . 185

33. El proceso de determinación de la capacidad 186
33.1. Juez competente y legitimados activos . . . 186
33.1.1. Juez competente (artículo 36) . . . 186
33.1.2. Legitimados activos (artículo 33) . . . 186
33.2. Medidas cautelares y entrevista personal . . . 187
33.2.1. Medidas cautelares (artículo 34) . . . 187
33.2.2. Entrevista personal (artículo 35) . . . 187
33.3. La persona como parte y asistencia letrada . . . 188
33.4. Dictamen interdisciplinario y contenido de la sentencia . . . 188
33.4.1. Artículo 37: el dictamen interdisciplinario . . . 188
33.4.2. Artículo 38: el contenido de la sentencia . . . 189
33.5. Registro, revisión, internación y traslados . . . 189
33.5.1. Registro (artículo 39) . . . 189
33.5.2. Revisión (artículo 40) . . . 189
33.5.3. Internación (artículo 41) y traslados (artículo 42) . . . 190
33.6. Cuadro Cornell: el proceso de determinación de la capacidad . . . 191

34. Validez de los actos y sistema de apoyos 192
34.1. Nulidad de los actos posteriores y anteriores a la sentencia . . . 192
34.1.1. Actos posteriores a la inscripción (artículo 44) . . . 192
34.1.2. Actos anteriores a la sentencia (artículo 45) . . . 192
34.2. Cese de las restricciones (artículo 47) . . . 193
34.3. El sistema de apoyos (artículo 43) y conclusiones . . . 193
34.3.1. Salvaguardias: conflicto de intereses e influencia indebida . . . 194
34.3.2. Criterio de actuación de los apoyos . . . 194
34.3.3. Conclusiones generales . . . 194

34.4. Cuadro comparativo: régimen anterior y régimen vigente 195
34.5. Cuadro Cornell: repaso general del régimen de restricciones a la capacidad 195

IX El fin de la existencia de la persona humana 199

35.La muerte: fin de la existencia de la persona humana 200
35.1. Ubicación temática y relevancia práctica 200
35.2. La muerte: concepto, comprobación y normativa 200
35.2.1. Principio general 200
35.2.2. ¿Qué es la muerte? 201
35.2.3. Comprobación de la muerte 201
35.2.4. Instrumentos para acreditar la muerte 202
35.3. Donación de órganos y criterios de muerte encefálica 202
35.3.1. Consentimiento presunto 202
35.3.2. Antecedentes legislativos 203
35.3.3. Criterios actuales y Protocolo 2019 203
35.3.4. Garantías y críticas al régimen vigente 204
35.4. Conmoriencia y prueba supletoria del fallecimiento 204
35.4.1. Conmoriencia 204
35.4.2. Prueba supletoria del fallecimiento 204
35.4.3. Ejemplos desarrollados 205
35.5. Efectos jurídicos de la muerte 206
35.5.1. Efectos extrapatrimoniales 206
35.5.2. Protección jurídica post mortem 206
35.5.3. Efectos patrimoniales 206
35.5.4. Derechos no transmisibles 206
35.6. Síntesis del capítulo 207
35.7. Cuadro Cornell: la muerte 207

36.Marco conceptual e histórico 210
36.1. Introducción: ausencia y presunción de fallecimiento 210
36.2. El problema jurídico de fondo 211

36.3. Antecedentes históricos 211

37. La ausencia (arts. 79 a 84 CCyC) 213

37.1. Concepto de ausencia 213
37.2. Legitimación y juez competente 213
37.3. Procedimiento y curatela 214
37.4. Conclusión de la curatela 214

38. La presunción de fallecimiento (arts. 85 a 92 CCyC) 215

38.1. Caso ordinario (Art. 85 CCyC) 215
38.2. Caso extraordinario genérico (Art. 86, 1.er párr.) 215
38.3. Caso extraordinario específico (Art. 86, 2.do párr.) 216
38.4. Tabla comparativa de los tres casos 216
38.5. Casos reales ilustrativos 217

39. Procedimiento y sentencia de presunción de fallecimiento 218

39.1. Legitimación y juez competente 218
39.2. Diligencias probatorias 218
39.3. Sentencia y día presuntivo de fallecimiento 219

40. Garantías y efectos de la reaparición 220

40.1. Las tres garantías adoptadas 220
40.2. Duración de la prenotación (Art. 91 CCyC) 220
40.3. Efectos de la reaparición (Art. 91 CCyC) 221
40.4. Cuadro Cornell: ausencia y presunción de fallecimiento 221

X El sujeto de la relación jurídica: las personas jurídicas 224

41. Introducción a las personas jurídicas 225

41.1. Presentación del tema 225
41.2. El problema de fondo: la asociatividad humana 225
41.3. Regulación en el Código de Vélez (Ley 340, 1871) 226
41.4. El nuevo Código Civil y Comercial: metodología 226
41.5. Definición del artículo 141 del CCyC 227

41.6. Principio de especialidad . . . 227
41.7. Teorías sobre la naturaleza jurídica . . . 227
41.7.1. Teoría de la ficción (Savigny) . . . 227
41.7.2. Teorías negatorias de la personalidad . . . 228
41.7.3. Teorías de la realidad . . . 228
41.7.4. Teorías normativistas (Kelsen) . . . 228
41.8. Clasificación: personas jurídicas públicas y privadas . . . 228
41.8.1. Personas jurídicas públicas (arts. 146 y 147) . . . 229
41.8.2. Personas jurídicas privadas (art. 148) . . . 229
41.9. Ley aplicable (art. 150) . . . 230
41.10Personalidad diferenciada e inoponibilidad (art. 144) . . . 231

42.Régimen de las personas jurídicas privadas 232
42.1. Nombre (art. 151) . . . 232
42.2. Domicilio y sede social (arts. 152 y 153) . . . 233
42.3. Capacidad y principio de especialidad (arts. 141, 156) . . . 233
42.4. Patrimonio (arts. 143 y 154) . . . 234
42.5. Comienzo de la existencia (art. 142) . . . 234
42.6. Estatutos y gobierno (arts. 150, 158, 159, 160) . . . 235
42.6.1. Contenido del estatuto . . . 235
42.6.2. Deber de lealtad y diligencia de los administradores (art. 159) . . . 235

43.Responsabilidad civil de las personas jurídicas 236
43.1. Evolución histórica: del artículo 43 de Vélez al nuevo Código . . . 236
43.2. Tres supuestos de responsabilidad . . . 236
43.2.1. Responsabilidad por actos de directivos y administradores (art. 1763) 236
43.2.2. Responsabilidad por cosas y actividades riesgosas (art. 1757) . . . 237
43.2.3. Responsabilidad por los dependientes (art. 1753) . . . 237
43.3. Responsabilidad de los administradores (art. 160) . . . 237

44.Fin de la existencia y fundaciones 239
44.1. Causales de disolución (art. 163) . . . 239
44.2. Revocación estatal — garantías (art. 164) . . . 240

44.3. Reconducción y liquidación . . . 241
44.4. Las fundaciones (arts. 193–224) . . . 241
44.4.1. Patrimonio inicial suficiente . . . 241
44.4.2. Órgano de gobierno: Consejo de Administración . . . 242
44.4.3. Control externo . . . 242
44.4.4. Inmutabilidad del objeto (art. 216) . . . 242

45. Asociaciones civiles y simples asociaciones 243
45.1. Asociaciones civiles (arts. 168–186) . . . 243
45.1.1. Concepto y objeto . . . 243
45.1.2. Diferencia fundamental con las sociedades . . . 243
45.1.3. Constitución y contenido del estatuto (art. 170) . . . 244
45.2. Órganos de gobierno . . . 244
45.2.1. Comisión Directiva (art. 171) . . . 244
45.2.2. Asamblea . . . 245
45.2.3. Órgano de fiscalización . . . 245
45.3. Poder disciplinario . . . 245
45.3.1. Principios que rigen el poder disciplinario . . . 245
45.3.2. Límites de la revisión judicial . . . 246
45.4. Simples asociaciones (arts. 187–192) . . . 246
45.4.1. Diferencias con las asociaciones civiles . . . 246
45.4.2. Responsabilidad en las simples asociaciones (art. 191) . . . 247
45.5. Cuadro Cornell: repaso general de las personas jurídicas . . . 248

XI El objeto de la relación jurídica: patrimonio, derechos y bienes 252

46. El patrimonio 253
46.1. Planteo general . . . 253
46.2. El patrimonio como atributo de la personalidad . . . 253
46.3. El patrimonio como garantía común de los acreedores . . . 254
46.4. El patrimonio como universalidad de derecho . . . 254
46.4.1. Los patrimonios especiales . . . 255

46.5. Cuadro Cornell: el patrimonio 256

47. Clasificación de los derechos **257**

47.1. Derechos patrimoniales y extrapatrimoniales 257

47.2. Los derechos reales 257

47.3. Los derechos personales 258

47.4. Los derechos intelectuales 258

47.5. Cuadro Cornell: clasificación de los derechos 259

48. Bienes y cosas **260**

48.1. Distinción entre bienes y cosas 260

48.2. Muebles e inmuebles 260

48.2.1. Inmuebles 260

48.2.2. Cosas muebles 261

48.2.3. Importancia práctica de la distinción entre muebles e inmuebles . . 261

48.3. Cosas divisibles e indivisibles 262

48.4. Cosas principales y accesorias 262

48.5. Cosas consumibles y no consumibles; fungibles y no fungibles 263

48.6. Frutos y productos 263

48.7. Bienes según las personas 264

48.7.1. Bienes de incidencia colectiva 265

48.8. Cuadro Cornell: bienes y cosas 265

49. Garantía patrimonial, acreedores y acciones **267**

49.1. El patrimonio como garantía: repaso y profundización 267

49.2. Tipos de acreedores y preferencias de cobro 267

49.3. Bienes inembargables (Art. 744 CCyC) 268

49.4. La protección de la vivienda (Arts. 244 y ss. CCyC) 268

49.5. Acciones de los acreedores 269

49.5.1. Medidas preventivas 269

49.5.2. Acción directa (Arts. 736 y 737 CCyC) 269

49.5.3. Acción subrogatoria (Arts. 739 y 740 CCyC) 270

49.5.4. Acción de simulación y acción revocatoria (inoponibilidad) 272

49.6. Cuadro Cornell: garantía, acreedores y acciones . . . 272
49.7. Síntesis de la parte . . . 274
49.7.1. Recorrido de la parte . . . 274
49.7.2. Síntesis final . . . 274

XII La causa de la relación jurídica: hechos y actos jurídicos 276

50. Fundamentos de los hechos y actos jurídicos 277
50.1. Introducción: la causa como tercer elemento de la relación jurídica . . . 277
50.2. Ubicación metodológica en el Código Civil y Comercial . . . 277
50.3. Definición de hecho jurídico en el CCyC . . . 278
50.4. Clasificación general de los hechos jurídicos . . . 279
50.5. Hechos voluntarios e involuntarios: importancia de la distinción . . . 279
50.6. Actos ilícitos: dolo y culpa . . . 279
50.7. Actos lícitos: simples actos lícitos y actos jurídicos . . . 281

51. La teoría del acto voluntario 282
51.1. Las condiciones del acto voluntario . . . 282
51.2. El discernimiento . . . 282
51.3. La intención y sus vicios: error y dolo . . . 283
51.4. La libertad y el vicio de violencia . . . 284
51.5. La exteriorización de la voluntad . . . 285
51.6. El silencio como (no) manifestación de voluntad . . . 285

52. Imputabilidad de los actos voluntarios 287
52.1. El deber de reparar: fundamento y presupuestos . . . 287
52.2. Tipos de consecuencias: inmediatas, mediatas y casuales . . . 288
52.3. El criterio de previsibilidad y la graduación de la responsabilidad . . . 288
52.4. El caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes . . . 289

53. Responsabilidad por actos involuntarios 290
53.1. Regla general: no responsabilidad por actos involuntarios . . . 290
53.2. La evolución: el principio de equidad . . . 290

53.3. El artículo 1750 del CCyC: régimen vigente . . . 291
53.4. Criterios de la equidad para la atenuación (Art. 1742 CCyC) . . . 292
53.5. Cuadro Cornell: hechos jurídicos, acto voluntario e imputabilidad . . . 292

54. El acto jurídico: concepto y elementos 296
54.1. Acto jurídico y contrato: alcance de la teoría general . . . 296
54.2. Definición y características del acto jurídico . . . 297
54.3. Acto jurídico frente al simple acto lícito . . . 297
54.4. Los elementos del acto jurídico . . . 297

55. El objeto del acto jurídico 298
55.1. Fundamento normativo . . . 298
55.2. Contenido moral y límite de la autonomía de la voluntad . . . 298
55.3. Requisitos del objeto . . . 299
55.3.1. Los hechos como objeto del acto . . . 299
55.3.2. Los bienes como objeto del acto . . . 299
55.4. Objeto ilícito: el caso de la venta de influencias . . . 299

56. La causa del acto jurídico 300
56.1. Causa fuente y causa fin . . . 300
56.2. Evolución histórica de la teoría de la causa . . . 300
56.2.1. Teoría causalista . . . 300
56.2.2. Crítica anticausalista . . . 301
56.2.3. Teoría moderna de la causa . . . 301
56.3. La causa en el Código de Vélez . . . 301
56.4. La causa en el Código Civil y Comercial . . . 302
56.4.1. Dimensiones objetiva y subjetiva de la causa . . . 302
56.4.2. Síntesis de las características de la causa . . . 303
56.5. Régimen de la causa . . . 303
56.6. Actos abstractos . . . 303
56.7. Cuadro Cornell: el acto jurídico, su objeto y su causa . . . 304

57. La forma del acto jurídico 307
57.1. Concepto de forma . . . 307

57.2. Regulación en el Código Civil y Comercial . . . 307
57.3. El formalismo en el derecho: ventajas y desventajas . . . 308
57.3.1. Ventajas del formalismo . . . 308
57.3.2. Desventajas del formalismo . . . 308

58. Clasificación de los actos jurídicos según la forma 309
58.1. Forma esencial y forma instrumental . . . 309
58.2. Primera clasificación: actos formales y no formales . . . 309
58.3. Segunda clasificación: actos solemnes y no solemnes . . . 309
58.4. Solemnidad absoluta y solemnidad relativa . . . 310
58.4.1. Conversión del acto jurídico . . . 310
58.5. Principio de Libertad de Formas . . . 310

59. Los instrumentos: clasificación general 312
59.1. Concepto de instrumento . . . 312
59.2. Clasificación de los instrumentos . . . 312
59.3. La firma como disposición general . . . 313
59.3.1. Firma digital y firma electrónica . . . 313

60. Los instrumentos públicos 315
60.1. Concepto y caracteres . . . 315
60.2. Enumeración legal . . . 315
60.3. Requisitos de validez . . . 316
60.4. Defectos de forma . . . 316
60.5. Eficacia probatoria del instrumento público . . . 317
60.5.1. Hechos percibidos directamente por el oficial público . . . 317
60.5.2. Declaraciones de las partes . . . 317

61. La escritura pública y las actas notariales 319
61.1. Concepto y protocolo notarial . . . 319
61.1.1. El protocolo notarial . . . 319
61.2. Requisitos de la escritura pública . . . 320
61.2.1. Estructura: encabezado, cuerpo y pie . . . 320
61.2.2. El «corresponde» en las transmisiones de inmuebles . . . 320

61.3. Copias y testimonios . . . 321
61.4. Actas Notariales . . . 321

62.Instrumentos particulares y fecha cierta 323
62.1. Clasificación y jerarquía . . . 323
62.2. Instrumentos privados: el requisito de la firma . . . 323
62.3. Reconocimiento de la firma . . . 323
62.4. Firma a ruego e impresión digital . . . 324
62.5. Documento firmado en blanco . . . 325
62.6. Enmiendas en instrumentos privados . . . 325
62.7. Fecha Cierta y Oponibilidad a Terceros . . . 325
62.7.1. El instrumento privado frente a terceros . . . 325
62.7.2. Medios para adquirir fecha cierta . . . 326

63.Instrumentos particulares no firmados y correspondencia 327
63.1. Concepto y amplitud . . . 327
63.2. Fuerza probatoria — criterios del juez . . . 327
63.3. La correspondencia . . . 328
63.4. Cuadro Cornell: forma e instrumentos del acto jurídico . . . 329

64.Clasificación de los actos jurídicos 333
64.1. Actos Unilaterales y Bilaterales . . . 334
64.2. Actos entre Vivos y de Última Voluntad . . . 334
64.3. Actos a Título Oneroso y a Título Gratuito . . . 334
64.4. Actos Principales y Accesorios . . . 335
64.5. Actos Formales y No Formales . . . 336
64.6. Actos Patrimoniales y Extrapatrimoniales . . . 337
64.7. Actos de Disposición, de Administración y de Conservación . . . 337
64.8. Actos Puros y Simples, y Actos Modales . . . 338
64.9. Actos Causales y Abstractos . . . 338
64.10Actos Positivos y Negativos . . . 339

65.Modalidades del acto jurídico 340
65.1. La Condición . . . 340

65.1.1. La Condición Impropia o Suposición . . . 341
65.1.2. Clasificación de las Condiciones . . . 342
65.1.3. Condiciones Prohibidas . . . 342
65.2. El Plazo . . . 343
65.3. El Cargo . . . 345
65.3.1. Cargo Simple y Cargo Condicional . . . 346
65.3.2. Cargos Prohibidos . . . 346
65.4. Cierre y Síntesis . . . 346
65.5. Cuadro Cornell: clasificación y modalidades de los actos jurídicos . . . 348

66. Principios generales de los efectos del acto jurídico 351
66.1. Introducción: los efectos del acto jurídico . . . 351
66.1.1. Importancia práctica . . . 351
66.2. Nemo plus iuris (Art. 399 CCyC) . . . 352
66.2.1. La transmisibilidad de los derechos como regla general . . . 352
66.2.2. Caso práctico: Juan, Verónica y Daniela . . . 352
66.3. Excepciones al nemo plus iuris . . . 353
66.3.1. Adquirente de buena fe y a título oneroso (Art. 392 CCyC) . . . 353
66.3.2. Otros supuestos de protección de terceros . . . 353
66.4. Cuadro Cornell: principios generales . . . 354

67. Las partes y el efecto relativo de los actos jurídicos 355
67.1. Efecto relativo de los actos jurídicos (Art. 1021 CCyC) . . . 355
67.2. Definición de parte (Art. 1023 CCyC) . . . 355
67.2.1. Distinción entre parte y representante . . . 355
67.3. Cuadro Cornell: partes y efecto relativo . . . 356

68. La representación 357
68.1. Tipos de representación (Art. 358 CCyC) . . . 357
68.2. Representación voluntaria (Arts. 362–381 CCyC) . . . 357
68.3. Facultades expresas (Art. 375 CCyC) . . . 358
68.4. Cuadro Cornell: representación . . . 359

69. Los sucesores 360

69.1. Sucesor universal 360
69.2. Sucesor singular 361
69.3. Cuadro Cornell: sucesores 362

70. Los terceros y las acciones a su disposición 363
70.1. Situación de los terceros 363
70.2. Las acciones de los acreedores frente a terceros 363
70.3. Cuadro Cornell: terceros y acciones 364
70.4. Síntesis general de los efectos del acto jurídico 364

XIII Vicios de los actos jurídicos: voluntad, equilibrio y sinceridad 366

71. Los vicios de los actos jurídicos: denominación y clasificación 367
71.1. Introducción: ¿vicios de la voluntad o del consentimiento? 367
71.2. Método del Código Civil y Comercial 368

72. El error como vicio de la voluntad (arts. 265 a 270 CCyC) 369
72.1. Concepto y clasificación del error de hecho 369
72.2. El error reconocible — Art. 266 370
72.3. El error esencial — supuestos del Art. 267 370
72.3.1. Inciso a) — Error sobre la naturaleza del acto 371
72.3.2. Inciso b) — Error sobre el objeto 371
72.3.3. Inciso c) — Error sobre la cualidad sustancial del bien 371
72.3.4. Inciso d) — Error sobre los motivos 372
72.3.5. Inciso e) — Error sobre la persona 372
72.4. Error de cálculo — Art. 268 372
72.5. Subsistencia del acto y nulidad relativa — Art. 269 373
72.6. Error en la declaración — Art. 270 373
72.7. Consecuencias del error: nulidad relativa y prescripción 373

73. El dolo como vicio de la voluntad (arts. 271 a 275 CCyC) 374
73.1. Las acepciones del dolo en el derecho civil 374
73.2. Concepto: acción y omisión dolosa — Art. 271 374

73.3. Dolo esencial — requisitos del Art. 272 . . . 375
73.4. Dolo incidental — Art. 273 . . . 376
73.5. Dolo de tercero — Art. 274 . . . 376
73.6. Consecuencias del dolo: nulidad y daños — Art. 275 . . . 377

74. La violencia como vicio de la voluntad (arts. 276 a 278 CCyC) 378
74.1. Concepto de violencia: fuerza e intimidación . . . 378
74.2. Requisitos de la intimidación — Art. 276 . . . 378
74.3. Violencia de tercero y responsabilidad solidaria — Art. 278 . . . 379
74.4. El temor reverencial . . . 380
74.5. Consecuencias de la violencia: nulidad y prescripción . . . 380
74.6. Cuadro Cornell: vicios de la voluntad: error, dolo y violencia . . . 381

75. Antecedentes históricos y derecho comparado de la lesión 384
75.1. Los vicios de los actos jurídicos según el Código Civil y Comercial . . . 384
75.2. Concepto de lesión: una distinción necesaria . . . 384
75.3. El derecho romano y el Código Justinianeo . . . 385
75.4. La Edad Media y el precio justo . . . 385
75.5. La legislación española como antecedente del derecho argentino . . . 386
75.6. El derecho comparado moderno . . . 386
75.6.1. El Código Civil Francés (1804): la lesión objetiva . . . 386
75.6.2. El Código Civil Alemán — BGB (1900): la lesión subjetiva . . . 387
75.6.3. El Código Suizo (1912) y el Código Italiano (1942) . . . 388
75.7. Cuadro Cornell: antecedentes históricos y derecho comparado de la lesión . 389

76. La lesión en el derecho argentino 390
76.1. El Código de Vélez (1869): la exclusión de la lesión . . . 390
76.2. La jurisprudencia anterior a la ley 17.711 . . . 391
76.3. La ley 17.711 y la reforma al art. 954 (1968) . . . 391
76.4. El art. 332 del CCC: texto y diferencias con el art. 954 . . . 392
76.5. Ámbito de aplicación del art. 332 . . . 392
76.6. El elemento objetivo: la desproporción de las prestaciones . . . 393
76.7. Los elementos subjetivos . . . 393

76.8. La presunción legal del art. 332 . . . 394
76.9. Las acciones, la legitimación y la prescripción . . . 395
76.10Figuras afines: cláusula penal y usura . . . 395
76.11Debate doctrinario: la esencia de la lesión . . . 396
76.12Cuadro Cornell: la lesión en el derecho argentino . . . 397

77.La simulación como vicio de los actos jurídicos 399
77.1. Concepto y noción general . . . 399
77.2. Definición doctrinaria y ubicación metodológica . . . 400
77.3. Definición legal de la simulación . . . 401
77.4. Simulación absoluta y simulación relativa . . . 401
77.4.1. Simulación absoluta . . . 401
77.4.2. Simulación relativa . . . 401
77.5. Simulación lícita e ilícita . . . 402
77.6. Naturaleza de la sanción: nulidad relativa . . . 402
77.7. La acción de simulación entre las partes . . . 402
77.7.1. Procedencia de la acción entre partes . . . 403
77.7.2. La prueba entre las partes: el contradocumento . . . 403
77.8. La acción de simulación ejercida por terceros . . . 404
77.8.1. Procedencia . . . 404
77.8.2. La prueba por indicios . . . 404
77.9. Efectos de la simulación frente a terceros . . . 405
77.10Prescripción de la acción de simulación . . . 406
77.11Cuadro Cornell: la simulación como vicio de los actos jurídicos . . . 407

78.El fraude como vicio de los actos jurídicos 409
78.1. Introducción y distinción con el fraude penal . . . 409
78.2. Definición doctrinaria . . . 409
78.3. La inoponibilidad como consecuencia del fraude . . . 409
78.4. La acción de inoponibilidad . . . 410
78.5. Requisitos de procedencia de la acción . . . 410
78.5.1. Crédito de causa anterior al acto impugnado . . . 410
78.5.2. Que el acto haya causado o agravado la insolvencia . . . 411

78.5.3. La complicidad del adquirente a título oneroso . . . 411
78.6. Efectos de la acción de inoponibilidad . . . 411
78.7. El desinterés del adquirente . . . 412
78.8. Extensión de la inoponibilidad . . . 412
78.9. Efectos frente a subadquirentes . . . 413
78.10Prescripción de la acción de inoponibilidad . . . 413
78.11Cuadro Cornell: el fraude como vicio de los actos jurídicos . . . 414
78.12Síntesis comparativa . . . 414

XIV La extinción de las relaciones jurídicas 417

79.Introducción: el cierre del ciclo de la relación jurídica 418
79.1. Objeto del tema . . . 418
79.2. Relevancia práctica . . . 418
79.3. Las tres vías de extinción . . . 418
79.4. Enumeración de la doctrina seguida . . . 419

80.Hechos jurídicos extintivos 420
80.1. La muerte como hecho extintivo . . . 420
80.2. La imposibilidad sobrevenida . . . 420
80.3. La confusión . . . 421
80.4. La compensación . . . 421
80.5. La caducidad (introducción) . . . 422
80.6. Cuadro Cornell: hechos jurídicos extintivos . . . 423

81.Actos jurídicos extintivos 425
81.1. El pago . . . 425
81.2. La dación en pago . . . 425
81.3. La novación . . . 426
81.4. La transacción . . . 426
81.5. La renuncia . . . 427
81.6. La remisión de deuda . . . 427
81.7. La resolución . . . 427

81.7.1. La cláusula resolutoria (o pacto comisorio) . . . 427
81.7.2. La señal o arras . . . 428
81.7.3. La condición resolutoria . . . 428
81.7.4. La frustración de la finalidad . . . 429
81.7.5. La teoría de la imprevisión . . . 429
81.7.6. Efectos generales de la resolución . . . 429
81.8. La rescisión . . . 430
81.9. La revocación . . . 430
81.9.1. Cuadro comparativo: resolución, rescisión y revocación . . . 431
81.10Cuadro Cornell: actos jurídicos extintivos . . . 432

82.Prescripción y caducidad **434**
82.1. Importancia de la prescripción en la práctica . . . 434
82.2. Prescripción adquisitiva y prescripción extintiva . . . 434
82.2.1. La prescripción adquisitiva (usucapión) . . . 435
82.2.2. La prescripción extintiva o liberatoria . . . 435
82.2.3. Reglas generales sobre la prescripción . . . 436
82.3. Suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción . . . 437
82.3.1. La suspensión . . . 437
82.3.2. La interrupción . . . 438
82.3.3. Cuadro comparativo: suspensión e interrupción . . . 439
82.4. La dispensa y los plazos de prescripción . . . 439
82.4.1. La dispensa . . . 439
82.4.2. Los plazos de prescripción . . . 440
82.5. La caducidad en profundidad . . . 440
82.6. Cuadro Cornell: prescripción y caducidad . . . 442
82.7. Síntesis de la extinción de las relaciones jurídicas . . . 443

A. Normativa citada en las fuentes **445**

Introducción general

La persona humana es el centro del derecho civil. Una máxima del derecho romano recogida en el Digesto lo expresa así: todo el derecho está constituido en razón del hombre. Este libro reúne en un único recorrido el estudio de la introducción al derecho civil y de la parte general del derecho civil argentino, tomando como eje el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC).

La exposición avanza de lo más general a lo más concreto. Las Partes I a V presentan el derecho, la codificación, el marco general del código, las fuentes y los límites al ejercicio de los derechos. A partir de allí, la organización sigue los elementos de la relación jurídica: el **sujeto** (quién entabla la relación), el **objeto** (la materia sobre la que recae) y la **causa** (el origen del que emergen las relaciones jurídicas), y se completa con la **extinción** de esas relaciones, es decir, con el modo en que termina aquello que nació.

Parte	Tema	Cuestión que responde y contenido
I	El derecho, la justicia y el derecho civil	¿Qué es el derecho y qué lugar ocupa el derecho civil? Justicia; derecho objetivo y subjetivo; grandes divisiones; relación jurídica y Parte General.
II	La codificación del derecho civil	¿Cómo se llegó al código vigente? Codificación; Código de Vélez Sarsfield y Ley 17.711; Código Civil y Comercial.
III	La Constitución y el Título Preliminar	¿Cómo se inserta el código en el orden jurídico? Constitucionalización del derecho privado; Título Preliminar; unificación civil y comercial.
IV	Las fuentes del derecho y la aplicación de la ley	¿De dónde proviene el derecho aplicable y desde cuándo rige? Fuentes; ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina; aplicación de la ley en el tiempo.
V	Límites al ejercicio de los derechos	¿Dónde están los límites de lo que se puede hacer con los derechos? Orden público; buena fe y equidad; abuso del derecho.
VI–IX	La persona humana	¿Quién es sujeto de derechos y cómo se protege? Reconocimiento, comienzo de la existencia y derechos personalísimos; atributos; capacidad y sus restricciones; muerte, ausencia y presunción de fallecimiento.
X	Las personas jurídicas	¿Qué otros sujetos pueden ser titulares de derechos? Concepto, régimen, responsabilidad, fin de la existencia, fundaciones y asociaciones.
XI	Patrimonio, derechos y bienes	¿Sobre qué recaen las relaciones y con qué responde el deudor? Patrimonio; clasificación de los derechos; bienes y cosas; garantía patrimonial y acciones de los acreedores.
XII	Hechos y actos jurídicos	¿Cómo nacen y qué efectos producen las relaciones jurídicas? Hechos jurídicos y acto voluntario; acto jurídico y sus elementos; forma e instrumentos; clasificación, modalidades y efectos.
XIII	Vicios de los actos jurídicos	¿Qué ocurre cuando el acto está afectado en su voluntad, en su equilibrio o en su sinceridad? Error, dolo, violencia; lesión; simulación y fraude.
XIV	Extinción de las relaciones jurídicas	¿Cómo terminan las relaciones jurídicas? Hechos y actos extintivos; prescripción y caducidad.

Cuadro 1: Mapa general del libro

Cada parte se despliega en capítulos que avanzan desde los conceptos fundamentales hacia sus aplicaciones, y la mayoría de ellos se cierra con un cuadro Cornell para el estudio activo, que permite recuperar las ideas centrales mediante preguntas. Las cajas de color

se reservan para definiciones, reglas, ejemplos y advertencias, y el texto corrido sigue siendo el soporte principal de la exposición. Las citas de artículos reproducen los textos tal como figuran en las fuentes de estos apuntes; cuando las propias fuentes presentan inconsistencias, se las señala en comentarios internos del archivo LaTeX con la marca `TODO`.

Parte I

El derecho, la justicia y el derecho civil

Esta parte plantea las preguntas más generales: qué se entiende por derecho y por justicia, en qué sentidos se usa la palabra «derecho», cómo se divide el orden jurídico y qué lugar ocupa el derecho civil —con su relación jurídica y su Parte General— dentro del derecho privado.

Capítulo 1

La noción de derecho y de justicia

Todo el estudio del derecho civil descansa sobre una pregunta previa: qué es el derecho. Este capítulo parte del significado original de la palabra, define la justicia como virtud que ordena las relaciones entre personas, explica la opción metodológica adoptada por estas notas y presenta los dos principios que estructuran el derecho privado: la dignidad de la persona y el bien común.

1.1. Origen etimológico de la palabra derecho

La palabra **derecho** proviene del latín *directum*, que significa «lo que está alineado, enderezado»: aquello contrario a lo torcido, lo que ha sido sujeto a una regla y dirigido conforme a ella.

Definición

Históricamente, el derecho se asoció también a la voz latina *ius* y a la voz griega *tó díkaion*, ambas expresivas de la idea de lo **justo**, entendido como el objeto de la justicia. Por una transición conceptual, la palabra *derecho* llegó a identificarse con la noción de *cosa justa*.

1.2. La justicia como dar a cada uno lo suyo

Definición: Derecho y justicia

El **derecho** es lo justo. **Lo justo** es el objeto de la **justicia**, y la justicia consiste en **dar a cada uno lo suyo**: una relación real de igualdad que vincula personas, cosas y comunidades según un criterio de **bien común**.

Los elementos —personas, cosas y comunidad— permiten determinar qué es lo justo en cada situación. A lo largo de toda la vida jurídica y de las distintas ramas del derecho está siempre en juego esa determinación. Lo justo puede estar fijado de dos modos:

- por la **ley positiva**, cuando la norma establece directamente qué debe ocurrir;
- por la **sentencia judicial**, cuando es el juez quien determina qué es lo justo en el caso concreto.

Ejemplo: Nulidad y restitución de frutos

Tras una nulidad, la ley determina qué es lo justo: el poseedor de buena fe devuelve los frutos desde cierto momento, mientras que el poseedor de mala fe los devuelve desde que los recibió. La restitución queda regulada por la ley, que fija el criterio de justicia para cada caso.

Ejemplo: Accidente de tránsito

Cuando se discute el alcance del deber de reparar los daños de un accidente de tránsito, es la sentencia judicial la que determina qué es lo justo: lo que se debe entre las personas, en torno a los daños, en el marco de la comunidad y con criterio de bien común.

1.2.1. Tipos de justicia

El derecho civil tiene como tema de fondo la justicia, entendida como la virtud que ordena la relación con los demás. Dentro de ella se distinguen tres tipos, según la dirección de la relación que regulan:

Tipo de justicia	Descripción	Campo de aplicación
Justicia legal	Del individuo hacia el todo: obliga a los miembros de la comunidad hacia el bien común.	**Derecho público / constitucional**
Justicia distributiva	Del todo hacia la parte: distribución de cargas y beneficios desde la comunidad hacia los individuos.	**Derecho administrativo / tributario**
Justicia conmutativa	Entre las partes: busca la igualdad en los intercambios y la reciprocidad.	**Derecho civil / contratos / daños**

Cuadro 1.1: Tipos de justicia

Definición: Justicia conmutativa

Es la justicia propia de las relaciones entre particulares, que busca la igualdad en los intercambios y la reciprocidad. Es el campo en el que se mueve el derecho civil, en lo que se ha llamado la reciprocidad de los cambios.

1.3. Opción metodológica: el iusnaturalismo

La concepción del derecho vinculada a la justicia implica una **opción metodológica** que se aparta de dos posiciones alternativas:

- El **positivismo jurídico**, que reduce el fenómeno jurídico al texto de la ley escrita o a una pura forma procedimental, sin contenido sustantivo.

- El **sociologismo jurídico**, que identifica al derecho con la percepción de lo que la mayoría desea, sin asegurar su vinculación con la idea de justicia.

La opción adoptada reconoce el valor de la ley positiva, pero sostiene que esta debe tener un **contenido sustantivo vinculado a principios fundamentales** accesibles a la **recta razón** humana.

Definición: Concepción clásica del derecho

El **derecho** es un **orden social**, fundado en la **virtud de la justicia**, que ordena las relaciones de **alteridad** —relaciones de convivencia entre personas— y cuyo contenido es dar a cada uno lo suyo.

1.4. Dignidad de la persona y bien común

De la concepción del derecho vinculada a la justicia se desprenden dos **principios estructurantes** del derecho privado.

Importante

1. **Dignidad de la persona humana.** El sujeto del derecho es la persona humana; según el Digesto, todo el derecho está constituido en orden a ella. La **dignidad** expresa la excelencia y el valor inherente a la persona: un valor inviolable por el que la persona nunca debe ser tratada como medio, sino siempre como un **fin en sí misma**.
2. **Bien común.** El respeto a la dignidad se complementa con la noción de **bien común político**: el conjunto de condiciones que permiten que las personas, las familias y las asociaciones logren sus propios fines y participen del bien dado a toda la comunidad.

Ambos principios constituyen el telón de fondo del derecho y de la justicia: la persona necesita bienes para realizar sus fines, los obtiene en el marco de relaciones con los demás y, en esas relaciones, debe respetarse la dimensión de justicia.

En el centro del derecho civil está, entonces, la persona humana, con su dignidad resaltada en el artículo 51 del CCyC, y protegida desde la concepción hasta la muerte natural (art. 19 CCyC). El derecho civil busca además el bien común político: el conjunto de condiciones que permite que las personas, las familias y las sociedades alcancen su perfección. Ambas normas se estudian en detalle en el capítulo 22 y en el capítulo 23.

1.5. Cuadro Cornell: la noción de derecho y de justicia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿De dónde proviene la palabra «derecho»?	Del latín *directum*, «lo alineado, enderezado». Se asoció también a *ius* y a *tó díkaion*, voces vinculadas a lo justo.
¿Qué es lo justo y cómo puede fijarse?	Es el objeto de la justicia, que consiste en dar a cada uno lo suyo con criterio de bien común. Lo fija la ley positiva (restitución de frutos tras una nulidad) o la sentencia judicial (deber de reparar en un accidente de tránsito).
¿Cuáles son los tres tipos de justicia y cuál es propia del derecho civil?	Legal (individuo hacia el todo), distributiva (todo hacia la parte) y conmutativa (entre las partes). El derecho civil se mueve en la justicia conmutativa.
¿Por qué la concepción adoptada es iusnaturalista?	Porque exige que la ley positiva tenga contenido sustantivo vinculado a principios accesibles a la recta razón, y rechaza reducir el derecho a la norma escrita (positivismo) o a la opinión mayoritaria (sociologismo).
¿Cuáles son los dos principios estructurantes del derecho privado?	La dignidad de la persona humana (valor inviolable; la persona es un fin en sí misma) y el bien común político (condiciones para que personas, familias y asociaciones alcancen sus fines).

Resumen: El derecho es lo justo, y la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo en relaciones de alteridad ordenadas al bien común. La ley y la sentencia determinan lo justo; el derecho civil opera en la justicia conmutativa. Dignidad de la persona y bien común estructuran el derecho privado.

Capítulo 2

Derecho objetivo, subjetivo y normativo

La palabra «derecho» no tiene un único significado. Este capítulo distingue sus sentidos, expone las principales teorías sobre el derecho subjetivo —la noción que más discusión ha generado— y presenta las críticas que desde posiciones opuestas se le han dirigido.

2.1. Las tres dimensiones de la palabra derecho

La palabra **derecho** es una **palabra análoga**: posee varios significados que guardan relación entre sí. El primer analogado es el concepto de *lo justo*; a partir de él, por analogía, se habla de derecho en otros sentidos.

Definición: Derecho objetivo

La misma **cosa justa**, el objeto de la justicia: aquello que se debe dar a la otra persona en una relación de justicia.

Definición: Derecho subjetivo

La **prerrogativa o facultad** reconocida a la persona para exigir de los demás un determinado comportamiento. Mira al sujeto y a su potestad de reclamar.

Definición: Derecho normativo

También llamado derecho efectivo o vigente: el conjunto de **normas** dispuestas por el legislador en un determinado país, es decir, las disposiciones y reglas dadas para determinar qué es lo justo.

La cosa justa (derecho objetivo) a veces está determinada por el derecho normativo; otras veces la ley no la determina directamente y debe establecerla la sentencia judicial en el caso concreto. Además de estos tres sentidos principales, también se denomina *derecho* a la **sentencia judicial**, en tanto precisa lo justo en el caso concreto, y a la **ciencia del derecho**, la disciplina que estudia todo lo relacionado con el derecho y la justicia.

2.2. Teorías clásicas del derecho subjetivo

La noción de derecho subjetivo ha dado lugar a numerosas teorías. Las principales posiciones clásicas son las siguientes:

Autor	Concepción del derecho subjetivo
Francisco Suárez (1548–1617)	Facultad moral sobre lo propio: facultad de exigir aquello que es propio del sujeto (escolástica española).
F. C. von Savigny (1779–1861)	Poder atribuido a la voluntad. Visión marcadamente individualista que enfatiza la voluntad como elemento esencial.
Rudolf von Jhering	Interés jurídicamente protegido con seguridad en el goce. El interés es decisivo, pero falta el elemento de la voluntad y la potestad de reclamar.

Cuadro 2.1: Teorías clásicas del derecho subjetivo

Importante

La teoría de **Savigny** presenta el riesgo propio del individualismo: al enfatizar la voluntad sin establecer un límite claro, puede dar lugar a ejercicios abusivos o arbitrarios del derecho. La teoría de **Jhering** señala correctamente que el interés es decisivo en materia de derecho, pero el goce en abstracto no puede concretarse en ausencia de la voluntad de ejercerlo: falta el elemento de la voluntad y la potestad de reclamar.

2.3. Críticas colectivista y positivista al derecho subjetivo

Dos corrientes niegan, desde perspectivas opuestas, la existencia o la relevancia del derecho subjetivo.

Definición: Posición de León Duguit (escuela colectivista)

El hombre no tiene derechos, sino únicamente **deberes** derivados de su pertenencia a la comunidad. Todo individuo tiene una función que cumplir y tareas que ejecutar. El fundamento de la regla de derecho no es un derecho subjetivo que el ser humano pueda reclamar para sí, sino el deber social de obrar y desenvolver su individualidad conforme a esa función, tanto para gobernantes como para gobernados.

Definición: Posición de Hans Kelsen (escuela positivista)

La noción de derecho subjetivo es **superflua**, porque lo único que importa es el **derecho normativo**, que establece las obligaciones jurídicas. El derecho subjetivo sería la contracara de la obligación: un concepto reflejo de utilidad didáctica, pero prescindible para la descripción científica. Lo que se denomina derecho subjetivo no es más que la conducta encuadrada en una norma que, dado cierto presupuesto, adjudica determinadas consecuencias jurídicas.

Frente a estas posiciones se reconoce la **importancia del derecho subjetivo** como expresión de la **dignidad de la persona humana**, especialmente en lo relativo a los derechos humanos y los derechos fundamentales. A partir de las teorías clásicas, el derecho subjetivo puede entenderse como una **prerrogativa reconocida a la persona por el**

ordenamiento jurídico para realizar un comportamiento tendiente a la satisfacción de **intereses humanos**, debiendo ejercerse en conformidad con esa finalidad.

2.4. La teoría de John Finnis

John Finnis (profesor de Oxford) concibe el derecho subjetivo como **exigencia derivada del principio de razonabilidad práctica**. Según esta concepción, el derecho subjetivo incluye:

- la **exigencia positiva o negativa** impuesta sobre otro: exigir un comportamiento determinado o exigir que el otro no interfiera con el propio desarrollo o disfrute de un bien;
- la **capacidad de reclamar** el cumplimiento de esa exigencia, o la posibilidad de quedar inmune frente a un intento de sometimiento.

Definición: Razonabilidad práctica (Finnis)

Principio que remite a una concepción de **ley natural**: principios fundamentales superiores al ordenamiento positivo, que el ser humano puede conocer a través de la recta razón y a la luz de los cuales es posible valorar el contenido del derecho vigente.

2.5. Cuadro Cornell: sentidos del derecho y derecho subjetivo

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué significa que «derecho» es una palabra análoga?	Que sus sentidos (objetivo, subjetivo, normativo) guardan relación con un primer analogado: lo justo.
¿Cómo se distinguen los tres sentidos principales?	Objetivo: la cosa justa. Subjetivo: la facultad de exigir un comportamiento. Normativo: el conjunto de normas del legislador.
¿Cómo definieron el derecho subjetivo Suárez, Savigny y Jhering?	Suárez: facultad moral sobre lo propio. Savigny: poder de la voluntad, con riesgo de ejercicio abusivo. Jhering: interés jurídicamente protegido, sin voluntad ni potestad de reclamar.
¿Por qué Duguit y Kelsen niegan el derecho subjetivo?	Duguit: solo hay deberes sociales según la función de cada individuo. Kelsen: es superfluo; solo importa el derecho normativo y la obligación jurídica.
¿Cómo concibe Finnis el derecho subjetivo?	Como exigencia derivada de la razonabilidad práctica, con capacidad de reclamar su cumplimiento, remitida a principios de ley natural.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**

Resumen: El derecho es una palabra análoga cuyo primer sentido es lo justo. El derecho subjetivo, expresión de la dignidad humana, ha sido explicado por la voluntad, el interés o la exigencia razonable, y negado por el colectivismo y el positivismo.

Capítulo 3

Las grandes divisiones del derecho

El derecho puede clasificarse según el fundamento de sus principios (natural y positivo) y según los sujetos que intervienen en la relación regulada (público y privado). Estas dos divisiones permiten situar luego al derecho civil.

3.1. Derecho natural y derecho positivo

Definición: Derecho natural

Está constituido por **principios fundamentales** que corresponden a la naturaleza humana, accesibles al ser humano mediante la **recta razón** y derivados de las inclinaciones fundamentales del ser hacia sus fines propios.

Se distinguen tres grandes **inclinaciones fundamentales** del ser humano, de las que se desprenden principios del derecho natural:

1. la inclinación a **conservar la propia vida**;
2. la inclinación a **transmitir la vida** y todo lo vinculado a la procreación;
3. la inclinación a **buscar el bien según la naturaleza racional** y a organizar la vida conforme a esa búsqueda.

Estos principios son con frecuencia genéricos y requieren **concreciones**. Allí interviene el derecho positivo.

Definición: Derecho positivo

Es el **dispuesto por el legislador** en orden al bien común. Comprende todas las normas escritas: la Constitución, los tratados, las leyes y los decretos.

Posición	Tesis fundamental
Positivismo jurídico	No existe un principio superior al derecho positivo. El derecho es lo que establece la autoridad competente; su justicia se debate en el plano político legislativo.
Iusnaturalismo	Existen principios superiores al derecho positivo, accesibles a la recta razón, a la luz de los cuales es posible valorar el contenido y la justicia de la ley vigente.
Corrientes trans-positivistas	Reconocen principios o valores superiores a la ley positiva, pero sin identificarlos con la ley natural clásica. Incluyen el neoconstitucionalismo y posiciones consensualistas o procedimentalistas.

Cuadro 3.1: Posiciones sobre la relación entre derecho natural y derecho positivo

3.2. Derecho público y derecho privado

Dentro del derecho positivo, la división fundamental distingue el derecho público del derecho privado.

Definición: Derecho público y derecho privado

El **derecho público** regula las relaciones en que **interviene el Estado** como comunidad frente a los individuos. El **derecho privado** regula las relaciones **entre particulares**, sin intervención del Estado en posición de poder.

Rama	Ámbito
Derecho constitucional, administrativo y penal	Público
Derecho civil y comercial	Privado
Derecho del trabajo	Privado (con elementos de derecho público)
Derecho procesal	Intersección entre público y privado

Cuadro 3.2: Principales ramas del derecho según su ámbito

Capítulo 4

El derecho civil, la relación jurídica y su Parte General

Situado el derecho privado, este capítulo define el derecho civil como su rama madre, explica el concepto de relación jurídica con sus tres elementos y describe cómo el Código Civil y Comercial organiza su contenido, con especial atención a la Parte General.

4.1. El derecho civil como rama madre del derecho privado

Definición: Derecho civil

Es la **rama madre del derecho privado**. Se ocupa del **hombre como sujeto de derecho**, sin distinción de cualidades accidentales, y de las **relaciones jurídicas** —tanto patrimoniales como extrapatrimoniales— que lo constituyen como sujeto, regulando las instituciones básicas y constituyendo el punto de partida de las demás ramas del derecho privado.

La palabra *civil* proviene del derecho romano: el *ius civile* era el derecho de los ciudadanos (*civis*) de la ciudad (*civitas*) romana. Tras la caída del Imperio Romano, este derecho subsistió en las distintas civilizaciones como derecho de los particulares, organizando las relaciones más fundamentales de la persona: obligaciones, contratos, derechos reales, familia y sucesiones.

Importante

El rasgo distintivo del derecho civil frente a otras ramas del derecho privado es que **mira a la persona en cuanto tal**, desprovista de cualidades accidentales. El derecho comercial la mira en cuanto comerciante; el derecho laboral, en cuanto trabajador; el derecho societario, en cuanto integrante de una sociedad. El derecho civil estudia a la persona humana y sus atributos (existencia, nombre, domicilio, estado, capacidad, patrimonio, derechos personalísimos), a la persona jurídica, a los bienes y las cosas, y a los hechos y actos jurídicos.

4.2. La relación jurídica: sujeto, objeto y causa

Un concepto central para el estudio del derecho civil es el de relación jurídica.

Definición: Relación jurídica

Es el **vínculo jurídico** que se establece entre uno o varios **sujetos**, en torno a un **objeto determinado** y fundamentado en el **derecho**. Da lugar a consecuencias jurídicas entre las partes.

Ejemplo: Contrato de mutuo

Cuando una persona presta dinero a otra se genera una relación jurídica entre dos sujetos (prestamista y prestatario), en torno a un objeto (el dinero), con una causa que es el contrato de mutuo, el cual fija las pautas de la relación y obliga a la restitución.

4.2.1. Sujetos (elemento personal)

Los **sujetos** son las personas que entablan relaciones jurídicas. El CCyC distingue dos clases:

- **Personas humanas:** todo ser humano, por el solo hecho de serlo, es persona. El término *persona* denota el valor y la excelencia en el ser de quien es capaz de entablar relaciones jurídicas; no es sinónimo de ciudadano, habitante o individuo.
- **Personas jurídicas:** surgen de la asociación de personas humanas para fines útiles, dando lugar a formas de actuación jurídicamente relevantes. Pueden ser *públicas* (el Estado nacional, provincial y municipal; los Estados extranjeros; los organismos públicos internacionales; la Iglesia Católica, entre otras) o *privadas* (las sociedades, las asociaciones civiles, las fundaciones, las iglesias y entidades religiosas, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, entre otras).

4.2.2. Objeto (elemento real)

El **objeto** es la **cosa o bien** sobre el que recae o se proyecta la relación jurídica. Los **bienes** son todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener valor, incluyendo ideas, derechos intelectuales, invenciones artísticas y científicas, y derechos creditorios. Las **cosas** son los objetos materiales susceptibles de tener valor y se clasifican, entre otras categorías, en muebles e inmuebles.

4.2.3. Causa (elemento normativo)

La **causa** es aquello que da origen a la relación jurídica. Puede provenir de:

- **hechos de la naturaleza**, como el granizo que arruina una cosecha y genera consecuencias jurídicas;
- **hechos ilícitos**, como un accidente de tránsito;
- **actos jurídicos**, como un contrato o un testamento.

4.3. La Parte General en el Código Civil y Comercial

El contenido del derecho civil se organiza en el Código Civil y Comercial de la Nación a través de seis libros:

Libro	Contenido
Primero	**Parte General.** La persona humana y sus atributos (existencia, nombre, domicilio, estado civil, capacidad, patrimonio, derechos personalísimos y situaciones especiales de capacidad); la persona jurídica y su clasificación; los bienes y las cosas; los hechos y los actos jurídicos como causa de las relaciones jurídicas.
Segundo	Relaciones de familia.
Tercero	Obligaciones y contratos, incluyendo todo lo relativo a la responsabilidad civil.
Cuarto	Derechos reales: derechos de las personas sobre las cosas.
Quinto	Sucesiones.
Sexto	Disposiciones comunes a los derechos reales y personales: derecho internacional privado, prescripción y otras disposiciones comunes.

Cuadro 4.1: Los seis libros del Código Civil y Comercial

Importante

La **Parte General** (Libro Primero) no constituye un sistema lógico deductivo cerrado. Su función es filosófica e introductoria: fijar los contenidos y márgenes fundamentales del derecho privado —persona, atributos, bienes y causa de las relaciones jurídicas— para comprender cómo surgen las relaciones jurídicas y qué las rige. Es la puerta de entrada conceptual a todas las demás ramas del derecho privado.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

4.4. Cuadro Cornell: el derecho civil y su Parte General

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué el derecho civil es la «rama madre» del derecho privado?	Porque proviene del *ius civile* romano, organizó las relaciones más fundamentales de la persona y la mira en cuanto tal, a diferencia de otras ramas que la contemplan como comerciante, trabajador o socio.
¿Cómo se distinguen derecho natural y derecho positivo?	El natural son principios accesibles a la recta razón, derivados de las inclinaciones humanas fundamentales; el positivo es el dispuesto por el legislador para concretarlos en orden al bien común.
¿Cómo se distinguen derecho público y privado?	El público regula las relaciones en que interviene el Estado; el privado, las relaciones entre particulares. El derecho procesal se sitúa en la intersección.
¿Qué elementos componen la relación jurídica?	Sujetos (personas humanas y jurídicas), objeto (bienes y cosas) y causa (hechos de la naturaleza, hechos ilícitos o actos jurídicos).
¿Cuál es la función de la Parte General?	No es un sistema deductivo cerrado: es una introducción filosófica y conceptual que fija persona, atributos, bienes y causa como puerta de entrada al derecho privado.

Resumen: El derecho civil, heredero del *ius civile*, estudia a la persona en cuanto tal y sus relaciones jurídicas. Toda relación jurídica se compone de sujeto, objeto y causa, y la Parte General del CCyC reúne esos elementos como introducción a todo el derecho privado.

Parte II

La codificación del derecho civil

El derecho civil argentino se expresa en un código. Esta parte estudia qué es la codificación, el Código de Vélez Sarsfield con su reforma por la Ley 17.711 y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Capítulo 5

La codificación: concepto, caracteres y orígenes

El derecho civil y la codificación son fenómenos inseparables: no puede comprenderse cabalmente el primero sin conocer el segundo. Este capítulo define qué es codificar, qué caracteres tiene un código, qué ventajas e inconvenientes presenta y cómo nació el movimiento codificador moderno.

5.1. Concepto y caracteres de la codificación

Definición: Codificación

Codificar es reunir orgánicamente en un cuerpo único todas las normas vigentes sobre una materia determinada del derecho. Un **código** es un cuerpo sistemático, orgánico y metódico de todas las normas y principios jurídicos relativos a una rama específica del ordenamiento jurídico.

Un código presenta tres caracteres fundamentales:

- **Unitario**: unifica en un solo cuerpo las normas de la materia.
- **Exclusivo**: no existen normas de la materia por fuera del código; todo lo referido a ella queda comprendido en él.
- **Sistemático**: posee un orden, una lógica y un método propios, lo que facilita la comprensión del fenómeno jurídico regulado.

5.2. Ventajas e inconvenientes de la codificación

La codificación da unidad y coherencia al sistema legislativo y brinda **seguridad jurídica**: ante una duda, el código es el lugar único donde se espera encontrar la respuesta, lo que facilita el conocimiento del ordenamiento. Presenta, no obstante, inconvenientes. Pretender que todo el ordenamiento quepa en un único instrumento responde a un cierto racionalismo, pero en la práctica la materia tiende a desbordar el código. Además, un código puede **cristalizar** un momento histórico; cuando después resulta necesario reformarlo, existe el riesgo de que las reformas alteren su carácter sistemático y generen incoherencias internas, afectando la unidad, la exclusividad y el orden que lo caracterizan.

Ventajas	Inconvenientes
Unidad y coherencia del sistema legislativo	Pretensión de exhaustividad nunca totalmente alcanzada
Seguridad jurídica: un lugar donde encontrar todo	Cristalización: el derecho puede quedar desactualizado
Facilita el conocimiento del ordenamiento	Las reformas parciales generan incoherencias internas

Cuadro 5.1: Ventajas e inconvenientes de la codificación

5.3. Orígenes históricos de la codificación moderna

El movimiento codificador se vincula con el pensamiento de la Ilustración y el racionalismo europeo del siglo XVIII. Comienza en Prusia, donde se elabora el *Código General de los Estados Prusianos*, obligatorio desde 1794 como derecho territorial de los estados y no limitado a la materia civil.

El código más importante de este movimiento es el **Código Civil francés de 1804** (Código Napoleón), que instaura el modelo de las codificaciones nacionales y ejerce una influencia decisiva, a inicios del siglo XIX, sobre numerosos países, incluidos los de América Latina. Los grandes codificadores latinoamericanos son **Freitas** (Brasil), **Andrés Bello** (Chile) y **Vélez Sarsfield** (Argentina); todos reciben una fuerte influencia del Código Napoleón, aunque se apartan de él en distintos aspectos.

Nota

La codificación no implica una ruptura con las instituciones preexistentes: el derecho civil abreva en una tradición jurídica que se remonta al derecho romano. La codificación pretende dotar a esas instituciones de unidad, sistematicidad y exclusividad, en consonancia con el espíritu racionalista e iluminista que confiaba en que la sola razón permitía abarcar y compendiar todo el conocimiento de una rama del derecho.

5.4. Cuadro Cornell: la codificación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es codificar y qué es un código?	Reunir orgánicamente en un cuerpo único las normas vigentes de una materia. El código es un cuerpo sistemático, orgánico y metódico de normas y principios de una rama del derecho.
¿Cuáles son los tres caracteres de un código?	Unitario, exclusivo y sistemático.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?	Ventajas: unidad, coherencia y seguridad jurídica. Inconvenientes: la materia desborda el código, cristaliza un momento histórico y las reformas parciales generan incoherencias.
¿Dónde y cuándo nace la codificación moderna?	En la Ilustración y el racionalismo del siglo XVIII; Prusia (obligatorio en 1794) y, sobre todo, el Código Civil francés de 1804.

Resumen: Codificar es reunir en un cuerpo unitario, exclusivo y sistemático las normas de una materia, con ventaja de seguridad jurídica y riesgo de cristalización. El movimiento nace con la Ilustración y se consolida con el Código Napoleón.

Capítulo 6

El Código de Vélez Sarsfield y la reforma de la Ley 17.711

La codificación argentina comienza con el Código Civil de Vélez Sarsfield y atraviesa más de un siglo de proyectos de reforma antes de su sustitución completa. Este capítulo describe el proceso de elaboración de ese código, sus fuentes y su método, y la primera gran reforma que lo modificó: la Ley 17.711.

6.1. Contexto constitucional y elaboración del Código de Vélez

La Constitución Nacional contemplaba que fuese el **Congreso de la Nación** quien dictara el Código Civil para todo el país. Al organizarse el Estado argentino, las provincias delegaron en el Congreso esa potestad, definición de gran importancia porque otorgaba unidad a una nación surgida de guerras fratricidas y fuertes disputas internas, que necesitaba consolidar su identidad y encontrar elementos de cohesión. Esa cohesión debía expresarse, entre otros ámbitos, en las instituciones básicas: la persona, la familia, los contratos, la propiedad y las sucesiones. Las provincias conservaron la potestad de dictar sus propios códigos procesales y organizar sus sistemas judiciales.

Por ley de 1863 se autorizó al Poder Ejecutivo a nombrar una comisión redactora. En 1864, el presidente Mitre encomendó la tarea a **Vélez Sarsfield**, jurista cordobés, quien se dedicó a ella durante cinco años y terminó el proyecto en 1869. El presidente Sarmiento lo envió al Congreso, que lo aprobó «libro cerrado» mediante la Ley 340.

Importante: Ley 340 (1869)

Aprobó el Código Civil de Vélez Sarsfield. Entró en vigencia el 1.º de enero de 1871.

6.2. Fuentes del Código de Vélez

El Código de Vélez se nutrió de las siguientes fuentes:

a) **Derecho romano**: llega a través de los estudios universitarios del propio Vélez Sarsfield y de la influencia de Savigny en su pensamiento.

b) **Legislación española y patria**: Vélez no pretendía marcar una ruptura con las formas y leyes del pueblo argentino, por lo que se advierte continuidad de instituciones provenientes de la legislación española.

c) **Derecho canónico**: influye especialmente en materia de matrimonio, cuyos efectos civiles quedan a cargo de Vélez Sarsfield (situación que cambiaría con la ley de matrimonio civil).

d) **Código Napoleón**: influye de forma directa e indirecta, a través de los comentaristas conocidos por Vélez, señalados en las notas al pie de su código.

e) **Código chileno de Andrés Bello, Código de Luisiana y Código uruguayo**.

f) **Proyecto de García Goyena** (España), obra de distintos juristas.

Importante

La influencia más importante fue la de **Augusto Teixeira de Freitas**, jurista brasileño, autor de una obra monumental —la *Consolidación de las Leyes* y el *Esbozo del Código Civil*— de la que Vélez tomó instituciones y contenidos. Es considerada la mayor influencia recibida por el Código Civil argentino, especialmente en cuanto a su método.

6.3. Método del Código de Vélez

El Código sancionado por la Ley 340 se estructuraba en dos títulos preliminares, cuatro libros y un título complementario:

Parte	Contenido
Título Preliminar I	De las leyes: teoría general de la ley
Título Preliminar II	Del modo de contar los intervalos del derecho
Libro I	De las personas (personas en general y derechos procedentes de las relaciones de familia)
Libro II	De los derechos personales en las relaciones civiles (obligaciones, hechos y actos jurídicos, contratos)
Libro III	De los derechos reales (vínculos directos entre persona y cosas)
Libro IV	Disposiciones comunes a los derechos reales y personales (sucesiones, privilegios, prescripción)
Título Complementario	Disposiciones de aplicación

Cuadro 6.1: Estructura del Código Civil de Vélez Sarsfield (Ley 340)

El método fue siempre muy valorado por tratar en un único título los hechos y actos jurídicos y por unificar los derechos reales. El matrimonio no era tratado entre los contratos sino dentro del derecho de familia propiamente dicho, y las sucesiones estaban separadas de las donaciones. Se le criticaba, sin embargo, la ausencia de una **parte general**.

6.4. Proyectos de reforma anteriores a 1968

Hubo distintos proyectos de reforma al Código de Vélez antes de su primera gran transformación:

Año	Proyecto	Características
1926	**Anteproyecto Bibiloni**	Jurista a cargo de la redacción inicial
1936	**Proyecto del 36**	Comisión que tomó como base el trabajo de Bibiloni
1954	**Anteproyecto Llambías**	Comisión presidida por Jorge J. Llambías; proyecto completo de reformas

Cuadro 6.2: Proyectos de reforma anteriores a la Ley 17.711

6.5. La Ley 17.711 (1968): primera reforma integral

La reforma efectiva llegó cien años después del Código de Vélez.

Importante: Ley 17.711 (1968)

Primera reforma integral del Código Civil argentino. Sancionada en abril de 1968, en vigencia desde el 1.º de julio de 1968.

La comisión redactora estuvo inicialmente integrada, según las fuentes, por Fleitas, Semon, Gorda, José Media López Olaciregui, Piensa, Aprobar, Tomar, Tiene Ruiz y Alberto. Tras distintas renuncias, el proyecto fue firmado por Martínez Ruiz, Fleitas e Híbrido. **Borda**, ministro del interior, es considerado el principal autor de la iniciativa.

La ley constituyó una transformación estructural muy importante, aunque no una derogación completa: conservó la estructura general del código e introdujo reformas en aspectos sustanciales.

6.5.1. Institutos incorporados

Definición: Lesión subjetiva (art. 954 del Código Civil)

Vicio del acto jurídico que permite solicitar la nulidad o modificación del acto cuando una parte, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtiene una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. Vélez la había rechazado expresamente en la nota al artículo 943; la Ley 17.711 la incorporó recogiendo las propuestas del Tercer Congreso de Derecho Civil realizado en Córdoba.

Definición: Teoría de la imprevisión

Permite resolver un contrato cuando ocurren circunstancias sobrevinientes que alteran sustancialmente la igualdad entre las prestaciones, tornándolas desproporcionadas para una de las partes. Su finalidad es restablecer la justicia contractual.

Definición: Abuso del derecho

Reconoce el carácter funcional de los derechos subjetivos: estos no pueden ejercerse de manera abusiva o contraria a los fines para los cuales fueron reconocidos.

Además, la reforma incorporó el factor moral en el derecho positivo, la protección de la buena fe, la corrección de un individualismo excesivo presente en algunos institutos del Código de Vélez y la equidad —también presente en la lesión subjetiva— como herramienta para corregir situaciones en el caso concreto. Su reforma del régimen de los efectos de la ley en el tiempo se estudia en el capítulo 14.

6.5.2. Reformas posteriores y proyectos de unificación

Con posterioridad se sucedieron reformas en materia de familia (leyes 23.264 y 23.515), en materia cambiaria y en materia de obligaciones, con la cuestión de la convertibilidad. Luego comenzaron los proyectos de reforma integral orientados a la **unificación** civil y comercial: en 1987 se conformó una comisión; en 1993 se presentaron el proyecto de la Cámara de Diputados —elaborado por una comisión federal— y un proyecto del Poder Ejecutivo; y en 1998 se presentó un nuevo proyecto, elaborado por una comisión designada por el Poder Ejecutivo. Este último ejerció una influencia decisiva sobre el Código Civil y Comercial de 2014, pues fue la base tomada por la comisión de 2011-2012.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

6.6. Cuadro Cornell: el Código de Vélez y la Ley 17.711

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo se elaboró y cuándo rigió el Código de Vélez?	El Congreso encargó la comisión (ley de 1863); Vélez lo redactó entre 1864 y 1869; fue aprobado «libro cerrado» por la Ley 340 y rigió desde el 1.º de enero de 1871.
¿Cuál fue su influencia principal?	Teixeira de Freitas, en especial en cuanto al método, junto con el derecho romano, la legislación española, el derecho canónico y el Código Napoleón.
¿Qué crítica se le hacía al método de Vélez?	La ausencia de una parte general.
¿Qué institutos incorporó la Ley 17.711?	Lesión subjetiva, teoría de la imprevisión y abuso del derecho, junto con el factor moral, la buena fe y la equidad.

Resumen: El Código de Vélez, sancionado en 1869 y vigente desde 1871, tuvo a Freitas como principal influencia y careció de parte general. Cien años después, la Ley 17.711 lo reformó sin derogarlo; los proyectos de unificación posteriores desembocaron en el Código Civil y Comercial.

Capítulo 7

El Código Civil y Comercial de la Nación

El Código Civil y Comercial de 2014 no es una reforma como la Ley 17.711: deroga el Código de Vélez y lo sustituye por un cuerpo nuevo. Este capítulo reconstruye su elaboración y trámite, compara su método con el del código anterior y expone sus grandes líneas.

7.1. Comisión redactora y elaboración del anteproyecto

En febrero de 2011, el **Decreto 191/2011** designó una comisión integrada por dos jueces de la Corte Suprema —el juez **Lorenzetti** y la doctora **Highton de Nolasco**— y una ex jueza de la Suprema Corte mendocina, la doctora **Aída Kemelmajer de Carlucci**. Estos tres juristas convocaron a 33 subcomisiones y a la colaboración de 90 profesores, y tomaron como base el proyecto de 1998. Las subcomisiones tuvieron poco diálogo entre sí, lo que se refleja en algunas inconsistencias internas entre tramos del proyecto; la comisión redactora unificó los aportes con la tarea de un coordinador, Federico De Lorenzo, aunque subsisten algunas inconsistencias.

Un año después la comisión presentó al Poder Ejecutivo el anteproyecto, que incluye fundamentos que reemplazan a las notas al pie y deroga completamente el Código de Vélez. El Poder Ejecutivo tomó tres meses adicionales para realizar sus propios ajustes y elevó el proyecto al Congreso el 8 de junio de 2012.

7.2. Trámite parlamentario

El proyecto ingresó por el Senado (expediente S-1157/2012). Se conformó una **comisión bicameral** de diputados y senadores, que estableció un mecanismo de trabajo con audiencias públicas en todo el país, con participación de particulares, organizaciones no gubernamentales, organizaciones públicas, jueces y abogados, y una expresión federal. Los temas más debatidos fueron la existencia de la persona, la maternidad subrogada, la propiedad indígena, la regulación de los consumidores y diversos temas de familia, propiedad, conjuntos inmobiliarios y otros derechos reales.

La comisión concluyó 2012 sin resultados y el proceso se mantuvo con perfil bajo durante 2013. Hacia octubre-noviembre de ese año se reencauzó: la comisión emitió su dictamen y el Senado dio media sanción el 27 de noviembre de 2013. En Diputados el tratamiento se retomó en septiembre y la sanción definitiva se produjo en la sesión del 1.º de octubre de 2014. El Poder Ejecutivo promulgó y publicó la norma en el Boletín Oficial el 8 de octubre de 2014.

Importante: Ley 26.994

Sancionada el 1.º de octubre de 2014 y promulgada el 8 de octubre de 2014, aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación. Entró en vigencia el 1.º de agosto de 2015 (la Ley 27.077 adelantó la fecha originalmente prevista).

7.3. Método del Código Civil y Comercial frente al Código de Vélez

El nuevo código cuenta con un **título preliminar** y **seis libros**, mientras que el de Vélez tenía dos títulos preliminares, cuatro libros y un título complementario. Su título preliminar se estudia en el capítulo 9.

Aspecto	Código de Vélez (1871)	Código Civil y Comercial (2014)
Títulos preliminares	Dos (leyes y modo de contar intervalos)	Uno, dividido en cuatro capítulos
Libros	Cuatro libros más título complementario	Seis libros
Parte general	No tenía	Libro Primero: Parte General (novedad metodológica)
Personas y familia	Libro I: personas y familia juntos	Separados: Libro I (personas / parte general) y Libro II (familia)
Personas humanas y jurídicas	Comenzaba por personas jurídicas	Comienza por personas humanas (Título I)
Sucesiones	En Libro IV (disposiciones comunes)	Libro Quinto (libro propio)
Notas al pie	Sí (fuentes y fundamentos de Vélez)	Reemplazadas por los Fundamentos del Anteproyecto
Unificación civil-comercial	No (Código de Comercio separado)	Sí (unifica materia civil y comercial)

Cuadro 7.1: Comparación metodológica entre el Código de Vélez y el Código Civil y Comercial

7.4. Grandes líneas del Código Civil y Comercial

7.4.1. En materia de persona y familia

La **persona humana** está regulada como principio fundamental al inicio del Libro Primero. Se deroga la definición de persona del Código de Vélez, por considerarse una noción previa al derecho: toda persona es un ser humano y no podría existir un ser humano que no sea persona. Se otorga centralidad al concepto de **dignidad**. Se ratifica que la existencia

de la persona comienza desde la concepción, pero se elimina la referencia al seno materno que contenía el código anterior, en atención al problema de los embriones.

Otras novedades en materia de personas son el capítulo de **derechos personalísimos** y una fuerte reforma en materia de capacidad, a la luz de las Convenciones de los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad, con tendencia hacia la **autonomía progresiva** de los niños y de las personas con discapacidad, acompañada de medidas de protección.

En materia de familia se advierte una marcada primacía de la autonomía individual: se debilita la institución matrimonial y aparece el **divorcio exprés**; en el régimen de bienes del matrimonio se habilita una opción de separación que antes no existía; se regula la **unión convivencial**, registrada o no; y en materia de filiación se incorporan las técnicas de reproducción asistida bajo la idea de voluntad procreacional, con problemas vinculados al derecho a la identidad. La maternidad subrogada, que había estado en el proyecto inicial, se excluyó del texto final, lo que dejó abierto un debate judicial en el que distintos jueces han dictado sentencias admitiéndola; conforme a las notas de origen, no está admitida en el ordenamiento argentino. La *patria potestad* pasó a llamarse **responsabilidad parental**. En materia sucesoria, el cambio más relevante es la reducción de la porción legítima —la de los descendientes pasó de cuatro quintos a dos tercios, y la de los ascendientes, de dos tercios a un medio— y se incorporó la posibilidad de mejorar la porción legítima a favor del heredero con discapacidad.

Institución	Código de Vélez	Código Civil y Comercial
Persona humana	Definida en el código (art. 30)	Concepto previo al derecho; se deroga la definición
Capacidad	Sistema rígido de incapacidades	Autonomía progresiva y apoyos para personas con discapacidad
Derechos personalísimos	Dispersos en el código	Capítulo específico en el Libro I
Matrimonio	Divorcio vincular (Ley 23.515)	Divorcio exprés, sin causales ni plazos
Régimen de bienes	Solo régimen de comunidad	Opción: comunidad o separación de bienes
Unión convivencial	No regulada	Regulada (registrada o no)
Filiación	Natural y matrimonial	Se agrega la filiación por técnicas de reproducción asistida
Maternidad subrogada	No regulada	Excluida del código (debate judicial abierto)
Patria potestad	Patria potestad (art. 264)	Responsabilidad parental
Legítima de descendientes	4/5	2/3
Legítima de ascendientes	2/3	1/2

Institución	Código de Vélez	Código Civil y Comercial

Cuadro 7.2: Comparación de institutos de persona y familia entre ambos códigos

7.4.2. En materia de derecho privado patrimonial

Se incorpora parcialmente el estatuto del consumidor y se regulan los contratos de consumo, aunque continúa vigente la ley de defensa del consumidor. En responsabilidad civil se incorpora la **función preventiva**, conservando la resarcitoria; no se regula la función punitiva, lo que dio lugar a un debate doctrinario. Se amplía la regulación de contratos, incorporando numerosos contratos antes no tipificados como nominados, y se incorporan nuevos derechos reales, como los conjuntos inmobiliarios. Se incorpora también, en el Libro Sexto, un título específico sobre derecho internacional privado.

Importante: Función preventiva de la responsabilidad civil

Antes del Código Civil y Comercial solo existía la función resarcitoria. El nuevo código reconoce expresamente la posibilidad de prevenir el daño antes de que ocurra (arts. 1710 a 1713 CCyC).

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

7.5. Cuadro Cornell: el Código Civil y Comercial

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo se elaboró?	Comisión designada por el Decreto 191/2011 (Lorenzetti, Highton de Nolasco y Kemelmajer de Carlucci), con 33 subcomisiones y 90 profesores, sobre la base del proyecto de 1998; trámite en comisión bicameral con audiencias públicas.
¿Cuándo se sancionó y cuándo rige?	Ley 26.994: sancionada el 1.º de octubre de 2014, promulgada el 8 de octubre de 2014; vigente desde el 1.º de agosto de 2015.
¿Qué cambia metodológicamente respecto de Vélez?	Un título preliminar y seis libros; parte general; persona humana antes que persona jurídica; familia y sucesiones en libros propios; unificación civil-comercial; fundamentos en lugar de notas.
¿Qué novedades trae en persona y familia?	Persona humana sin definición, dignidad central, derechos personalísimos, autonomía progresiva, divorcio exprés, uniones convivenciales, reproducción asistida y responsabilidad parental.
¿Qué novedad aporta en responsabilidad civil?	La función preventiva del daño (arts. 1710 a 1713), además de la resarcitoria.

Resumen: El Código Civil y Comercial deroga y sustituye al de Vélez, unifica la materia civil y comercial, abre con la persona humana y reconoce la autonomía progresiva, la autonomía individual en familia y la prevención del daño.

Parte III

La Constitución y el Título Preliminar del Código Civil y Comercial

El Código Civil y Comercial no se lee de manera aislada. Esta parte examina cómo la Constitución y los tratados de derechos humanos inciden en el derecho privado y cómo el Título Preliminar ordena el resto del código y concreta la unificación de la materia civil y comercial.

Capítulo 8

La constitucionalización del derecho privado

El Código Civil y Comercial no puede leerse aislado de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. Este capítulo explica qué significa constitucionalizar el derecho privado, por qué vías opera y qué ventajas y riesgos se han señalado, siguiendo a Corral Talciani.

8.1. Qué significa constitucionalizar el derecho privado

Definición: Constitucionalización del derecho privado

Influencia que ejercen la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos —con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22 CN)— sobre el derecho privado, proyectando efectos sobre todas las ramas jurídicas, incluida la del derecho civil.

El tema adquiere particular relevancia a partir de la reforma constitucional de 1994, que incorporó con jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos.

8.2. Las tres vías de constitucionalización

Corral Talciani explica que la constitucionalización opera a través de tres vías: la reformadora, la hermenéutica y la de aplicación directa.

8.2.1. La vía reformadora

A partir de los tratados de derechos humanos y de sus disposiciones se generan cambios en el ámbito legislativo.

Ejemplo: Vía reformadora

En 2008 Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 12 establece exigencias sobre la regulación de la capacidad de ejercicio y de la capacidad jurídica en general. Su recepción llevó a que en 2010 se sancionara una ley que modificó parcialmente el Código de Vélez en lo referido a las sentencias en materia de capacidad de ejercicio. De modo similar, la Convención sobre los Derechos del Niño —con principios como el interés superior del niño y el derecho del niño a ser oído— fue generando cambios legislativos sucesivos hasta la sanción del Código Civil y Comercial, que recepta las indicaciones de esa y de otras convenciones.

8.2.2. La vía hermenéutica

Refiere al modo de interpretar la ley: los principios y los tratados de derechos humanos operan como criterio para determinar su alcance y como pauta al momento de juzgar.

Regla: Art. 2 CCyC: interpretación

La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

Este artículo recoge en el texto del código la importancia de los tratados de derechos humanos como guía interpretativa.

8.2.3. La vía de aplicación directa

En algunos casos se verifica una aplicación directa de los tratados y de los principios constitucionales. La Constitución de 1994 incorporó, por ejemplo, normas sobre el consumidor y sobre hábeas data, que se aplican generalmente a través de legislación específica —la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Protección de Datos Personales—, pero en ciertos casos puede aplicarse directamente la norma constitucional. Esta situación es excepcional, porque el texto constitucional suele aparecer mediado por la legislación y por la tarea del Poder Legislativo.

Ejemplo: Caso emblemático (2019)

La Corte Suprema recurrió al principio de la dignidad y al derecho a la vida para modificar, en favor de una persona con discapacidad, el orden en que se cobran los créditos en el régimen de privilegios de la quiebra (Ley de Concursos y Quiebras). Fue un caso de aplicación directa de un principio constitucional para modificar una ley, reconocido como excepcional.

8.3. Ventajas y riesgos de la constitucionalización

8.3.1. Ventajas

Ventaja	Descripción	Reflejo en el CCyC
Centralidad de la persona y su dignidad	Se coloca a la persona humana en el centro del ordenamiento, resaltando su dignidad.	Art. 51 (dignidad), art. 19 (inicio de la existencia), art. 57 (protección del embrión)
Re-materialización del derecho	Incorporación de contenidos sustanciales frente a la idea de un derecho meramente procedimental o formal.	Todo el Título Preliminar y los artículos de la parte general sobre persona y familia

Ventaja	Descripción	Reflejo en el CCyC
Rehabilitación de la dimensión práctica o valorativa	Se recupera la importancia de la argumentación y de los principios en la tarea de juzgar.	Art. 2 (interpretación), art. 3 (deber de decidir de modo razonablemente fundado)
La Constitución como fuente del derecho	La Constitución, sus principios y sus valores se transforman en fuente del derecho aplicable.	Art. 1 (fuentes: Constitución y tratados junto a la ley)

8.3.2. Riesgos

Desde la filosofía jurídica, quienes sostienen una posición iusnaturalista entienden que existe el riesgo de pasar de un positivismo legalista a un positivismo constitucionalista, perdiendo la dimensión de los principios superiores al orden jurídico que iluminan e inciden en la valoración del ordenamiento. Se trata de un debate profundo sobre el rol del juez y sobre la jurisprudencia como fuente: en qué medida el juez crea el derecho o lo aplica cuando existe una ley que regula la situación.

Riesgo	Descripción
Pérdida de especificidad del derecho civil	La expansión del derecho constitucional puede afectar las metodologías de otras ramas. El derecho civil tiene principios sectoriales propios —como las reglas para calcular una indemnización— que pueden perderse cuando todo se constitucionaliza.
Positivismo judicial	El juez que, al aplicar la Constitución, se aparta excesivamente de la finalidad de la ley estaría determinando qué es lo obligatorio, alterando la división de poderes y erosionando la construcción republicana.
Inseguridad jurídica	Si en las relaciones civiles no se supiera a qué atenerse, la inseguridad resultante paralizaría la vida económica y social, generaría mayores costos y crearía problemas nuevos.
Desborde de fuentes del derecho	Por la pérdida de relevancia de la ley aparecen como fuentes fallos de tribunales internacionales, recomendaciones y convenciones de otros sistemas, lo que dificulta determinar el derecho aplicable.
Relativismo filosófico	A veces se sostiene que estas posiciones solo son admisibles en una construcción relativista. Desde el iusnaturalismo se sostiene que es posible conocer, a partir de la racionalidad humana, principios fundamentales: que la vida es un bien y que quitar la vida a una persona es un mal.

8.4. Cuadro Cornell: la constitucionalización del derecho privado

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es y desde cuándo es relevante?	La influencia de la Constitución y de los tratados de derechos humanos sobre el derecho privado; adquiere relevancia desde la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22 CN).
¿Cuáles son las tres vías?	Reformadora (cambios legislativos), hermenéutica (criterio de interpretación, art. 2 CCyC) y de aplicación directa (excepcional, como el caso de 2019).
¿Qué ventajas se señalan?	Centralidad de la persona, re-materialización del derecho, rehabilitación de la dimensión valorativa y la Constitución como fuente.
¿Qué riesgos se señalan?	Pérdida de especificidad del derecho civil, positivismo judicial, inseguridad jurídica, desborde de fuentes y relativismo filosófico.

Resumen: La constitucionalización opera por vías reformadora, hermenéutica y de aplicación directa. Aporta centralidad de la persona y de los principios, pero plantea riesgos para la especificidad del derecho civil, la seguridad jurídica y la división de poderes.

Capítulo 9

El Título Preliminar y la unificación civil y comercial

El Título Preliminar es el núcleo de significaciones generales del código. Este capítulo describe su estructura y el alcance de la unificación de la materia civil y comercial que el código concreta.

9.1. Importancia y estructura del Título Preliminar

El artículo 1 del CCyC señala la relevancia de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos como pautas para resolver los casos regidos por el código.

Nota

La Constitución puede compararse con la estructura de un edificio: define dónde pueden ir las paredes y cuánto peso pueden soportar. El Código Civil y Comercial es el interior del edificio —habitaciones, puertas, contratos, familia, herencias—, cuyo diseño debe respetar esa estructura madre. El Título Preliminar es el plano que explica cómo leer todo el edificio: qué fuentes son válidas, cómo interpretar las normas y qué principios prevalecen.

El Título Preliminar se divide en cuatro capítulos y consta de 18 artículos. Según la elevación del proyecto, estos artículos proyectan sus efectos sobre los seis libros del código.

Cap.	Título	Contenido principal	Artículos
1	**El derecho**	Fuentes y aplicación. Distinción entre derecho y ley.	**1, 2 y 3**
2	**La ley**	Ámbito de vigencia temporal y espacial. Efectos de la ley en relación al tiempo.	**4 a 8**
3	**Ejercicio de los derechos**	Principio del abuso del derecho y principio de buena fe.	**9 a 14**
4	**Derechos y bienes**	Clasificación de bienes jurídicos, cosas, patrimonio, cuerpo humano.	**15 a 18**

Cuadro 9.1: Estructura del Título Preliminar

Importante

El Título Preliminar ofrece un núcleo de significaciones generales para todo el código: en torno a él se encuentran los principios fundamentales que influyen sobre los demás libros.

9.2. La distinción entre derecho y ley

En los fundamentos del proyecto se distinguió entre «derecho» y «ley», señalando que el derecho es más que la ley. Los tres primeros artículos lo reflejan: el artículo 1 trata las fuentes del derecho (Constitución, tratados, ley, costumbre); el artículo 2, la interpretación de la ley; y el artículo 3, el deber de emitir una decisión razonablemente fundada. El texto de los artículos 1 y 2 y su análisis se desarrollan en el capítulo 11.

La importancia de «el derecho», como noción que supera a la ley, se enfatiza en el Título Preliminar, aunque en la práctica la ley sigue siendo la principal de las fuentes, como se aprecia en el capítulo 2 del mismo título.

9.3. Unificación de la materia civil y comercial

En la Argentina existieron distintas iniciativas de unificación de la materia civil y comercial (véase el capítulo 6). El Código Civil y Comercial la concreta, aunque, según los autores que han estudiado el tema, se trata de una unificación **parcial**. Se incorporan la teoría general de las condiciones y los contratos, con sus instituciones comunes, y ciertos temas en materia de actos jurídicos y de contabilidad y registros contables.

9.3.1. Materias que permanecen fuera del código

Continúan reguladas por sus propias leyes especiales: las sociedades comerciales (Ley General de Sociedades), las quiebras y concursos (Ley de Concursos y Quiebras) y la defensa de la competencia. La empresa como institución y el empresario no están incluidos ni regulados específicamente en el código. Tampoco existe en él una definición de la materia comercial: quedó derogado el Código de Comercio, que contenía un artículo específico sobre el acto de comercio y las definiciones de acto de comercio y de comerciante.

9.3.2. Contenido comercial incorporado

- La contabilidad y la rendición de cuentas.
- Toda la teoría de la representación (arts. 358 y siguientes).
- La parte especial de contratos, con numerosos contratos comerciales típicos.
- Las relaciones de consumo.
- Las reglas de interpretación de contratos que estaban en el Código de Comercio.

- El valor de los usos y las costumbres, con mayor presencia como fuente, especialmente en materia de contratos.
- Los títulos de crédito.

Parte IV

Las fuentes del derecho y la aplicación de la ley

Antes de estudiar a las personas, los bienes y los actos, esta parte presenta de dónde proviene el derecho aplicable (las fuentes), qué disponen los artículos 1 y 2 del código, cómo se forma la ley, desde cuándo rige y cómo se aplica en el tiempo, y qué papel cumplen la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.

Capítulo 10

Concepto y clasificación de las fuentes del derecho

Los seis primeros capítulos de esta parte abordan las fuentes del derecho en el derecho civil argentino, con especial énfasis en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994, en adelante CCyC). Se estudian la clasificación de las fuentes (formales y materiales), la ley como fuente principal (su concepto, clasificación, jerarquía y vigencia), la costumbre jurídica, la jurisprudencia (incluidos los fallos plenarios) y la doctrina como fuente material.

Nota

El conocimiento de las fuentes del derecho constituye una competencia fundamental para abogados, jueces, escribanos, funcionarios públicos y asesores legales: todo el razonamiento jurídico descansa en saber dónde buscar la norma aplicable, cuál tiene mayor jerarquía y cómo interpretarla cuando el texto no es claro. Por ejemplo, quien redacta un contrato debe saber si una cláusula contradice una norma imperativa (y por tanto es nula) o si simplemente desplaza una norma supletoria (lo cual está permitido). Un juez que resuelve un litigio debe ordenar las fuentes: primero la Constitución y los tratados de derechos humanos, luego las leyes, luego los decretos, y sólo entonces la costumbre o la doctrina como orientación no vinculante. Dominar el tema evita también errores graves: citar jurisprudencia como si fuera obligatoria cuando no lo es, ignorar un fallo plenario que sí lo es, o desconocer que una costumbre mercantil puede integrar válidamente un contrato comercial.

10.1. Concepto de fuentes del derecho

Las fuentes son los **modos de expresión del derecho**, es decir, las maneras en que el derecho se exterioriza. Su estudio comprende el concepto y la clasificación de las fuentes, las disposiciones generales del Código Civil y Comercial y el desarrollo de la principal de ellas, que es la ley.

10.2. Fuentes formales y fuentes materiales

Es habitual y clásica la distinción entre fuentes formales y fuentes materiales.

Definición: Fuentes formales

Son aquellas que son **obligatorias** y **vinculan al intérprete**; constituyen el modo de manifestarse externamente del derecho positivo.

Definición: Fuentes materiales

Son aquellas que **no son obligatorias**. Dan el contenido; persuaden por su razonabilidad; ofrecen razonamientos y argumentos en torno a lo justo, pero no son vinculantes.

Quien tiene a su cargo interpretar la ley (por ejemplo, un juez) no está obligado a seguir una fuente material. Sin embargo, la fuente material muchas veces **nutre a las fuentes formales**: la jurisprudencia, que durante mucho tiempo es una fuente material, cuando se consolida puede dar lugar a que se sancione, por ejemplo, una ley que recepta algo que la jurisprudencia ya venía sosteniendo.

10.2.1. Fuentes formales en el derecho argentino

Fuente formal	Definición
La ley en sentido material	Norma escrita, obligatoria, de carácter general, dictada por quien tiene el cuidado de una sociedad en orden al bien común. Esta norma de carácter general, escrita, promulgada y conocida es una fuente en sentido formal.
La costumbre jurídica	Conducta repetida de manera generalizada, en forma uniforme, por una porción importante de una comunidad, con la convicción de que se trata de un deber jurídico. No es un mero repetir de un hecho como un uso puramente social: existe una convicción jurídica.
Los fallos plenarios	Sentencias emanadas de una cámara de apelaciones reunida en pleno, cuando resuelve una cuestión en torno a la cual existen sentencias contradictorias de salas de esa misma cámara. Establece una doctrina que se vuelve obligatoria por disposición del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

10.2.2. Fuentes materiales en el derecho argentino

Fuente material	Descripción
La jurisprudencia en general	El conjunto de sentencias que dictan los jueces.
La doctrina	La opinión de los autores sobre los distintos temas jurídicos.
El derecho comparado	El recurso al estudio y análisis del ordenamiento jurídico de otros países, de sus leyes y de las decisiones de sus tribunales.
Los principios y valores jurídicos	Enunciados en el artículo 2 del CCyC.

10.3. El desborde de las fuentes

En el momento actual se asiste a un cierto **desborde de las fuentes del derecho**. Las razones que se señalan son las siguientes:

- La relevancia otorgada a la Constitución, a los tratados de derechos humanos y a los principios jurídicos fundamentales hace que muchas veces se invoquen tratados y que la ley pierda relevancia o fuerza.
- Esta situación se acompaña de una cierta crisis del positivismo jurídico y de un avance de teorías interpretativas, como el neoconstitucionalismo en sus distintas variantes. Estas teorías sostienen que el juez debe realizar la mejor interpretación posible, mirar el derecho bajo su mejor luz y tratar de descubrir la mejor solución en cada caso, lo cual quita relevancia a la ley.
- La existencia de comités de derechos humanos y la abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronuncia sobre muchísimos temas (opiniones consultivas, sentencias de homologación de acuerdos, de supervisión del cumplimiento de sentencias, de interpretación de sentencias), genera un enorme material y plantea la duda de si debe o no aplicarse.
- Aparece el denominado *soft law*: derecho no tan rígido ni tan formalizado, que surge de recomendaciones de un comité o de algún considerando de la Corte Interamericana en un caso determinado, respecto del cual se plantea cómo debe ser aplicado.

Todo ello tiene como consecuencia una cierta **inseguridad jurídica**. Es el contexto en el que se ejerce el derecho en el siglo XXI: un contexto de creciente **constitucionalización del derecho privado**.

Importante

Para el derecho civil, el Código Civil y Comercial sigue siendo la fuente principal (fuente formal especial), aunque exista una presencia muy fuerte de los tratados de derechos humanos. Esto marca nuevos desafíos para el intérprete.

10.4. Cuadro Cornell: concepto y clasificación de las fuentes

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué son las fuentes del derecho?	Son los modos de expresión del derecho; las maneras en que el derecho se exterioriza. Se clasifican en fuentes formales (obligatorias, vinculantes para el intérprete, como la ley, la costumbre y los fallos plenarios) y fuentes materiales (no vinculantes, pero que orientan por su razonabilidad, como la jurisprudencia general, la doctrina y el derecho comparado).

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Cuál es la diferencia entre fuente formal y fuente material?	La fuente formal obliga al intérprete: si existe una ley aplicable, el juez debe aplicarla. La fuente material persuade pero no obliga: un juez puede considerar la doctrina de un autor reconocido o un fallo de otro tribunal, pero no está obligado a seguirlos. La jurisprudencia, salvo los fallos plenarios, es fuente material en Argentina.
¿Cuáles son las fuentes formales y materiales en el derecho argentino?	Formales: la ley en sentido material, la costumbre jurídica y los fallos plenarios. Materiales: la jurisprudencia en general, la doctrina, el derecho comparado y los principios y valores jurídicos (art. 2 CCyC).
¿Qué se entiende por desborde de las fuentes?	La relevancia dada a la Constitución, a los tratados de derechos humanos y a los principios jurídicos, junto con la crisis del positivismo, el avance de teorías interpretativas como el neoconstitucionalismo y la abundante producción de comités y de la Corte Interamericana (incluido el *soft law*), hace que la ley pierda relevancia y genera inseguridad jurídica.

Resumen: Las fuentes son los modos de expresión del derecho. Las formales (ley en sentido material, costumbre jurídica y fallos plenarios) obligan al intérprete; las materiales (jurisprudencia general, doctrina, derecho comparado y principios y valores jurídicos) persuaden por su razonabilidad pero no obligan, aunque pueden nutrir a las formales. En el contexto actual de desborde de las fuentes y constitucionalización del derecho privado, el CCyC sigue siendo la fuente principal del derecho civil.

Capítulo 11

El Código Civil y Comercial: fuentes, aplicación e interpretación

11.1. Artículo 1: fuentes y aplicación

El artículo 1, titulado «Fuentes y aplicación», marca el tono del tema de las fuentes.

Regla: Art. 1 CCyC: Fuentes y aplicación

Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

De la primera parte surge la **ley como fuente formal**. La segunda parte refiere a la **costumbre**: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes (fuente en sentido formal) cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

Respecto de la redacción, la palabra «casos» parecería remitir siempre a una conflictividad, cuando a veces puede tratarse de una situación o relación jurídica (que es lo que propiamente trata el derecho civil y comercial) sin que haya un caso en sentido jurídico-técnico propio. Se trata de una disquisición sin mayor relevancia.

11.1.1. Tratados que no son de derechos humanos

El artículo 1 tampoco menciona a los tratados y convenciones que no son de derechos humanos. La materia que rige el CCyC es mucho más amplia que los tratados de derechos humanos, y existen tratados y convenciones que, aunque no sean de derechos humanos, son aplicables a materias civiles y especialmente comerciales. Tienen un rango superior a la ley, por lo que son fuente formal aunque no tengan jerarquía constitucional.

Regla: Art. 2594 CCyC: Normas aplicables (Derecho Internacional Privado)

Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas del derecho internacional privado argentino de fuente interna.

11.2. La jurisprudencia en el artículo 1: el debate legislativo

La comisión redactora del anteproyecto, integrada por quien era presidente de la Corte Suprema, por la magistrada que integró la Corte y por la autora del proyecto, terminó su tarea en marzo de 2012 y elevó el anteproyecto. En esa versión, el artículo 1 incluía a la jurisprudencia como fuente: establecía que los casos debían resolverse teniendo en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso.

Esto dio lugar a un debate en la comisión bicameral (el Ejecutivo envía el proyecto al Senado y se conforma una comisión bicameral). En el debate en el Congreso, los legisladores decidieron quitar esa frase.

El fundamento dado por la comisión bicameral en su dictamen final es que se optó por suprimir la referencia a la jurisprudencia porque esta importa un criterio vinculado al análisis del asunto judicial en cuestión, en procura de soluciones jurídicas más adecuadas que se fundamentan en el antecedente judicial: algo más que un criterio de interpretación directa. Básicamente se quiso señalar que **no se quería dar a la jurisprudencia el carácter de fuente formal**.

Importante

Si la jurisprudencia hubiera figurado en el artículo 1, podría haber sido considerada fuente formal y podría haberse pensado en un pasaje hacia un sistema donde la jurisprudencia fuera obligatoria. La jurisprudencia es una fuente material y no tiene carácter de fuente formal, a diferencia de otros sistemas con un deber mucho más estricto de seguir el precedente, que no está presente en el sistema argentino.

11.3. Artículo 2: interpretación de la ley

El artículo 2 brinda criterios para interpretar la ley, tema importante porque la ley siempre está sujeta a interpretación. Se reconoce como antecedente el artículo 16 del Código Civil de Vélez.

Regla: Art. 2 CCyC: Interpretación

La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

Criterio	Desarrollo
Palabras de la ley	Se atiende a qué palabras usa la norma. Por ejemplo, el art. 765 dice «puede liberarse»: el «puede» indica una opción o posibilidad del deudor; no dice que el acreedor deba aceptar.
Finalidad de la norma	Es un concepto difícil de determinar. Por ejemplo, la finalidad de la ley de alquileres podría ser favorecer una mayor seguridad jurídica y la protección de los vulnerables.
Leyes análogas	Cuando un tema no puede resolverse por el texto ni por la finalidad de la ley, se recurre a otras leyes. Durante años no hubo normas sobre consentimiento informado para actos médicos en general, pero sí una sobre consentimiento informado para trasplante de órganos; por analogía se aplicaba la ley de trasplante de órganos hasta que en 2009 llegó la Ley de Derechos del Paciente (26.529).
Tratados de derechos humanos	Criterio importante de interpretación, en base al proceso de constitucionalización y a la idea de que los tratados tienen rango constitucional.
Principios y valores jurídicos	Ha dado lugar a importantes discusiones. Los sectores positivistas señalan que esto abre demasiado la cuestión interpretativa. Una visión iusnaturalista diría que son principios que emanan de la razón humana y están por encima de la ley positiva; una visión neoconstitucionalista, que emanan del consenso internacional (como el principio de dignidad humana en la Declaración Universal de Derechos Humanos). Hay una coincidencia: al final hay una referencia a principios superiores a la ley positiva.
Coherencia del ordenamiento	Todo debe hacerse de forma coherente con todo el ordenamiento jurídico, tratando de salvar su coherencia interna.

11.4. Cuadro Cornell: artículos 1 y 2 del Código

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué establece el art. 1 del CCyC sobre las fuentes?	Titulado «Fuentes y aplicación», dispone que los casos se resuelven según las leyes aplicables, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. También establece que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones no regladas, siempre que no sean contrarios a derecho.
¿Por qué se eliminó la jurisprudencia del art. 1?	La comisión bicameral, en su dictamen final, optó por suprimir la referencia a la jurisprudencia para no darle el carácter de fuente formal, evitando la posibilidad de pasar a un sistema de precedente obligatorio. La jurisprudencia es fuente material.
¿Qué ocurre con los tratados que no son de derechos humanos?	El art. 1 no los menciona, pero existen tratados y convenciones aplicables a materias civiles y comerciales que tienen rango superior a la ley; son fuente formal aunque no tengan jerarquía constitucional.
¿Cómo se interpreta la ley según el art. 2 CCyC?	Teniendo en cuenta: 1) las palabras de la ley; 2) su finalidad; 3) las leyes análogas; 4) las disposiciones de los tratados de derechos humanos; 5) los principios y valores jurídicos; 6) todo ello de modo coherente con el ordenamiento jurídico en su conjunto.

Resumen: El art. 1 del CCyC reconoce como fuentes formales la ley (conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos) y la costumbre (cuando la ley o los interesados se refieren a ella o en situaciones no regladas, si no es contraria a derecho). La jurisprudencia fue suprimida del texto para no otorgarle carácter de fuente formal. El art. 2 establece los criterios de interpretación: palabras, finalidad, leyes análogas, tratados de derechos humanos, principios y valores jurídicos y coherencia con todo el ordenamiento.

Capítulo 12

La ley como fuente formal

12.1. Concepto de ley: definición iusnaturalista

Definición: Ley (Tomás de Aquino, iusnaturalismo)

La ley es una **ordenación de la razón** en orden al **bien común**, **promulgada** por quien tiene el cuidado de la comunidad.

La ley marca y prescribe conducta, regula, establece qué se puede hacer, señala aquello que debe realizarse, prohíbe conductas e indica sanciones para quien quebranta una disposición.

- **Ordenación de la razón:** se espera que la ley exprese fundamentos, se derive de principios lógicos y tenga una lógica interna que mueva a la voluntad. Las personas se mueven según fines y, para ver esos fines, cuentan con la racionalidad, que permite comprender qué es aquello que se debe hacer. La ley puede disponer algo que parezca irrazonable, lo que da lugar a la discusión sobre las leyes injustas; pero en principio se supone que toda ley prescribe algo para el bien común.
- **Bien común:** es la realización del conjunto de condiciones que permiten que las personas, las familias y las asociaciones puedan alcanzar su perfección. Para ello se necesita una autoridad que disponga qué debe hacer cada uno, señale los límites de las conductas y lo debido al otro.
- **Promulgada:** la ley necesita ser conocida; no puede quedar en la mente de quien gobierna o del Congreso, sino que debe ser dada a conocer.
- **Proviene de la autoridad:** quien no tiene autoridad no puede lograr, por ejemplo, que le transfieran un impuesto. La Constitución establece los mecanismos formales por los que se establecen las leyes, los decretos y las distintas normas.

Ejemplo: Alimentos en la familia

En la familia se deben alimentos: los padres hacia los hijos. Es algo que hace al bien común porque resulta bueno que haya un deber de acompañar a los niños en su crianza, lo cual tiene implicancias económicas. La ley prescribe que se paguen alimentos, y eso apunta al bien común: si los niños crecen y se desarrollan, la sociedad progresa, con más personas libres, sanas y capaces de entablar relaciones y buscar el bien entre todos.

12.2. Ley en sentido formal y ley en sentido material

Esta clasificación suele generar muchas confusiones.

Tipo	Concepto	Ejemplo
Ley en sentido **formal**	Actos que emanan del Poder Legislativo y que han sido elaborados por el procedimiento establecido en la Constitución en el título de la formación y sanción de leyes, que requiere también la participación del Poder Ejecutivo, que promulga o veta.	El Código Civil y Comercial (Ley N.° 26.994): el Congreso, bajo el procedimiento establecido, emite estos actos, los numera y los publica en el Boletín Oficial.
Ley en sentido **material**	Norma escrita, general y obligatoria que emana de la autoridad estatal competente. También es una fuente formal; la clave es que es norma escrita en general. Puede ser un decreto del Poder Ejecutivo o una resolución. El carácter de ley se lo dan la generalidad y la obligatoriedad.	El Decreto 1089/2012, que reglamenta la Ley 26.529 de Derechos del Paciente: no es ley en sentido formal (no fue aprobada por el Congreso) pero sí en sentido material.

Ejemplo: Derechos del paciente

Ante un problema como paciente (por ejemplo, en el contexto de la pandemia, por no haber recibido un trato adecuado), se recurre a la Ley de Derechos del Paciente (26.529, ley en sentido formal) y a su decreto reglamentario. Ambas son leyes aplicables al caso: leyes en sentido material.

Generalmente la ley en sentido formal es también ley en sentido material. Muy pocas veces hay leyes en sentido formal que no lo son: a veces se aprueba una pensión para alguien o alguna disposición muy específica que no tiene el alcance general de las leyes en sentido material. Por lo tanto, **no toda ley en sentido formal es ley en sentido material**.

12.3. Caracteres de la ley como fuente formal

Carácter	Explicación
Obligatoriedad	Es imperativa; se impone a la voluntad porque ha sido establecida por la autoridad que tiene la competencia dada constitucionalmente. El art. 4 CCyC establece: «Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales».
Generalidad	Rige a un número indeterminado de personas: a quienquiera que esté comprendido en el ámbito de su aplicación. Esto la distingue de los actos administrativos, donde el Estado decide respecto de un particular concreto (por ejemplo, al adjudicar una licitación).
Origen público	Emana de la autoridad con competencia en la materia. En sentido formal, del Congreso; en sentido material, de cada autoridad competente (por ejemplo, resoluciones de organismos como la Inspección General de Justicia), siempre dentro del marco de la ley y la Constitución.
Coactividad	Ante el incumplimiento existen maneras de forzar el cumplimiento. Por ejemplo, en el derecho civil, si alguien comete un ilícito civil y causa un daño, se puede lograr coactivamente que pague, embargando sus bienes y ejecutándolos. Las sanciones son resarcitorias o represivas.

12.4. Procedimiento de formación de las leyes

N.°	Etapa	Descripción
1°	Iniciativa	Presentar o proponer un proyecto de ley. Están facultados los miembros de cada cámara y el Poder Ejecutivo; también puede haber iniciativa popular si se dan ciertos requisitos que la Constitución establece con una ley reglamentaria.
2°	Discusión	Debate al interior de cada cámara. Hay cámara de origen y cámara revisora; ciertas materias deben comenzar por una cámara y no por la otra. Dentro de cada cámara hay comisiones de debate, se elaboran dictámenes, los dictámenes conforman el «orden del día», este se lleva al plenario y el plenario vota.
3°	Sanción	Acto por el cual el Poder Legislativo aprueba el proyecto. La cámara de origen aprueba; la otra revisa y, si hace cambios, vuelve a la cámara de origen. Si la cámara revisora aprobó sus cambios con dos terceras partes, la cámara de origen debe insistir con esa mayoría para vencer a la cámara revisora.
4°	Promulgación	El Poder Ejecutivo tiene la atribución de promulgar u observar (vetar) parcial o totalmente. La promulgación puede ser expresa (mediante un decreto) o tácita (si transcurren diez días sin que el Ejecutivo se pronuncie, se considera promulgada).
5°	Publicación	Acto por el cual se da a conocer la ley a través del Boletín Oficial, instancia en la que se puede conocer el texto completo. Ha ocurrido que alguien busca la ley en Google y obtiene un texto que no es el correcto (una versión previa o el proyecto originario); la versión vigente debe buscarse en el Boletín Oficial y en los sitios oficiales.

12.5. Clasificación de las leyes

Criterio	Tipo	Descripción y ejemplo
Por su contenido dispositivo	Prohibitiva	Ejemplo: art. 57 CCyC: «Queda prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia» (normas de ingeniería genética sobre embriones, para preservar la integridad de la especie humana y evitar actos eugenésicos).
	Dispositiva	Regula un hecho. Ejemplo: el plazo mínimo de un contrato de locación según la nueva ley de alquileres del año 2020 debe ser de tres años.
Por la materia	De fondo (sustantivas)	Regulan materias que hacen a los derechos fundamentales. Según el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, dictarlas es competencia del Congreso de la Nación (como el CCyC). Las provincias no podrían dictar sus propios códigos civiles.
	De forma (adjetivas)	Códigos procesales: son competencia de las provincias. El sistema federal hace que las provincias conserven el poder que no han delegado en el gobierno central.
Por su imperatividad	Imperativas (indisponibles)	Obligatorias; se imponen a las partes, que no pueden dejarlas de lado en sus convenciones. Ejemplo: el plazo mínimo del contrato de locación (3 años); no puede pactarse por 1 año aunque las partes quieran.
	Supletorias (disponibles)	Las partes pueden dejarlas de lado. Rigen por defecto, cuando las partes no dispusieron nada. Ejemplo: si el código permite la sublocación salvo acuerdo en contrario y el contrato nada dice, rige supletoriamente la permisión de sublocar.

Regla: Art. 962 CCyC: Normas indisponibles y supletorias en contratos

Las normas legales relativas a los contratos son supletorias por regla general, en materia de contratos. La excepción se da cuando del modo de expresión, de su contenido o de su contexto resulta su carácter indisponible.

12.5.1. Ejemplo problemático: el artículo 765 CCyC

Regla: Art. 765 CCyC: Concepto de obligación dineraria (texto parcial)

Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.

La regla según la cual «el deudor puede liberarse» ha dado lugar a dos interpretaciones: una parte de la doctrina argentina considera que es una norma **supletoria** (porque dice «puede liberarse»); otra parte sostiene que es **imperativa**.

Ejemplo: Consecuencias prácticas de la calificación del art. 765

Supóngase que se prestaron dólares y el contrato dice que quien los recibe se obliga a devolver en dólares y renuncia a la potestad de entregar el equivalente en moneda de curso legal. Si se interpreta que la norma es imperativa, esa cláusula no tendría ningún valor y el deudor podría, de todos modos, entregar pesos. Si se la interpreta como supletoria, la cláusula es válida.

La mayoría en las Jornadas de Derecho Civil del año 2015 opinó que esta norma era de carácter supletorio, y esta es la interpretación que ha primado hasta el momento.

12.6. Orden jerárquico de las leyes en el derecho argentino

La norma suprema es la Constitución Nacional. Los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional están dotados de esa jerarquía por el artículo 75, inciso 22, y se interpretan como complementarios de las normas de la primera parte de la Constitución.

Rango	Norma	Base constitucional
1°	Constitución Nacional y tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional	Art. 75 inc. 22 CN: norma suprema.
2°	Tratados internacionales y concordatos (no de derechos humanos), con jerarquía supralegal	Art. 75 inc. 22 CN: superiores a las leyes, inferiores a la Constitución.
3°	Leyes nacionales	Art. 75 inc. 12 y otros.
4°	Decretos del Poder Ejecutivo	Art. 99 CN.
5°	Resoluciones y reglamentos de organismos de la administración pública	Marco dado por las leyes.

Esta misma estructura se puede repetir en cada provincia con sus propias constituciones provinciales, leyes y decretos.

Ejemplo: Resolución de la Inspección General de Justicia

Al constituirse una asociación civil resulta aplicable una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el ámbito de Buenos Aires, que debe ser obedecida. Pero esa resolución no puede contradecir ni el Código Civil ni la Constitución Nacional. Si, en su manera de interpretar este marco, la IGJ los contradijera, estaría ante algo inválido que se podría impugnar.

12.7. Cuadro Cornell: la ley como fuente formal

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Cuál es la definición de ley según Tomás de Aquino?	Ordenación de la razón en orden al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Esta definición iusnaturalista destaca que la ley debe ser racional (derivada de principios lógicos), orientada al bien común, proveniente de quien tiene autoridad y promulgada (conocida).
¿Cuál es la diferencia entre ley formal y ley material?	Ley en sentido formal: emana del Poder Legislativo siguiendo el procedimiento constitucional (con participación del Poder Ejecutivo, que promulga o veta). Ley en sentido material: cualquier norma escrita, general y obligatoria emanada de autoridad estatal competente, aunque no sea del Congreso (decretos, resoluciones, etc.). Generalmente la ley formal es también material, pero no toda ley formal lo es (por ejemplo, la que aprueba una pensión para una persona determinada).
¿Cuáles son los caracteres de la ley?	Obligatoriedad (art. 4 CCyC), generalidad (rige a un número indeterminado de personas), origen público (autoridad competente) y coactividad (existen medios para forzar el cumplimiento; las sanciones son resarcitorias o represivas).
¿Cómo se forma una ley?	Iniciativa, discusión, sanción, promulgación (expresa o tácita a los diez días) y publicación en el Boletín Oficial.
¿Qué son las leyes imperativas y supletorias?	Las imperativas (indisponibles) se imponen a las partes y no pueden ser dejadas de lado por convención privada (ej.: el plazo mínimo de 3 años en la locación). Las supletorias (disponibles) rigen por defecto cuando las partes no dispusieron nada y pueden ser desplazadas por acuerdo (ej.: la sublocación, permitida salvo pacto en contrario). El art. 962 CCyC establece que en materia de contratos la regla es que las normas son supletorias.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es el orden jerárquico normativo en Argentina?	1°) Constitución Nacional y tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22). 2°) Tratados internacionales sin jerarquía constitucional (supralegales, pero inferiores a la Constitución). 3°) Leyes nacionales. 4°) Decretos del Poder Ejecutivo. 5°) Resoluciones y reglamentos de organismos administrativos. Una resolución que contradiga las normas superiores es inválida y puede impugnarse.

Resumen: La ley, definida como ordenación de la razón al bien común promulgada por quien cuida de la comunidad, puede ser formal (emanada del Congreso por el procedimiento constitucional) o material (norma escrita, general y obligatoria de autoridad competente). Sus caracteres son obligatoriedad, generalidad, origen público y coactividad. Se clasifica por su contenido (prohibitiva, dispositiva), por la materia (de fondo, de forma) y por su imperatividad (imperativas y supletorias). La jerarquía normativa va de la Constitución y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional hasta las resoluciones y reglamentos administrativos.

Capítulo 13

Vigencia temporal de la ley y cómputo de plazos

13.1. Vigencia temporal de la ley

Regla: Art. 5 CCyC: Vigencia

Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen.

La ley rige desde el octavo día de su publicación en el Boletín Oficial (desde el día de la publicación se cuentan ocho días y allí comienza su vigencia), salvo que la propia ley determine algo distinto. A veces la ley dice «esta ley rige desde el día de su publicación» o «a los 90 días» o «a los 180 días».

Ejemplo: Entrada en vigencia del Código Civil y Comercial

El Código Civil y Comercial iba a regir inicialmente a partir del 1° de enero de 2016, pero otra ley dispuso que rigiera a partir del 1° de agosto de 2015. El Código fue sancionado en octubre de 2014 y publicado en el Boletín Oficial el 8 de octubre de 2014; desde octubre hasta agosto no estuvo vigente, porque la ley determinó que entrara en vigencia el 1° de agosto. El legislador puede establecer cuándo rige la ley.

13.1.1. Modos de derogación

Tipo	Descripción
Expresa	La ley posterior dispone explícitamente la derogación de la anterior. Ejemplo: el CCyC (Ley 26.994) derogó expresamente el Código Civil de Vélez Sarsfield (Ley 340).
Tácita por incompatibilidad	Cuando la ley posterior y la anterior resultan incompatibles entre sí, la nueva ley deroga a la anterior.
Ley especial deroga ley general	Cuando hay una ley especial en la materia, se aplica la especial. Ejemplo: en materia de sociedades, la ley de sociedades es la ley especial respecto del CCyC (ley general).
Ley general posterior no deroga ley especial	Salvo que se pueda percibir la voluntad derogatoria del legislador.
Caducidad	A veces la propia ley establece su duración temporal; o pierde fuerza porque hay una costumbre contraria a ella o porque cambiaron las circunstancias y ya no tiene ese valor. Esto suele pasar muy raramente.

13.2. Modo de contar los intervalos del derecho (art. 6 CCyC)

Regla: Art. 6 CCyC: Modo de contar los intervalos del derecho

El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar desde uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al día siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente.

Tipo de plazo	Regla de cómputo	Ejemplo
En días	Se excluye el día del cómputo; empieza a contarse desde el día siguiente. Un día se toma de medianoche a medianoche.	Plazo de 15 días desde el 15/08: no cuenta el 15; comienza el 16; vence el 30/08 a las 24 h.
En meses	Se cuentan de fecha a fecha (mes a mes), no por días exactos.	3 meses desde el 15/08: vence el 15/11, aunque tengan distintas cantidades de días.
En años	Se cuentan de fecha a fecha (año a año).	1 año desde el 15/08/2020 vence el 15/08/2021.
Mes de vencimiento sin día equivalente	Si en el mes del vencimiento no existe esa fecha, se toma el último día del mes.	Plazo que vence el 31/02 (inexistente): vence el 28/02 (o 29 en año bisiesto).
Días inhábiles	El cómputo civil es de días completos y continuos; no se excluyen los días inhábiles o no laborables (admite prueba en contrario por ley o acuerdo de partes).	A diferencia del cómputo procesal, que sí excluye inhábiles.

Nota

Estas normas son de carácter supletorio, porque las partes pueden disponer un cómputo distinto en sus contratos o una ley especial puede establecer otras reglas.

13.3. Cuadro Cornell: vigencia de la ley y cómputo de plazos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuándo entra en vigencia una ley?	Desde el octavo día de su publicación en el Boletín Oficial, salvo que la propia ley determine algo distinto (desde el día de su publicación, a los 90 días, a los 180 días, o una fecha determinada).
¿Cómo deja de regir una ley?	Por derogación expresa (la nueva ley lo indica), tácita (incompatibilidad entre leyes), o mediante la regla de que la ley especial desplaza a la general; una ley general posterior no deroga a la especial, salvo voluntad derogatoria del legislador. También por caducidad, situación que suele ocurrir muy raramente.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Cómo se cuentan los plazos según el art. 6 CCyC?	Un día va de medianoche a medianoche. Los plazos en días excluyen el día del cómputo (se empieza a contar desde el día siguiente). Los plazos en meses y años se cuentan de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no existe el día equivalente, se toma el último día de ese mes. El cómputo civil es de días completos y continuos, sin excluir inhábiles. Estas reglas son supletorias: las partes o la ley especial pueden pactar otra cosa.

Resumen: Las leyes rigen desde el octavo día de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, y dejan de regir por derogación expresa o tácita, por la primacía de la ley especial o por caducidad. Los plazos civiles se computan de días completos y continuos, sin excluir inhábiles, salvo acuerdo o ley especial en contrario.

Capítulo 14

Los efectos de la ley con relación al tiempo

Este capítulo aborda una cuestión central del derecho civil: qué sucede cuando una ley cambia mientras una relación o situación jurídica se extiende en el tiempo. El problema recorre tres momentos: el sistema del Código de Vélez (1871), la reforma de la Ley 17.711 (1968) y el régimen vigente del artículo 7 del CCyC. La exposición sigue ese orden: primero se plantea el conflicto; luego se examina la solución del código originario, basada en la distinción entre derecho **adquirido** y **expectativa**; después se explica por qué esa solución resultó insuficiente y fue reemplazada por el criterio de los hechos **cumplidos**; y finalmente se muestra que el código vigente conserva esa lógica, con un agregado de protección al consumidor.

14.1. Planteamiento del problema

La pregunta que estructura el capítulo es: ¿qué sucede si hay cambios en la legislación aplicables a situaciones y relaciones jurídicas que se extienden en el tiempo? ¿Puede el legislador dictar normas retroactivas? ¿Con qué límites?

Ejemplo: El préstamo en dólares

Una persona presta a otra diez mil dólares a una tasa del cinco por ciento anual, mediante un contrato de mutuo regido por el Código Civil. Mientras la relación está en curso, el Código cambia y la nueva ley dispone que quien prestó dólares debe recibir la devolución en pesos. Se genera un conflicto entre las leyes a lo largo del tiempo: la relación jurídica no nació y concluyó bajo una misma ley, sino que se desarrolló en el tiempo y durante ese desarrollo cambió la norma.

14.1.1. Tres modos de aplicación de la ley en el tiempo

1. **Aplicación inmediata**: la nueva ley rige las consecuencias no cumplidas de relaciones jurídicas en curso.
2. **Aplicación retroactiva**: la nueva ley pretende regir situaciones jurídicas ya concluidas bajo la ley anterior.
3. **Aplicación para el futuro**: la nueva ley rige únicamente las relaciones jurídicas que nazcan a partir de su vigencia.

Ejemplo: Aplicación retroactiva sobre un préstamo ya cumplido

Si el dinero se prestó en enero de 2015 y se devolvió en julio de 2015, y el nuevo Código —vigente desde agosto de 2015— pretendiera aplicarse a lo ya cumplido, habría aplicación retroactiva. La aplicación para el futuro rige solo a partir de la entrada en vigencia del nuevo código, hacia adelante.

Ejemplo: El divorcio y los alimentos

Bajo el Código Civil anterior, el cónyuge declarado culpable en un divorcio podía ser condenado a pagar alimentos al cónyuge inocente. El Código Civil y Comercial eliminó la figura de la culpa en el divorcio y dispuso que ya no correspondía el pago de alimentos por esa causa. Frente a los reclamos de quienes debían seguir pagando alimentos bajo la ley anterior, los jueces entendieron que la nueva ley se aplicaba de inmediato a la situación jurídica en curso, de modo que el obligado dejaba de pagar desde la entrada en vigencia de la nueva norma.

14.2. El sistema del Código de Vélez (1871)

El código originario (Ley 340) regulaba la materia en su **artículo 3**, inspirado en el Código Civil francés.

Regla: Art. 3, Código de Vélez (texto original)

«La ley ha de disponer para lo futuro; no tiene efecto retroactivo, ni puede alterar los derechos adquiridos.»

Este artículo consagra el **principio de irretroactividad**: en principio, una ley rige el presente y el futuro y no alcanza a lo que ya ha ocurrido. Todo el sistema estaba organizado en torno a la noción de **derecho adquirido**.

Definición: Derecho adquirido

Un derecho está adquirido cuando se cumplieron todos los recaudos que la ley de fondo dispone para que ingrese al patrimonio de la persona, de modo que pueda considerarse su titularidad. Se distingue del derecho en expectativa (art. 4044) y de la mera facultad (art. 4045).

14.2.1. El derecho en expectativa (art. 4044)

Regla: Art. 4044, Código de Vélez

La nueva ley que entra en vigencia no se considera retroactiva si priva a los particulares de meros derechos en expectativa.

Definición: Derecho en expectativa

Aquel respecto del cual todavía no se han configurado los presupuestos necesarios para que la adquisición ocurra; por eso no está protegido frente a una nueva ley.

Ejemplo: La expectativa de heredar

Si una persona tiene la expectativa de heredar a un familiar y una nueva ley cambia el régimen de modo que ya no puede heredar, no puede sostener que la ley sea retroactiva, porque el familiar todavía no ha muerto y no se produjo la adquisición del patrimonio. Distinto sería que el familiar ya hubiera muerto y la nueva ley dispusiera que, de las personas fallecidas en los últimos dos años, solo heredan determinados familiares, excluyendo a quien reclama: allí habría retroactividad sobre un derecho ya adquirido, porque ya se habían cumplido todos los recaudos para que el derecho sucesorio ingresara al patrimonio del heredero.

14.2.2. La mera facultad (art. 4045)

Regla: Art. 4045, Código de Vélez

Si la ley anterior otorgaba una facultad de reclamar algo y esa facultad no fue ejercida, la nueva ley que priva de esa facultad no es retroactiva.

Quien tenía la facultad y no la ejerció es privado de algo que, en rigor, no llegó a tener.

14.2.3. Las excepciones del sistema

El sistema se completaba con dos artículos tradicionalmente considerados excepciones al principio de irretroactividad: los artículos 4 y 5.

14.2.3.1. Las leyes interpretativas (art. 4): una falsa excepción

Regla: Art. 4, Código de Vélez

Las leyes que tengan por objeto aclarar o interpretar otras leyes no tienen efecto respecto de los casos ya juzgados.

Ejemplo: Ley interpretativa sobre la tasa de interés

Si una ley dispone que la tasa de interés no puede superar un monto razonable y al año siguiente otra ley aclara que ese monto no puede superar el cinco por ciento, la segunda interpreta a la primera. La ley interpretativa se aplica a los casos en curso, pero no a los ya juzgados.

La doctrina la considera una **falsa excepción**: al ser interpretativa, en realidad se sigue aplicando la ley originaria y solo cambia la interpretación que se le da.

14.2.3.2. Las leyes de orden público (art. 5): la verdadera excepción

Regla: Art. 5, Código de Vélez

Ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público.

Importante

El artículo 5 es una excepción genuina: una nueva ley de orden público —es decir, que expresa principios fundamentales relativos a la subsistencia de la organización social— podía aplicarse retroactivamente. Esto generaba una considerable inseguridad jurídica, por lo que la Corte Suprema estableció que la ley de orden público no podía afectar derechos como la propiedad, garantizados por la Constitución. La noción de orden público se estudia en el capítulo 17.

Artículo	Contenido
Art. 3	Principio de irretroactividad de la ley y protección de los derechos adquiridos.
Art. 4044	El derecho en expectativa no está protegido frente a la nueva ley.
Art. 4045	La mera facultad no ejercida no está protegida frente a la nueva ley.
Art. 4	Las leyes interpretativas se aplican a casos en curso, no a casos juzgados (falsa excepción).
Art. 5	Las leyes de orden público pueden afectar derechos adquiridos (excepción real).

Cuadro 14.1: Síntesis del sistema del Código de Vélez

14.2.4. Crítica al sistema de Vélez

Una crítica que se volvió clásica, siguiendo al autor francés Roubier, sostiene que la teoría de los derechos adquiridos no servía para explicar cuándo una ley era retroactiva, especialmente en situaciones o relaciones que se prolongan en el tiempo.

Ejemplo: El préstamo en cuotas

Si un préstamo se pactó en varias cuotas, la primera cumplida y la segunda pendiente, y cambia la ley disponiendo que en lugar de dólares se pueden entregar pesos, el deudor pretende pagar en pesos y el acreedor cobrar en dólares conforme a la ley anterior. La idea de derecho adquirido no resuelve el conflicto: el acreedor sostendrá que el derecho está adquirido desde el primer momento; el deudor, que es una mera expectativa.

14.3. La reforma de la Ley 17.711 (1968)

La Ley 17.711 es el punto de inflexión decisivo: en lo sustancial, su sistema continúa rigiendo en la Argentina, pues el CCyC lo mantuvo en su parte central. Modificó el **artículo 3** y derogó los artículos 4, 5, 4044 y 4045.

Importante

La Ley 17.711 abandona la noción de derechos adquiridos y adopta la **teoría de los hechos cumplidos, o del consumo jurídico**, como criterio para determinar la retroactividad de la ley.

Definición: Teoría de los hechos cumplidos o del consumo jurídico

Un hecho jurídico es una contingencia susceptible de producir consecuencias jurídicas. Cuando un hecho está totalmente cumplido —se ha consumido, agotó la virtualidad de producir consecuencias jurídicas— se dice que se ha producido el consumo jurídico. Este criterio permite comprender que existe un elemento dinámico en las relaciones y situaciones jurídicas: los hechos pueden agotar todas sus consecuencias en un instante o cumplirse a lo largo del tiempo.

Ejemplo: Bicicleta y venta en cuotas

La compra de una bicicleta, en la que se paga y se entrega la cosa en un mismo acto, agota sus consecuencias jurídicas de manera instantánea. Una venta pactada en cuotas se cumple a lo largo del tiempo: la relación se consume recién cuando se paga la última cuota.

Regla: Art. 3, Código Civil, según la Ley 17.711

«A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias.»

Este artículo incorpora tres principios, que reemplazan a los cinco artículos del sistema originario.

14.3.1. Primer principio: efecto inmediato de la nueva ley imperativa

Definición: Efecto inmediato

A partir de su entrada en vigencia, la nueva ley se aplica de inmediato a las **consecuencias** de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, que se extienden en el tiempo. Se refiere a las **leyes imperativas**, es decir, las que se imponen a los particulares y que estos no pueden dejar de lado.

Ejemplo: Cuota pendiente de un préstamo

Si se prestó dinero y la primera cuota fue pagada pero la segunda no, esta última es una consecuencia no cumplida de la relación jurídica; la nueva ley se aplica a esa consecuencia pendiente.

14.3.2. Segundo principio: irretroactividad de la ley

Este principio se desagrega en cuatro componentes:

1. Las leyes no tienen efecto retroactivo: se aplican para el futuro, no hacia el pasado.
2. Deja de ser relevante si la ley es o no de orden público, en coincidencia con la derogación del artículo 5.
3. La propia ley puede disponer su retroactividad («excepto disposición en contrario»).
4. La retroactividad que establezca la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Respecto del segundo componente, la irretroactividad y el orden público dejan de confundirse: se trata siempre de leyes imperativas, pero la imperatividad puede o no coincidir con el orden público, tanto en el Código Civil como en el CCyC. En consecuencia, el carácter de orden público ya no resulta decisivo para la retroactividad: la regla general sigue siendo la irretroactividad, salvo disposición expresa en contrario, sea o no la ley de orden público.

Ejemplo: Retroactividad expresa: filiación por técnicas de reproducción asistida

Al sancionarse, el CCyC aplicó retroactivamente las normas sobre filiación derivada de la fecundación artificial a personas nacidas con anterioridad al código, para solucionar el problema filiatorio de esas personas. Es un caso de retroactividad establecida expresamente por la ley.

Importante

El legislador tiene la potestad de ordenar hacia el pasado, pero con un límite: la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Una ley que dispusiera que todos los préstamos en dólares de los últimos dos años deben transformarse a pesos afectaría un derecho de propiedad ya adquirido.

14.3.3. Tercer principio: efecto diferido de la nueva ley supletoria

Definición: Ley imperativa y ley supletoria

La **ley supletoria** es aquella que las partes de un contrato pueden dejar de lado mediante pacto en contrario; si nada dicen, se aplica lo que la ley dispone. La **ley imperativa** se impone a las partes, que carecen de libertad para apartarse de ella.

Ejemplo: La sublocación

En el CCyC, si las partes de una locación no dicen nada sobre la posibilidad de sublocar, se entiende que sí pueden hacerlo, pero pueden pactar algo distinto. Si el Código cambia esa regla supletoria, el cambio no rige la cláusula que las partes ya integraron a su contrato.

Ejemplo: El plazo mínimo de la locación de vivienda

La locación destinada a vivienda tiene un plazo mínimo de dos años que las partes no pueden dejar de lado. Esa imperatividad es distinta del carácter de la ley supletoria.

Una nueva ley supletoria tiene, entonces, **efecto diferido**: no se aplica de inmediato, sino recién a las relaciones jurídicas que se celebren desde su vigencia; no se aplica a un contrato en curso de ejecución.

14.4. El régimen vigente: artículo 7 del CCyC

El CCyC, vigente desde 2015, mantuvo en lo sustancial la redacción de 1968, ahora en su **artículo 7**.

Regla: Art. 7 CCyC

«A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.»

Los dos primeros principios no presentan cambios. La novedad está en el tercero.

Importante

Las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución, **con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo**: si el contrato en curso es de consumo, la nueva norma más favorable al consumidor se aplica de inmediato.

Nota

Se ha observado críticamente que este agregado transforma, en los hechos, la norma del consumidor en una norma imperativa, dado que se aplica de inmediato y las normas de protección al consumidor suelen ser imperativas. Resultaría algo inconsistente técnicamente, porque se formula como excepción referida a normas supletorias cuando la norma favorable al consumidor suele ser imperativa. El cambio se explica por la incorporación del derecho del consumidor al nuevo código, ausente en el anterior.

Aspecto	Vélez (1871): arts. 3, 4, 5, 4044, 4045	Ley 17.711 (1968) / CCyC (2015): arts. 3 y 7
Criterio rector	Derechos adquiridos	Hechos cumplidos / consumo jurídico
Irretroactividad	Principio general (art. 3)	Principio general; admite retroactividad expresa con límite constitucional
Orden público	Excepción real a la irretroactividad (art. 5)	Irrelevante a estos fines: no se confunde con la imperatividad
Leyes interpretativas	Falsa excepción (art. 4)	No reguladas como categoría aparte
Leyes supletorias y contratos en curso	No reguladas expresamente	Efecto diferido; excepción a favor del consumidor (solo CCyC, art. 7)

Cuadro 14.2: Comparación de los tres sistemas normativos

14.5. Cuadro Cornell: efectos de la ley en el tiempo

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es el problema y qué modos de aplicación existen?	Qué ocurre con la ley cuando una relación jurídica se extiende en el tiempo y cambia la norma. Modos: aplicación inmediata, retroactiva y para el futuro.
¿Cómo resolvía Vélez el problema?	Con la noción de derecho adquirido (art. 3), distinguida de la expectativa (art. 4044) y de la mera facultad (art. 4045), con dos excepciones: leyes interpretativas (falsa excepción) y leyes de orden público (excepción real).
¿Por qué fue criticado ese sistema?	Porque, según Roubier, la teoría de los derechos adquiridos no explica la retroactividad en relaciones que se prolongan en el tiempo (ejemplo del préstamo en cuotas).
¿Qué adoptó la Ley 17.711?	La teoría de los hechos cumplidos o del consumo jurídico, con tres principios: efecto inmediato de la ley imperativa, irretroactividad e efecto diferido de la ley supletoria.
¿Qué agrega el art. 7 CCyC?	Mantiene la redacción de 1968 y agrega la aplicación inmediata de las normas más favorables al consumidor en contratos de consumo en curso.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

Resumen: El sistema de derechos adquiridos de Vélez fue reemplazado en 1968 por el criterio de los hechos cumplidos, articulado en efecto inmediato, irretroactividad (sea o no de orden público, salvo disposición expresa y con límite constitucional) y efecto diferido de la ley supletoria. El art. 7 del CCyC lo conserva y agrega la excepción favorable al consumidor.

Capítulo 15

La costumbre como fuente formal

15.1. Concepto y elementos

Definición: Costumbre

Observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento por parte de los miembros de una comunidad social, con la convicción de que ese comportamiento responde a una necesidad jurídica.

La costumbre es una conducta que se repite, generalizada y uniforme, pero no cualquier conducta repetida: existe una **convicción de que es un deber jurídico**. Este elemento es muy importante, porque distingue la costumbre de un mero uso social.

Elemento	Denominación	Descripción
Objetivo	*Corpus*	Repetición de un comportamiento por cierto tiempo razonablemente prolongado, por parte de una comunidad.
Subjetivo	*Animus* (*opinio iuris*)	Convicción de los miembros de la comunidad de la obligatoriedad de esa conducta. Permite distinguir la costumbre de cualquier otro uso social.

Ejemplo: Costumbre y uso social

Un ejemplo trivial: una persona tiene la costumbre de ir siempre a un mismo café, pero ello no responde a un deber jurídico; no se obligó a consumir en ese café todos los días. Para demostrar que existe una costumbre jurídica hay que demostrar la observancia constante de un comportamiento, pero con la convicción de su obligatoriedad.

15.2. Importancia histórica de la costumbre

La costumbre fue durante mucho tiempo la fuente más importante en la producción normativa. Ha influido en institutos típicos del derecho francés, que son la base del ordenamiento argentino:

Instituto	Descripción
El patrimonio como garantía de los acreedores	La expectativa de poder exigir y ejecutar coactivamente el patrimonio (los bienes) del deudor.
La fuerza vinculante de los contratos (*pacta sunt servanda*)	Los pactos deben cumplirse y honrarse entre las partes.
La revocabilidad de las donaciones	Instituto que surgió de la costumbre.
La prescripción desde la exigibilidad	El cómputo de la prescripción comienza el día de la exigibilidad de una obligación.

Todas estas cuestiones surgieron del derecho consuetudinario en Francia, fueron recogidas por el Código Francés y pasaron así a los distintos ordenamientos. Además, la costumbre tiene importancia, y sigue teniéndola, en materia comercial y en muchas materias vinculadas con los contratos.

15.3. Tipos de costumbre

Tipo	Latín	Descripción
Costumbre según la ley	*Secundum legem*	Rige cuando la ley delega en la costumbre la atribución de regular una cierta situación; su autoridad está de alguna manera delegada por la propia ley. Ejemplo: el art. 1255 CCyC sobre el precio de los contratos de obra y servicios, regulado por los usos y costumbres.
Costumbre en ausencia de ley	*Praeter legem*	Rige en ausencia de disposición legal: en cierta materia nunca hubo una ley que regulara un tema, pero existió una costumbre. Ejemplo: antes de la Ley 18.248 (sobre nombre de personas físicas) existían costumbres que regulaban el nombre.
Costumbre contra la ley	*Contra legem*	La que contradice una disposición expresa; en principio no es válida. Ejemplo histórico: una norma en Francia que prohibía a las mujeres usar pantalones, vigente hasta 2010; la costumbre ya la había dejado obsoleta aunque no hubiera sido derogada formalmente.

15.4. La costumbre en el Código Civil y Comercial

En el Código Civil de Vélez, el artículo 17 decía que los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente: una fórmula negativa que el nuevo Código modifica. En el Código de Comercio, antes de la unificación, también había una gran importancia de la costumbre; su artículo 2 decía que en las materias en que las convenciones particulares pueden derogar la ley, la tradición (costumbre) autoriza al juez a indagar si la esencia del acto utiliza la costumbre.

El CCyC amplía la noción respecto del código anterior: antes se hablaba de «usos y costumbres»; ahora se agrega la expresión «prácticas». La costumbre es vinculante (fuente formal) cuando se dan los siguientes supuestos, conforme a la última parte del art. 1:

Supuesto	**Explicación**
La ley se refiere a ellos	Costumbre *secundum legem*. Igual que en el código anterior.
Las partes se refieren a ellos	Novedad del CCyC: las partes pueden pactar que su relación jurídica se rija en ciertos aspectos por las costumbres. Tiene especial relevancia en materia comercial.
Situaciones no regladas legalmente	Costumbre *praeter legem*. Ya estaba en el código anterior.
Que no sean contrarios a derecho	Condición agregada por el CCyC (no estaba en el código anterior). Es una fórmula de mayor amplitud que simplemente «no oponerse a la ley»: la costumbre no puede ser contraria al derecho en su conjunto.

15.4.1. Presencia de la costumbre en materia de contratos

Regla: Art. 964 CCyC: Integración del contrato

El contenido del contrato se integra con: a) las normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas; b) las normas supletorias; c) los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, siempre que su aplicación sea razonable.

Regla: Art. 970 CCyC: Contratos nominados e innominados (parcial)

Los contratos innominados están regidos, en el siguiente orden, por: a) la voluntad de las partes; b) las normas generales sobre contratos y obligaciones; c) los usos y prácticas del lugar de celebración [...].

Regla: Art. 1063 CCyC: Significado de las palabras (interpretación)

Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar de celebración.

Operación	En qué consiste	Art.
Integrar	Determinar qué cláusulas existen. Si un contrato no dice nada sobre un tema, se recurre a la ley imperativa, luego a la supletoria y luego a los usos y prácticas, que pasan a ser parte del contenido del contrato.	964
Interpretar	Determinar el alcance y sentido de una cláusula existente. Uno de los criterios para interpretar las palabras de un contrato son los usos y prácticas del lugar.	1063

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

15.5. Cuadro Cornell: la costumbre jurídica

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuáles son los elementos de la costumbre jurídica?	*Corpus* (elemento objetivo): repetición constante y uniforme de un comportamiento por parte de una comunidad, durante un tiempo razonablemente prolongado. *Animus* u *opinio iuris* (elemento subjetivo): convicción de los miembros de la comunidad de que esa conducta responde a un deber jurídico. Sin el segundo elemento, es un mero uso social, no costumbre jurídica.
¿Cuáles son los tipos de costumbre?	*Secundum legem*: la ley remite a la costumbre para regular cierta situación (ej.: precio de los contratos de obra). *Praeter legem*: rige en ausencia de ley. *Contra legem*: contradice una disposición legal expresa; en principio inválida. El CCyC exige que la costumbre no sea contraria a derecho.
¿Cuándo es vinculante la costumbre según el CCyC?	Cuando las leyes o los interesados se refieren a ella, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sea contraria a derecho. Novedades respecto del código anterior: se agrega el término «prácticas», la posibilidad de que las partes se refieran a ellas y la condición de no ser contrarios a derecho.
¿Qué diferencia hay entre integrar e interpretar un contrato?	Integrar (art. 964) es determinar qué cláusulas existen: ley imperativa, luego supletoria y luego usos y prácticas. Interpretar (art. 1063) es determinar el alcance y sentido de una cláusula existente, para lo cual los usos y prácticas del lugar son un criterio.

Resumen: La costumbre jurídica requiere *corpus* y *animus*. Puede ser *secundum*, *praeter* o *contra legem*. El art. 1 del CCyC la reconoce como vinculante cuando la ley o los interesados se refieren a ella o en situaciones no regladas, siempre que no sea contraria a derecho, y tiene presencia en materia de contratos (arts. 964, 970 y 1063).

Capítulo 16

Jurisprudencia, fallos plenarios y doctrina

16.1. La jurisprudencia como fuente material

La jurisprudencia es el conjunto de sentencias que dictan los tribunales de justicia. Es indudablemente una **fuente material**, porque no es vinculante.

La sentencia es la decisión judicial adoptada ante un caso concreto y, por lo tanto, tiene fuerza vinculante para las partes de ese caso. Por una aspiración de justicia, si ante una situación análoga se resolvió de una manera, existe la expectativa de obtener la misma resolución ante una situación parecida: el sentido de justicia lleva a preguntarse cómo puede ser que ante el mismo caso se resuelva distinto.

En el sistema argentino, sin embargo, la jurisprudencia no obliga: el hecho de que un juez haya dicho algo no obliga al siguiente, que puede resolver distinto. Tiene autoridad (un juez que ve que varios casos se resolvieron de una manera determinada puede considerar que no debe apartarse), pero no está obligado. Si hay una línea jurisprudencial muy uniforme o francamente mayoritaria, es difícil cambiarla, salvo que existan factores fundamentales superiores vinculados con principios fundamentales del ordenamiento jurídico o con la dignidad de la persona.

Como se vio en el capítulo sobre el CCyC, el artículo 1 no menciona la jurisprudencia. En el proyecto, elaborado por una comisión creada por decreto presidencial en febrero de 2011 y que entregó el anteproyecto en marzo de 2012, el artículo 1 la incluía como criterio para interpretar la ley y resolver un caso. Los legisladores de la comisión bicameral quitaron esa frase para evitar que la jurisprudencia pasara a ser fuente formal con obligatoriedad general.

16.2. Los fallos plenarios como fuente formal

Salvo los fallos plenarios, la jurisprudencia en principio no es fuente formal.

Definición: Fallo plenario

Sentencia dictada por una cámara de apelaciones en pleno que resuelve una cuestión en torno a la cual existen sentencias contradictorias dictadas por salas del mismo tribunal, y que se convierte en **obligatoria** para todas las salas y tribunales inferiores de ese fuero, en esa jurisdicción y competencia.

Para comprenderlo es necesario entender cómo funciona un tribunal. Los tribunales están organizados en instancias; se toma como ejemplo el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires:

Instancia	**Órgano**	**Función**
Primera instancia	Juzgados de primera instancia (unipersonales)	Tramita la demanda, contestación, producción de prueba, alegatos y sentencia.
Segunda instancia	Cámara de Apelaciones (organizada en salas de 3 miembros cada una: Sala A, B, C… hasta la M)	Revisa por vía de apelación las decisiones de primera instancia. Cada sala resuelve de manera independiente.
Tribunal en pleno	Todas las salas de la Cámara reunidas	Resuelve cuando hay contradicción entre salas sobre una misma cuestión jurídica. El fallo resultante es obligatorio.

Ejemplo: Contradicción entre salas que motiva un fallo plenario

Siguiendo con el tema del art. 765 (dólares): en una causa toca la Sala E, que sostiene que el art. 765 es supletorio, de modo que puede pactarse que la liberación sea sólo en dólares. La parte queda conforme porque pactó que el deudor no podría liberarse entregando pesos. En otro juicio se apela y la causa va a la Sala C, que entiende que la norma es imperativa y que las partes no pueden pactar que se entreguen siempre dólares: el deudor siempre tiene la potestad de entregar pesos. Hay contradicción: la Sala E dice una cosa y la Sala C otra.
Ante el fallo de la Sala C que perjudica a la parte, esta interpone el **recurso de inaplicabilidad de la ley**, que solicita a la Sala C que convoque el plenario de todas las salas. Todas las salas (A, B, C, …, M) se reúnen en plenario y resuelven el tema, unificando la interpretación. Esa posición se convierte en obligatoria para todas las salas y para todos los tribunales inferiores de ese fuero, en esa jurisdicción y competencia.

> **Arts. 300 y 303 del CPCCN — Efectos del fallo plenario.** La interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales aquélla sea tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión personal. Sólo podrá modificarse dicha doctrina por medio de una nueva sentencia plenaria.

El fundamento de los fallos plenarios es **unificar la jurisprudencia** y evitar criterios dispares, porque ofenden el sentido de justicia. El recurso se interpone dentro de los diez días de la sentencia definitiva, mencionando el precedente contradictorio y exponiendo

los fundamentos; el tribunal resuelve si es procedente. Si se dicta un fallo plenario, este establece la doctrina legal aplicable y sólo puede ser cambiado por otro plenario.

Importante

Un plenario de la Cámara Civil de Buenos Aires obliga a los jueces civiles de la Ciudad de Buenos Aires, pero no puede obligar a las cámaras de Córdoba o de Mendoza, que tendrán sus propios plenarios de acuerdo con sus códigos procesales.

16.3. Difusión de la jurisprudencia

Fuente de difusión	Descripción
Publicaciones oficiales de la CSJN	La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene su sitio oficial (www.csjn.gov.ar) con sus fallos.
Centro de Información Judicial (CIJ)	Publica a nivel nacional las sentencias que los tribunales tienen la obligación de remitir, con los datos debidamente analizados en los casos donde puede haber una cuestión de intimidad.
Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ)	También recoge mucha jurisprudencia, la publica y la difunde junto con distintos artículos y revistas.
Revistas especializadas	«La Ley», «El Derecho», «Jurisprudencia Argentina» y muchas otras, varias de base online, que difunden la jurisprudencia.

16.4. La doctrina como fuente material

La doctrina es la opinión de los juristas. Es una fuente material y, obviamente, no es obligatoria.

Hubo un momento histórico, en el primer milenio romano, en que ciertos juristas tenían el *ius respondendi ex auctoritate principis*: la autoridad para responder cuestiones y decir el derecho con la autoridad del príncipe. Fue un momento histórico determinado y ya no sería posible.

La doctrina tiene valor material: los autores escriben y publican en las revistas, esos textos llegan a los jueces, que los citan muchas veces al interpretar. Las partes también citan en sus escritos de demanda y contestación a autores que refuercen su postura. Por ejemplo, al interpretar el art. 765, se cita a un autor que dice que la norma es imperativa y a otro que dice que es supletoria; por la autoridad de ese jurista puede convenir citarlo, y así se convence a los jueces. El juez verá si los argumentos son convincentes, porque es una fuente material y por lo tanto no es obligatoria.

16.5. Otras fuentes materiales: derecho comparado y principios jurídicos

Fuente material	Descripción y alcance
Derecho comparado	Estudio y análisis de la legislación positiva existente en otros países, así como de la interpretación y aplicación que hacen sus propios tribunales. Tiene un valor relativo: que un juez de otro país haya dicho algo no implica que el juez argentino deba seguirlo. A veces tiene más valor si la ley argentina sigue a una ley extranjera (por ejemplo, el error reconocible del CCyC viene del Código italiano, caso en que el derecho comparado tiene más valor interpretativo). No es fuente formal: el juez no está obligado porque en España se resuelva de determinada manera.
Principios y valores jurídicos	El art. 2 señala que para interpretar la ley hay que tener en cuenta los principios y valores jurídicos. Es un criterio de interpretación que también de alguna manera es fuente material: informa la manera de determinar lo que es justo. Hay debate: los positivistas señalan que abre demasiado la cuestión interpretativa; el iusnaturalismo dice que son principios que emanan de la razón humana y están por encima de la ley positiva; el neoconstitucionalismo dice que emanan del consenso internacional (como la dignidad humana en la Declaración Universal de Derechos Humanos).

16.6. Cuadro Cornell: jurisprudencia, plenarios y doctrina

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué significa que la jurisprudencia es fuente material?	Que los fallos de los jueces orientan pero no obligan a otros jueces. Cada juez puede resolver distinto del anterior, incluso en casos análogos. La sentencia es vinculante sólo para las partes del juicio. La excepción son los fallos plenarios, cuya doctrina sí es obligatoria.
¿Qué es un fallo plenario y por qué es fuente formal?	Es una sentencia dictada por una cámara de apelaciones reunida en pleno, convocada mediante el recurso de inaplicabilidad de la ley, cuando existen criterios contradictorios entre salas. Unifica la interpretación y su doctrina es obligatoria para todas las salas y jueces de primera instancia de ese fuero y jurisdicción. Sólo puede ser modificada por otro plenario. Se regula en los arts. 288 y ss. y 300 a 303 del CPCCN.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué valor tiene la doctrina como fuente del derecho?	Es la opinión de los juristas. Es fuente material: no obliga pero puede persuadir. Los jueces pueden citarla y las partes la utilizan en sus escritos para fundar sus posiciones. Su peso depende de la autoridad del jurista y de sus argumentos. El *ius respondendi* fue un momento histórico que ya no sería posible.
¿Qué valor tienen el derecho comparado y los principios jurídicos?	El derecho comparado tiene un valor relativo y no es fuente formal; tiene más valor interpretativo cuando la ley argentina sigue a una ley extranjera. Los principios y valores jurídicos (art. 2) informan la manera de determinar lo que es justo y son objeto de debate entre positivistas, iusnaturalistas y neoconstitucionalistas.

Resumen: La jurisprudencia es fuente material: no obliga más allá de las partes del caso, salvo los fallos plenarios, que unifican criterios contradictorios entre salas y son obligatorios para las salas y los tribunales inferiores del fuero. La doctrina, el derecho comparado y los principios y valores jurídicos son fuentes materiales que orientan y persuaden, pero no obligan.

16.7. Síntesis de las fuentes del derecho

Las fuentes del derecho son el punto de partida de todo razonamiento jurídico: indican de dónde proviene la norma que debe aplicarse y qué jerarquía tiene frente a otras.

En el derecho argentino, el Código Civil y Comercial (art. 1) reconoce como fuentes formales (vinculantes) la ley (en sentido formal y material), la costumbre jurídica (cuando la ley o las partes se refieren a ella, o en situaciones no reguladas, siempre que no contravenga el derecho) y los fallos plenarios (sentencias de cámaras en pleno que unifican criterios contradictorios entre salas y resultan obligatorias para los tribunales inferiores del fuero). Son fuentes materiales (orientadoras pero no obligatorias) la jurisprudencia general, la doctrina, el derecho comparado y los principios y valores jurídicos (art. 2).

La ley, como fuente principal, puede ser formal (emanada del Congreso siguiendo el procedimiento constitucional) o material (cualquier norma escrita, general y obligatoria emanada de autoridad competente). Se clasifica, además, en imperativa (cuyas disposiciones las partes no pueden derogar) y supletoria (que rige por defecto cuando las partes no acordaron otra cosa). La interpretación de la ley exige integrar sus palabras con su finalidad, las leyes análogas, los tratados de derechos humanos y los principios jurídicos, todo de manera coherente con el ordenamiento.

Las leyes rigen desde el octavo día de su publicación oficial, salvo que establezcan otra fecha, y los plazos se computan de días completos y continuos, sin excluir inhábiles, salvo acuerdo en contrario. Comprender este sistema jerárquico y las reglas de vigencia e

interpretación es indispensable para cualquier profesional del derecho: permite saber qué norma aplicar, con qué fuerza, desde cuándo y cómo.

Parte V

Límites al ejercicio de los derechos: orden público, buena fe y abuso

Establecido de dónde proviene el derecho aplicable, esta parte precisa los límites de lo que las personas pueden hacer con él: el orden público, los principios de buena fe y equidad, y el abuso del derecho, tanto en su problema conceptual y sus criterios teóricos como en su recepción en el derecho argentino.

Capítulo 17

El orden público

El orden público es uno de los conceptos más transversales del derecho civil: aparece cada vez que una persona firma un contrato, alquila una vivienda, hereda un bien, se casa, se divorcia o negocia en otro país. Comprenderlo permite saber cuándo un acuerdo es válido y cuándo puede ser declarado nulo por afectar principios que la sociedad considera indisponibles, evitar redactar contratos inválidos, asesorar sobre cláusulas abusivas o leoninas y anticipar conflictos en alquileres, sucesiones internacionales y matrimonios celebrados en el extranjero.

Todos los temas del capítulo giran alrededor de una misma idea: la libertad de contratar tiene un límite. Es como las reglas de tránsito: cada conductor es libre de elegir su destino y su camino, pero no puede saltarse un semáforo en rojo porque pone en riesgo a toda la comunidad. Las personas son libres de pactar lo que quieran (autonomía de la voluntad), pero no pueden pasar por encima de ciertos principios básicos de la sociedad, ya sea dentro del país, frente a una ley extranjera o a lo largo del tiempo.

17.1. Punto de partida: la libertad de contratar

Dentro del derecho civil, las personas son libres para hacer contratos, convenciones y acuerdos. Este principio es la capacidad de autonomía, que el derecho civil clásicamente denomina **autonomía de la voluntad** y que se identifica con la libertad personal consagrada en la Constitución Nacional.

Regla: Art. 19 Constitución Nacional

«Nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe ni obligado a lo que la ley no manda.»

A partir de este principio, y siguiendo al derecho francés, existe una noción que limita los contratos: el **orden público**. No es posible celebrar una convención que tenga por finalidad afectar el orden público o que, aunque no se lo proponga, lo afecte de hecho.

El orden público no debe confundirse con el orden en la vía pública. Es un conjunto de principios fundamentales vinculados a la manera en que una sociedad se organiza y que limitan lo que las partes pueden pactar. Existen otros límites, como las leyes imperativas, que no necesariamente coinciden con él.

17.2. Teorías sobre el orden público

A lo largo del tiempo se intentó explicar qué es el orden público mediante distintas teorías:

- **Identificación con el derecho público.** Es inexacta, porque también existen normas de orden público dentro del derecho privado.
- **Identificación con el interés general.** Aproximación más precisa, pero imperfecta, ya que existen muchas normas de interés general que no son de orden público.
- **Identificación con la intuición del intérprete.** Identifica el orden público con lo que el juez debe decidir; no explica qué es, sino solamente quién decide sobre él.
- **Identificación con la voluntad del legislador.** El legislador determina cuándo algo es de orden público; sin embargo, la Corte Suprema ha dicho que una ley no es necesariamente de orden público solo porque el legislador lo diga, sino que depende de los principios fundamentales en juego.
- **Teoría de Bordas (leyes imperativas).** Para este autor, el orden público se identifica con las leyes imperativas.

17.2.1. Leyes imperativas y leyes supletorias

Para comprender esa última teoría hay que distinguir dos tipos de leyes. La **ley imperativa**, que el CCyC llama también indisponible, es la que las partes no pueden dejar de lado sin quebrantarla; de lo contrario, el acto sería nulo. Las **leyes supletorias** son las que las partes pueden dejar de lado mediante acuerdo (véase el capítulo 14).

Leyes imperativas (indisponibles)	Leyes supletorias
Las partes no pueden dejar de lado lo dispuesto por la ley; si lo hacen, el acto puede ser nulo.	Las partes pueden dejar de lado lo dispuesto por la ley y acordar algo distinto.
Ejemplo: el contrato de alquiler de vivienda no puede celebrarse por un plazo menor a dos años.	Ejemplo: el Código dice que el locatario puede subalquilar salvo disposición en contrario; las partes pueden acordar otra cosa.

Cuadro 17.1: Leyes imperativas y supletorias

Ejemplo: Alquiler de vivienda por seis meses

Quien quiere alquilar su casa es libre de contratar o no con una persona y de fijar el valor, pero el plazo mínimo del alquiler para vivienda es de dos años por una ley imperativa. Si las partes pactan seis meses, el contrato igualmente se entiende celebrado por dos años (sin perjuicio de que, a los seis meses, el inquilino pueda ejercer la facultad de rescindir, que es una cuestión distinta).

17.2.2. Género y especie: la crítica a la teoría de Bordas

Bordas sostenía que toda ley imperativa es de orden público y que todo orden público es imperativo. Los autores actuales (se citan Borda, Llambías, Rivera, Tobías y Alterini, entre otros) coinciden en general en que la ley imperativa es el género y las leyes de orden público una especie: no todas las leyes imperativas son de orden público, pero todas las de orden público son imperativas.

Ejemplo: Los tres prenombres

El Código Civil dice que no se pueden imponer a un hijo más de tres prenombres. Quien quisiera anotar a su hijo con cinco nombres de pila encontraría que el registro le permite solo tres. Es una ley imperativa, pero no necesariamente de orden público: hace a la forma de organización social —que alguien tenga tres nombres, cuatro o uno solo— sin comprometer principios esenciales de la sociedad.

17.2.3. Definición mayoritaria y caracteres del orden público

Definición: Orden público

«Un conjunto de principios esenciales de orden político, jurídico, económico, moral y religioso, sobre los cuales se sustenta la organización social y la persistencia de la misma en el tiempo.»

Es un concepto amplio e indeterminado, que no puede encontrarse listado y que cambia con el tiempo. El propio legislador, en ocasiones, aclara que una ley es de orden público —como la Ley de Defensa del Consumidor— para enfatizar que no puede ser dejada de lado. Siguiendo a Borda, son dos sus características: es **eminentemente particular de cada país** (lo que es de orden público en uno puede no serlo en otro) y es **mutable**, lo que se vincula con el derecho internacional privado.

Nota: Tres conceptos que no deben confundirse

La *opinión pública* es un concepto sociológico, de la comunicación, sin implicancias jurídicas. El *derecho público* regula al Estado y a los particulares en su relación con él. El *orden público* es un conjunto de principios que inspiran a una sociedad y limitan lo que las partes pueden disponer; es un concepto propio del derecho privado, vinculado a la limitación de la autonomía de la voluntad.

17.3. Tres grandes supuestos de aplicación

Pueden identificarse tres supuestos: el orden público frente a la autonomía de la voluntad, frente a la aplicabilidad de la ley extranjera y frente a los efectos de la ley en el tiempo.

17.3.1. Orden público y autonomía de la voluntad

Regla: Art. 958 CCyC: libertad de contratación

Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Celebrar un contrato significa hacerlo cuando se quiera y con quien se quiera; determinar su contenido también es libre, pero dentro de esos límites. El orden público es un límite distinto de la ley misma: señala principios que van más allá de lo que la ley dice expresamente, aunque a veces ambos se conjugan, cuando la ley declara que cierta materia es de orden público.

Ejemplo: La compraventa de órganos

Quien ofrece vender su riñón encuentra un límite impuesto por la ley, que prohíbe la compraventa de órganos, y también por la moral y las buenas costumbres, que consideran que vender órganos afecta un sentido moral.

El artículo 12 del CCyC. El artículo 958 se vincula con el artículo 12 del título preliminar, de origen en el Código francés y presente ya en el Código de Vélez.

Regla: Art. 12, primera parte, CCyC

Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público.

La redacción anterior aludía también a la moral y las buenas costumbres; la mención se quitó, lo que se trataría de una omisión involuntaria, dado que las buenas costumbres subsisten en el artículo 958. El artículo 12 se refiere a algo más intenso que las leyes imperativas comunes: las partes pueden apartarse de las leyes supletorias, pero tampoco de las imperativas en general, aunque esto último no esté dicho expresamente y sea sobreentendido.

Regla: Art. 279 CCyC: objeto del acto jurídico

El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana.

Nulidad de los actos contrarios al orden público. Otras normas reiteran la lógica:

Regla: Art. 1004 CCyC: objeto de los contratos

No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos.

Regla: Art. 1014 CCyC: causa

Es nulo el contrato cuando su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Regla: Art. 386 CCyC: nulidad absoluta

Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres.

El artículo 279 corresponde al Libro Primero (actos jurídicos como categoría general) y el 1004 al Libro Tercero (contratos): los actos jurídicos son el género y el contrato es una especie. El **acto jurídico** es el acto voluntario y lícito que tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos (art. 259) y puede hacer nacer, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas; abarca contratos, testamentos y matrimonios.

Definición: Nulidad absoluta y nulidad relativa

La **nulidad** es una sanción que consiste en privar a un acto de sus efectos propios por un vicio existente al momento de su celebración. La **nulidad absoluta** se da cuando el acto contraría el orden público: no puede confirmarse, es imprescriptible y puede ser declarada de oficio si es manifiesta. La **nulidad relativa** protege un interés particular, por lo que el acto puede eventualmente ser confirmado.

Facultades del juez para modificar el contrato.

Regla: Art. 960 CCyC

Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público.

Es una facultad extraordinaria, muy importante, que no estaba en el código anterior.

17.3.2. El fraude a la ley

Regla: Art. 12, segunda parte, CCyC

El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir.

Ejemplo: El alquiler «turístico»

Hay una norma que prohíbe alquilar una vivienda por menos de dos años. Quien invoca la norma que permite contratos temporarios por turismo y hace pasar por turismo lo que en realidad es un alquiler para vivienda por seis meses, con el fin de evitar el efecto de la inflación en un contrato largo, hace trampa a la ley. Su alquiler debe sujetarse a

la norma imperativa que se trató de eludir: se considera que dura dos años aunque se lo haya denominado alquiler turístico.

El fraude a la ley no se analiza en el derecho civil como un delito que deba perseguirse penalmente. Puede ser cometido por ambas partes en connivencia, en cuyo caso el juez impone igualmente el orden público, o por una sola de ellas.

17.3.3. La renuncia general a las leyes

Regla: Art. 13 CCyC

Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba.

Este texto guarda similitud con el artículo 19 de la Constitución Nacional y subyace en él la idea de que una renuncia general a la ley compromete, en general, el orden público.

17.3.4. Orden público y ley extranjera

El segundo supuesto parte del principio de territorialidad:

Regla: Art. 4 CCyC

Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República Argentina.

Por las reglas del derecho internacional privado puede, sin embargo, invocarse en ciertas circunstancias la aplicación de una ley extranjera.

Ejemplo: Matrimonio con bienes en España

Un matrimonio casado en la Argentina tiene bienes regidos por la ley española. Al divorciarse en la Argentina, el juez argentino aplica la ley española respecto de ese bien. Es un tema típico del derecho internacional privado.

Regla: Art. 2600 CCyC

Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino.

Su antecedente es el artículo 14 del código anterior, que hablaba de límites a la aplicación de la ley extranjera sin mencionar expresamente el orden público. El actual es más claro.

Ejemplo: Hijos matrimoniales y extramatrimoniales

En un país «X» subsisten diferencias entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Una familia de ese país se instala en la Argentina y se invoca, para la sucesión, una ley en la que el hijo extramatrimonial no hereda. Los jueces no aplican esa ley extranjera

porque viola el orden público nacional, en el que los hijos son todos iguales (la herencia es igualitaria desde 1985).

Nota: Matrimonios y divorcios en el extranjero

Un divorcio realizado en el exterior por una pareja casada en la Argentina puede tener validez, pero debe analizarse conforme al derecho internacional privado: normalmente se examina primero la validez del matrimonio (según la ley del lugar de celebración) y luego la disolución del vínculo, que puede regirse por la ley local del divorcio o por la ley de celebración, según el caso. Como ejemplo extremo, el matrimonio de una niña de doce años celebrado en su país de origen no puede inscribirse en la Argentina, porque viola el principio de orden público según el cual el matrimonio de niños está prohibido (en principio, solo con dispensa judicial para menores de 16 años o con autorización de los padres entre los 16 y los 18). El *punto de conexión* es el criterio que determina cuál es la ley aplicable; el juez competente puede ser de un país y el derecho aplicable el de otro.

17.3.5. Orden público y efectos de la ley en el tiempo

El tercer supuesto fue estudiado en el capítulo 14. Bajo el artículo 5 del código de Vélez, las leyes de orden público podían aplicarse retroactivamente incluso contra derechos adquiridos. La reforma de 1968 modificó esa solución y el artículo 7 del CCyC dispone que las leyes no son retroactivas, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario: el orden público dejó de ser decisivo respecto de la retroactividad. La Ley 17.711 hizo cambios importantes casi exclusivamente en este supuesto; en autonomía de la voluntad y ley extranjera no hubo mayores cambios.

17.4. Cuestiones frecuentes sobre el orden público

¿Cómo se sabe si una ley es de orden público? A veces la ley lo dice expresamente (como la Ley de Defensa del Consumidor); otras veces hay que analizar si la norma protege los principios fundamentales del funcionamiento de la sociedad. Es un tema difícil y, en definitiva, el juez determina en cada caso si algo es de orden público. Se mencionó como ejemplo de actualidad la discusión sobre las normas de pago en dólares: no hay respuesta única y las resuelven los jueces.

¿Todo queda librado a la subjetividad del juez? No: conforme al artículo 3 del CCyC, todo juez debe dar una decisión razonable y fundada; cuando invoca la moral, las buenas costumbres o el orden público debe explicar por qué, en la situación concreta, se trata de un supuesto de orden público.

¿Varía el orden público con el tiempo? Sí; las leyes pueden seguir calificándose de orden público mientras la valoración social cambia. En principio se toma como de orden público lo que la ley así califica, y el juez determina si esa calificación se mantiene. Los jueces no pueden dejar de aplicar leyes imperativas ni las partes apartarse de ellas.

¿Son los contratos leoninos contrarios al orden público? No necesariamente. El contrato leonino abusa de la posición de una parte y se vincula más propiamente con el vicio de lesión (art. 332 CCyC); pueden cruzarse lesión, abuso de derecho y orden público, pero son figuras distintas.

¿Siempre prevalecen las normas de derecho internacional? No: depende del punto de conexión, y un juez argentino puede aplicar derecho extranjero o un juez extranjero, derecho argentino.

17.5. Cuadro Cornell: el orden público

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el orden público y qué límites impone?	Conjunto de principios esenciales de orden político, jurídico, económico, moral y religioso que sustentan la organización social; limita la autonomía de la voluntad (arts. 958, 12 y 279).
¿Cómo se distinguen leyes imperativas y supletorias, y qué relación hay con el orden público?	Las imperativas no pueden dejarse de lado; las supletorias sí. Toda ley de orden público es imperativa, pero no toda imperativa es de orden público (ejemplo de los tres prenombres).
¿Qué consecuencias tiene contravenirlo?	Nulidad absoluta (art. 386): no confirmable, imprescriptible y declarable de oficio si es manifiesta; el juez puede modificar el contrato de oficio (art. 960).
¿Qué es el fraude a la ley?	Acto que invoca una norma para lograr un resultado análogo al prohibido por una norma imperativa (art. 12); se somete a la norma eludida.
¿Cómo opera frente a la ley extranjera?	Art. 2600: se excluye el derecho extranjero que conduce a soluciones incompatibles con los principios de orden público argentino.
¿Qué rol tiene respecto de la retroactividad?	Ninguno desde 1968: las leyes no son retroactivas, sean o no de orden público, salvo disposición expresa (art. 7).

Resumen: El orden público es el límite de la autonomía de la voluntad: su violación acarrea nulidad absoluta, el fraude a la ley se corrige sometiendo el acto a la norma eludida, excluye la ley extranjera incompatible y ya no determina la retroactividad de las leyes. Es mutable y propio de cada país, y lo determina el juez con decisión fundada.

Capítulo 18

Principios del derecho civil: buena fe y equidad

Además de la justicia, la dignidad y el bien común (véase la sección 1.4), el derecho civil se apoya en principios que el Título Preliminar proyecta sobre todo el código. Este capítulo estudia los de buena fe y equidad.

18.1. El principio de buena fe

Regla: Art. 9 CCyC: principio de buena fe

Los derechos deben ser ejercidos de buena fe.

Este principio se incorpora en el Título Preliminar y proyecta sus efectos sobre todo el código. Presenta dos grandes dimensiones:

Dimensión	Descripción	Ejemplo
Buena fe objetiva	Conformidad con ciertas reglas; obrar conforme a estándares objetivos de comportamiento.	El poseedor es de buena fe cuando no conoce —ni puede conocer— que carece de derecho; por ejemplo, quien compra algo con un vicio en la cadena de transmisión sin saberlo.
Buena fe subjetiva	Deber de lealtad; se vincula con el modo en que las partes ejecutan y desenvuelven los contratos: con honestidad, sin ocultar ni retener información relevante.	Deber de honestidad entre contratantes durante las negociaciones y la ejecución; una parte no puede retener información que la otra necesita para decidir.

Cuadro 18.1: Dimensiones de la buena fe

18.2. El principio de equidad

Otro principio central es la equidad, vinculada con la justicia en el caso concreto: según la formulación aristotélica, la «rectificación de lo justo legal en el caso concreto». Ya se encontraba en la Ley 17.711 y en el Código Civil anterior; en el CCyC se la encuentra especialmente en los artículos 332 y 1742.

Regla: Art. 332 CCyC: lesión

Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. El juez debe apreciar subjetivamente las circunstancias y puede hacer reajustes equitativos cuando se presenta una situación desproporcionada.

Regla: Art. 1742 CCyC: atenuación de la responsabilidad

El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable.

En ambos casos los jueces pueden efectuar rectificaciones o reajustes equitativos, procurando corregir la situación injusta que se presenta en el caso concreto.

18.3. Cuadro Cornell: título Preliminar, unificación y principios

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo se estructura el Título Preliminar?	Cuatro capítulos y 18 artículos: el derecho (1 a 3), la ley (4 a 8), ejercicio de los derechos (9 a 14) y derechos y bienes (15 a 18).
¿Qué distinción introduce entre derecho y ley?	Que el derecho es más que la ley: art. 1 (fuentes), art. 2 (interpretación) y art. 3 (decisión razonablemente fundada).
¿Qué alcance tiene la unificación civil y comercial?	Es parcial: se incorporan contratos, representación, consumo, contabilidad y títulos de crédito; quedan fuera sociedades, concursos y quiebras y defensa de la competencia.
¿Qué dimensiones tiene la buena fe?	Una vinculada a reglas objetivas de comportamiento y otra al deber de lealtad y honestidad en la ejecución de los contratos (art. 9).
¿Qué es la equidad y dónde aparece?	La rectificación de lo justo legal en el caso concreto; arts. 332 (lesión) y 1742 (atenuación de la indemnización).

Resumen: El Título Preliminar contiene el núcleo de principios del código. Distingue derecho de ley, concreta una unificación parcial de la materia civil y comercial y consagra la buena fe y la equidad como principios que permiten corregir el caso concreto.

Capítulo 19

El problema conceptual del abuso del derecho

19.1. Introducción

El abuso del derecho es uno de los institutos más importantes del Derecho Civil argentino. Su estudio comprende tres cuestiones: qué significa ejercer un derecho de forma «abusiva», cuáles son los criterios teóricos para identificarlo y cómo fue incorporado progresivamente al ordenamiento jurídico argentino, desde el Código Civil de Vélez Sarsfield hasta el Código Civil y Comercial de 2015.

Importante

El artículo 10 del Código Civil y Comercial se aplica en todas las ramas del derecho: civil, comercial, laboral, administrativo y ambiental. En contratos, sociedades, propiedad horizontal o relaciones laborales, el abuso del derecho es un límite que los jueces aplican cotidianamente para evitar injusticias.

Desde el punto de vista profesional, el abuso del derecho constituye:

- una **herramienta de defensa y ataque**: puede invocarse para proteger a un cliente cuando alguien ejerce un derecho de manera dañina, inequitativa o contraria a la buena fe;
- un **límite a las pretensiones desmedidas**, aplicado por los jueces en distintos ámbitos;
- un **principio transversal**, que rige también las relaciones de vecindad, de consumo, comerciales y familiares.

Ejemplo: hilo conductor del capítulo

Un vecino construyó una parrilla en el espacio común del edificio. Otro copropietario tiene derecho a reclamarle que la retire. Pero si este último hizo algo similar y no le reclama al resto, cabe preguntarse si el derecho que ejerce sigue siendo justo. La pregunta que recorre el tema es: **¿cuándo el ejercicio de un derecho se vuelve abusivo?**

Los temas se encadenan lógicamente: primero se analiza el problema conceptual, luego los criterios teóricos y, finalmente, cómo el derecho argentino fue respondiendo a este desafío.

19.2. El dilema del abuso del derecho

La expresión **abuso del derecho** plantea, desde el comienzo, una aparente contradicción lógica: ¿cómo es posible que algo que de por sí es justo — es decir, que es derecho, algo exigible, una potestad conforme a una cierta regla — se torne abusivo? Este es el gran dilema de una noción que se presenta como contradictoria.

19.2.1. La noción de derecho subjetivo como punto de partida

La posición que se adopte frente al concepto de **derecho subjetivo** determina si se admite o no la posibilidad del abuso del derecho: según la noción de derecho subjetivo que se tenga, se tendrá una visión del abuso del derecho, admitiéndolo o no admitiéndolo.

19.3. Caso práctico: propiedad horizontal

Para ilustrar el concepto se presenta un caso concreto resuelto por los tribunales argentinos.

Ejemplo: reclamo selectivo en propiedad horizontal

Un copropietario tiene la potestad de exigir que otro condómino que construyó algo en violación del reglamento de copropiedad lo derribe. Sin embargo, si todos los copropietarios también construyeron en infracción al reglamento, y quien reclama (a) solo le exige a uno y no al resto, y además (b) él mismo tampoco cumplió con el reglamento, los tribunales consideraron que ese ejercicio del derecho era abusivo. La pretensión fue declarada inadmisible.

El interrogante que plantea el caso es hasta qué punto se tiene derecho a exigir a otro que cumpla con el reglamento de copropiedad cuando quien reclama tampoco lo ha cumplido. Si bien existe un derecho a reclamar en una propiedad horizontal — por ejemplo, contra el condómino que construyó en exceso, incluso invadiendo zonas comunes —, en este caso se consideró que quien pedía también había realizado actos que violentaban el reglamento, por lo que su reclamo constituía un abuso del derecho.

19.4. Críticas a la noción de abuso del derecho

La noción de abuso del derecho ha recibido críticas doctrinarias, en particular desde la visión que concibe al derecho subjetivo como una potestad absoluta de la voluntad.

Planiol sostuvo que, si el derecho es una potestad confiada a la voluntad, la expresión «abuso del derecho» choca contra sí misma: no podría haber abuso, porque la persona siempre estaría ejerciendo algo que de por sí es legítimo. Además, si es la voluntad la que determina el contenido de la noción de derecho, es la propia voluntad la que fija dicho contenido.

Esta posición individualista extrema tuvo su recepción en la redacción original del Código Civil argentino, aunque luego fue modificada con la reforma de 1968 y con el Código Civil y Comercial de 2015.

19.5. Terminología técnica correcta

Importante

La terminología exacta es **«ejercicio abusivo de un derecho»**, y no «abuso del derecho». La pregunta correcta es *cuándo el ejercicio de un derecho se torna abusivo*: el derecho en sí mismo es legítimo; lo abusivo es la manera en que se lo ejerce.

19.6. Cuadro Cornell: el problema conceptual del abuso

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué es el abuso del derecho?	Es el ejercicio de un derecho subjetivo legítimo de una manera que se torna abusiva. La terminología exacta es «ejercicio abusivo de un derecho», porque el derecho en sí mismo es legítimo; lo abusivo es la forma en que se lo ejerce.
¿Por qué es una noción contradictoria?	Porque si un derecho es algo justo y exigible, resulta paradójico que pueda tornarse abusivo. Este es el gran dilema de la noción.
¿De qué depende que se admita o no el abuso del derecho?	De la noción de derecho subjetivo que se adopte: según ella se tendrá una visión del abuso del derecho, admitiéndolo o no admitiéndolo.
¿Cómo resolvieron los tribunales el caso del reclamo selectivo en propiedad horizontal?	Consideraron abusivo el reclamo de quien exigía a un solo condómino la demolición de lo construido en infracción al reglamento, cuando todos los copropietarios habían construido en infracción y quien reclamaba tampoco lo había cumplido. La pretensión fue declarada inadmisible.
¿Cuál fue la crítica de Planiol?	Que si el derecho es una potestad confiada a la voluntad, la expresión «abuso del derecho» choca contra sí misma, porque la persona siempre estaría ejerciendo algo legítimo.

Resumen: el abuso del derecho plantea la paradoja de que un derecho legítimo pueda ejercerse de modo abusivo. La posibilidad de admitirlo depende de la noción de derecho subjetivo que se adopte, y fue criticado desde la visión de la voluntad como potestad absoluta. Por eso la expresión técnicamente exacta es «ejercicio abusivo de un derecho». Un caso de propiedad horizontal muestra cómo los tribunales rechazaron un reclamo selectivo por considerarlo abusivo.

Capítulo 20

Criterios teóricos para determinar el abuso

La doctrina elaboró criterios para identificar cuándo hay ejercicio abusivo de un derecho. Se distingue entre criterios **subjetivos** y criterios **objetivos**, y existe además una postura que los combina.

20.1. Criterios subjetivos

Los criterios subjetivos miran a las condiciones del agente que ejerce el derecho. Son tres:

N.°	Criterio	Descripción
1.°	**Intención de dañar**	El ejercicio es abusivo cuando la finalidad del agente es causar un daño. La intención dañosa es el elemento determinante.
2.°	**Negligencia en el ejercicio**	El ejercicio es abusivo cuando el derecho se ejerce de forma negligente, sin tomar las diligencias que le son propias.
3.°	**Sin interés alguno**	El ejercicio es abusivo cuando se realiza sin ningún interés detrás; es decir, sin un interés legítimo que lo justifique.

Cuadro 20.1: Criterios subjetivos de determinación del abuso.

20.2. Criterios objetivos

Los criterios objetivos atienden a circunstancias, elementos o factores objetivos, más allá de las disposiciones subjetivas del agente que ejerce el derecho.

N.°	Criterio	Descripción
1.°	**Fin económico y social**	Será abusivo el ejercicio que va en contra del fin económico y social que tiene ese derecho.
2.°	**Fin de su institución**	Es abusivo el ejercicio contrario a los fines para los cuales fue instituido el derecho. Este criterio fue receptado por la Ley 17.711.
3.°	**Buena fe y buenas costumbres**	Criterio de Borda: es abusivo el ejercicio que excede los límites de la moral, la buena fe y las buenas costumbres. Ejemplo: intereses usurarios.

Cuadro 20.2: Criterios objetivos de determinación del abuso.

Ejemplo: intereses usurarios

El caso típico y habitual se da cuando se reclaman intereses que llegan a ser usurarios. La **usura** es una tasa de interés desmedida: se acepta una tasa de interés razonable, pero si esta se convierte en desmedida, se están excediendo los límites de la moral. Se trata de un exceso respecto de la moral; no de una contrariedad con la buena fe y las buenas costumbres, pues de ser así no sería derecho.

20.3. Criterio mixto

Existe también una postura que combina ambos tipos de criterios: será el juez, en cada caso, quien mediante una ponderación de los elementos objetivos y subjetivos evalúe si el ejercicio del derecho ha sido abusivo.

20.4. Cuadro Cornell: criterios para determinar el abuso

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué miran los criterios subjetivos y cuáles son?	Miran las condiciones del agente que ejerce el derecho. Son: 1.° intención de dañar (finalidad de causar un perjuicio); 2.° negligencia en el ejercicio (no se toman las diligencias debidas); 3.° ausencia de todo interés legítimo que justifique el ejercicio.
¿Qué miran los criterios objetivos y cuáles son?	Miran circunstancias o factores objetivos, más allá de las disposiciones subjetivas del agente. Son: 1.° contrariedad con el fin económico y social del derecho; 2.° contrariedad con los fines de su institución (receptado por la Ley 17.711); 3.° exceso sobre los límites de la moral, la buena fe y las buenas costumbres (criterio de Borda; ejemplo: intereses usurarios).

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué es la usura?	Una tasa de interés desmedida. Se acepta una tasa razonable, pero cuando esta se vuelve desmedida se exceden los límites de la moral.
¿Cuál es el criterio mixto?	El juez pondera en cada caso concreto tanto los elementos subjetivos como los objetivos para determinar si el ejercicio fue abusivo.

Resumen: los criterios subjetivos atienden a la situación del agente (intención de dañar, negligencia, ausencia de interés); los objetivos, a factores externos a él (fin económico y social, fin de la institución, límites de la moral, la buena fe y las buenas costumbres). El criterio mixto encomienda al juez la ponderación de ambos en cada caso. Los criterios objetivos son los que terminaron siendo receptados por el derecho positivo argentino.

Capítulo 21

El abuso del derecho en el derecho argentino

Este capítulo analiza la evolución histórica del instituto en el ordenamiento jurídico argentino.

21.1. El Código Civil de Vélez Sarsfield (1871)

El Código Civil de 1871 está imbuido de una filosofía liberal e individualista propia de la época. Vélez Sarsfield entiende el derecho subjetivo como una potestad que el orden jurídico confiere para alcanzar la voluntad y, por lo tanto, **rechaza la noción de abuso del derecho**.

Regla: art. 1071, redacción original del Código Civil (1871)

«El ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituirse como ilícito.»

Redacción originaria según Decreto-Ley 340/1869, en vigencia desde 1871. Esta norma rechazaba expresamente la posibilidad del abuso del derecho: ejercer un derecho nunca podía configurar un acto ilícito.

Según esta norma no podía haber abuso del derecho, porque ejercer un derecho no es un ilícito. Vélez Sarsfield se aparta así de toda teoría del abuso del derecho y no recepta esa idea en ningún artículo.

21.2. La jurisprudencia anterior a la reforma de 1968

Antes de la Ley 17.711, los tribunales comenzaron a reconocer el instituto por vía pretoriana. A través de distintos fallos — entre ellos casos de intereses excesivos — la jurisprudencia entendió que podía haber abuso de derechos. El instituto se mezclaba con otros, pero estaba presente la idea de limitar la visión del derecho subjetivo como algo absoluto.

21.3. La Constitución de 1949

La Constitución de 1949, que luego fue derogada en 1956, constituyó un hito importante en la evolución constitucional del concepto.

Regla: art. 35, Constitución Nacional de 1949 (derogada en 1956)

«Los derechos y garantías reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio; tampoco para amparar a ningún habitante de la nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otros. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o lleguen a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre configuran delitos que serán castigados por las leyes.»

Se trata de una norma del campo constitucional, no específicamente del derecho civil, pero con una resonancia indudable en este. Corresponde a un momento de impronta social y de fuerte intervención estatal, que coloca límites a las potestades individuales, sobre todo a la propiedad: esta queda sometida también a una finalidad de bien común y a ciertos límites, de modo que no puede hacerse un uso absoluto del derecho.

21.4. El fallo Reina (Corte Suprema, 1956)

Días antes de la derogación de la Constitución de 1949, la Corte Suprema dictó el fallo **Reina**, en un caso de abuso del derecho. La Corte sostuvo que, aunque no estuviera en ninguna norma — previendo que la Constitución de 1949 sería derogada —, la teoría que ve el ejercicio abusivo del derecho es **inherente a la noción del derecho**, porque todo derecho es relativo y tiene una finalidad que debe cumplir.

Los derechos encuentran, entonces, un límite, y la teoría del abuso del derecho — aunque no esté registrada en una norma — corresponde a la concepción misma del derecho. El fallo buscaba dejar a salvo la institución más allá de la inminente derogación del artículo 35 de la Constitución de 1949.

21.5. La Ley 17.711 (1968): reforma del artículo 1071

En 1968, la Ley 17.711 produjo una reforma integral del Código Civil de Vélez Sarsfield, que tocó lugares centrales; el artículo 1071 es uno de ellos.

Esta reforma es parangonada con la modificación, en aquel momento, del artículo referido al 954, que incorporó la imprevisión y la lesión, así como el factor moral y el factor social, como limitación de una visión excesivamente individualista.

Regla: art. 1071, redacción según Ley 17.711 (1968)

«El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituirse como ilícito. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.»

21.5.1. Tres cambios fundamentales

N.°	Cambio	Explicación
1.°	**Se agrega «regular»**	El ejercicio de un derecho propio pasa a ser «el ejercicio regular» de un derecho propio. Lo regular es conforme a una cierta regla, medida o título. Si el ejercicio es irregular, se acerca al abuso del derecho.
2.°	**Reconocimiento expreso**	Se agrega la frase «La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos». Es una definición expresa de que no se admitirá el abuso del derecho.
3.°	**Dos criterios objetivos**	(a) Contrario a los fines que tuvo en mira la ley al reconocer ese derecho (criterio de Josserand). (b) Exceso de los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (criterio de Borda). Se usa «exceder» y no «contrario» porque, si fuera contrario, habría un problema de compatibilidad con el objeto del acto.

Cuadro 21.1: Cambios introducidos por la Ley 17.711 al artículo 1071.

Definición: ejercicio regular

Es el ejercicio conforme a una cierta regla, medida o título. Si el ejercicio es irregular, se acerca al abuso del derecho.

La palabra «regular» es muy importante: en el nuevo código se la encuentra en muchos otros artículos, como una manera de calificar el ejercicio de los derechos.

21.6. El Código Civil y Comercial de la Nación (2015)

El Código Civil y Comercial del año 2014, con vigencia desde 2015, ratifica la vigencia de la institución del abuso del derecho en el derecho argentino y la amplía.

Regla: art. 10, Código Civil y Comercial de la Nación (2015)

«El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituirse como ilícito. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraríe los fines del ordenamiento jurídico o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior o fijar una indemnización.»

21.6.1. Tres cambios respecto de la Ley 17.711

N.°	Cambio	Explicación
1.°	**Ubicación metodológica: Título Preliminar**	Ya no está en la parte de daños, sino en el Título Preliminar (art. 10). Esto le da fuerza expansiva a todo el derecho civil y comercial.
2.°	**«Fines del ordenamiento jurídico»**	El art. 1071 hablaba de «los fines que tuvo en mira la ley al reconocer ese derecho»; el art. 10 habla de «los fines del ordenamiento jurídico». Es más amplio.
3.°	**Atribuciones expresas para el juez**	Se explicitan los poderes del juez: debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo; procurar la reposición al estado anterior; y fijar una indemnización por los daños si ya ocurrieron.

Cuadro 21.2: Cambios introducidos por el art. 10 del Código Civil y Comercial.

21.7. Otros artículos relacionados del Código Civil y Comercial

El ejercicio regular y el abuso del derecho aparecen en múltiples artículos del Código, formando un sistema coherente.

Artículo	Contenido / relación con el abuso del derecho
Art. 9	Principio de buena fe. Base axiológica del artículo 10 sobre abuso del derecho.
Art. 10	Abuso del derecho. Norma principal del instituto, ubicada en el Título Preliminar.
Art. 11	Abuso de posición dominante. Se aplican los principios de los arts. 9 y 10 a quien abusa de su posición dominante en el mercado.
Art. 14	Derechos individuales y colectivos. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva.
Art. 53	Uso de la expresión «ejercicio regular» en materia de derechos de la personalidad.
Art. 235	Ejercicio regular de extraer aguas y otras disposiciones relativas al dominio público.
Art. 240	Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre bienes en función de los derechos de incidencia colectiva.
Art. 1.718	Responsabilidad civil. El daño causado por el ejercicio regular de un derecho propio está justificado y no es antijurídico (inciso a).

Cuadro 21.3: Artículos del Código Civil y Comercial relacionados con el ejercicio regular y el abuso del derecho.

La expresión «ejercicio regular» encontró mucho arraigo en el derecho civil y tiene su origen en la reforma de 1968.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

21.8. Cuadro Cornell: el abuso del derecho en el derecho argentino

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo trató el tema el Código de Vélez?	El art. 1071 original decía que el ejercicio de un derecho propio no puede constituirse como ilícito. No recepcionó el abuso del derecho: para Vélez Sarsfield, ejercer un derecho era siempre legítimo, por su concepción liberal e individualista del derecho subjetivo.
¿Qué hizo la jurisprudencia antes de 1968?	Reconoció el instituto por vía pretoriana en distintos fallos, como casos de intereses excesivos, limitando la visión del derecho subjetivo como algo absoluto.
¿Qué aportó la Constitución de 1949?	Su art. 35 establecía que los abusos de los derechos que perjudiquen a la comunidad o lleguen a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre configuran delitos. Aunque fue derogada en 1956, marcó un punto de inflexión constitucional, con límites a las potestades individuales, sobre todo a la propiedad.
¿Qué dijo la Corte en el fallo Reina (1956)?	Que la teoría del ejercicio abusivo del derecho es inherente a la noción del derecho mismo, porque todo derecho es relativo y tiene una finalidad. El instituto existe aunque no esté registrado en una norma.
¿Cuáles son los 3 cambios de la Ley 17.711 (1968)?	1.° Se agrega la palabra «regular» al art. 1071. 2.° Se expresa que «la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos». 3.° Se incorporan dos criterios objetivos: contrariedad con los fines que tuvo en mira la ley (Josserand), o exceso de los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres (Borda).
¿Por qué se usa «exceder los límites» y no «contrario a»?	Porque si el derecho fuera directamente contrario, habría un problema de compatibilidad con el objeto del acto (art. 279 / ex art. 953 CC). «Exceder los límites» implica que el derecho en sí es válido, pero su ejercicio sobrepasa las fronteras de lo aceptable.
¿Cuáles son los 3 cambios del Código Civil y Comercial (2015)?	1.° Se ubica en el Título Preliminar (art. 10), con alcance expansivo. 2.° Se amplía el criterio: de «fines que tuvo la ley» a «fines del ordenamiento jurídico». 3.° Se explicitan las atribuciones del juez: evitar los efectos del ejercicio abusivo, reponer al estado anterior e indemnizar.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué otros artículos del CCC se relacionan con el ejercicio regular?	Arts. 9 (buena fe), 11 (abuso de posición dominante), 14 (derechos individuales y colectivos), 53, 235, 240 y 1.718 inc. a) (justificación del daño por ejercicio regular).

Resumen: el Código de Vélez Sarsfield (1871) rechazaba el abuso del derecho al concebir el derecho subjetivo como potestad absoluta de la voluntad. La jurisprudencia lo incorporó por vía pretoriana; la Constitución de 1949 lo elevó al plano constitucional (aunque fue derogada en 1956); el fallo Reina lo consideró inherente a la noción del derecho; la Ley 17.711 (1968) lo positivizó en el art. 1071 con la palabra «regular» y dos criterios objetivos; y el Código Civil y Comercial (2015) lo amplió en el art. 10, ubicado en el Título Preliminar, extendiéndolo a los fines del ordenamiento jurídico y dotando al juez de atribuciones expresas para prevenir, reponer e indemnizar.

Parte VI

La persona humana: reconocimiento, existencia y dignidad

Con el marco general fijado comienza el estudio del sujeto de la relación jurídica. Esta parte trata a la persona humana: su fundamento y su reconocimiento jurídico, el comienzo de su existencia y los derechos personalísimos que protegen su dignidad.

Capítulo 22

La persona humana: fundamento y reconocimiento jurídico

La persona humana constituye el centro del derecho civil y comprender su concepto es el punto de partida de toda práctica profesional: cada vez que un abogado redacta un contrato, representa a un cliente, interpreta una norma o litiga, opera sobre la categoría de persona. El concepto de dignidad humana y el reconocimiento de la personalidad no son abstracciones: son las razones por las que el derecho protege la vida, el nombre, el honor, la libertad y el patrimonio. Este capítulo avanza de lo más abstracto a lo más concreto: qué es una persona según la filosofía y la etimología, por qué el derecho la reconoce a partir de los tratados de derechos humanos y de la dignidad, y cómo la regula el CCyC.

22.1. Fundamentos filosóficos y etimológicos

22.1.1. El origen etimológico de *persona*

La palabra *persona* designaba en la antigüedad la máscara del teatro que representaba al personaje. La máscara, en latín, cumplía una función técnica: permitía que la voz del actor sonara más alto (*per-sonare*). El término designaba tanto el objeto —la máscara— como el rol o estatus que el personaje representaba. Con el tiempo dejó de designar la máscara y pasó a identificarse con el mismo ser humano que la usaba; ese sentido de rol y estatus se trasladó luego a la filosofía.

22.1.2. La definición filosófica de Boecio

Definición: Persona, según Boecio

«Persona es la sustancia individual de naturaleza racional.»

- **Sustancia**: no es un accidente; es un ser que existe por sí mismo.
- **Individual**: es indivisible, único y uno; cada persona es irrepetible y no tiene copia.
- **De naturaleza racional**: tiene una esencia que implica la capacidad de raciocinio, lo que no significa que ejerza efectivamente esa capacidad en todo momento, sino que esa es su naturaleza.

22.1.3. El ser humano como ser en relación

Los seres humanos no están solos: vienen a la existencia en una comunidad —la familia, el barrio, la ciudad, el país, el mundo— y por eso tienen vínculos de **alteridad**. De esa dimensión relacional se derivan tres consecuencias jurídicas fundamentales:

Consecuencia	Explicación
La justicia	Siempre que hay relaciones de alteridad, hay relaciones de justicia: dar a cada uno lo suyo.
Los contratos	El ser humano tiene dominio de sí y es capaz de hacer compromisos o pactos vinculantes, lo que funda el orden contractual.
La norma jurídica	Se le pueden imponer normas porque tiene racionalidad y reconoce que hay autoridades que deben velar por el bien común. La ley es una ordenación de la razón en orden al bien común, dictada por quien tiene el cuidado de la comunidad.

Cuadro 22.1: Consecuencias jurídicas de la dimensión relacional de la persona

La palabra *persona* —a diferencia de *ciudadano*, *individuo* o *habitante*— expresa un **valor y una dignidad** y, a la vez, una dimensión jurídica: son seres que se proyectan hacia los demás, individuales y relacionales.

22.1.4. Todo ser humano es persona

Importante

En el derecho no es posible —ni legítimo— distinguir entre ser humano y persona humana. **Todo ser humano es persona.** La personalidad no es una creación artificial del legislador, sino un dato de la naturaleza que la ley positiva reconoce.

Se cita a Borda: la persona no nace porque el derecho objetivo le atribuya la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, sino que le reconoce esa capacidad. Nadie recibe la personalidad como una concesión al nacer; se es persona por el solo hecho de existir. La elección del verbo **reconocer** —en contraposición a *adjudicar* o *conceder*— admite que la personalidad es anterior al ordenamiento jurídico.

Ejemplo: El absurdo de los criterios arbitrarios

Si el derecho dijera que son personas los seres humanos que usan anteojos y que los que no los usan no lo son, ¿cómo se justificaría ese criterio? Sería completamente arbitrario: todo ser humano es persona.

22.2. La persona en los tratados internacionales de derechos humanos

22.2.1. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

La Declaración Universal nació como reacción global ante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial: ante la constatación de que un gobierno había impuesto la degradación de ciertos seres humanos a los que no consideraba personas y los exterminaba, la comunidad internacional afirmó que ningún Estado puede adjudicar la personalidad.

Importante

Artículo 6: «Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.» Artículo 1: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos.»

A diferencia de una licencia de conducir —que el Estado adjudica cuando se reúnen requisitos—, la personalidad jurídica no requiere cumplir ningún requisito: se reconoce por el solo hecho de ser humano.

22.2.2. El Pacto de San José de Costa Rica

Regla: Convención Americana de Derechos Humanos, art. 1.2

«Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.»

Lo mismo se encuentra en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto influye en la codificación argentina: el CCyC (art. 1) debe respetar los tratados de derechos humanos y, por lo tanto, no puede decir que son personas solo ciertos seres humanos.

22.2.3. La dignidad humana: concepto y dimensiones

La palabra **dignidad** es central en el sistema de derechos humanos y aparece en el artículo 51 del CCyC. Pueden identificarse tres formas de comprenderla:

Dimensión	Definición	Ejemplo
Funcional / del cargo	Respeto por la función que una persona desempeña en la sociedad.	El presidente de la Nación merece respeto por su cargo, no por ser «más» como ser humano.
Moral / de la conducta	Respeto por las acciones virtuosas o rechazo de las conductas indignas.	Los médicos que se expusieron durante la pandemia actuaron con dignidad; quienes lucraron con la crisis, de manera indigna.
Ontológica (la más importante para el derecho)	Merecimiento de respeto por el solo hecho de ser humano, independientemente de cualquier cualidad o conducta.	La tienen por igual la persona condenada por el delito más grave y la persona más honesta.

Cuadro 22.2: Dimensiones de la dignidad humana

Importante

El concepto de dignidad que se toma es, sobre todo, el de la **dignidad ontológica**: un merecimiento de respeto por el solo hecho de ser humano, una excelencia en el ser. Es el fundamento de todos los derechos humanos.

22.3. La persona humana en el Código Civil y Comercial

El CCyC (Ley 26.994) tiene un Título Preliminar de cuatro capítulos (véase el capítulo 9) y un Libro Primero que comienza con el Título I, dedicado a la persona humana, y el Título II, a la persona jurídica; luego siguen los bienes, los hechos y actos jurídicos y la transmisión de los derechos.

Aspecto	Código de Vélez (Ley 340)	CCyC (Ley 26.994)
Terminología	Persona física / de existencia visible	Persona humana
Definición de persona	Art. 30: «entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones»	No incluye definición (se reconoce, no se define)
Orden en el libro	Primero personas jurídicas, luego físicas	Primero persona humana (Título I), luego persona jurídica (Título II)
Definición de persona física	Art. 51: «entes con signos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes»	Eliminada; se da por supuesta
Marco de referencia	Derecho positivo nacional	Tratados de derechos humanos integrados al bloque constitucional

Cuadro 22.3: Terminología y método: Vélez y CCyC en materia de persona

Esto es toda una definición: el nuevo código coloca en el centro del derecho civil y comercial a la persona humana.

22.3.1. Los textos derogados de Vélez

Nota: Art. 51 del Código de Vélez (derogado)

«Personas físicas o de existencia visible son todos los entes que presenten signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes.»

Vélez quería decir que todo ser humano es persona. Incluyó «sin distinción de cualidades o accidentes» porque en el derecho romano se discutía si era persona quien nacía con una malformación muy severa —a quienes se llamaba «monstruosos» o «prodigiosos»— o si la viabilidad era un requisito; para Vélez, ninguna cualidad o accidente quita la condición de persona.

Nota: Art. 30 del Código de Vélez (derogado)

«Personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones.»

La definición englobaba a la persona humana y a las personas jurídicas, sujetos colectivos surgidos de la asociatividad. El nuevo código la eliminó por considerar que el concepto de persona es anterior al derecho positivo: el derecho no tiene por qué definir quiénes son personas, pues lo son todos los seres humanos. Los fundamentos siguen aquí al Proyecto de 1998, elaborado por una comisión encabezada, entre otros, por Alterini, Alegría, Highton de Nolasco y Méndez Costa.

22.3.2. El artículo 51 vigente

Regla: Art. 51 CCyC

La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.

22.4. Cuestiones frecuentes sobre el concepto de persona

Persona física y persona no física. En el Código de Vélez se llamaba persona física o de existencia visible a la persona humana, por oposición a las personas jurídicas o de existencia ideal, que son los entes colectivos: una asociación civil, una sociedad, el Estado, una iglesia, una fundación.

¿Puede un robot ser persona? El Código de Vélez asociaba la personalidad con la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, y no existían robots en su época. El profesor Carlos Muñiz sostiene que el término persona se vincula centralmente con el ser humano, concepto históricamente asociado a él. Los animales merecen respeto, pero no pueden entablar relaciones jurídicas como los humanos; un proyecto de reforma del CCyC habla de nominarlos «seres sintientes» para darles un estatuto especial y regular su protección. El término persona, por involucrar una dignidad vinculada al dominio de sí, no sería fácilmente trasladable a un robot: hoy lo controla alguien, un programador humano que se hace cargo. Si un robot celebrara contratos por sí mismo habría que analizar la analogía con las personas jurídicas, pero siempre habría una persona humana o jurídica detrás.

Persona jurídica y persona moral. A la persona jurídica se la llama también persona moral o colectiva. El CCyC simplifica el esquema de Vélez en personas humanas y personas jurídicas. Una persona jurídica es una organización con personalidad jurídica, para lo cual hay que tramitar una autorización o que la ley se la conceda; no cualquier asociación lo es, debe asumir uno de los tipos reconocidos (arts. 141 y siguientes, especialmente las formas privadas de los arts. 147 y 148): sociedad anónima o de responsabilidad limitada si tiene forma societaria; fundación o asociación civil si no tiene fines de lucro; o entidad religiosa. La Iglesia Católica tiene personería jurídica pública porque la Constitución le da un estatuto especial (art. 2). El Estado, los Estados extranjeros y organizaciones internacionales como la ONU también son personas jurídicas.

¿Son lo mismo honor y dignidad? No exactamente. La dignidad es más amplia y es el fundamento de todos los derechos humanos; el honor se refiere a la reputación y tiene una dimensión personal (la honra) y otra social (la fama). Del reconocimiento de la dignidad pueden derivarse el derecho a la vida, al honor y a la libertad.

22.5. Cuadro Cornell: la persona humana

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué significa etimológicamente «persona»?	Del latín: la máscara teatral que amplificaba la voz (*per-sonare*); pasó a designar el rol y luego al ser humano mismo.
¿Cuál es la definición de Boecio?	«Sustancia individual de naturaleza racional»: ser que existe por sí mismo, único e irrepetible, de esencia racional aunque no la ejerza en todo momento.
¿Por qué la persona tiene dimensión jurídica?	Es un ser en relación (alteridad): de ello surgen la justicia, los contratos y la sujeción a normas.
¿Todo ser humano es persona? ¿Qué importa el verbo «reconocer»?	Sí, sin excepción. La personalidad es un dato de la naturaleza que el derecho reconoce, no adjudica ni concede; no depende de ningún requisito estatal.
¿Qué establecen los tratados?	DUDH (1948), art. 6: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; art. 1: libres e iguales en dignidad. Pacto de San José, art. 1.2: persona es todo ser humano.
¿Qué es la dignidad ontológica?	El merecimiento de respeto por el solo hecho de ser humano, independiente de cargo, conducta o cualidad; fundamento de los derechos humanos.
¿Qué cambió el CCyC?	Persona humana en lugar de persona física; sin definición de persona; abre con la persona humana (Título I) y consagra la inviolabilidad y dignidad (art. 51).

Resumen: Todo ser humano es persona por el solo hecho de serlo; el derecho reconoce, y no concede, esa personalidad. El CCyC suprime las definiciones de Vélez, coloca a la persona humana al inicio del Libro Primero y consagra en el artículo 51 su inviolabilidad y su dignidad ontológica, fundamento de todos los derechos.

Capítulo 23

El comienzo de la existencia: la persona por nacer

La cuestión del comienzo de la existencia de la persona posee dimensiones biológicas, filosóficas, morales y jurídicas. Este capítulo se concentra exclusivamente en la **dimensión civil**, dejando de lado las repercusiones propias del derecho penal u otras ramas, y recorre su evolución desde el derecho romano hasta el debate actual sobre el artículo 19 del CCyC y los embriones no implantados.

23.1. La tradición romana

Definición: *Nasciturus pro iam nato habetur*

Al que está concebido o por nacer se lo tiene como si ya hubiera nacido: se lo equipara jurídicamente al nacido. Es el antecedente más remoto de la protección jurídica del concebido.

Ejemplo: Herencia del hijo concebido antes de la muerte del padre

Si un padre fallece mientras su hijo está concebido pero no ha nacido, el derecho romano concluyó que el hijo hereda igualmente, aunque nazca después de la muerte del causante. Se consideró injusto excluirlo, dado que ya era hijo por haber sido concebido antes de la muerte y puede haber hasta nueve meses entre concepción y nacimiento.

Ejemplo: Libertad del hijo de una mujer que cae en esclavitud

Cuando una mujer concebía siendo libre y luego caía en esclavitud, el momento de la concepción —y no el del nacimiento— determinaba el estatus del hijo, que nacía libre.

23.2. El Código de Vélez (1871)

El principio llega al Código argentino a través de los artículos 70 y 63.

Nota: Art. 70 del Código de Vélez (texto histórico)

Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de la persona física.

Vélez recoge la tradición romanista y la lleva a su máxima expresión: mientras otros códigos —como el chileno— disponen que la persona existe desde que nace, aunque el concebido se equipare al nacido a efectos de su protección, Vélez declaró directamente que la persona existe desde la concepción. La categoría de «persona por nacer» proviene de Teixeira de Freitas.

Nota: Art. 63 del Código de Vélez (texto histórico)

Son personas por nacer las que, no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno.

23.3. La reforma constitucional de 1994 y los tratados

En 1994 se incorporaron tratados de derechos humanos que refuerzan la protección del concebido:

- **Art. 75 inc. 23 CN**: el Congreso tiene potestad para dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección de la madre y el niño, *desde el embarazo*, lo que revela que existe una etapa prenatal protegida.
- **Ley 23.849** (ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño): declaración interpretativa con valor de reserva, según la cual niño es todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años; integra las condiciones de vigencia de la Convención y por tanto es texto constitucional para interpretar el comienzo de la existencia.
- **Pacto de San José, art. 4**: todo ser humano tiene derecho a la vida, en general, a partir del momento de la concepción; de la interpretación conjunta resulta que persona es todo ser humano.
- **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**: prohíbe aplicar la pena de muerte a mujeres embarazadas, lo que implica un reconocimiento implícito de la personalidad del no nacido.

23.4. El Código Civil y Comercial

23.4.1. El debate de elaboración y el texto del artículo 19

Importa distinguir el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo del texto sancionado. El proyecto establecía que la existencia comenzaba con la concepción en el seno materno y que, en las técnicas de reproducción humana asistida, comenzaba con la implantación del embrión en la mujer: preveía **dos momentos distintos**, de modo que el mismo embrión sería persona dentro del cuerpo de la mujer pero no fuera de él. Esa solución generó un intenso debate en la Comisión Bicameral y el criterio de la implantación fue eliminado en el debate parlamentario.

Regla: Art. 19 CCyC (Ley 26.994)

La existencia de la persona humana comienza con la concepción.

Se eliminó la expresión «en el seno materno» del código anterior. La postura que ubica el comienzo en el nacimiento resultó minoritaria en el derecho argentino y no hubo proyecto de ley en tal sentido.

Importante

El problema abierto por el artículo 19 no es si el concebido es persona por nacer —esa tradición se mantiene sin discusión—, sino qué ocurre con los **embriones no implantados**, generados *in vitro*, fuera del seno materno, mientras no son transferidos.

23.4.2. Concepción: ¿fecundación o implantación?

Primera postura: concepción equivale a fecundación. Identifica la concepción con la unión del óvulo y el espermatozoide, que forma un nuevo organismo individual (el cigoto). La sostienen la Cámara Federal de Salta, la Suprema Corte de Mendoza, las Jornadas de Derecho Civil de 2003, el artículo 17 del CCyC y profesores como Sambrizzi y Ambrosi.

Regla: Art. 17 CCyC: cuerpo humano (según la explicación de las fuentes)

Existe una protección del cuerpo humano desde el momento en que este se inicia, que es la fecundación. El cuerpo es el soporte de la persona y se forma cuando se fusionan el óvulo y el espermatozoide: surge un nuevo cuerpo, distinto del de los padres y del de los gametos, aunque la fusión sea *in vitro*.

Segunda postura: concepción equivale a implantación. Se funda en el fallo *Artavia Murillo*, defendida también por Marisa Herrera y Andrés Gil Domínguez.

Ejemplo: Caso Artavia Murillo y otros c. Costa Rica (CIDH, noviembre de 2012)

Matrimonios con infertilidad, sin gametos de terceros, solicitaron acceder a la fecundación *in vitro*, que Costa Rica no permitía por considerar que ponía en riesgo a embriones y que en el sistema interamericano «concepción» equivalía a fecundación. La Corte Interamericana entendió que Costa Rica se había extralimitado, sostuvo que para esas circunstancias el concepto debía equipararse a «implantación» y condenó al país.

Consideraciones críticas. El contexto de *Artavia Murillo* es distinto del argentino: en Costa Rica la fecundación *in vitro* estaba totalmente prohibida y en la Argentina no. Las sentencias de la Corte Interamericana obligan solo a las partes del litigio; para los demás países son una pauta de interpretación de la que se puede apartar con argumentación fundada, en el marco del control de convencionalidad. El fallo es una sentencia, no una ley; la norma sigue empleando «concepción» y lo discutido es su interpretación. Interpretar «concepción» como «implantación» resulta, según esta crítica, contrario al principio *pro homine*, pues la palabra remite semánticamente al inicio de algo; y el artículo 1 del CCyC excluyó deliberadamente a la jurisprudencia como fuente.

Importante

La Corte Suprema argentina ha señalado que los pronunciamientos de la Corte Interamericana son una pauta de interpretación, de la que cabe apartarse cuando el ordenamiento, las circunstancias o el contexto son distintos. Usar *Artavia Murillo* —referido a la creación de embriones mediante fecundación asistida— para autorizar la destrucción de embriones ya existentes sería trasladar sus conclusiones a una circunstancia distinta de la litigada. En los precedentes de la Cámara Federal de Salta se discutieron cuestiones de cobertura y de diagnóstico genético preimplantatorio que *Artavia Murillo* no abordó.

23.4.3. Otras cuestiones sobre embriones

El proyecto original contemplaba la inseminación artificial *post mortem*, pero la previsión fue eliminada del texto sancionado, entre otras razones por los problemas éticos que plantea. Si el embrión ya existe, existe también una persona —según esta postura— y la cuestión pasa a ser garantizar su derecho a la vida. El destino de los embriones sobrantes de la fecundación *in vitro* es un problema abierto que las fuentes no desarrollan en profundidad: se señala que lo habitual es procurar no generar embriones congelados, que una vez generados no hay solución éticamente indiscutida, y se afirma, sin mayor desarrollo, que su destrucción no es una solución adecuada.

23.5. La época de la concepción (art. 20 CCyC)

El artículo 20 retoma los artículos 76 y 77 del código anterior.

Regla: Art. 20 CCyC

Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta, excluyendo el día del nacimiento. Este plazo se cuenta retroactivamente desde el día de ese nacimiento.

Proviene de una larga tradición legislativa; el máximo y el mínimo se fijan para resolver situaciones vinculadas principalmente a la determinación de la paternidad y a conflictos sucesorios.

Ejemplo: El soldado en guerra

Un soldado casado parte a la guerra el 1.º de enero de 2020 y regresa el 30 de junio de 2021. Su esposa le presenta un hijo nacido en mayo de 2021. Contando nueve meses hacia atrás desde el nacimiento, la concepción habría ocurrido mientras él estaba en la guerra, por lo que no podría reconocerse la paternidad. Antes de las pruebas genéticas, este cálculo era la principal herramienta para determinarla.

Ejemplo: El heredero inventado

Fallece una persona el 1.º de octubre de 2020 sin hijos y sus padres inician la sucesión. Se presenta una mujer que dice tener un hijo concebido por el fallecido, nacido el 31 de diciembre de 2020. Contando retroactivamente 300 días desde esa fecha se llega a una época en la que el causante ya había fallecido, por lo que no puede presumirse a ese hijo como heredero, sin perjuicio de que la presunción admite prueba biológica en contrario.

El nuevo código eliminó los artículos 65, 66, 67, 68 y 78 del Código de Vélez, referidos a la postergación de compromisos y a los controles admitidos durante el embarazo.

23.6. El nacimiento con vida (art. 21 CCyC)

El artículo 21 subsume los antiguos artículos 71 a 75.

Regla: Art. 21 CCyC

Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume.

Esta condición ya existía en el código anterior y no implica que el concebido sea «menos persona»: su finalidad histórica es evitar fraudes.

Ejemplo: Heredero simulado por embarazo ficticio

Fallece un hombre sin descendencia y una mujer dice estar embarazada de él. No pueden practicarse estudios genéticos a la mujer embarazada sin su consentimiento, por ser una persona con derechos propios; el embarazo puede acreditarse con su simple declaración. Si el hijo por nacer falleciera durante el embarazo, ella lo heredaría y excluiría a los padres del causante. La condición del nacimiento con vida —si nace sin vida se considera que nunca existió— evita este tipo de conflictos sucesorios simulados.

23.6.1. Qué significa nacer con vida

Nacer con vida implica quedar completamente separado de la madre. El código anterior admitía la prueba por amplitud de medios; el vigente presume que se nace con vida, y quien sostenga lo contrario debe probarlo: por ejemplo, si los pulmones llegaron a expandirse, si alguien escuchó llorar al recién nacido o si se cortó el cordón umbilical. Si el niño muere dentro del útero, la figura penal aplicable es la de aborto; si muere fuera, la de homicidio. A los fines civiles, la cuestión es relevante centralmente en materia sucesoria.

Ejemplo: Caso Píparo

En una salidera bancaria se dispara contra una mujer embarazada; el hijo por nacer nace y fallece poco después. Al haber nacido con vida —aunque brevemente—, el hecho

fue calificado como homicidio y no solo como lesión a la madre. Ilustra, en el plano penal, las consecuencias del artículo 21, aunque excede el ámbito civil.

23.7. El régimen jurídico de la persona por nacer

Norma	Contenido
Art. 24 CCyC	Las personas por nacer son incapaces de ejercicio, pero capaces de derecho: no pueden actuar por sí mismas, pero sí ser titulares de derechos y adquirirlos, razón por la cual necesitan representación.
Art. 101 CCyC	Sus representantes son sus padres, de la misma manera en que representan a la persona ya nacida menor de edad.
Art. 2279 CCyC	Pueden ser herederas las personas concebidas que nazcan con vida; también las concebidas mediante técnicas de fecundación *in vitro*, si se cumple el requisito del consentimiento del art. 561. Los bienes heredados no se inscriben a su nombre hasta que nazca con vida, para evitar conflictos sucesorios.
Art. 57 CCyC	Se prohíben las prácticas destinadas a modificar genéticamente el embrión cuando la alteración se transmita a su descendencia; reconoce plenamente al embrión como persona, lo que es relevante para interpretar «concepción».
Art. 592 CCyC	Puede imponerse preventivamente la filiación del hijo por nacer.
Art. 574 CCyC	Puede reconocerse prenatalmente al hijo por nacer.
Alimentos	El hijo por nacer tiene derecho a alimentos, desde la concepción; la mujer embarazada puede reclamarlos al progenitor. Consisten en una suma de dinero destinada al mantenimiento y la crianza de los hijos.

23.8. Evolución del reconocimiento de la persona por nacer

Sistema / norma	¿Qué establece?	¿Desde cuándo hay persona?
Derecho romano	*Nasciturus pro iam nato habetur*	**Desde la concepción (para efectos específicos)**
Código de Vélez (art. 70)	Existencia desde la concepción en el seno materno	**Desde la concepción en el seno materno**
Código Civil chileno	El concebido se equipara al nacido	**Desde el nacimiento (con protección prenatal)**
Art. 75 inc. 23 CN (1994)	Seguridad social especial desde el embarazo	**Reconoce al niño prenatal**
Ley 23.849 (CDN)	Niño: todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años	**Desde la concepción**
Pacto de San José (art. 4)	Derecho a la vida, en general, desde la concepción	**Desde la concepción (con matiz «en general»)**
Art. 19 CCyC (2015)	La existencia comienza con la concepción	**Desde la concepción (debate: fecundación o implantación)**
***Artavia Murillo* (CIDH, 2012)**	Concepción = implantación, para el sistema interamericano	**Desde la implantación (pauta interpretativa)**

Cuadro 23.2: Evolución normativa del reconocimiento de la persona por nacer

23.9. Cuadro Cornell: el comienzo de la existencia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué significa *nasciturus pro iam nato habetur* y qué aplicaciones tuvo?	Que el concebido se tiene por nacido: hereda aunque nazca tras la muerte del padre y su libertad depende de la concepción, no del nacimiento.
¿Cómo recogió Vélez el principio?	Arts. 70 y 63: la existencia comienza desde la concepción en el seno materno; categoría de «persona por nacer» tomada de Freitas.
¿Qué tratados refuerzan la protección en 1994?	Art. 75 inc. 23 CN, Ley 23.849 (niño desde la concepción), Pacto de San José (art. 4) y Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué dice el art. 19 y qué problema deja abierto?	La existencia comienza con la concepción; el problema son los embriones no implantados: ¿concepción es fecundación o implantación?
¿Qué regulan los arts. 20 y 21?	Época de la concepción (entre 180 y 300 días antes del nacimiento) y condición del nacimiento con vida, que se presume; si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.
¿Cuál es el régimen de la persona por nacer?	Incapaz de ejercicio y capaz de derecho (art. 24), representada por sus padres (art. 101), puede heredar (art. 2279), tiene alimentos, reconocimiento prenatal (art. 574) y protección frente a la manipulación genética (art. 57).

Resumen: La existencia de la persona humana comienza con la concepción, tradición que va del derecho romano al art. 19 CCyC. El debate actual gira en torno a si concepción es fecundación o implantación. La persona por nacer es capaz de derecho pero incapaz de ejercicio, y sus derechos quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida.

Capítulo 24

Derechos personalísimos: noción, caracteres y régimen

24.1. Introducción

Los derechos personalísimos son derechos subjetivos fundamentales que protegen la dignidad humana en sus manifestaciones físicas y espirituales. Estos derechos reconocen y garantizan a cada persona el respeto a su vida, integridad corporal, libertad, honor, intimidad e identidad.

En el ejercicio profesional de la abogacía, la comprensión de estos derechos resulta necesaria para:

- Defender a clientes cuyos derechos personalísimos han sido vulnerados.
- Asesorar sobre el consentimiento informado en procedimientos médicos.
- Proteger la intimidad y la privacidad de datos en el entorno digital.
- Litigar casos de difamación, invasión de la privacidad e injurias.
- Orientar cuestiones relacionadas con la bioética y los experimentos humanos.
- Comprender la protección constitucional de la dignidad humana.

Estos derechos adquieren especial relevancia en el contexto de la tecnología digital avanzada, donde los datos personales, las imágenes y la información íntima pueden ser capturados, almacenados y difundidos sin consentimiento. El marco legal que se desarrolla a continuación permite proteger tanto los derechos propios como los ajenos frente a estos desafíos contemporáneos.

24.2. Alcance y orden de exposición

Los derechos personalísimos forman un sistema integrado en el que la dignidad humana constituye el principio rector. La exposición comienza con los conceptos generales y los antecedentes, continúa con las características y la clasificación, prosigue con la regulación en el Código Civil y Comercial y se detiene, finalmente, en el derecho a la libertad. Cada bloque se construye sobre el anterior, de forma análoga a las capas que envuelven un núcleo central de protección de la persona humana.

24.3. Noción de derechos personalísimos

Los derechos personalísimos corresponden a la persona humana. Son derechos que pertenecen a todo ser humano por el solo hecho de ser tal.

Definición: Derechos personalísimos (Tobías)

Los derechos personalísimos son derechos subjetivos que reconocen y garantizan a la persona humana el goce en su propia entidad, en su interioridad, en todas sus manifestaciones físicas y espirituales.

Estos derechos no deben confundirse con los atributos de la personalidad, distinción que tampoco realiza el Código Civil y Comercial. Los atributos de la personalidad son cualidades esenciales que permiten que la persona despliegue su personalidad y entable relaciones jurídicas. Los derechos personalísimos, en cambio, son verdaderos derechos subjetivos que protegen dimensiones fundamentales de la persona.

Estos derechos protegen dos dimensiones fundamentales:

1. La **dimensión de la integridad física**: la vida y la integridad corporal.
2. La **dimensión espiritual**: la libertad, el honor, la imagen, la intimidad y la identidad de la persona.

24.4. Importancia y contexto actual

A lo largo de la historia siempre ha existido una protección de los valores esenciales de la persona: la vida, la integridad física, la libertad, la imagen y el honor. Sin embargo, especialmente en la última mitad del siglo XX, se dieron circunstancias que motivaron a los juristas y al legislador a sancionar normas y a adoptar tratados internacionales orientados a proteger estas dimensiones de la persona humana.

Han surgido nuevas formas de amenaza que reclaman una respuesta jurídica. En el entorno de las biotecnologías, hoy es posible intervenir sobre el cuerpo humano de una manera mucho más poderosa: el conocimiento de la genética y de la biología ha dado lugar a enormes beneficios, pero también a nuevas formas de intervención que pueden no ser respetuosas de la integridad física.

Nota

A lo largo de la historia se han realizado experimentos sobre personas humanas sin su consentimiento, aprovechando la condición de vulnerabilidad de determinados grupos, lo que ha dado lugar a fuertes reacciones éticas y jurídicas.

Las nuevas tecnologías inciden también en la transmisión de la vida humana, en los trasplantes de órganos y en las intervenciones biomédicas y biotecnológicas en general. Respecto de la investigación en seres humanos, la genética permite hoy intervenciones de gran alcance, como ocurrió en China en el año 2018, cuando se obtuvieron seres genéticamente modificados. Estas posibilidades tecnológicas son enormemente promisorias para el

bienestar y el avance de las personas, pero presentan también aspectos problemáticos que requieren una reflexión cuidadosa.

24.4.1. Datos personales y privacidad digital

Otro ámbito relevante es el de la recolección, el uso, el tratamiento, la transmisión y el almacenamiento de los datos personales: datos vinculados con la identidad, con las características personales, con el consumo o con la salud. La cantidad de datos que hoy se almacena es enorme, fenómeno conocido como *big data*: la tendencia a generar grandes colecciones de datos de las personas para elaborar perfiles, realizar seguimientos y dirigir ofertas publicitarias.

Los datos personales permiten tomar decisiones más racionales y conocer mejor a las personas, lo cual puede traer beneficios, pero también nuevas posibilidades de discriminación y de ataques a las personas en función de sus datos. Cuando se trata de datos sensibles existen nuevas posibilidades de manipulación; así, en determinadas situaciones políticas, las campañas se han dirigido a públicos específicos para persuadirlos e influir en su voto.

Importante

El desarrollo de la informática ha transformado radicalmente la capacidad de procesamiento de datos personales —antes limitada a fichas escritas a mano— lo que exige nuevas formas de protección de la intimidad, la identidad y el honor de las personas. La posibilidad actual de captar la voz y la imagen de manera mucho más poderosa hace que estos elementos, una vez registrados, se conviertan también en datos personales sujetos a este mismo régimen de protección.

24.5. Antecedentes en Argentina

Entre los autores que en la Argentina han desarrollado el estudio de esta materia se encuentran Salvat, Cifuentes, Rivera, Navarro Floria y Tobías, entre otros. Cabe señalar que este tema desborda el contenido propio de la parte general del derecho civil y podría constituir por sí mismo una materia completa.

24.5.1. El Código de Vélez

El Código de Vélez no contenía un tratamiento metódico y orgánico de los derechos personalísimos. No obstante, los autores reconocen la presencia del tema en algunos de sus artículos:

Disposición	Contenido
Artículos 428 y 2.126	Hablan de derechos inherentes a la persona.
Artículo 1.075	Establece que toda afectación de un derecho que se confunda con la existencia de la persona puede ser materia de un delito.

También en la nota al artículo 2.312, el Código de Vélez hacía referencia a ciertos derechos que tienen origen en la existencia del individuo mismo, como la libertad, el honor, el cuerpo y la patria potestad. Se trata de una mención presente en el código, aunque no sistemática ni ordenada.

24.5.2. Evolución legislativa en Argentina

Norma	Contenido
Ley 11.723 (1933) — Ley de Propiedad Intelectual	Norma que continúa vigente. En sus artículos 31 a 35 regula la fotografía y el derecho a la imagen, incluyendo el consentimiento y los casos en que puede prescindirse de él.
Ley 21.173 — incorporó el artículo 1.071 bis al código anterior	Protegía el derecho a la intimidad. Este artículo sería recogido posteriormente por el nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 1.770.
Ley 24.193 (1992) — Ley de Trasplantes	Reemplazada en 2018 por la Ley 27.447.
Ley 25.326 (2000) — Ley de Protección de Datos Personales	Aún vigente, con proyectos de reforma.
Ley 26.529 (2009) — Ley de Derechos del Paciente	Reformada en 2012 por la Ley 26.742.

Estas normas reflejan las dimensiones de los derechos personalísimos vinculadas con la integridad física, la integridad espiritual y la libertad.

24.5.3. La Constitución Nacional de 1994

La reforma constitucional de 1994 incorpora, en el artículo 75 inciso 22, diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que consagran derechos correspondientes a la personalidad.

Se produce así una convergencia entre el derecho público y el derecho privado. Aunque los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución corresponden al derecho público, tienen resonancias directas en el derecho privado, en tanto corresponden a la persona humana, que se despliega fundamentalmente en el campo civil.

Nota

La protección de estos derechos tiene también faceta penal: la protección del derecho al honor puede dar lugar al delito de calumnias e injurias, además de a la protección civil. Ambas protecciones suelen coexistir. El presente desarrollo se limita a las dimensiones civiles del asunto y a su incorporación al Código Civil y Comercial.

24.6. Caracteres de los derechos personalísimos

Según Tobías, los derechos personalísimos presentan los siguientes caracteres:

- **Son derechos subjetivos privados:** corresponden a la esfera de las personas, dimensión donde operan el derecho privado y el derecho civil.
- **Son derechos innatos y originarios:** no son derechos concedidos por el legislador, sino reconocidos. Un ser humano, por el solo hecho de ser tal, tiene derecho a la vida, al honor, a la imagen y a la identidad.
- **Son vitalicios y necesarios:** acompañan a la persona durante toda su vida; una persona humana siempre debe tenerlos.
- **Son absolutos (o de exclusión):** tienen un sujeto pasivo universal. Frente a cualquier persona existe la obligación de respetarlos, sin que sea necesario haber celebrado un contrato ni haber tenido relación previa alguna.
- **Son inherentes a la persona:** no pueden separarse de la persona; forman parte de su ser mismo.
- **Son intransmisibles:** no es posible transmitir completamente, por ejemplo, el derecho a la integridad física, ni delegar en otro la toma de decisiones sobre estos derechos.
- **Son relativamente indisponibles:** en principio no se pueden disponer, salvo mediante disposiciones relativas, de carácter restrictivo y siempre con posibilidad de revocación.
- **Son irrenunciables:** no es posible renunciar a estos derechos. La manifestación de ceder o renunciar, por ejemplo, al derecho a la imagen, carece de validez.

Importante

Estos caracteres protegen dimensiones fundamentales de la persona y, en última instancia, tienen como bien jurídico común la dignidad humana.

24.7. Clasificación tripartita

Se adopta aquí la clasificación tripartita habitualmente utilizada por el profesor Tobías, sin perjuicio de que otros autores propongan clasificaciones distintas.

Integridad física	Libertad	Integridad espiritual
Vida Integridad corporal Salud	Concepto que comprende aspectos tanto corporales como espirituales	Honor Intimidad Imagen Identidad

En torno a esta clasificación se organiza el desarrollo del capítulo, que aborda las disposiciones generales del Código Civil y Comercial y una primera aproximación al derecho a la libertad.

24.8. Regulación en el Código Civil y Comercial

Metodológicamente, el Código Civil y Comercial incorpora los derechos personalísimos en el Capítulo 3, Título Primero del Libro Primero. El Libro Primero —Parte General— se abre con el Título Primero, dedicado a la persona humana; dentro de este título, luego de regular el comienzo de la existencia de la persona y la capacidad de las personas, aparecen los derechos personalísimos en los artículos 51 a 62.

Importante

La incorporación sistemática de los derechos personalísimos constituye una de las grandes novedades del Código Civil y Comercial, en la medida en que el Código de Vélez no traía un tratamiento sistemático de estos derechos. Esta incorporación otorga una mayor presencia e importancia a la dignidad humana en el tratamiento del Código Civil y Comercial.

24.8.1. Disposiciones generales: artículo 51

El capítulo se abre con el artículo 51, referido a la inviolabilidad de la persona humana:

Regla: Artículo 51 CCyC

«La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.»

El artículo no menciona explícitamente el derecho a la vida, como sí lo hacían proyectos anteriores, pero dicha protección puede reconocerse detrás de la noción de inviolabilidad de la persona: no es posible afectar su persona, ni su cuerpo, ni su integridad física, ni su integridad espiritual. La expresión «reconocimiento» señala que la dignidad no constituye una concesión del ordenamiento jurídico, sino algo preexistente que el ordenamiento se limita a reconocer.

24.8.2. Medios de protección: prevención y reparación

El artículo 52 establece que la enumeración de medios de protección no es taxativa, sin perjuicio de que exista una sistematización que distingue entre:

Prevención	Reparación
Consiste en evitar que ocurra el hecho que menoscabaría la dignidad; se trata de impedir que se produzca el acto dañino.	Si el hecho ocurriere, se trata de volver al estado anterior y, si ello no fuera posible, de indemnizar los daños producidos.

El Código incorpora, además, nuevas formas de reparación, entre ellas la posibilidad de publicar la sentencia en la que se ha discutido la afectación de un derecho personalísimo. Esta forma de reparación, presente ya en artículos anteriores, se incorpora también en la parte de daños del Libro Tercero como posibilidad específica cuando se encuentra afectado el honor de la persona.

24.8.3. Disponibilidad relativa: artículo 55

El artículo 55 dispone que los derechos personalísimos no son disponibles, salvo mediante el consentimiento de la persona, consentimiento que se encuentra sujeto a una serie de límites.

Regla: Artículo 55 CCyC — Disponibilidad relativa

El consentimiento no puede ser contrario a las buenas costumbres. El consentimiento no se presume; es de interpretación restrictiva y, ante la duda, se interpreta que no ha sido otorgado. Es libremente revocable en cualquier momento.

Importante

El consentimiento sobre los derechos personalísimos debe reunir las siguientes condiciones:

- No puede ser contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres.
- Debe ser expresado; no puede presumirse a partir de la mera falta de oposición. Puede manifestarse por escrito, en forma verbal o mediante un gesto comprensible, pero siempre debe existir una manifestación real.
- Es de interpretación restrictiva: ante la duda, se interpreta que no hubo consentimiento. Así, el consentimiento otorgado para el uso de la propia imagen en una campaña de bien común no se extiende, por interpretación restrictiva, a una campaña con fines comerciales.
- Es libremente revocable: la persona puede dar marcha atrás y revocar el consentimiento oportunamente otorgado.

24.9. Derecho a la libertad

El valor de la libertad constituye uno de los derechos personalísimos más importantes. Su fuente se ubica generalmente en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Regla: Artículo 19 de la Constitución Nacional

«Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe.»

Este constituye un principio de libertad fundamental en el ordenamiento jurídico argentino. Desde la perspectiva civil, la protección de la libertad se vincula sobre todo con los supuestos en que una persona sufre violencia para celebrar un acto; en tal caso, la persona afectada tiene derecho a reclamar los daños y perjuicios correspondientes.

También existe protección de la libertad en el campo de los derechos constitucionales, a través del habeas corpus, de la acción de amparo y de la acción de inconstitucionalidad, instrumentos que permiten conocer la situación de una persona, su paradero y su situación respecto de su integridad y de su libertad.

Nota

Al igual que en el resto de los derechos personalísimos, las formas de protección de la libertad se articulan a través del artículo 52, mediante la prevención y la reparación.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

24.10. Cuadro Cornell: derechos personalísimos

El siguiente cuadro permite repasar los conceptos centrales desarrollados en este capítulo mediante la técnica de recuperación activa propia del método Cornell.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué son los derechos personalísimos?	Son derechos subjetivos que reconocen y garantizan a la persona humana el goce en su propia entidad, en su interioridad, en todas sus manifestaciones físicas y espirituales. Protegen dimensiones fundamentales del ser humano inherentes a su naturaleza y dignidad.
¿Cuál es la diferencia entre derechos personalísimos y atributos de la personalidad?	Los atributos de la personalidad son cualidades esenciales que permiten que la persona despliegue su personalidad y entable relaciones jurídicas (como el nombre, el domicilio o la capacidad). Los derechos personalísimos son verdaderos derechos subjetivos que protegen dimensiones fundamentales de la persona (como la vida, el honor o la integridad física).
¿Por qué es importante estudiar los derechos personalísimos hoy?	Las circunstancias contemporáneas —biotecnologías, big data, privacidad digital— han generado nuevas amenazas a estos derechos que requieren una respuesta jurídica actualizada, orientada a proteger a las personas frente a formas de intromisión y vulneración que no existían en épocas anteriores.
¿Cuáles son los caracteres principales de los derechos personalísimos?	Son: subjetivos privados; innatos y originarios (reconocidos, no concedidos); vitalicios y necesarios; absolutos (sujeto pasivo universal); inherentes a la persona; intransmisibles; relativamente indisponibles; e irrenunciables. Todos estos caracteres buscan proteger la dignidad humana.
¿Cómo se clasifican los derechos personalísimos?	En forma tripartita: integridad física (vida, integridad corporal, salud); libertad (concepto que comprende aspectos corporales y espirituales); e integridad espiritual (honor, intimidad, imagen, identidad).

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Dónde se regulan los derechos personalísimos en el Código Civil y Comercial?	En el Capítulo 3, Título Primero, Libro Primero (artículos 51 a 62). El artículo 51 abre el capítulo con el principio de inviolabilidad de la persona humana y su derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.
¿Cuáles son los medios de protección de los derechos personalísimos?	El artículo 52 establece: la prevención, que busca evitar que ocurra el acto dañino, y la reparación, que busca volver al estado anterior o indemnizar. También se prevé la publicación de la sentencia como forma específica de reparación en casos de daño al honor, la intimidad o la identidad.
¿Qué significa que los derechos personalísimos son relativamente indisponibles?	No pueden ser dispuestos en principio, salvo mediante consentimiento que: no sea contrario a las buenas costumbres; no se presuma (debe ser expresado); sea de interpretación restrictiva; y sea libremente revocable.
¿Cómo se protege la libertad en el derecho civil?	A través de acciones civiles cuando existe violencia o coacción para celebrar un acto (reclamo de daños y perjuicios). También existen protecciones constitucionales, como el habeas corpus, el amparo y la acción de inconstitucionalidad, más específicas respecto de la libertad física.

Resumen: Los derechos personalísimos constituyen un sistema integrado de protección de la dignidad humana en todas sus dimensiones. Fundados en el reconocimiento de que cada persona posee una dignidad inherente, protegen la vida, la integridad física y espiritual, la libertad, el honor, la intimidad y la identidad de todo ser humano. Aunque tienen raíces profundas en la historia del derecho, adquieren una importancia renovada en el contexto contemporáneo, en el que las biotecnologías, la digitalización y el almacenamiento masivo de datos han generado nuevas amenazas a estas esferas fundamentales de la persona. El Código Civil y Comercial supone un avance significativo al sistematizar estos derechos en su Parte General, reconociendo su carácter innato, vitalicio, necesario, absoluto, inherente, intransmisible e irrenunciable. Su protección se articula mediante dos vías principales: la prevención y la reparación.

Parte VII

Los atributos de la persona humana

Esta parte estudia los atributos de la persona humana —el nombre, el domicilio y el estado civil— a partir de su enumeración general.

Capítulo 25

Los atributos de la persona humana

Tras estudiar la persona humana y el comienzo de su existencia, el derecho civil se ocupa de sus atributos: los elementos que permiten que la personalidad jurídica se despliegue. Los atributos posibilitan que las personas, en tanto sujetos en relación, establezcan relaciones y situaciones jurídicas y puedan identificarse dentro de ellas.

25.1. Enumeración de los atributos

La doctrina clásica reconoce cinco atributos de la persona humana: el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad y el patrimonio.

Atributo	Función
Nombre	Permite identificar a la persona.
Domicilio	Permite ubicar a la persona.
Estado	Permite establecer frente a qué relaciones jurídicas se encuentra la persona.
Capacidad	Permite determinar qué aptitud tiene la persona para entablar relaciones jurídicas.
Patrimonio	Permite conocer qué bienes tiene una persona.

Cuadro 25.1: Atributos de la persona humana y su función

Nota

Algunos autores discuten la clasificación clásica, en particular la inclusión del patrimonio como atributo. Estas notas siguen la distinción clásica de nombre, domicilio, estado, capacidad y patrimonio. Los capítulos siguientes estudian el nombre (capítulo 26), el domicilio (capítulo 27), el estado civil (capítulo 28) y la capacidad (capítulo 29).

Capítulo 26

El nombre

El nombre es el primer atributo en el orden de exposición: permite identificar a la persona. Este capítulo define el nombre, expone su régimen legal, las reglas sobre prenombre y apellido según el tipo de filiación, el cambio de nombre y sus acciones de protección, y explica la filiación como presupuesto de la atribución del apellido.

26.1. Concepto y caracteres

Definición: Nombre

Es la identificación exclusiva que corresponde a una persona.

El nombre es un concepto intuitivo, regulado de manera clara en el CCyC. Sus caracteres son: **necesario, obligatorio, único, inalienable, inembargable, imprescriptible, inmutable e indivisible**.

Está compuesto por dos elementos:

- el **nombre individual**, de pila o familiar, que el Código denomina **prenombre**: la denominación que permite distinguir a la persona dentro de su familia;
- el **apellido**: la denominación común a los integrantes de una misma familia.

Coloquialmente se habla de «nombre y apellido» por practicidad, pero jurídica y técnicamente ambos integran el concepto único de **nombre**. Al prenombre se lo conoce como «nombre de pila» por la pila bautismal, tradición de raíz cristiana; el código actual utiliza la palabra técnica «prenombre».

26.2. Régimen legal: evolución legislativa

La regulación del nombre se ubica en el Libro Primero, Título 1 (La persona humana), Capítulo 4 (El nombre), artículos 62 a 72 del CCyC, y deroga la Ley 18.248, conocida como «ley del nombre».

Etapa	Régimen
Código de Vélez (Ley 340)	Sin regulación específica del nombre; se regía por la costumbre.
Ley 18.248 (1969)	Primera «ley del nombre», complementaria del Código de Vélez.
CCyC vigente	Incorpora la regulación en su texto (arts. 62 a 72) y deroga la Ley 18.248.

Cuadro 26.1: Evolución legislativa de la regulación del nombre

26.3. El nombre como derecho y como deber (art. 62)

Regla: Art. 62 CCyC

La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponde.

La doctrina mayoritaria sostiene que el uso del nombre es simultáneamente un derecho y un deber. Es un **derecho subjetivo**, porque la persona puede exigir que se la reconozca con un determinado nombre. Es también un **deber**, porque existe un interés público en identificar a las personas; como correlato, la persona debe identificarse con su propio nombre, sin usar un nombre falso ni mentir al respecto.

26.4. El prenombre (art. 63)

26.4.1. Adquisición y orden de elección

Regla: Art. 63 inc. a) CCyC

El prenombre se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento, a pedido de quien ostente el derecho a elegirlo.

El orden de prelación de quienes eligen el prenombre es el siguiente:

1. Los **padres**, en conjunto o uno solo de ellos, sobreentendiéndose en este caso la autorización del otro (art. 641 CCyC, sobre responsabilidad parental).
2. Los padres pueden **delegar** la elección en un tercero, otorgándole autorización.
3. Si uno de los padres no está presente, elige el otro (por ejemplo, una persona soltera).
4. Si no hay padre conocido (por ejemplo, un niño abandonado), eligen los guardadores designados judicialmente, el Ministerio Público o el funcionario del Registro Civil y de Capacidad de las Personas.

26.4.2. Reglas y límites

Rige un principio de **libertad de elección**, que incluso permite inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes, autóctonas o latinoamericanas. Los límites son:

Importante

No pueden inscribirse más de tres prenombres, ni apellidos como prenombres, ni primeros prenombres idénticos a los de hermanos vivos, ni prenombres extravagantes.

Ejemplo: Apellidos como prenombres

No es posible inscribir a un hijo con el prenombre «Messi» o «Maradona», porque son apellidos.

La prohibición de repetir el primer prenombre entre hermanos vivos no se aplica a los nombres compuestos, como María de las Mercedes, María del Rosario, María del Pilar, Juan Bautista, Juan Segundo, Juan Manuel o Juan Ignacio.

Respecto de los nombres extravagantes, la ley anterior a 1948 era más amplia: no podían inscribirse nombres extravagantes o ridículos, que expresaran tendencias políticas o ideológicas, o que fueran equívocos respecto del sexo de quien los llevara. Hoy ese conjunto se sintetiza en la expresión «extravagantes», que deja un margen de discusión: un nombre como «Revolución» probablemente lo sería, y lo mismo los nombres de marcas famosas como «Amazon» o «Google», práctica que existió en Estados Unidos. Quien define en la práctica si un nombre es extravagante es el Registro del Estado Civil; ante un conflicto, la persona interesada puede recurrir a la vía judicial.

26.5. El apellido

26.5.1. Filiación matrimonial (art. 64)

El CCyC innovó respecto de la Ley 18.248, que establecía que el hijo llevaba necesariamente el apellido paterno.

Regla: Art. 64 CCyC: apellido de los hijos matrimoniales

El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo sobre qué apellido llevará, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro cónyuge. Todos los hijos comunes deben llevar el mismo apellido y, en el mismo orden, que el primero de los hijos.

El orden de apellidos fijado para el primer hijo —por acuerdo o por sorteo— queda establecido para todos los hijos comunes posteriores. Para agregar el apellido del otro progenitor a pedido del interesado, el Código usa el estándar de **edad y madurez suficiente**, que evalúa en concreto el Registro Civil; como criterio orientativo, se señala que debería contar al menos con trece años, edad en que el Código presume discernimiento para los actos

lícitos, sin perjuicio del análisis de cada caso. El artículo 64 solo permite agregar apellidos, no suprimirlos.

26.5.2. Filiación extramatrimonial

1. **Un solo progenitor reconoce al hijo** (por ejemplo, solo la madre): el hijo lleva el apellido de quien lo reconoce.
2. **El segundo progenitor reconoce al hijo con posterioridad:** deben ponerse de acuerdo; si no lo logran, decide el juez teniendo en cuenta el interés superior del niño.
3. **Ambos reconocen al mismo tiempo:** rigen las reglas de la filiación matrimonial; si no hay acuerdo, sorteo.

26.5.3. Persona sin filiación determinada (art. 66)

Una persona puede carecer de filiación determinada, lo que suele ocurrir en zonas marginales, en familias sin contacto con instituciones estatales o de protección, donde nunca fue inscripta aunque la comunidad la conozca por un apellido. No se puede excluir a un niño de la educación escolar por no contar con DNI. En estos casos, el oficial del Registro Civil anota la circunstancia utilizando el apellido que ya use la persona o asignándole un apellido común.

Regla: Art. 66 CCyC

La persona, con edad y grado de madurez suficiente, que carezca de apellido inscripto, puede pedir la inscripción del que está usando.

26.5.4. Apellido de los cónyuges, viudez y adopción

Durante el matrimonio. El Código consagra la libertad de que cualquiera de los cónyuges opte por usar el apellido del otro, con la partícula «de» o sin ella, como apellido adicional al propio. Es un derecho indistinto, a diferencia del régimen anterior en que era la mujer quien tomaba el apellido del marido; el texto actual está redactado en términos neutros.

Divorcio y nulidad. Quien adoptó el apellido del otro deja de usarlo, salvo que por motivos razonables un juez autorice a conservarlo.

Ejemplo: Motivo razonable: uso comercial

Un cónyuge que usaba el apellido adquirido por matrimonio para identificar a su empresa continuó usándolo tras el divorcio por razones económicas, dado que era el nombre con el que su empresa era reconocida en el mercado.

Viudez. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro mientras no contraiga nuevas nupcias ni constituya una nueva unión convivencial; su uso no es obligatorio.

Adopción. El régimen varía según el tipo:

Tipo de adopción	Apellido del adoptado
Plena	Lleva el apellido del adoptante; si la adopción es conjunta, rigen las reglas de la filiación matrimonial sobre el orden. Excepcionalmente, fundado en el derecho a la identidad y a pedido del interesado, puede agregarse o anteponerse el apellido de origen (identidad en su dimensión estática).
Simple	No corta el vínculo con la familia de origen. El adoptado puede solicitar mantener su apellido de origen adicionándole el del adoptante; si no manifiesta voluntad, se aplica la regla de la adopción plena. La consulta sobre mantener el apellido de origen es la regla, mientras que en la plena es excepcional.
De integración	Adopción del hijo del cónyuge o conviviente: se aplican las reglas del tipo de adopción de que se trate (plena o simple).

Cuadro 26.2: Apellido del hijo adoptado

26.6. Cambio de nombre y acciones de protección

Importante

El nombre es inmutable. El cambio de nombre y apellido solo procede si existen justos motivos, y puede tramitarse por vía judicial o administrativa.

26.6.1. Vía judicial: justos motivos (art. 69)

Debe alegarse y acreditarse un justo motivo. El artículo 69 enumera algunos, a título orientativo:

Regla: Art. 69 CCyC: justos motivos (enumeración no taxativa)

El seudónimo, cuando hubiere adquirido notoriedad; la raigambre cultural, étnica o religiosa; la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.

El **seudónimo notorio** se da habitualmente entre artistas. La **raigambre cultural, étnica o religiosa** se refiere a quien descubre una raíz propia y desea reflejarla en su nombre. La **afectación de la personalidad** se vincula con nombres que han provocado bullying, burlas o vergüenza social. Se trata de una lista enunciativa: puede haber otros justos motivos con fuerza suficiente para convencer a un juez, en el proceso judicial específico.

26.6.2. Vía administrativa

También prevista en el artículo 69, se aplica en dos supuestos en que la ley autoriza el cambio sin acudir a un juez: por razón de identidad de género, conforme a la Ley 26.743; y por haber sido víctima de desaparición forzada, sustitución de identidad, alteración o supresión del estado civil, o de un delito que afecte la personalidad. Se recurre directamente al Registro Civil.

26.6.3. Procedimiento y acciones de protección

El procedimiento está regulado en el artículo 70 y las acciones de protección en el artículo 71:

Acción (art. 71)	Procede cuando...	Ejemplo
Reclamación	Se desconoce a una persona el uso de su propio nombre.	Una universidad anota incorrectamente el nombre; la persona reclama que se lo anote bien.
Impugnación o usurpación	Otra persona usa el nombre de quien reclama, causándole un perjuicio.	Alguien abre una cuenta en una red social con el nombre de otra y actúa en su nombre.
Defensa o supresión	El uso del nombre por un tercero causa un perjuicio a quien lo lleva.	El nombre aparece como nombre de fantasía en una serie o telenovela.

Cuadro 26.3: Acciones de protección del nombre

Definición: Seudónimo

Nombre ficticio empleado por una persona, generalmente en el ámbito artístico, en el ámbito de despliegue de su actividad. Su uso es lícito. Si goza de notoriedad, tiene la misma protección que el nombre y le corresponden las acciones del artículo 71.

26.7. La filiación y el nombre

La regulación del apellido depende de la filiación, que conviene precisar.

Definición: Filiación

Es el estatuto de hijo: un vínculo jurídico entre progenitores e hijos, que tiene su origen en la naturaleza, en un reconocimiento jurídico por el cual una persona reconoce a su hijo extramatrimonial, en la fecundación *in vitro* (con regulación propia dentro del derecho de familia) o en la adopción.

Filiación matrimonial. Cuando dos personas se casan, los hijos que tengan se presumen del matrimonio. La presunción puede no coincidir con la realidad biológica en todos los casos, pero la ley la establece por razones de orden social: el matrimonio es ordenador de la vida social, los cónyuges se comprometen a vivir juntos y a educar a los hijos que nazcan, y la sociedad reconoce ese compromiso otorgando a esos hijos el apellido fijado y presumido legalmente.

Filiación por naturaleza. Cuando una mujer da a luz, la maternidad queda determinada por el parto. Si la madre está casada, la ley presume la paternidad del cónyuge; si no lo está, la persona tiene en principio un solo progenitor determinado, salvo que otra persona la reconozca. En estos casos la ley sigue un modelo binario que sigue a la biología.

Filiación extramatrimonial. Puede ser fruto de un reconocimiento voluntario —técnicamente un acto jurídico de reconocimiento— o de una acción judicial.

Definición: Acción de filiación forzosa

Acción judicial por la cual se obliga al padre que no reconoce voluntariamente a su hijo a reconocerlo y a pasar alimentos; al asignarse el vínculo, el hijo pasa a tener determinados a ambos progenitores.

Frente a la filiación determinada existe la filiación no determinada, en la que se desconoce el vínculo y se usa el apellido que ya emplea el hijo (art. 66).

El interés superior del niño. Cuando el juez resuelve atendiendo al interés superior del niño —por ejemplo, ante el desacuerdo sobre el apellido— se remite centralmente a la Convención sobre los Derechos del Niño, sin perjuicio de la Ley 26.061. Es un concepto complejo con un componente objetivo —determinar qué es lo mejor para ese niño en concreto— que también tiene en cuenta la opinión del niño según su edad y madurez.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

26.8. Cuadro Cornell: el nombre

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el nombre y cuáles son sus caracteres?	La identificación exclusiva de una persona. Es necesario, obligatorio, único, inalienable, inembargable, imprescriptible, inmutable e indivisible; se compone de prenombre y apellido.
¿Por qué es derecho y deber (art. 62)?	Es derecho subjetivo a ser reconocido con un nombre y deber por el interés público en identificar a las personas.
¿Qué límites tiene la elección del prenombre?	No más de tres, no apellidos, no el primer prenombre de hermanos vivos (salvo compuestos) y no extravagantes; decide el Registro y cabe vía judicial.
¿Cómo se determina el apellido del hijo?	Matrimonial: primer apellido de cualquiera de los cónyuges, por acuerdo o sorteo, igual orden para los hermanos. Extramatrimonial: según quién reconoce y cuándo. Adopción: según sea plena, simple o de integración.
¿Cuándo procede el cambio de nombre?	Solo con justos motivos (art. 69): vía judicial (seudónimo notorio, raigambre cultural, étnica o religiosa, afectación de la personalidad) o administrativa (identidad de género, víctimas de ciertos delitos).
¿Qué acciones protegen el nombre?	Reclamación, impugnación o usurpación, y defensa o supresión (art. 71).

Resumen: El nombre, compuesto por prenombre y apellido, identifica a la persona y es un derecho y un deber regulados en los arts. 62 a 72 CCyC. La libertad de elección del prenombre tiene límites; el apellido depende de la filiación; el cambio exige justos motivos y el nombre se protege con acciones específicas.

Capítulo 27

El domicilio

El domicilio es el atributo que permite ubicar a la persona. Este capítulo lo define y lo distingue del domicilio constitucional y de la residencia, expone su clasificación en general y especial, desarrolla el domicilio real y el legal, los tipos de domicilio especial, las reglas del domicilio desconocido y los efectos jurídicos del domicilio.

27.1. Concepto, finalidad y ubicación normativa

El domicilio es un concepto jurídico civil específico, que no debe confundirse con el domicilio que figura en el documento nacional de identidad (DNI). Este último es una forma de registración, mientras que el domicilio depende de reglas propias del derecho civil. Está regulado en el Libro Primero, Título Primero (La persona humana), Capítulo Quinto (El domicilio), artículos 73 a 78 del CCyC.

Definición: Domicilio

Es el asiento jurídico de la persona: el lugar donde, a los efectos jurídicos correspondientes, se considera que se encuentra una persona.

El domicilio resulta relevante para:

- **determinar la ley aplicable** a una situación (por ejemplo, la ley aplicable a un inmueble es la del territorio donde se encuentra);
- **determinar la jurisdicción del juez competente** (en una sucesión, el juez del último domicilio de la persona fallecida);
- **practicar válidamente las notificaciones**;
- **determinar el lugar de cumplimiento de las obligaciones** (en un préstamo, el deudor devuelve el dinero en el domicilio del acreedor).

27.1.1. Domicilio civil y domicilio constitucional

Cuando la Constitución se refiere a la inviolabilidad del domicilio protege la vida privada, la vivienda y la imposibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial, junto con una serie de recaudos vinculados a la concepción política constitucional.

Importante

El domicilio civil sirve a los fines de las relaciones jurídicas —cumplimiento de obligaciones, ley aplicable, competencia judicial y notificaciones—; el domicilio constitucional protege la inviolabilidad de la vivienda y la vida privada frente a injerencias como los allanamientos sin orden judicial.

El domicilio civil surge de la ley: a veces coincide con la residencia real de la persona y otras veces la ley lo asigna en función de una determinada función que la persona desempeña en una situación dada.

27.1.2. Domicilio y residencia

La **residencia** es el lugar donde, en los hechos, se encuentra una persona, y puede ser habitual o actual. Es un concepto de hecho que puede o no coincidir con el domicilio jurídico.

Ejemplo: Residencia actual o habitación

Quien se va de vacaciones y habita transitoriamente una casa en Mar del Plata tiene allí su residencia actual (también llamada habitación), aunque su domicilio continúe en la ciudad donde reside habitualmente. La residencia actual no implica, por sí sola, un cambio de domicilio.

27.2. Clasificación: domicilio general y especial

Definición: Domicilio general

Rige para la generalidad de las relaciones o situaciones jurídicas de una persona. Debe ser uno solo y puede ser real o legal.

Definición: Domicilio especial

Tiene efectos para una o algunas relaciones jurídicas particulares determinadas. Una persona puede tener varios.

Dentro del domicilio general, el **domicilio real** es el que la persona elige y donde tiene el asiento jurídico de su familia y sus negocios; el **domicilio legal** es el que la ley asigna en ciertos casos.

Advertencia

No es correcto identificar el «domicilio legal» con el domicilio que figura en el DNI. Normalmente toda persona tiene un domicilio real, que es voluntario; solo en circunstancias previstas expresamente por la ley corresponde asignarle un domicilio legal.

Ejemplo: Múltiples domicilios especiales

Una persona puede celebrar un préstamo fijando un domicilio y, al día siguiente, otro préstamo fijando uno distinto, pues puede constituir tantos domicilios especiales como quiera. La multiplicidad puede complicar en la práctica la administración de los efectos jurídicos, ya que cada contraparte enviará notificaciones o pagos al domicilio fijado en su contrato.

Importante

El domicilio general es **necesario** —ninguna persona puede carecer de él— y **único**: más de uno generaría confusión sobre dónde ubicar a la persona a todos los efectos jurídicos.

27.3. El domicilio real (art. 73)

Definición: Domicilio real (art. 73, primer párrafo, CCyC)

Es el lugar donde la persona tiene el lugar de su residencia habitual.

El artículo 73 contempla dos supuestos distintos: el primer párrafo regula el domicilio real y el segundo, un domicilio especial (el profesional, tratado más abajo). Son instituciones distintas, reguladas en el mismo artículo.

Caracteres. El domicilio real es **voluntario**: depende de la persona constituirlo, mantenerlo, exigirlo o modificarlo, en virtud del principio de libre elección del domicilio. La facultad de cambiar de domicilio no puede ser coartada por contrato ni por una imposición de última voluntad.

Ejemplo: Imposibilidad de coartar el cambio de domicilio

Unos padres regalan a su hijo una casa de casamiento bajo la condición de que nunca se mude de allí. La condición no puede disponerse válidamente: no es posible obligar a una persona a no cambiar nunca su domicilio.

Elementos: corpus y ánimo.

Definición: Corpus

La residencia efectiva en un lugar: la materialidad de estar viviendo en un lugar determinado.

Definición: Ánimo

La intención de permanecer en un lugar y de constituir allí el domicilio; el elemento subjetivo por el cual la persona quiere estar en ese lugar.

Ejemplo: El estudiante de otra provincia

Una persona de Santa Rosa que se traslada a Buenos Aires para cursar una carrera reside allí transitoriamente, sin intención de cambiar su domicilio de origen: conserva su domicilio real en Santa Rosa, aunque su habitación esté en Buenos Aires.

Constitución, mantenimiento y extinción. El domicilio real se constituye cuando concurren corpus y ánimo.

Regla: Art. 77 CCyC: permanencia y cambio

El domicilio real se mantiene mientras subsista alguno de sus dos elementos (corpus o ánimo). El cambio de domicilio se produce instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.

Una persona puede mudarse físicamente conservando el ánimo de regresar al domicilio anterior; para el cambio efectivo se requieren ambos elementos. El domicilio real se extingue por la constitución de un nuevo domicilio o porque la ley impone un domicilio legal.

27.4. El domicilio legal (art. 74)

El domicilio legal, a diferencia del real, es **forzoso**: la ley lo impone.

Definición: Domicilio legal (art. 74 CCyC)

Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que la persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Se trata de una presunción *iuris et de iure*: se impone a la persona y no le permite demostrar lo contrario. Sus caracteres son:

- **forzoso**: lo impone la ley;
- **de interpretación restrictiva**: no cabe la analogía para crear supuestos no previstos;
- **excepcional**: en principio toda persona tiene domicilio real;
- **único**, por ser una especie de domicilio general.

Regla: Art. 74 CCyC: supuestos de domicilio legal

- Los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar donde deben cumplir sus funciones, sea que las cumplan de manera permanente, periódica o por comisión.
- Los militares en servicio activo, en el lugar en que están prestando servicio.
- Los transeúntes o las personas que no tienen domicilio conocido, en el lugar de su residencia actual.
- Las personas incapaces, en el domicilio de su representante.

Ejemplo: Los cuatro supuestos

Funcionarios: un ministro de la Corte Suprema o del Poder Ejecutivo tiene domicilio donde cumple sus funciones. **Militares**: en el lugar donde prestan servicio activo. **Transeúntes**: personas cuya profesión o manera de vida implica traslados constantes o en situación de calle; por ejemplo, los integrantes de un circo tienen domicilio donde residan en cada momento. **Incapaces**: los menores tienen su domicilio en el de su representante; si un menor tiene un derecho en una sucesión, las notificaciones se dirigen al domicilio de sus representantes.

El régimen anterior contemplaba un caso adicional, el del servicio doméstico agregado a la casa de sus empleadores, que fue eliminado del Código actual.

27.5. El domicilio especial

27.5.1. Domicilio convencional o de elección

Definición: Domicilio especial convencional

Es el que las partes de un contrato eligen para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Las notificaciones enviadas a ese domicilio son válidas aunque la persona ya no resida allí, salvo que se modifique el contrato o se notifique y acepte el cambio.

Ejemplo: La cláusula de domicilio en un contrato

En el encabezado de un contrato se identifica a cada parte con un domicilio donde serán válidas todas las notificaciones. Ante una discusión derivada del contrato, la notificación enviada a ese domicilio tendrá efecto aunque la persona se haya mudado y alegue que ya no vive allí.

El fundamento reside en la fuerza vinculante de los contratos: el acuerdo de respetar como válidas las notificaciones al domicilio pactado debe respetarse mientras no se modifique el contrato.

27.5.2. Domicilio procesal

El domicilio procesal, o *ad litem*, presenta hoy una modalidad electrónica, utilizada a través del sistema de notificaciones del Poder Judicial, que coincide con el número de CUIT del profesional interviniente. Existe además el domicilio constituido, que generalmente coincide con el del abogado interviniente.

Ejemplo: Domicilio constituido en distintos procesos

Una persona que vive en un domicilio determinado constituye, para un proceso concreto, domicilio en el estudio de su abogado; si tiene otro abogado en un juicio distinto, tendrá en ese otro proceso un domicilio especial diferente.

27.5.3. Domicilio profesional (art. 73, segundo párrafo)

Definición: Domicilio profesional

La persona que ejerce actividad profesional o económica tiene su domicilio en el lugar donde la desempeña, para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.

Comprende las profesiones liberales: contador, abogado, ingeniero, psicólogo, psiquiatra, médico.

Ejemplo: El abogado con un problema de familia

Un abogado con un problema sobre el régimen de cuidado de sus propios hijos no es notificado donde ejerce su profesión sino en su domicilio real, porque el problema no se vincula con su actividad profesional.

27.6. Domicilio desconocido (art. 76)

Regla: Art. 76 CCyC

La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra; y si este también se ignora, en su último domicilio conocido.

La regla es relevante en la práctica, especialmente con deudores que procuran no ser ubicados; adquiere importancia el domicilio registrado en el DNI o en los trámites electorales.

Ejemplo: El deudor que no aparece

Si se desconoce el domicilio de un deudor y las cédulas enviadas al último domicilio conocido son rechazadas, corresponde solicitar un oficio al Registro de las Personas para que informe el último domicilio conocido y notificar allí.

Frente a esa notificación, la persona puede alegar que ya no vivía allí y pedir que se la declare inválida junto con las actuaciones derivadas; se abre entonces un proceso para determinar si la persona realmente no residía allí o si quien notificó conocía el verdadero domicilio.

Importante

Distribución de la carga de la prueba: si quien notificó afirma que no conocía el verdadero domicilio, se aplica el artículo 76 y corresponde a la otra parte demostrar la mala fe de quien notificó; si no lo logra, se considera debidamente notificado.

En principio, una notificación que llega a un domicilio donde la persona ya no vive no surte efectos, pues debe llegar efectivamente al lugar donde reside. Cuando se han intentado distintos domicilios sin éxito, se procura notificar en el del DNI y, si tampoco resulta posible, se notifica bajo responsabilidad de la parte actora para continuar válidamente con el proceso.

27.7. Efectos jurídicos del domicilio (art. 78)

Regla: Art. 78 CCyC

El domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. Allí debe notificarse a la persona, intimarla, demandarla o requerirla extrajudicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

Incluye la elección de domicilio respecto de la competencia: si una persona constituye un domicilio en un contrato, ello produce efectos frente a la competencia del juez ante el que podrá ser demandada.

27.8. Precisiones adicionales

Personas privadas de su libertad. La situación depende del caso: en principio tendrán el domicilio donde residen actualmente, aunque la cuestión se rige más por las reglas penitenciarias y de ejecución de la pena. Cuando el traslado fue contrario a su voluntad no se configuran, en rigor, corpus y ánimo, por ausencia de voluntad libre de constituir allí su residencia.

Argentinos residentes en el exterior. Pueden trasladar su domicilio al exterior; para la ley argentina dejan de tener domicilio en el país. Si el último domicilio de una persona fallecida estaba en el exterior, la sucesión se tramita allí. La materia se vincula con el derecho internacional privado, donde el domicilio es un punto de conexión.

Domicilio procesal y cambio de domicilio. Constituido domicilio en un proceso, las cédulas siguen dirigiéndose allí mientras no se informe un cambio en el expediente, momento en que se constituye uno nuevo. Distinto es el caso de una notificación —como una carta documento— enviada antes de constituir domicilio en un proceso: si se dirige a un lugar donde la persona ya no vive, en principio no surte efectos.

27.9. Cuadro Cornell: el domicilio

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el domicilio y para qué sirve?	El asiento jurídico de la persona (arts. 73 a 78). Determina ley aplicable, competencia judicial, notificaciones y lugar de cumplimiento de las obligaciones.
¿En qué se distingue de la residencia y del domicilio constitucional?	La residencia es un hecho (habitual o actual); el domicilio constitucional protege la vivienda y la vida privada; el DNI es solo una forma de registración.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es la clasificación del domicilio?	General (único y necesario; real o legal) y especial (varios; convencional, procesal, profesional).
¿Qué elementos tiene el domicilio real y cómo se mantiene?	Corpus (residencia efectiva) y ánimo (intención de permanecer); se mantiene mientras subsista alguno y cambia cuando se trasladan ambos (art. 77).
¿Cuáles son los cuatro supuestos de domicilio legal?	Funcionarios públicos, militares en servicio activo, transeúntes e incapaces (en el domicilio de su representante); presunción *iuris et de iure*, interpretación restrictiva.
¿Qué ocurre si el domicilio se ignora?	Se tiene por domicilio el lugar donde la persona se encuentra y, si también se ignora, el último domicilio conocido (art. 76).

Resumen: El domicilio es el asiento jurídico de la persona. El general es único y puede ser real (voluntario: corpus y ánimo) o legal (forzoso, en cuatro supuestos); el especial puede ser múltiple (convencional, procesal, profesional). Si se ignora, rige el último domicilio conocido, y sus efectos alcanzan a la competencia, las notificaciones y el cumplimiento de obligaciones.

Capítulo 28

El estado civil

El estado civil es el atributo que permite establecer frente a qué relaciones jurídicas se encuentra la persona. Este capítulo define el estado civil, repasa sus antecedentes romanos y su sentido en la era de los derechos humanos, estudia las acciones de estado, la posesión de estado con sus cuatro aplicaciones y la prueba del estado civil mediante las partidas del Registro Civil.

28.1. Concepto de estado civil

El término «estado» es polisémico: habitualmente remite a la organización política de una nación, pero esa es solo una de sus acepciones.

Definición: Estado civil

En derecho civil, el **estado** es la posición que la persona ocupa en la sociedad y en la familia. Se lo denomina estado civil y se asocia con las categorías de casado, soltero o divorciado —más vinculadas a lo matrimonial—, pero también comprende la **filiación** (la relación entre padres e hijos: paternidad y maternidad) y el **parentesco**.

28.1.1. Antecedentes en el derecho romano

En Roma el estatus determinaba el plexo de derechos de una persona. Existían tres:

Estatus	Contenido
Status libertatis	Definía si la persona era libre o esclava; el libre tenía derechos que no tenía el esclavo.
Status civitatis	Estado en relación con la ciudad: ciudadano romano o extranjero; los ciudadanos tenían derechos que los extranjeros no tenían.
Status familiae	Estado en relación con la familia; la cabeza era el *paterfamilias*, con derechos que no tenían los demás miembros.

Cuadro 28.1: Los tres estatus del derecho romano

El sistema vinculado al *status libertatis* —la distinción entre libres y esclavos— ha sido abolido.

28.1.2. El estado en la era de los derechos humanos

Con el tiempo la división en estatus que determinaba más o menos derechos se desvaneció: en la era de los derechos humanos no pueden hacerse distinciones de ese tipo, pues todos los seres humanos son iguales en derechos y condiciones. Por eso el estado pierde relevancia para determinar derechos.

Importante

A lo sumo reaparecen formas asimilables a estados particulares, que apuntan a una mayor protección de los sectores vulnerables, como ocurre con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: quien presenta una discapacidad tiene un conjunto mayor de protecciones y derechos, para favorecer su inclusión y su desarrollo. No es, sin embargo, el concepto tradicional de estado: es una noción distinta. La noción de estado civil se reduce a la posición de la persona en la familia y en la sociedad.

28.1.3. Importancia e incidencia del estado civil

El estado civil incide en otros institutos y atributos:

- **Domicilio**: los incapaces, especialmente los hijos mientras dura la responsabilidad parental, tienen su domicilio en el de sus padres (capítulo 27).
- **Capacidad**: por ejemplo, los cónyuges no pueden contratar entre sí bajo el régimen de comunidad.
- **Apellido de los hijos**: los matrimoniales llevan el de sus padres; si la filiación es extramatrimonial, el del progenitor que los reconoció, si tienen una sola filiación determinada (capítulo 26).
- **Alimentos**: la determinación del estado incide en la obligación alimentaria entre parientes, especialmente en la responsabilidad parental.
- Otras obligaciones, como la de informar ciertas situaciones cuando existe una relación de familia.

Regla: Art. 344 CCyC

Está prohibida la condición que afecte de modo grave la libertad de las acciones de la persona, como la de elegir un domicilio o una religión, o decidir sobre su estado civil —por ejemplo, no casarse, o casarse o no con determinada persona—.

No se puede imponer como condición de un contrato o de una donación que alguien cambie o no cambie su estado civil, ni exigir como condición para donar una casa que nunca contraiga matrimonio: sería contrario a la libertad básica de las personas.

28.2. Las acciones de estado

Definición: Acción de estado

Posibilidad técnica de iniciar reclamos en sede judicial orientados a la **reclamación** o a la **impugnación** de un estado determinado. El caso típico es el de la **filiación**.

Acción de reclamación. La persona busca ser emplazada en un estado determinado, como ocurre cuando no ha sido reconocida por uno de sus progenitores.

Ejemplo: Reclamación de filiación

Quien no ha sido reconocido por uno de sus progenitores presenta pruebas y ofrece un estudio genético. La parte reclamada contesta y puede negar el vínculo; se genera un contradictorio en el que se ofrecen y controvierten pruebas, se realiza el estudio genético y una sentencia determina si la persona es o no hija.

Acción de impugnación. Busca desplazar a una persona de un estado determinado. Cuando alguien siente que quien pasa por su padre o madre no es su verdadero progenitor, puede iniciar una acción de impugnación de la filiación; también la puede iniciar el propio interesado.

Importante

A veces una persona reconoce a un hijo creyendo hacerle un bien, lo cual no es así: es el **reconocimiento complaciente**. Es problemático porque no es la vía jurídica para establecer la filiación, que es muy importante para la identidad y hace al conocimiento de los orígenes.

El Código regula distintas variantes que exceden esta presentación. Como en todo proceso, las acciones pueden prosperar o no; si el juez de primera instancia no hace lugar a las pruebas, siempre cabe apelar a segunda instancia, donde interviene un tribunal colegiado (al menos tres jueces en la Capital Federal). La prueba biológica y genética es especialmente decisiva en la filiación por naturaleza.

Importante

Si se parte de un principio de verdad biológica, la ley presupone que el vínculo filiatorio se establece por el origen genético. Pero la filiación es un instituto complejo, compuesto también de elementos estáticos, como la posesión de estado.

28.3. La posesión de estado

La posesión de estado es análoga a la posesión de las cosas. En el CCyC la posesión es la situación de quien detenta una cosa con espíritu de dueño, con independencia de que tenga o no el título; el Código denomina a estas situaciones relaciones de poder.

Ejemplo: Posesión de cosas y prescripción adquisitiva

El poseedor que durante veinte años posee un inmueble como si fuera el dueño puede iniciar una acción para ser tenido por dueño ante el Registro de la Propiedad Inmueble. El Código denomina a esta figura **prescripción adquisitiva**.

Definición: Posesión de estado

Es el goce de hecho de un estado determinado, con independencia de si la persona detenta o no el título correspondiente.

Importante

Título y posesión coinciden en la mayoría de los casos, pero son cosas distintas. En el estado de hijo, el **título** es estar anotado como hijo de una persona en el Registro Civil; la **posesión** es ser tratado como hijo, en los hechos, por quienes figuran como sus padres.

28.3.1. Elementos históricos: *nomen*, *tractatus* y *fama*

Elemento	Contenido
Nomen	El nombre: ser llamado como hijo (en el caso de la filiación).
Tractatus	El trato: ser tratado como hijo.
Fama	Ser conocido por los demás como hijo.

Cuadro 28.2: Elementos romanos de la posesión de estado

Hoy el elemento más importante es el **trato**.

Ejemplo: Cómo se acredita el trato como hijo

La fotografía de un cumpleaños, el pago de la obra social, de la cuota del colegio, del club o de un profesor particular, o llevar a la persona de vacaciones con la fotografía correspondiente.

28.3.2. Las cuatro aplicaciones en el CCyC

Primera: posesión de estado matrimonial (art. 423). Por regla, no acredita el matrimonio, que es un acto jurídico solemne con consentimiento expresado ante el oficial del Registro Civil. Quienes simplemente conviven no acceden por ello a los beneficios del matrimonio: el Código regula la unión convivencial como vinculación distinta. La excepción se presenta cuando hubo un problema de forma en el acta de celebración.

Regla: Art. 423 CCyC (según la explicación de las fuentes)

La posesión de estado matrimonial no acredita el matrimonio, que es un acto jurídico solemne. Sin embargo, si existió posesión de estado y se presenta un acta de celebración, los defectos formales del acta no pueden alegarse contra su existencia.

Ejemplo: Error formal en el acta

Al fallecer un cónyuge, el sobreviviente se presenta al Registro Civil para iniciar la sucesión y se le informa que hay un error en el acta de un matrimonio celebrado veinticinco años atrás, por lo que sería nulo. Como hubo posesión del estado de cónyuge durante todo ese tiempo, el vicio formal queda saneado y el matrimonio se considera válidamente celebrado.

Segunda: reconocimiento de la filiación (art. 584). Es la aplicación más típica.

Regla: Art. 584 CCyC

La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético.

Si quien reclama prueba que el progenitor le pagaba la escuela, lo trataba, convivía con él y lo llevaba de vacaciones, acredita la posesión de estado; pero la prueba genética prevalece sobre la posesión de estado cuando entran en conflicto.

Tercera: límite a la negación de la filiación presumida (art. 591). Si una persona está casada se presume que los hijos nacidos durante el matrimonio son de ambos cónyuges. El cónyuge que no dio a luz puede negar esa filiación en un plazo muy inmediato al nacimiento —el caso habitual es alegar una infidelidad—, pero no puede negarla si hubo posesión de estado, es decir, si trató al hijo como propio.

Cuarta: adopción de personas mayores de edad (art. 597). En principio se adopta a menores, pero el Código permite adoptar excepcionalmente a un mayor cuando hubo posesión de estado de hijo durante su minoridad. Puede tener un efecto sucesorio importante, porque el hijo adoptivo podría suceder a quien lo trató como padre o madre.

Artículo	Materia	Efecto de la posesión de estado
423	**Matrimonio**	No acredita el matrimonio, pero sanea los defectos formales del acta.
584	**Reconocimiento de la filiación**	Vale como reconocimiento, salvo prueba genética en contrario.
591	**Negación de la filiación presumida**	Impide negar la filiación si se trató al hijo como propio.
597	**Adopción de mayores de edad**	Habilita la adopción excepcional del mayor tratado como hijo en su minoridad.

Cuadro 28.3: Aplicaciones de la posesión de estado en el CCyC

28.4. La prueba del estado civil

28.4.1. Las partidas

Regla: Regla general sobre la prueba del estado civil

El nacimiento, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas se prueban con las partidas del Registro Civil.

El Registro Civil se denomina técnicamente Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La forma de registración está regida por una ley nacional —la Ley 26.413, que uniforma la registración de los hechos y actos relativos al estado civil en todo el país—, pero la organización de cada registro depende de cada provincia, por la organización federal.

La exigencia de registración se funda en que el estado civil está constituido a partir de hechos: el nacimiento, su tiempo y lugar y el sexo al nacer son hechos; el nombre se adjudica y la filiación se determina jurídicamente. Existe un interés público sustantivo en que la sociedad registre estos eventos. Los grandes hechos y actos a registrar son la adopción, el matrimonio, el divorcio y el fallecimiento, que cierra el ciclo; de allí los tres grandes tipos de partida: de nacimiento, de matrimonio y de defunción.

Definición: Partida

Asiento en el libro del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en el que constan los hechos y actos constitutivos del estado: nacimiento, matrimonio y defunción.

Importante

Las partidas son **instrumentos públicos**: tienen valor probatorio propio y hacen plena fe de su contenido.

Nota

La partida no se confunde con el certificado médico de nacimiento o de defunción: este lo expide el médico y sirve para concurrir al Registro Civil, donde se confecciona la partida. Lo que siempre debe ofrecerse como prueba es la partida; solo si no existiera corresponde recurrir a otros medios.

28.4.2. La prueba supletoria

La ausencia de partidas puede deberse a que no hay registro, a que falta la partida o el asiento, o a que este es nulo.

Ejemplo: El incendio de un Registro Civil

Si un incendio destruyera los libros de un período, la persona puede acompañar otros certificados —por ejemplo, de un hecho religioso como el bautismo, o una constancia de inscripción escolar que consigne la fecha de nacimiento— para acreditar su fecha de nacimiento, o la de defunción de otra persona, a los fines de elaborar la partida.

28.4.3. Fallecimiento sin hallazgo o identificación del cadáver (art. 98)

El artículo 98 contempla, en su segunda parte, el caso en que fallece una persona pero no se encuentra el cadáver, o no puede identificarse, aunque no haya duda de que murió.

Regla: Art. 98 CCyC

Si el cadáver de una persona no es hallado, o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta.

El ejemplo del alpinista, junto con la distinción entre esta figura y la presunción de fallecimiento, se desarrolla en la sección 35.4.2.

Ejemplo: El accidente aéreo

Fallecen todos los ocupantes de una aeronave y los cadáveres pueden no identificarse individualmente. Si se prueba que una persona estaba en ese vuelo, se la puede anotar como fallecida y iniciar los trámites sucesorios.

No es un fallecimiento presunto, sino indudable: las circunstancias deben hacer tener la muerte por cierta. Acreditado el fallecimiento, se expide una partida de defunción común.

28.5. Cuadro Cornell: el estado civil

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el estado civil?	La posición de la persona en la sociedad y en la familia: estado matrimonial, filiación y parentesco.
¿Por qué pierde relevancia en la era de los derechos humanos?	Porque ya no se admiten estatus que determinen más o menos derechos (a diferencia de Roma: *status libertatis*, *civitatis* y *familiae*); la protección de vulnerables no es el estado tradicional.
¿Qué condiciones están prohibidas?	Las que afectan gravemente la libertad de decidir sobre el estado civil (art. 344): casarse o no, o hacerlo con determinada persona.
¿Qué son las acciones de estado?	Acciones judiciales de reclamación (emplazar en un estado) e impugnación (desplazar de un estado), típicas en la filiación.
¿Qué es la posesión de estado y cuáles son sus cuatro aplicaciones?	El goce de hecho de un estado con independencia del título; elementos *nomen*, *tractatus* (el más importante) y *fama*. Arts. 423 (matrimonio), 584 (reconocimiento), 591 (límite a la negación) y 597 (adopción de mayores).
¿Cómo se prueba el estado civil?	Con las partidas del Registro Civil (instrumentos públicos de plena fe: nacimiento, matrimonio, defunción); supletoriamente por otros medios; art. 98 para la muerte cierta sin cadáver.

Resumen: El estado civil es la posición de la persona en la familia y la sociedad. Se discute mediante acciones de reclamación e impugnación, la posesión de estado tiene cuatro aplicaciones en el CCyC y se prueba con las partidas del Registro Civil, que son instrumentos públicos.

Parte VIII

La capacidad de la persona humana

Esta parte estudia la capacidad: el régimen general, el de las personas menores de edad y las restricciones a la capacidad de las personas con discapacidad, desde su marco convencional hasta los tipos de restricción, el proceso judicial, la validez de los actos y el sistema de apoyos.

Capítulo 29

La capacidad jurídica

La capacidad es el atributo que permite determinar qué aptitud tiene la persona para entablar relaciones jurídicas. Es el punto de partida del derecho civil porque define quién puede ser titular de derechos y quién puede ejercerlos por sí mismo, con incidencia en los contratos, las sucesiones, la representación judicial y la protección de menores y personas con discapacidad.

Un caso guía atraviesa el capítulo: una niña de corta edad hereda un inmueble de su padre fallecido. Es titular del derecho sobre el bien (capacidad de derecho), pero no puede ejercerlo por sí misma (carece de capacidad de ejercicio), por lo que la representan sus padres o un tutor. Si, ya adulta, un juez determinara que necesita apoyo para administrar bienes, se le designaría un asistente y no un representante. En todo el recorrido, el Ministerio Público vela por sus intereses.

29.1. Concepto de capacidad jurídica

La capacidad es una aptitud para entablar relaciones jurídicas que presenta dos componentes: uno de **derecho** (aptitud para ser titular de derechos y obligaciones) y otro **de hecho o de ejercicio** (aptitud para ejercer esos derechos). El Código los regula bajo el concepto común de **capacidad jurídica**.

Regla: Art. 22 CCyC: regla general de la capacidad

Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados.

La razón de fondo es existencial: si los seres humanos se desarrollan entablando relaciones jurídicas, negar esa aptitud equivaldría a impedirles satisfacer sus necesidades básicas y desplegar su personalidad. Ese despliegue requiere ser titular de derechos y deberes, comenzando por los derechos humanos, que no son concedidos sino reconocidos: libertad, libertad de contrato, libertad de asociación y otras libertades básicas.

29.1.1. Capacidad de derecho

Algunos autores identifican la capacidad de derecho con la condición de persona; un ser humano con incapacidad absoluta de derecho sería un muerto civil. Por eso se reconoce a toda persona; solo pueden existir limitaciones o privaciones —las llamadas incapacidades de derecho relativas— para ciertas circunstancias.

Importante

Las incapacidades de derecho son siempre **relativas**, se aplican a **actos puntuales** y se establecen para proteger el **interés general**. No pueden suplirse por medio de un representante y su violación genera **nulidad absoluta**.

29.1.2. Capacidad de ejercicio

Es la aptitud para desplegar y gozar los derechos por sí mismo; la clave es la actuación por sí. A diferencia de las limitaciones a la capacidad de derecho, las de ejercicio se establecen para **proteger a la propia persona**.

Ejemplo: Menor de edad

Un menor es incapaz de ejercicio no porque carezca de derechos, sino porque, por su inmadurez, se le proveen representantes y salvaguardias que lo tutelan en su vulnerabilidad.

29.2. Incapacidades de derecho: el artículo 1002

El ejemplo más ilustrativo son las inhabilidades para contratar.

Regla: Art. 1002 CCyC: inhabilidades para contratar

No pueden contratar en interés propio: los funcionarios públicos respecto de bienes cuya administración o enajenación está a su cargo; los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, árbitros, mediadores y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido; los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en que intervienen o han intervenido; los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí; los albaceas que no son herederos respecto de bienes de las testamentarías a su cargo.

La razón es de interés público: no se admite que el funcionario que administra un bien lo compre, que un árbitro adquiera los bienes en disputa o que un juez compre la casa en remate en su propio juzgado, pues habría conflicto de intereses.

Característica	Incapacidad de derecho	Incapacidad de ejercicio
¿A quién protege?	Al interés general o público	A la propia persona
¿Puede ser absoluta?	Nunca (siempre relativa)	Sí, en casos extremos (art. 32)
¿Se suple con representante?	No	Sí
Alcance	Actos puntuales determinados	Puede ser amplio
Regulación	A lo largo de todo el Código	Art. 24 y siguientes
Sanción por violación	Nulidad absoluta	Acto anulable (según el caso)

Cuadro 29.1: Incapacidad de derecho e incapacidad de ejercicio

29.3. Incapaces de ejercicio

Regla: Art. 24 CCyC

Son incapaces de ejercicio: a) la persona por nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2.ª de este Capítulo; c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.

Personas por nacer. Conforme al artículo 19, están concebidas hasta el nacimiento. Son personas, las representan sus padres (art. 101) y pueden recibir bienes, pero la adquisición de derechos patrimoniales queda sujeta al nacimiento con vida (art. 21), como se vio en el capítulo 23.

Personas menores de edad. Definida en el artículo 25 como quien no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, es por regla incapaz de ejercicio, pero adquiere una capacidad progresiva a medida que crece.

Importante

Desde que nace hasta los 18 años —mayoría de edad— la persona evoluciona. La representación que corresponde primero a sus padres (responsabilidad parental) decrece a medida que crecen sus aptitudes, hasta que se hace plenamente capaz.

El Estado reconoce a los padres autoridad para educar porque los considera en las mejores condiciones para criar a sus hijos; en casos muy graves pueden ser privados de la responsabilidad parental, pero la regla es que ellos representan al hijo.

Personas declaradas incapaces por sentencia (art. 32, último párrafo). Son casos excepcionales en que la persona está absolutamente imposibilitada de interaccionar

con su entorno y no puede expresar su voluntad de ningún modo, y el sistema de apoyo resulta ineficaz.

Regla: Art. 32, último párrafo, CCyC

Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.

El juez debe determinar en qué actos y funciones puede actuar la persona y se nombra un curador; son casos muy extremos, generalmente de discapacidad severa.

Ejemplo: Caso de Juana Fernández

Juana Fernández tiene 3 años; su padre fallece y es única heredera de un inmueble y dinero en una cuenta bancaria. Las decisiones sobre esos bienes no las tomará una niña de tres años: se nombra un tutor o representante. Los bienes están a su nombre (capacidad de derecho), pero no puede ejercer ese derecho por sí misma (capacidad de ejercicio); el tutor interviene en esto último.

29.4. Capacidad restringida y sistemas de apoyo

Este apartado presenta el régimen de restricciones en sus rasgos generales; su desarrollo completo se encuentra en los capítulos 31 a 34.

La persona con capacidad restringida es capaz de ejercicio, pero una sentencia judicial establece que ciertos actos no puede realizarlos sola y necesita apoyo. Es hoy prácticamente la regla del sistema, especialmente a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según la cual deben integrarse a la sociedad y pueden expresar sus preferencias aun necesitando apoyos.

Ejemplo: Restricción para actos patrimoniales

Una persona con discapacidad mental puede manejarse con pequeñas sumas pero no comprende el valor de un inmueble. El juez restringe su capacidad: en la vida cotidiana actúa libremente, pero para vender inmuebles necesita el apoyo de un familiar.

El apoyo no ocupa el lugar de la persona ni ejerce los derechos en su nombre: es un caso de **asistencia**, en el que concurren ambas voluntades, con las funciones que determina el juez. Si el apoyo advierte que se hace un mal negocio —por ejemplo, vender muy barato en un momento de caída de precios— puede negarse: existe para dar seguridad, aconsejar y evitar que se aproveche a quien no comprende bien el valor del dinero.

Aspecto	Representación	Asistencia (apoyos)
¿Para quién?	Incapaces de ejercicio	Personas con capacidad restringida
¿Quién actúa?	El representante, en nombre del incapaz	Ambos: persona y apoyo
Voluntad del titular	No es necesaria	Es necesaria y principal
¿Quién designa?	La ley o el juez	El juez (proceso específico)
Finalidad	Sustituir al incapaz	Acompañar y proteger

Cuadro 29.2: Representación y asistencia

29.4.1. Personas inhabilitadas (pródigos)

Regla: Art. 48 CCyC: inhabilitación por prodigalidad

Pueden ser inhabilitados quienes, por la prodigalidad en la gestión de sus bienes, expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Se considera que hay prodigalidad cuando, sin mediar razones atendibles, se dilapidan los bienes.

Iniciada la causa, se restringe la capacidad de la persona y se le nombran apoyos para la administración de sus bienes.

29.4.2. Representantes legales (art. 101)

Regla: Art. 101 CCyC

Son representantes: a) de las personas por nacer, sus padres; b) de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres y, si faltan, son incapaces o fueron privados de la responsabilidad parental, un tutor; c) de las personas con capacidad restringida y de las declaradas incapaces, los apoyos (cuando tengan representación) y el curador, respectivamente.

29.5. El Ministerio Público (art. 103)

Institución de fundamento constitucional, extrapoder, que en materia civil vela por los intereses de menores, incapaces y personas con capacidad restringida. Se divide en Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal; aquí interesa el primero. Es una protección complementaria: a los incapaces se les provee representante o asistente, pero además el Ministerio Público vela siempre por sus intereses.

Regla: Art. 103 CCyC

La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos, puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal.

Actuación	Cuándo	Ejemplo
Judicial complementaria	En todos los procesos con menores, incapaces o personas con capacidad restringida; se les da vista de las actuaciones, sin sustituir al representante.	En una sucesión con un heredero menor, de cada paso que toque sus intereses se da vista al asesor o defensor de menores e incapaces; la madre sobreviviente sigue siendo representante principal.
Judicial principal	Cuando los intereses están comprometidos y los representantes no accionan, para exigir a los representantes que cumplan sus deberes o cuando se carece de representante legal.	Un menor con un solo progenitor que no pasa alimentos: el Ministerio Público promueve el juicio. Una niña huérfana: actúa como si fuera el representante, sustituyendo a los del art. 101.
Extrajudicial	Extraordinaria; sin proceso, para preservar derechos económicos, sociales y culturales ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes.	Un niño expuesto a un ambiente de drogas y peligroso, con padres inactivos o promotores de la situación.

Cuadro 29.3: Formas de actuación del Ministerio Público

Capítulo 30

El régimen de capacidad de las personas menores de edad

Este capítulo estudia el régimen de capacidad de las personas menores de edad en el CCyC: los principios rectores que lo estructuran, los actos que la ley autoriza según la edad y las consecuencias y modos de finalización de la incapacidad de ejercicio. Es un contenido de aplicación directa en las áreas de familia, niñez y adolescencia, salud, contratos laborales y responsabilidad civil: determina qué puede hacer un menor por sí mismo, cuándo intervienen sus representantes y cuáles son los límites de esa representación.

Ejemplo: El recorrido de la capacidad progresiva

Los temas del capítulo pueden entenderse como un recorrido de menor a mayor autonomía. Juan nació sin capacidad de ejercicio y fue creciendo: a los 13 años pudo decidir sobre un tratamiento médico sencillo; a los 16 pudo trabajar, firmar contratos y cuidar su propio cuerpo como un adulto; al contraer matrimonio antes de los 18 años quedó emancipado, aunque con ciertas restricciones para proteger su patrimonio. Así se articula la tensión entre **autonomía y protección** que atraviesa todo el capítulo.

30.1. Régimen general

30.1.1. Menor de edad y adolescente

Regla: Art. 25 CCyC

Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Si hubiera cumplido 13 años, se la denomina adolescente.

La categoría de adolescente —el menor de entre 13 y 18 años— ha sido criticada por no constituir un concepto plenamente técnico, aunque está consagrada en el Código.

30.1.2. La incapacidad de ejercicio como medida de protección

El punto de partida es una **incapacidad de ejercicio**. No es una disminución de la persona: el menor es un sujeto con dignidad, titular de derechos y con aptitud para adquirirlos. Toda persona nace en una familia, y por eso el ordenamiento confía primero en los padres como representantes: ofrecen el ámbito de educación, crianza y contención necesario para el desarrollo.

Importante

La incapacidad de ejercicio **no es una sanción** ni una disminución de la persona: es una herramienta jurídica que **protege** al menor, supliendo su falta de madurez con la actuación de sus representantes legales.

Ejemplo: El niño de diez años que hereda un inmueble

No sabe el valor de las cosas ni cómo negociar un contrato; puede hacer un negocio que lo perjudique o ser abusado por personas inescrupulosas. Por eso se le designa un representante que actúe en su nombre.

El derecho contempla a la vez el **derecho a ser oído**: la relación entre padres e hijos presupone una manera de ir educando y llevando hacia la madurez a una persona necesariamente inmadura.

30.1.3. La mayoría de edad a través del tiempo

Período	Edad de mayoría	Norma
Código Civil histórico	22 años	Código de Vélez Sarsfield
Reforma intermedia	21 años	Modificación legislativa
Ley 26.579 (2009)	18 años	Ley 26.579
Código Civil y Comercial (2015)	18 años	Ratificado por el CCyC

Cuadro 30.1: Evolución de la mayoría de edad en la Argentina

Fijar la mayoría en 18 años mantiene coherencia con la Convención sobre los Derechos del Niño, que define como niño a todo ser humano hasta esa edad. Se advierte contra reducir la mayoría de edad con espíritu demagógico: bajarla implica también dejar de brindar alimentos al joven; por eso la ley dispuso que, aunque se sea mayor a los 18, en algunos casos debe continuar la provisión de alimentos mientras la persona se forma y no tiene trabajo independiente.

Nota

El régimen alimentario posterior a la mayoría extiende la obligación hasta los 21 años con carácter general, y hasta los 25 si el joven se encuentra en proceso de formación educativa o universitaria.

30.1.4. ¿Regla de capacidad o de incapacidad?

Existe debate. Un sector sostiene que, por aplicación de las convenciones internacionales, el principio sería la capacidad; otra parte relevante de la doctrina argentina entiende que la regla es la **incapacidad**, que va admitiendo una capacidad progresiva.

Regla: Art. 26 CCyC, primera parte

La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico.

30.2. Principios rectores (arts. 26 y 639)

El artículo 639, ubicado en la responsabilidad parental (Libro Segundo), enuncia tres principios:

Interés superior del niño. Tiene como fuente la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por la Ley 23.849 e incorporada con jerarquía constitucional por la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22 CN). La palabra «interés» remite a un valor objetivo: qué es lo mejor para ese niño.

Autonomía progresiva. A medida que el niño crece en madurez y edad, disminuye la representación de los padres y aumenta su capacidad de ejercer por sí sus derechos. Se empalma con el artículo 26: la autonomía va acompañada de autorizaciones legales que el ordenamiento otorga progresivamente.

Derecho a ser oído. Proviene del artículo 12 de la Convención y tiene su correlato en el artículo 26: ser oído en todos los asuntos de su vida y participar en las decisiones fundamentales sobre la conducción de su persona. Por ejemplo, en un divorcio con hijos menores se los escucha sobre dónde vivirán o a qué colegio asistirán.

30.2.1. Representación de los menores

Representante	Fuente legal	Carácter
Padres / progenitores	**Art. 101 CCyC; responsabilidad parental**	Principal y primario
Tutores	**Art. 101 CCyC**	Supletorio (a falta de padres, por fallecimiento, privación de la responsabilidad parental u otra causa)
Abogado del niño	**Ley 26.061**	Técnico, en juicio: asesora al niño ante un conflicto de intereses que sus progenitores no pueden representar
Ministerio Público	**Art. 103 CCyC**	Genérico: judicial o extrajudicial, principal o complementario

Cuadro 30.2: Sistema de representación del menor de edad

30.2.2. Grado de madurez suficiente

A veces la ley fija un límite de edad (por ejemplo, 10, 13 o 16 años); otras usa la fórmula amplia «grado de madurez suficiente», criticada por parte de la doctrina. Cuando la cuestión llega a un juez, este —con el asesoramiento de su equipo interdisciplinario— determina si el menor tiene la madurez exigida. Rivero critica esa indeterminación y sostiene que debería sustituirse por edades fijas; según las notas originales, existe un proyecto de reforma del CCyC elaborado por una comisión presidida por dicho autor que tiende a eliminarla.

30.3. Actos que la ley autoriza realizar según la edad

30.3.1. Tratamientos médicos (art. 26)

Regla: Art. 26 CCyC: tratamientos médicos

Desde los 13 años se presume que la persona menor de edad posee aptitud para decidir sobre tratamientos no invasivos o que no comprometan su vida o su salud. Si el tratamiento es invasivo y compromete su salud, se requiere la asistencia de la persona menor de edad y de sus padres; en caso de discordancia se decide con base en la opinión médica, teniendo en cuenta el interés superior. Desde los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para el cuidado de su propio cuerpo.

Edad	Tipo de tratamiento	¿Quién decide?
0 a 12 años	Cualquier tratamiento	Los padres (o tutores)
13 a 15 años	No invasivo / sin riesgo de vida	El propio menor (presunción de capacidad)
13 a 15 años	Invasivo / con riesgo de vida	Menor y padres (asistencia conjunta)
16 años en adelante	Cuidado del propio cuerpo	El adolescente, como adulto

Cuadro 30.3: Decisiones médicas según la edad

30.3.2. Resumen de actos permitidos

Desde temprana edad. Pequeños contratos de menor cuantía (art. 684): quien compra algo en el kiosco o en la librería celebra un contrato que no es nulo.

Desde los 13 años.

- Decidir sobre tratamientos no invasivos (art. 26).
- Iniciar una acción para conocer sus orígenes (art. 596).

- Reconocer hijos.
- Ejercer la responsabilidad parental, con la supervisión del artículo 644: los abuelos pueden intervenir en las cuestiones más trascendentes ante la inacción de los progenitores adolescentes y vetar decisiones contrarias al interés del niño.
- Participar en forma autónoma en juicio con autorización de sus progenitores (art. 677).

Desde los 16 años.

- Ser equiparado a los adultos en el cuidado del propio cuerpo (art. 26, *in fine*).
- Celebrar contrato de trabajo: la Ley 26.390, en clave con el Convenio de la OIT, prohíbe el trabajo de menores de 16 años en sus distintas formas; desde los 16 se presume que pueden celebrarlo con autorización de sus padres, o solos si viven de forma independiente.
- Ser donante de sangre con autorización de sus padres.

30.3.3. El título habilitante (art. 30)

Regla: Art. 30 CCyC

La persona menor de edad que obtiene un título habilitante de profesión puede ejercerla por cuenta propia, celebrar todos los actos que la profesión le exija y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiera con el producto de su trabajo.

Quien obtuvo a los 16 años el título de profesor de piano puede ejercer y administrar lo que gane. La doctrina discute el caso del menor de 16 años con título: un sector entiende que el artículo no distingue edad; otro, que quien pudo obtener el título —con validación del Ministerio de Educación y requisitos formales— ya demostró madurez suficiente para ejercer la profesión.

30.3.4. El matrimonio de personas menores de edad

Edad	¿Puede casarse?	Requisito
18 años o más	**Sí**	Ninguno adicional (regla general)
16 y 17 años	**Sí**	Autorización de los representantes legales; si la niegan, dispensa judicial
Menor de 16 años	**Eventualmente**	Siempre con dispensa judicial

Cuadro 30.4: Régimen matrimonial según la edad

30.4. Consecuencias jurídicas y fin de la incapacidad

30.4.1. Nulidad relativa de los actos celebrados sin representación

Si no se respeta el régimen y el menor actúa sin representación, el acto es de nulidad relativa, porque está puesta para proteger al menor; si el acto lo beneficia, los padres pueden confirmarlo; y solo el menor o sus representantes pueden alegarla, no la contraparte.

Ejemplo: El cuadro heredado

Una persona de 13 años heredó un cuadro valuado en 2.000 dólares y lo vendió en una plataforma en línea por 4.000. Sus padres, en lugar de anular el acto, lo confirmaron porque resultó un buen negocio.

30.4.2. Responsabilidad civil por daños causados por menores

Situación	Responde el menor	Responden los padres
Menor de 10 años, acto ilícito	No (acto involuntario)	Sí, siempre (objetiva)
Mayor de 10 años, acto ilícito	Sí, con su patrimonio	Sí, también (objetiva)

Cuadro 30.5: Responsabilidad por daños según la edad del menor

Los padres responden siempre, con responsabilidad objetiva fundada en el deber de vigilancia, aunque el menor de más de 10 años responda también con su propio patrimonio.

30.4.3. Fin de la incapacidad: la mayoría de edad

Importante

El día en que la persona cumple 18 años es automáticamente mayor de edad y plenamente capaz. No se requiere acto formal; basta acreditar la edad. Rige en el campo del derecho civil (contratos, familia, patrimonio) y no debe confundirse con la responsabilidad penal ni con el sufragio.

30.4.4. Fin de la incapacidad: la emancipación por matrimonio

La emancipación confiere anticipadamente la plena capacidad a un menor. El CCyC mantiene un único tipo. Históricamente existían la emancipación por habilitación de edad —entre los 18 y los 21 años, cuando la mayoría era a los 21— y la emancipación por matrimonio; al bajar la mayoría a los 18, la primera desapareció y queda solo la matrimonial.

Regla: Art. 27 CCyC: emancipación

La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este Código. La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio

no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien el matrimonio fue anulado.

30.4.5. Restricciones a la capacidad del emancipado (arts. 28 y 29)

Regla: Art. 28 CCyC: actos prohibidos, ni con autorización judicial

Las personas emancipadas no pueden: aprobar las cuentas de sus tutores ni darles finiquito; hacer donación de bienes que hubieran recibido a título gratuito; ser fiadores.

Fundamentos: el menor que tuvo tutor no puede aprobar sus cuentas hasta ser mayor (regla del art. 130); la prohibición de donar lo heredado proviene del Código de Vélez y evita que disponga de bienes cuyo valor no comprende cabalmente; la de ser fiador busca custodiar su patrimonio.

Regla: Art. 29 CCyC: disposición de bienes recibidos a título gratuito

El emancipado puede disponer de ellos a título oneroso (venderlos, no donarlos), pero requiere autorización judicial, que solo procede en caso de absoluta necesidad o ventaja evidente.

Ejemplo: El inmueble heredado por el emancipado

No puede venderlo libremente: solo con autorización judicial y si existe absoluta necesidad (como una operación médica urgente) o ventaja evidente (un gran negocio). El CCyC unificó el sistema eliminando la excepción del Código de Vélez que admitía prescindir de la dispensa cuando uno de los cónyuges era mayor de edad.

Acto	Artículo	¿Puede?	Condición
Aprobar cuentas del tutor	**28**	**No**	Nunca, ni con autorización judicial
Donar bienes recibidos gratuitamente	**28**	**No**	Nunca, ni con autorización judicial
Ser fiador	**28**	**No**	Nunca, ni con autorización judicial
Vender bienes recibidos gratuitamente	**29**	**Sí, con límites**	Autorización judicial: necesidad absoluta o ventaja evidente

Cuadro 30.6: Restricciones del emancipado

30.4.6. Mayoría de edad anticipada para egresados de institutos (Ley 27.364)

Estableció una mayoría de edad anticipada para adolescentes que egresan de institutos y no cuentan con cuidados parentales. La doctrina la criticó: por tratarse de adolescentes

sin cuidados parentales y provenientes de la institucionalización, podría funcionar como forma de abandono, aunque la ley contempla un programa estatal de protección.

30.5. Cuadro Cornell: la capacidad jurídica y el régimen de los menores

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué distingue la capacidad de derecho de la de ejercicio?	La de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y deberes (se reconoce a toda persona; sus limitaciones son siempre relativas, protegen el interés general y su violación causa nulidad absoluta). La de ejercicio es la aptitud para ejercerlos por sí; sus limitaciones protegen a la propia persona y se suplen con representante.
¿Quiénes son incapaces de ejercicio (art. 24)?	La persona por nacer, la que no tiene edad y madurez suficiente y la declarada incapaz por sentencia (art. 32, última parte, solo en casos extremos con curador).
¿Qué diferencia hay entre representación y asistencia?	En la representación el representante actúa en nombre del incapaz; en la asistencia, la persona con capacidad restringida actúa junto con su apoyo y su voluntad es necesaria.
¿Cómo actúa el Ministerio Público (art. 103)?	De forma judicial complementaria (vista), judicial principal (cuando falta o no actúa el representante) y extrajudicial (extraordinaria).
¿Qué principios rigen la capacidad de los menores?	Interés superior del niño, autonomía progresiva y derecho a ser oído (arts. 26 y 639).
¿Qué puede hacer un adolescente según su edad?	Desde los 13: tratamientos no invasivos, acción de orígenes, reconocer hijos; desde los 16: cuidado del propio cuerpo como adulto, trabajar, título habilitante (art. 30); matrimonio con autorización o dispensa.
¿Cómo termina la incapacidad y qué límites tiene el emancipado?	Por mayoría a los 18 años o emancipación por matrimonio (art. 27). El emancipado no puede aprobar cuentas del tutor, donar lo recibido gratuitamente ni ser fiador (art. 28) y necesita autorización judicial para vender lo recibido gratuitamente (art. 29).

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

Resumen: La capacidad se compone de capacidad de derecho (reconocida a todos) y de ejercicio (limitada para proteger a la persona), con representación, asistencia y Ministerio Público como mecanismos de protección. En los menores rige la autonomía progresiva: la incapacidad es una medida de protección que cede con la edad y la madurez, y termina con la mayoría de edad o la emancipación.

Capítulo 31

El marco convencional y los antecedentes del régimen de capacidad

31.1. Presentación del tema

Este capítulo y los tres siguientes reconstruyen el sistema de restricciones a la capacidad de las personas regulado en el Código Civil y Comercial argentino. Se aborda el contexto constitucional que ofrece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su artículo 12, los tres tipos de restricción que regula el código —capacidad restringida, incapacidad e inhabilitación por prodigalidad—, el procedimiento judicial que las rodea —legitimación, medidas cautelares, entrevista personal, dictamen interdisciplinario, sentencia, registro y revisión— y el sistema de apoyos que reemplaza, como criterio general, a la antigua representación absoluta.

Quien ejerza la abogacía —en un estudio, en un juzgado, en el Ministerio Público o en cualquier área que involucre contratos, sucesiones, salud o familia— tarde o temprano se encontrará con una persona cuya capacidad está restringida, o con la necesidad de evaluar si conviene promover esa restricción para proteger a alguien. Comprender este sistema permite redactar contratos que no terminen siendo nulos, asesorar correctamente a una familia que enfrenta el deterioro cognitivo de un mayor, intervenir con criterio en un proceso de determinación de la capacidad y, sobre todo, evitar dos errores opuestos: privar de autonomía a quien todavía puede decidir por sí mismo, o desproteger a quien necesita un apoyo real.

Estas reglas tampoco son ajenas a la vida cotidiana de las familias: un padre, una madre, un abuelo o un hermano pueden necesitar, en algún momento, ser acompañados con un apoyo para tomar decisiones. Entender este sistema ayuda a saber qué pedir, qué esperar de un juez y, fundamentalmente, cómo acompañar a esa persona sin sustituir su voluntad.

Nota

El sistema puede organizarse en cuatro bloques que se relacionan entre sí. El primero explica por qué existe una convención internacional que exige no apartar a la persona de la toma de decisiones, sino acompañarla mediante apoyos. El segundo distingue qué tipo de restricción corresponde a cada situación: una restricción limitada para quien conserva gran parte de su autonomía (capacidad restringida), una restricción más intensa para quien no puede en absoluto interaccionar con su entorno (incapacidad), o una limitación específica para quien administra sus bienes de manera perjudicial para su familia (inhabilitación por prodigalidad). El tercero regula el procedimiento judicial que debe seguirse, con las garantías correspondientes, para decidir si corresponde

imponer una restricción y de qué alcance. El cuarto explica qué sucede cuando una persona actúa en contra de lo dispuesto por la sentencia, cómo se recupera la plena capacidad y cómo funciona, en concreto, el sistema de apoyos que reemplaza a la antigua representación absoluta.

Al regular la capacidad jurídica se distingue entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Dentro de la capacidad de ejercicio, la regla siempre fue la capacidad, pero existen algunos casos de incapaces: las personas por nacer, las personas menores de edad —que van teniendo una capacidad progresiva— y todo el universo de situaciones en que se presenta alguna discapacidad por razones de salud mental. Es en este último campo donde se ubica el tema desarrollado en esta sección: la Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título Primero, Libro Primero del Código Civil y Comercial, que trata las restricciones a la capacidad.

Dentro de la capacidad de ejercicio la regla fue siempre la capacidad, con algunos casos de incapaces: las personas por nacer, las menores de edad —con capacidad progresiva— y el universo de situaciones de discapacidad por razones de salud mental. El régimen general de la capacidad y el de las personas menores de edad se estudian en los capítulos 29 y 30. El tema de este capítulo se ubica en la Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título Primero, Libro Primero del CCyC.

31.2. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)

Para entender el tema es necesario tener presente el contexto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención es del año 2006; la Argentina la ratifica en 2008 mediante la Ley 26.378.

Importante

Artículo 75, inciso 22 — Constitución Nacional. La jerarquía constitucional de ciertos tratados internacionales de derechos humanos se otorga mediante el procedimiento previsto en esta norma. En 2014, por este procedimiento, la CDPD obtuvo jerarquía constitucional, equiparándose a la primera parte de la Constitución Nacional (declaraciones, derechos y garantías).

En 2014 se le dio jerarquía constitucional: la Convención pasó a tener la misma jerarquía que la primera parte de la Constitución —las declaraciones, derechos y garantías—, incorporándose como uno de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

31.2.1. El artículo 12 de la CDPD: igual reconocimiento como persona ante la ley

El artículo clave de la Convención para este tema es el **artículo 12**, titulado «Igual reconocimiento como persona ante la ley». La Convención parte de reafirmar que las personas con discapacidad son seres humanos que deben gozar de igualdad de condiciones

y ser incorporadas e incluidas en la comunidad y en la sociedad, lo que supone superar barreras.

La discapacidad surge, según la Convención, de la interacción entre una deficiencia —que puede ser física, psíquica, sensorial o motriz— y una barrera que impide la plena incorporación de la persona. Esta idea de barreras que deben eliminarse resulta especialmente clara en la dimensión arquitectónica: las rampas obligatorias en las construcciones o la adaptación de los colectivos con rampa son un modo de superar la barrera que representa, por ejemplo, una escalera.

Junto con la noción de barreras a eliminar, la Convención introduce dos nociones fundamentales: los **apoyos** y los **ajustes razonables**.

Definición: Apoyo (noción convencional)

El apoyo consiste en brindar la ayuda necesaria para que la persona con discapacidad pueda integrarse por sí misma. Resulta fundamental en materia del ejercicio de la capacidad jurídica.

Definición: Ajuste razonable

Los ajustes razonables son las adaptaciones del procedimiento que permiten la plena integración y participación de la persona. Se encuentran, en el Código Civil y Comercial, en los artículos 35 y 36, referidos al proceso judicial vinculado con la capacidad. Por ejemplo, si se debe tomar una audiencia y la persona es sordomuda, corresponde disponer de un traductor de lenguaje de señas para que pueda entender lo que sucede y participar.

Importante

Artículo 12, inciso 1 — CDPD. Las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Importante

Artículo 12, inciso 2 — CDPD. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.

Sobre el alcance de la expresión «capacidad jurídica» en este inciso existen dos posturas: quienes entienden que se refiere solo a la capacidad de derecho (ser titular de derechos) y quienes sostienen que comprende ambas dimensiones —capacidad de derecho y capacidad de ejercicio—. Agustina Palacios y Francisco Bariffi son referentes argentinos en el estudio de la Convención; Palacios sostiene, en un capítulo de libro sobre el tema, que el concepto de capacidad jurídica del artículo 12, inciso 2, comprende tanto la capacidad de derecho como la de ejercicio, es decir, que corresponde partir de un principio de capacidad. El propio Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, creado por la Convención, sostiene la misma interpretación.

Importante

Artículo 12, inciso 3 — CDPD. Los Estados que han suscripto esta Convención deben garantizarle a las personas con discapacidad los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica.

La palabra «apoyo» constituye un concepto clave del sistema del nuevo código. Se trata de un concepto amplio, que involucra un conjunto de medidas: por ejemplo, una persona con discapacidad visual puede utilizar apoyos informáticos o perros guía. En este contexto, la referencia es más específica: apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, es decir, apoyos para la toma de decisiones.

Ejemplo: Apoyo para la venta de un inmueble

Una persona con discapacidad mental que es dueña de un inmueble y quiere venderlo puede recibir del juez la designación de un apoyo que la asesore y preste su conformidad, a fin de evitar que alguien se aproveche de la situación y le compre el bien muy por debajo de su valor. La decisión de vender sigue siendo de la persona; el apoyo la asiste en la toma de esa decisión.

Importante

Artículo 12, inciso 4 — CDPD (salvaguardias). Los Estados deben asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona; que estén libres de conflicto de intereses e influencia indebida; que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona; que se apliquen en el plazo más corto posible; y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial.

Las salvaguardias deben ser adecuadas y efectivas, y la medida que adopte un juez debe ajustarse a la persona concreta. En primer lugar, deben respetarse los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona; a diferencia de la Convención de los Derechos del Niño, aquí no aparece la noción de «interés superior», sino la de respeto de la voluntad y las preferencias.

Ejemplo: Respeto de la voluntad y las preferencias

Una persona dueña de un campo prefiere sembrar soja porque le gusta esa tarea. Si el apoyo designado considera más conveniente destinar el campo al ganado por rendir más, de todos modos debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona titular del campo.

Debe evitarse, además, todo conflicto de intereses o influencia indebida.

Definición: Conflicto de intereses e influencia indebida

El conflicto de intereses es un concepto más objetivo: existe, por ejemplo, cuando quien es designado apoyo de una persona es, a la vez, quien le alquila un inmueble que administra o sobre el que debe decidir. La influencia indebida es más difícil de

determinar, porque supone cierta manipulación de la voluntad de la persona, como puede ocurrir cuando quien ejerce una influencia decisiva convive con ella.

31.2.2. El Comité de la CDPD y el modelo de apoyo a la decisión

Una observación general del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del año 2014, señala que los Estados deben reemplazar los regímenes basados en la sustitución de decisiones —lo que habitualmente se conoce como representación, en la cual otra persona sucede a la titular en su lugar— por regímenes basados en el apoyo, de modo que la persona pueda decidir por sí misma. Esto es precisamente lo que instrumenta el nuevo código.

En definitiva, existe un delicado equilibrio entre autonomía y protección: la Convención tiende a enfatizar la autonomía, pero también prevé protecciones, de modo que corresponde articular ambos objetivos.

31.3. El régimen del Código Civil derogado: incapaces e inhabilitados

El código anterior, en su artículo 141, se refería a los incapaces. Eran declaradas incapaces de hecho las personas que, por demencia —también llamadas insanas—, padecieran una enfermedad mental que no les permitía administrar su persona ni sus bienes. Existían también los inhabilitados.

En su configuración posterior a la Ley 17.711, es decir, en la configuración inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del nuevo código, el ordenamiento contemplaba dos figuras.

31.3.1. Figura 1: los incapaces de hecho declarados judicialmente

También llamados insanos o interdictos, eran personas declaradas incapaces de hecho por la concurrencia de dos factores: uno biológico (la presencia de una enfermedad mental) y uno jurídico (la ineptitud para administrar su persona o sus bienes). Se les designaba un curador y eran, básicamente, incapaces.

31.3.2. Figura 2: los inhabilitados (artículo 152 bis)

El inhabilitado, en cambio, partía de un principio de capacidad y se le nombraba, por sentencia judicial, un curador con funciones delimitadas por esa sentencia. Se preveían tres supuestos:

- **Embriaguez habitual o uso de estupefacientes**, cuando exponían al otorgamiento de actos perjudiciales para el patrimonio o la persona —por ejemplo, alguien con alcoholismo que puede aprovecharse y vender bienes a bajo precio o regalarlos.

- **Disminución de facultades** que no llegara al supuesto de incapacidad del artículo 141, pero en la cual el juez estimara que podía producirse un daño a la persona o a su patrimonio.
- **Prodigalidad**: quienes, por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes, exponían a su familia a la pérdida del patrimonio. Este supuesto solo procedía si la persona tenía familia y había dilapidado ya parte de sus bienes; es el caso típico de la persona con ludopatía.

Nota

En el sistema del código anterior existían, en síntesis, dos grandes esquemas: el incapaz de hecho, totalmente incapaz y sujeto a curador, y el inhabilitado, capaz pero con restricciones puntuales, también sujeto a curador. En el inhabilitado la regla era la capacidad, con una excepción limitada a los tres supuestos mencionados.

31.4. La Ley de Salud Mental 26.657 y el artículo 152 ter

Dos años después de que Argentina aprobara la Convención, en 2010, se sancionó la Ley de Salud Mental (Ley 26.657), que incorporó al código anterior un artículo 152 ter con tres precisiones para el dictado de la sentencia de incapacidad o inhabilitación.

Importante

Artículo 152 ter — Código Civil (texto incorporado por Ley 26.657). Para declarar la incapacidad o la inhabilitación se requiere un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. La sentencia no podrá extenderse por más de tres años. La sentencia debe especificar las funciones y actos que se limitan.

Esta reforma constituyó un primer intento —parcial y no del todo coherente con el resto del sistema— de recoger los principios de la Convención, ya que la figura de la incapacidad y su regla general seguían existiendo. Sin embargo, la exigencia de que la sentencia especificara qué funciones y actos se limitaban anticipaba una idea central del nuevo código: que la regla es la capacidad y que corresponde precisar qué es lo que no puede hacerse. Pese a ello, en la práctica muchos jueces continuaron dictando sentencias que declaraban a la persona «incapaz para todos los actos de la vida civil».

31.5. Cuadro Cornell: el marco convencional y los antecedentes del régimen de capacidad

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué la CDPD cambió el paradigma de la capacidad jurídica?	Porque, a través de su artículo 12, reconoce la personalidad jurídica de las personas con discapacidad y su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, reemplazando el modelo de sustitución de decisiones (representación) por un modelo de apoyo a la toma de decisiones, que promueve la autonomía y respeta la voluntad y las preferencias de la persona.
¿Qué diferencia hay entre un apoyo y un ajuste razonable?	El apoyo es la ayuda que permite a la persona con discapacidad ejercer su capacidad jurídica y tomar decisiones por sí misma. El ajuste razonable es la adaptación del procedimiento judicial (por ejemplo, un intérprete de lengua de señas) que garantiza la accesibilidad y la participación efectiva de la persona en el proceso.
¿Cómo regulaba la capacidad el Código Civil derogado?	Mediante dos figuras: los incapaces de hecho (declarados por un factor biológico y uno jurídico, con curador) y los inhabilitados del artículo 152 bis (embriaguez o toxicomanía, disminución de facultades, o prodigalidad), que partían de la capacidad con restricciones puntuales y también tenían curador.
¿Qué cambios introdujo la Ley 26.657 antes del nuevo código?	Incorporó el artículo 152 ter, que exigió examen interdisciplinario para declarar incapacidad o inhabilitación, fijó un plazo máximo de tres años para la sentencia y obligó a especificar las funciones y actos limitados, anticipando el principio de que la regla es la capacidad.

Resumen: La CDPD, con jerarquía constitucional desde 2014, impone un modelo social de la discapacidad basado en apoyos y ajustes razonables, en reemplazo de la sustitución de la voluntad. El Código Civil derogado, incluso tras la reforma de la Ley 26.657, mantenía la incapacidad y la inhabilitación como ejes del sistema, con curadores en ambos casos; este es el punto de partida que el nuevo Código Civil y Comercial viene a transformar.

Capítulo 32

Tipos de restricciones a la capacidad en el Código Civil y Comercial

El nuevo Código Civil y Comercial regula el tema a partir de un concepto general de restricciones a la capacidad y de reglas generales aplicables a todos los supuestos.

32.1. Reglas generales del artículo 31

Importante

Artículo 31 — Código Civil y Comercial (reglas generales). La capacidad de ejercicio se presume, incluso cuando la persona se encuentra internada. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. La intervención estatal tiene carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de ella. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.

La regla general es la capacidad: se presume incluso cuando la persona está internada. Por ello, la internación en un establecimiento psiquiátrico no implica necesariamente una restricción a la capacidad; puede haber internación sin restricción, restricción sin internación, o ambas situaciones combinadas.

Las limitaciones a la capacidad son excepcionales y se imponen en beneficio de la persona. En materia de salud mental se parte de que todas las personas son capaces, y la sentencia judicial cumple un rol central porque delimita con precisión qué actos y funciones se limitan.

La intervención estatal debe ser interdisciplinaria. Las disciplinas que habitualmente intervienen son la psiquiatría, la psicología y el trabajo social: la psiquiatría, por tratarse de una especialidad médica, permite diagnosticar y prescribir tratamiento; la psicología aporta la comprensión de los dinamismos psíquicos y el bienestar integral; el trabajo social aporta información sobre el entorno de la persona, dado que la intensidad de la restricción puede variar según cuente o no con una red de contención familiar y social.

32.2. Personas con capacidad restringida (artículo 32, primer párrafo)

Importante

Artículo 32, primer párrafo — Código Civil y Comercial. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

La persona con capacidad restringida constituye el supuesto base del sistema. Se requiere, en primer lugar, sentencia judicial de restricción de la capacidad, en tanto la Convención establece que toda medida que afecte la capacidad de ejercicio debe ser dictada por una autoridad judicial independiente.

32.2.1. Requisitos del artículo 32

1. **Ser mayor de trece años.** Entre los 13 y los 18 años la regla es la incapacidad de ejercicio con capacidad progresiva; la sentencia dictada en esa etapa restringirá aquello vinculado con las atribuciones propias de un adolescente. Antes de los 13 años, el artículo 261 del código presume que la persona carece de discernimiento para los actos lícitos, por lo que no es necesaria una restricción judicial.
2. **Requisito intrínseco o biológico**: presencia de una adicción o de una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad. El código no precisa el término «adicción»; la doctrina tiende a interpretarlo a la luz del artículo 4 de la Ley de Salud Mental, que define la adicción como el consumo problemático de drogas, legales o ilegales. Una afición intrascendente —como cierta afición a una serie de televisión— carece de la gravedad necesaria para justificar la limitación de la capacidad. La «alteración mental permanente o prolongada», también de suficiente gravedad, refiere a una situación en la que la persona está afectada en su funcionamiento o en sus capacidades mentales, a los fines de un proceso judicial civil, y no debe confundirse con el certificado de discapacidad, que es un concepto distinto.
3. **Requisito extrínseco**: que del ejercicio de la plena capacidad pueda resultar un daño a la persona o a sus bienes. El código no contempla el daño a terceros; si existiera riesgo de daño a terceros, correspondería otra regulación —la de la responsabilidad civil— y, eventualmente, un supuesto de internación si el riesgo fuera cierto e inminente.

32.2.2. Régimen de las personas con capacidad restringida

Las personas con capacidad restringida son, como regla, capaces; la sentencia limita únicamente los actos y funciones específicamente indicados, debe ser proporcional y ajustada a la situación concreta de la persona. Se les designa un **apoyo** —y no un curador—, cuya modalidad de actuación fija el juez: puede tratarse de un apoyo cuyo consentimiento deba

concurrir junto con el de la persona, o de un apoyo de consejo. El artículo 101, inciso b, admite también el apoyo con funciones de representación, supuesto que la doctrina considera excepcional y que debe estar especialmente fundado, para no convertirse en una curatela con otro nombre.

Ejemplo: Apoyo con función de asistencia en la venta de un inmueble

Si a una persona con una adicción se le designa un apoyo con funciones de asistencia para la venta de su inmueble, al momento de celebrarse la escritura concurren el escribano, la persona con capacidad restringida y el apoyo, y ambos firman en el ámbito de su respectiva intervención.

32.3. Personas incapaces (artículo 32, último párrafo)

Importante

Artículo 32, último párrafo — Código Civil y Comercial. Excepcionalmente, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.

La incapacidad constituye un supuesto excepcional, no la regla. Un análisis de las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil durante los dos primeros años de vigencia del código mostró que los casos de capacidad restringida eran ampliamente mayoritarios frente a los de incapacidad, que resultaron poco frecuentes.

Se trata de casos muy severos: la persona no puede en absoluto entablar una relación con su entorno ni expresar su voluntad por ningún modo, medio o formato adecuado, y además el sistema de apoyos resulta ineficaz para asistirla. De no designarse un representante en estos supuestos extremos, la persona quedaría, como un «muerto civil», sin posibilidad de que se protejan sus derechos —por ejemplo, para participar en la asamblea de una sociedad anónima o para administrar bienes en caso de encontrarse en coma.

32.3.1. Régimen de las personas incapaces

La sentencia también debe establecer qué actos y funciones se limitan, aunque la limitación será mayor que en la capacidad restringida. Se designa un **curador** con funciones de representación, a diferencia del supuesto anterior, en el que se designaban apoyos. En el nuevo código, la figura del curador queda restringida a este supuesto excepcional del artículo 32, último párrafo.

32.4. Inhabilitados por prodigalidad (artículo 48)

Importante

Artículo 48 — Código Civil y Comercial. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos inhabilitados se les designarán apoyos. Solo podrán otorgar los actos de disposición entre vivos previstos en la sentencia con la conformidad del apoyo. De ser necesario, el juez puede ampliar la nómina de actos que requieren la conformidad del apoyo.

La denominación de «inhabilitados» proviene del código anterior, pero en el nuevo código queda restringida exclusivamente al supuesto de prodigalidad; los otros dos supuestos que antes contemplaba el artículo 152 bis —embriaguez o toxicomanía, y disminución de facultades— pasan a encuadrarse en la capacidad restringida.

Definición: Pródigo

Pródigo es quien derrocha sus bienes —no debe confundirse con «prodigio», que designa a alguien extraordinario en sus capacidades—. La figura no protege solo a la persona pródiga, sino también a su familia frente al riesgo de pérdida del patrimonio.

A diferencia del régimen anterior, que exigía la dilapidación efectiva de una parte del patrimonio, el artículo 48 no requiere que la dilapidación ya se haya producido: basta con que se ponga en riesgo la posibilidad de dilapidar el patrimonio.

32.4.1. Régimen de los inhabilitados

Las personas inhabilitadas son, como regla, capaces, pero tienen limitada la posibilidad de realizar actos de disposición de bienes —aquellos que impliquen enajenarlos— y los demás actos que fije la sentencia. Se les designan apoyos.

Ejemplo: El pródigo y la protección del patrimonio familiar

Ante una persona que dilapida bienes jugando en el casino, la familia puede iniciar la acción de inhabilitación; la sentencia puede disponer, por ejemplo, que para vender su automóvil o sus bienes registrables, o para hipotecar, necesite el consentimiento de su cónyuge. De ese modo se preserva el patrimonio familiar. Si la persona no tuviera familia, no podría ser declarada inhabilitada en estos términos.

32.5. Cuadro Cornell: tipos de restricciones a la capacidad en el Código Civil y Comercial

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Cuándo puede un juez restringir la capacidad de una persona?	Cuando la persona es mayor de trece años, padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, y del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes (art. 32, primer párrafo).
¿Por qué la incapacidad es hoy un supuesto excepcional?	Porque solo procede cuando la persona está absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno, no puede expresar su voluntad por ningún modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulta ineficaz; en la práctica, los casos de capacidad restringida resultan mucho más frecuentes que los de incapacidad.
¿Qué protege realmente la inhabilitación por prodigalidad?	Protege al cónyuge, conviviente o hijos menores o con discapacidad frente al riesgo de pérdida del patrimonio familiar por la mala gestión de los bienes de la persona pródiga, limitando sus actos de disposición y exigiendo la conformidad de un apoyo.

Resumen: El Código Civil y Comercial distingue tres figuras según la intensidad de la limitación: la capacidad restringida (la regla, con apoyos), la incapacidad (excepcional, con curador) y la inhabilitación por prodigalidad (protección patrimonial familiar, con apoyos). En todos los casos rige el principio general de capacidad del artículo 31.

Capítulo 33

El proceso de determinación de la capacidad

El Código Civil y Comercial incorpora normas de tipo procesal. Aunque se trata de un código de fondo —y los códigos de procedimiento corresponden a las provincias y a la Nación, cada una para su propio fuero—, el código incluye normas procesales que apuntan a dar una regulación común a una materia que afecta directamente la capacidad de una persona.

33.1. Juez competente y legitimados activos

33.1.1. Juez competente (artículo 36)

El juez competente para intervenir en un proceso de determinación de la capacidad es el del domicilio o el del lugar de internación de la persona. La jurisprudencia tiende a aplicar un principio de inmediatez: si la persona tiene domicilio en un lugar pero está internada en otro, suele resultar competente el juez más cercano al lugar de la internación.

33.1.2. Legitimados activos (artículo 33)

Importante

Artículo 33 — Código Civil y Comercial (legitimados para solicitar la declaración). Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida: a) el propio interesado; b) el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado; c) los parientes dentro del cuarto grado y, si fuera por afinidad, dentro del segundo grado; d) el Ministerio Público.

Una novedad del nuevo código es que el propio interesado puede iniciar el proceso; el código anterior no lo contemplaba. Esto cobra sentido, por ejemplo, cuando una persona a la que se le diagnosticó una enfermedad de deterioro cognitivo desea anticiparse y solicitar su propia restricción de la capacidad, proponiendo a alguien de su confianza como apoyo.

También puede solicitarlo el cónyuge, mientras no esté separado de hecho ni divorciado, y el conviviente. En torno al alcance del término «conviviente» existe cierta ambigüedad en el código, que la doctrina discute: si abarca a toda persona que convive o solo a quienes tienen una unión convivencial registrada; la interpretación parecería ser amplia.

Los parientes legitimados son los que se encuentran dentro del cuarto grado —quienes tendrían vocación hereditaria en caso de fallecimiento— y, si el parentesco es por afinidad, hasta el segundo grado. El código anterior admitía como legitimado a cualquier vecino

cuando la persona era considerada «furiosa» (peligrosa); esa posibilidad fue eliminada. Actualmente, quien no encuadre en los supuestos legitimados debe acudir al Ministerio Público (regulado en el artículo 103 del Código Civil y Comercial), que evaluará la situación y, en su caso, se presentará ante el juez para iniciar el proceso.

33.2. Medidas cautelares y entrevista personal

33.2.1. Medidas cautelares (artículo 34)

Importante

Artículo 34 — Código Civil y Comercial (medidas cautelares). Durante el proceso, el juez puede ordenar medidas de restricción al ejercicio de la capacidad, con el fin de garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. El juez debe determinar con precisión para qué actos se disponen estas medidas y designar los apoyos necesarios, o excepcionalmente el curador para el caso de los incapaces.

Durante el trámite del proceso la persona es, en principio, capaz; sin embargo, el juez puede disponer restricciones cautelares, siempre de manera excepcional y justificada, respetando los principios generales del artículo 31 y de la Convención, para atender situaciones de urgencia —por ejemplo, la designación de un apoyo para decisiones referidas a un inmueble o a un fondo de inversión mientras la persona atraviesa un problema de salud mental.

33.2.2. Entrevista personal (artículo 35)

Importante

Artículo 35 — Código Civil y Comercial (entrevista personal). El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente, antes de dictar resolución alguna. Debe asegurar la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel. El Ministerio Público y, al menos, un letrado que preste asistencia al interesado durante el proceso deben estar presentes en las audiencias.

Si bien la entrevista personal ya era una práctica habitual en algunos fueros desde hace décadas, el nuevo código la establece como exigencia general: antes de adoptar una decisión tan significativa, el juez debe conocer personalmente a la persona involucrada, garantizando accesibilidad y ajustes razonables.

33.3. La persona como parte y asistencia letrada

Importante

Artículo 36 — Código Civil y Comercial. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción a la capacidad ante el juez, éste debe nombrar un abogado que lo represente, si la persona afectada no tuviera letrado propio. En el caso de personas incapaces, también es necesaria la presencia del Ministerio Público.

El artículo 36 enfatiza que la persona interesada no puede quedar ausente de su propio proceso, situación que en ocasiones ocurría en el pasado. La persona reviste calidad de parte y tiene derecho a aportar pruebas; si carece de abogado propio, el Estado —normalmente a través del Ministerio Público— debe proveerle uno, cuya función es específicamente la representación judicial, distinta de la del apoyo o de la del curador.

33.4. Dictamen interdisciplinario y contenido de la sentencia

33.4.1. Artículo 37: el dictamen interdisciplinario

Importante

Artículo 37 — Código Civil y Comercial (dictamen e informe interdisciplinario). Para la declaración de incapacidad o de capacidad restringida es necesario el dictamen de un equipo interdisciplinario. El dictamen debe contener: 1) diagnóstico y pronóstico; 2) época en que se manifestó la situación; 3) recursos personales, familiares y sociales existentes; 4) régimen aconsejable para la protección y asistencia del interesado, con la mayor autonomía posible. Estos puntos deben reflejarse en la sentencia.

La Convención no exige literalmente un análisis interdisciplinario, pero de su espíritu se desprende que el examen no debe limitarse a lo médico, sino integrar distintos saberes. La interdisciplina implica que las disciplinas involucradas —psiquiatría, psicología y trabajo social— alcancen un conocimiento común, dentro de los límites de sus respectivas competencias profesionales.

El equipo interdisciplinario debe expedirse sobre el diagnóstico y pronóstico —distinguiendo, por ejemplo, una crisis psiquiátrica aguda de una situación permanente o de un deterioro cognitivo severo—; la época en que se manifestó la situación, relevante para la eventual anulación de actos anteriores conforme al artículo 45; los recursos personales, familiares y sociales existentes, que permiten conocer la red de apoyo natural de la persona; y el régimen aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible.

33.4.2. Artículo 38: el contenido de la sentencia

Importante

Artículo 38 — Código Civil y Comercial (alcance de la sentencia). La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, designa una o más personas de apoyo o curadores según el caso, y señala las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción indicando si la persona debe actuar con la asistencia o representación del apoyo o curador.

El artículo 38 concreta la personalización que exige la Convención: a diferencia del artículo 152 ter del código anterior, que resultaba desajustado respecto del resto del ordenamiento, en el nuevo código todo el sistema parte de la capacidad, y la sentencia se limita a precisar qué actos y funciones se restringen y con qué modalidad de apoyo.

33.5. Registro, revisión, internación y traslados

33.5.1. Registro (artículo 39)

La sentencia debe registrarse en el Registro de Estado Civil, anotándose al margen del acta de nacimiento. A partir de la inscripción se producen efectos frente a terceros: los actos posteriores a la inscripción que sean contrarios a lo dispuesto por la sentencia son nulos. Cuando se levanta la restricción, corresponde cancelar la anotación mediante oficio al Registro Civil.

Este registro plantea una tensión entre la protección de la intimidad —por tratarse de un dato altamente sensible— y la necesidad de dar publicidad suficiente, ya que quienes contratan deben poder conocer si su interlocutor tiene alguna restricción a la capacidad.

33.5.2. Revisión (artículo 40)

Importante

Artículo 40 — Código Civil y Comercial (revisión). La sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a tres años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado. Puede ser revisada en cualquier momento a instancia del interesado. El Ministerio Público debe fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión periódica establecida e instarla, si corresponde.

La revisión puede solicitarse en cualquier momento, pero no puede dejar de producirse por más de tres años. Corresponde un nuevo dictamen interdisciplinario, una nueva audiencia y una nueva sentencia; el Ministerio Público debe fiscalizar que el juez cumpla con esta obligación y, en su caso, instarla.

33.5.3. Internación (artículo 41) y traslados (artículo 42)

Importante

Artículo 41 — Código Civil y Comercial (internación). La internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad, procede solo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y se cumplen los requisitos de esta sección. En particular, la internación involuntaria solo es procedente cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros.

No es posible internar a una persona contra su voluntad si no existe riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para ella o para terceros. Este estándar, proveniente de la Ley de Salud Mental y ratificado por el nuevo código, busca evitar los abusos que en el pasado llevaron a internar a personas por carecer de vivienda o por resultar molestas; la internación involuntaria debe ser breve, acotada, orientada a la recuperación en un contexto de crisis y a la posterior reintegración, con supervisión periódica, debido proceso, control judicial y defensa —entre otros mecanismos, la Unidad de Letrados del artículo 22 de la Ley de Salud Mental, encargada de velar por los derechos de las personas internadas por razones de salud mental.

33.6. Cuadro Cornell: el proceso de determinación de la capacidad

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Quién puede iniciar un proceso de restricción de la capacidad?	El propio interesado, el cónyuge o conviviente no separado de hecho, los parientes dentro del cuarto grado (segundo grado por afinidad) y el Ministerio Público (art. 33).
¿Por qué el juez debe entrevistar personalmente al interesado?	Porque el artículo 35 exige inmediatez y entrevista personal antes de dictar cualquier resolución, garantizando accesibilidad y ajustes razonables, de modo que el juez conozca directamente a la persona antes de restringir su capacidad.
¿Qué garantiza que la persona no quede ausente de su propio proceso?	El artículo 36, que le reconoce calidad de parte, derecho a aportar pruebas y derecho a contar con un abogado —provisto por el Estado si no tuviera uno propio— que la asista específicamente en el proceso judicial.
¿Qué cuatro aspectos debe abordar toda sentencia?	Según el artículo 37, el dictamen y la sentencia deben contener: diagnóstico y pronóstico; época en que se manifestó la situación; recursos personales, familiares y sociales existentes; y régimen aconsejable para la protección y promoción de la mayor autonomía posible.
¿Cuándo es legítimo internar a una persona contra su voluntad?	Solo ante riesgo cierto e inminente de daño para la persona o para terceros, fundado en evaluación interdisciplinaria, con control judicial inmediato, asistencia letrada y revisión periódica (art. 41).

Resumen: El proceso de determinación de la capacidad está atravesado por garantías procesales: legitimación amplia pero acotada, medidas cautelares excepcionales, entrevista personal obligatoria, calidad de parte del interesado con asistencia letrada, dictamen interdisciplinario con contenido mínimo obligatorio, registro con efectos frente a terceros, revisión periódica no mayor a tres años, e internación involuntaria limitada al riesgo cierto e inminente.

Capítulo 34

Validez de los actos y sistema de apoyos

34.1. Nulidad de los actos posteriores y anteriores a la sentencia

34.1.1. Actos posteriores a la inscripción (artículo 44)

Importante

Artículo 44 — Código Civil y Comercial (actos posteriores a la sentencia). Son nulos los actos de la persona incapaz o con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia realizada con posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Si una persona sujeta a una sentencia que restringe su capacidad realiza un acto prohibido por esa sentencia, el acto es nulo. La nulidad es la sanción civil que deja sin efecto el acto y retrotrae la situación al estado anterior: si se entregó un inmueble, debe restituirse; si se entregó dinero, debe restituirse.

Ejemplo: Venta de un inmueble contraria a la sentencia

Una persona con discapacidad mental que vive de la renta de varias cocheras tiene una sentencia que exige el apoyo de un hermano o hermana para vender inmuebles. Si, sin ese apoyo, vende un inmueble y el escribano no advierte la restricción, el acto es nulo: la venta no produce efectos y las partes deben restituirse lo entregado.

Se trata de una nulidad relativa. Para que proceda, el acto debe ser posterior a la inscripción de la sentencia y contrario a lo que ella dispone. Si la sentencia solo restringe, por ejemplo, la venta de inmuebles, el consentimiento que la misma persona preste para una intervención quirúrgica —materia no alcanzada por la sentencia— es perfectamente válido.

34.1.2. Actos anteriores a la sentencia (artículo 45)

Importante

Artículo 45 — Código Civil y Comercial (actos anteriores a la sentencia). Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes requisitos: a) la enfermedad mental era ostensible al momento de la celebración del acto; b) quien contrató con ella era de mala fe; c) el acto fue a título gratuito.

Estos actos son, en principio, válidos, pero pueden anularse si concurre alguno de los requisitos del artículo 45. El dictamen interdisciplinario del artículo 37, al establecer la época en que se manifestó la situación, permite determinar si existían causales al momento de celebrarse el acto anterior.

Ejemplo: Contratante de mala fe

Un profesional de la salud que atiende a una persona con capacidad restringida y, conociendo su situación, le compra un inmueble a bajo precio, actúa de mala fe. Si, en cambio, el acto fue a título gratuito, no existe perjuicio patrimonial porque la persona no recibió contraprestación alguna.

34.2. Cese de las restricciones (artículo 47)

Importante

Artículo 47 — Código Civil y Comercial (cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad). El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme a las pautas del artículo 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento es total, el juez deja sin efecto la sentencia. Si el restablecimiento es parcial o el interesado solicita expresamente la revisión, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con la asistencia o representación de los apoyos designados.

Además de la revisión obligatoria del artículo 40, el interesado puede solicitar en cualquier momento el cese de la restricción, mediante el mismo procedimiento: un nuevo examen interdisciplinario conforme al artículo 37 (diagnóstico, pronóstico, época, recursos personales, familiares y sociales, y régimen aconsejable).

34.3. El sistema de apoyos (artículo 43) y conclusiones

Importante

Artículo 43 — Código Civil y Comercial (concepto de apoyo). Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

El código toma de la Convención la noción de apoyo como cualquier medida judicial o extrajudicial que facilite la toma de decisiones. El apoyo judicial es el que se designa en la sentencia; el apoyo extrajudicial resulta más difícil de precisar, porque toda persona recibe apoyos informales de quienes la rodean, sin que ello implique control judicial. La cuestión se presenta cuando el apoyo adquiere relevancia jurídica.

Ejemplo: Apoyo extrajudicial sin relevancia jurídica

Durante una situación de aislamiento, un vecino que hace las compras de una persona mayor que no puede salir —recibiendo el dinero, comprando y entregando la mercadería— presta un apoyo de hecho que no requiere control judicial, en la medida en que no involucre actos como vender un inmueble, comprar un automóvil o hipotecar una propiedad.

34.3.1. Salvaguardias: conflicto de intereses e influencia indebida

Para designar apoyos, el juez debe valorar la eventual existencia de conflicto de intereses e influencia indebida, dos mecanismos de salvaguarda previstos por la Convención para evitar abusos. El conflicto de intereses es más objetivo —por ejemplo, cuando quien administra un inmueble como apoyo es, a la vez, quien lo alquila—; la influencia indebida es más difícil de probar, porque supone cierta manipulación de la voluntad, situación que puede presentarse, por ejemplo, cuando una persona mayor con discapacidad mental convive con uno de sus hijos y los demás hijos consideran que existe manipulación.

34.3.2. Criterio de actuación de los apoyos

El criterio de actuación de los apoyos es el respeto de la voluntad y las preferencias de la persona, principio que surge directamente del artículo 12 de la Convención. El apoyo puede ser propuesto por la propia persona interesada. La posibilidad de que una persona jurídica actúe como apoyo se encuentra en discusión doctrinaria y no consta que exista jurisprudencia que la haya admitido respecto de la institución donde se encuentra internada una persona.

34.3.3. Conclusiones generales

El nuevo código se adapta a la Convención mediante conceptos y terminología propios de ella —apoyos, ajustes razonables, accesibilidad, autonomía, recursos personales y familiares—. Ratifica el criterio de la Ley de Salud Mental según el cual la regla es la capacidad y las limitaciones son excepcionales, por actos y funciones concretos. El sistema general es el de apoyos; se reconoce ampliamente el derecho de la persona a participar en el proceso y a ser escuchada; la sentencia debe revisarse periódicamente; y se consolida el criterio de intervención interdisciplinaria.

Subsiste, sin embargo, la cuestión de la incapacidad y de los supuestos de sustitución de la voluntad, en tanto se discute si esas formas de representación respetan plenamente la Convención. La doctrina mayoritaria entiende que no la vulneran, por tratarse de situa-

ciones absolutamente excepcionales en las que la persona no puede expresarse de ningún modo y en las que, de no designarse representante, quedaría sin protección jurídica alguna. A ello se suma que la persona conserva el derecho a participar y puede dejar directivas anticipadas —instituto recibido de manera limitada en el artículo 139, que permite a una persona señalar anticipadamente quién podría ser su curador ante la eventual pérdida de conciencia.

34.4. Cuadro comparativo: régimen anterior y régimen vigente

Situación	Código Civil derogado	Código Civil y Comercial vigente
Regla general	Incapacidad como eje del sistema; el inhabilitado era la excepción acotada a tres casos.	La capacidad es la regla; toda restricción es excepcional y se impone en beneficio de la persona (art. 31).
Figura de protección	Curador con función de representación, para incapaces e inhabilitados.	Apoyos para personas con capacidad restringida e inhabilitados; curador solo para incapaces (art. 32, último párrafo).
Intervención profesional	Evaluación médica (luego interdisciplinaria, desde el art. 152 ter de 2010).	Dictamen interdisciplinario obligatorio: psiquiatría, psicología y trabajo social (art. 37).
Duración de la sentencia	Sin plazo, hasta el art. 152 ter (2010), que fijó un máximo de tres años.	Revisión obligatoria cada tres años como máximo, o antes a pedido del interesado (art. 40).
Voz de la persona	No estaba prevista la entrevista personal obligatoria ni la condición de parte.	Entrevista personal obligatoria (art. 35) y la persona es parte del proceso (art. 36).
Sistema de apoyos	No existía el sistema de apoyos; solo representación a través del curador.	Sistema de apoyos como regla; respeto de la voluntad y preferencias de la persona (art. 43).

34.5. Cuadro Cornell: repaso general del régimen de restricciones a la capacidad

Este cuadro de repaso reúne las preguntas y conceptos clave desarrollados a lo largo de los cuatro bloques, pensado para el estudio activo previo a un examen.

Pregunta / concepto clave	Notas / respuesta / explicación
¿Qué jerarquía tiene la CDPD en Argentina?	Fue ratificada en 2008 (Ley 26.378) y en 2014 obtuvo jerarquía constitucional mediante el procedimiento del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, equiparándose a la primera parte de la Constitución.
¿Qué establece el artículo 12 de la CDPD?	Reconoce la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, su derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, la obligación estatal de garantizar apoyos para el ejercicio de esa capacidad y la exigencia de salvaguardias que respeten la voluntad, evitando conflictos de intereses e influencia indebida.
¿Cuáles son las reglas generales del artículo 31 del CCyC?	La capacidad se presume, incluso en caso de internación; las restricciones son excepcionales y en beneficio de la persona; la intervención es interdisciplinaria; hay derecho a información accesible y a asistencia letrada gratuita; y deben priorizarse las alternativas menos restrictivas.
¿Cuáles son los tres tipos de restricción a la capacidad del CCyC?	Personas con capacidad restringida (art. 32, primer párrafo, la regla), personas incapaces (art. 32, último párrafo, supuesto excepcional) e inhabilitados por prodigalidad (art. 48).
¿Qué requisitos exige el artículo 32 para restringir la capacidad?	Persona mayor de trece años; adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad; y que el ejercicio de la plena capacidad pueda causarle un daño a su persona o a sus bienes.
¿Cuándo corresponde declarar la incapacidad?	Solo cuando la persona esté absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno, no pueda expresar su voluntad por ningún modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz. Se designa entonces un curador con funciones de representación.
¿Qué protege la inhabilitación por prodigalidad?	Protege al cónyuge, conviviente o hijos menores o con discapacidad frente al riesgo de pérdida del patrimonio por la mala gestión de los bienes; limita los actos de disposición y exige la conformidad del apoyo para ciertos actos.
¿Quiénes están legitimados para pedir la restricción de la capacidad?	El propio interesado, el cónyuge o conviviente no separado de hecho, los parientes dentro del cuarto grado (segundo grado por afinidad) y el Ministerio Público (art. 33).

Pregunta / concepto clave	Notas / respuesta / explicación
¿Qué exige la entrevista personal del artículo 35?	Que el juez garantice la inmediatez con el interesado y lo entreviste personalmente antes de dictar cualquier resolución, asegurando accesibilidad y ajustes razonables del procedimiento.
¿Qué cuatro puntos debe contener el dictamen y reflejar la sentencia según el artículo 37?	1) Diagnóstico y pronóstico; 2) época en que se manifestó la situación; 3) recursos personales, familiares y sociales existentes; 4) régimen de protección y promoción de la mayor autonomía posible, sobre la base del dictamen interdisciplinario.
¿Cuándo es válida una internación involuntaria?	Solo ante riesgo cierto e inminente de daño para la persona o para terceros, fundada en evaluación interdisciplinaria, con control judicial inmediato, asistencia letrada y revisión periódica (art. 41).
¿Qué efectos produce un acto contrario a la sentencia?	Si es posterior a la inscripción de la sentencia, el acto es nulo (art. 44); si es anterior, puede anularse si la enfermedad era ostensible, hubo mala fe del contratante, o el acto fue a título gratuito (art. 45).
¿Qué es un apoyo según el artículo 43?	Cualquier medida judicial o extrajudicial que facilite a la persona la toma de decisiones para dirigir su vida, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos, promoviendo su autonomía y respetando su voluntad y preferencias.
¿Qué diferencia hay entre conflicto de intereses e influencia indebida?	El conflicto de intereses es objetivo y visible (el apoyo que administra un inmueble que él mismo alquila); la influencia indebida es más sutil y difícil de probar, porque supone una manipulación de la voluntad de la persona.

Pregunta / concepto clave	Notas / respuesta / explicación
Síntesis final:	El Código Civil y Comercial argentino adapta el sistema de restricciones a la capacidad al modelo social de la discapacidad consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Parte de un principio general de capacidad y reserva la restricción para casos excepcionales, debidamente fundados en un dictamen interdisciplinario y resueltos por sentencia judicial personalizada. Reconoce tres figuras —capacidad restringida, incapacidad e inhabilitación por prodigalidad— que se diferencian por la intensidad de la limitación y por la naturaleza de la figura de protección: el apoyo, que asiste sin sustituir la voluntad, o el curador, reservado a los casos más extremos de imposibilidad absoluta de interacción. Todo el procedimiento está atravesado por garantías procesales —entrevista personal, calidad de parte, asistencia letrada, revisión periódica— que buscan que la persona nunca quede ausente de las decisiones que la afectan. Finalmente, el sistema de apoyos del artículo 43, con sus salvaguardias contra el conflicto de intereses y la influencia indebida, condensa el espíritu de toda la reforma: acompañar para que la persona pueda decidir por sí misma, y proteger solo en la medida estrictamente necesaria.

Parte IX

El fin de la existencia de la persona humana

Así como la existencia de la persona humana comienza, también termina. Esta parte estudia el fin de su existencia por la muerte y las figuras que regulan la incertidumbre sobre su vida: la ausencia y la presunción de fallecimiento.

Capítulo 35

La muerte: fin de la existencia de la persona humana

35.1. Ubicación temática y relevancia práctica

La regulación civil de la persona humana comienza con el primer momento de su existencia —que en el ordenamiento argentino, en consonancia con las normas constitucionales, se sitúa en el momento de la concepción— y concluye con el fin de la existencia, es decir, con la muerte. El estudio de esta última etapa presenta dos grandes cuestiones: por un lado, la situación de la muerte propiamente dicha y su acreditación civil; por otro, el instituto de la presunción de fallecimiento, figura jurídica aplicable cuando una persona se encuentra ausente de su domicilio sin que se tengan noticias de ella durante el plazo fijado por la ley. En este capítulo se desarrolla exclusivamente el fin de la existencia por muerte comprobada; la presunción de fallecimiento se estudia en el capítulo 36.

Nota

Los distintos apartados de este capítulo se encuentran conectados entre sí. Ante el fallecimiento de una persona es necesario, en primer lugar, comprender qué es la muerte y cómo se comprueba. Cuando no se dispone de un cadáver, corresponde analizar cómo se acredita judicialmente el fallecimiento. Si dos o más personas fallecen simultáneamente, la conmoriencia determina las relaciones sucesorias entre ellas. Finalmente, la muerte produce consecuencias jurídicas concretas sobre el patrimonio y los derechos de la persona fallecida.

El fin de la existencia de la persona humana constituye uno de los pilares del derecho civil: el sistema de herencias, la donación de órganos, los registros civiles, los seguros de vida y las sucesiones dependen de determinar cuándo, cómo y con qué efectos jurídicos se produce la muerte. En el ejercicio profesional del derecho privado resulta indispensable gestionar partidas de defunción, iniciar sucesiones, asesorar a las familias en situaciones de presunción de fallecimiento, promover o impugnar declaraciones judiciales de muerte y conocer los límites de la transmisión hereditaria.

35.2. La muerte: concepto, comprobación y normativa

35.2.1. Principio general

El Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CCyC) establece el principio general que rige la finalización de la existencia de la persona humana:

Regla: Art. 93 CCyC — Principio general

La existencia de la persona humana termina por su muerte.

El Código Civil anterior contenía una disposición similar, aunque hacía referencia a la «muerte natural». El término «natural», en la redacción del Código de Vélez Sarsfield, no se oponía a «provocada» —como si una persona asesinada no muriera— sino que aludía a la muerte biológica y, fundamentalmente, procuraba excluir cualquier forma de muerte civil.

Nota

La muerte civil implicaba que el derecho consideraba muerta a una persona por el solo cumplimiento de determinada circunstancia —por ejemplo, una pena, o el ingreso a una comunidad religiosa, especialmente de votos solemnes, situación en la cual la persona «moría al mundo» para entrar en religión—. Esta institución nunca tuvo aplicación efectiva en el derecho argentino desde el Código Civil anterior, y el CCyC simplifica la cuestión disponiendo, sin más, que la existencia de la persona termina con su muerte.

35.2.2. ¿Qué es la muerte?

Definición: Muerte

Cese irreversible de las funciones corporales; fin de la unidad de cuerpo y alma. El momento exacto en que la muerte ocurre permanece, en gran medida, en el plano del misterio: el derecho civil no define en qué instante preciso se produce, sino que regula el modo en que se **comprueba** su acaecimiento, comprobación que siempre resulta posterior al hecho biológico en sí.

El momento exacto de la muerte de una persona resulta, por lo tanto, muy difícil de determinar. Aquello de lo que se ocupa el derecho civil es de su comprobación.

35.2.3. Comprobación de la muerte

Regla: Art. 94 CCyC — Comprobación de la muerte

La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver.

La comprobación de la muerte se realiza conforme a estándares médicos que van variando a lo largo del tiempo, a medida que avanza la ciencia, y que permiten detectar el cese irreversible de las funciones corporales —especialmente las cardiorrespiratorias y cerebrales, que son las que comandan el organismo humano.

Se habla de «comprobación» precisamente porque esta ocurre con posterioridad al hecho de la muerte. Lo que se obtiene es una certeza moral, no una certeza apodíctica: las certezas sobre la muerte se basan siempre en observaciones empíricas que, en principio, podrían tener alguna falla, pero que —con el acompañamiento de los estándares médicos—

se procuran hacer lo más rigurosas posible, de manera de no dejar duda alguna acerca del fallecimiento de la persona. De allí la confianza depositada en la intervención médica.

35.2.4. Instrumentos para acreditar la muerte

Regla: Ley 26.413 — Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas

Regula la forma en que deben ser expedidos el certificado médico de defunción y la partida de defunción. El certificado médico es expedido por un profesional de la salud siempre sobre la base de la presencia del cadáver. La partida de defunción es el instrumento público en el que consta el asiento en el registro civil, con la fecha, la hora y los demás elementos que rodean a la muerte.

La normativa distingue con claridad dos instrumentos:

Cuadro 35.1: Certificado médico de defunción y partida de defunción

Certificado médico de defunción	Partida de defunción
Expedido por un profesional de la salud	Instrumento público del Registro Civil
Siempre requiere la presencia del cadáver	No requiere la presencia del cadáver (se basa en el certificado)
Documento de base para inscribir la muerte	Constancia del asiento en el Registro del Estado Civil
Contiene fecha, hora y elementos que rodean la muerte	Regulada también por la Ley 26.413

35.3. Donación de órganos y criterios de muerte encefálica

35.3.1. Consentimiento presunto

Cuando una persona fallece sin haber expresado su voluntad respecto de la donación de órganos, la ley presume que es dadora.

Regla: Ley 27.447 (2018) — Trasplante de Órganos y Tejidos

Establece que cuando una persona fallece sin haber expresado su voluntad, se presume que es dadora de órganos. La negativa debe ser expresa, realizada ante los organismos señalados en la ley. El artículo 36 dispone que la muerte puede certificarse con la confirmación del cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas. El artículo 37 remite a un protocolo fijado por el Ministerio de Salud con asesoramiento del INCUCAI (Resolución 716/2019), estableciendo que la certificación debe ser realizada por dos médicos, uno de los cuales debe ser neurólogo o neurocirujano y no puede integrar el equipo de ablación.

Nota

La Ley 27.447 presume que toda persona es donante de órganos, salvo que haya expresado directamente una negativa ante los organismos señalados en la norma. Esta solución ha generado controversias, tanto por suprimir el rol de la familia en la decisión como por presumir una voluntad que, para algunos, debería quedar estimulada en lugar de presumida.

35.3.2. Antecedentes legislativos

Regla: Ley 21.541 (1977) — Primera ley de trasplantes

Definió el fallecimiento como la disfunción total e irreversible de las funciones encefálicas, verificada por un equipo médico. La reglamentación establecía los signos mínimos que debían presentarse en su totalidad.

Regla: Ley 24.193 (1993) — Ley de trasplantes anterior a 2018

Establecía que la muerte se constataba por: ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia; ausencia de respiración espontánea; ausencia de reflejos cefálicos; pupilas fijas no reactivas; e inactividad encefálica comprobada por medios técnicos o instrumentales (electroencefalograma plano y constante durante seis horas). No era necesario comprobar la inactividad encefálica en caso de paro cardiorrespiratorio total e irreversible.

Esta definición de la Ley 24.193 estuvo vigente entre 1993 y 2018.

35.3.3. Criterios actuales y Protocolo 2019

A partir de 2018, la ley opta por no incorporar en su texto una descripción tan detallada de los signos, remitiéndola a un protocolo. Se dispone que el fallecimiento de una persona puede certificarse con la confirmación del cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas —cualquiera de los dos supuestos, tanto el paro cardiorrespiratorio como el encefálico.

Importante

La palabra clave del criterio vigente es la **irreversibilidad**. Si existe la posibilidad de reversión —como ocurre con un paro cardíaco que puede revertirse mediante reanimación— no hay persona fallecida, sino una persona cuya función circulatoria puede ser terapéuticamente reanimada. El fallecimiento, en sentido propio, es un cese irreversible de las funciones.

Respecto de la certificación, el artículo 37 de la Ley 27.447 remite a un protocolo fijado por el Ministerio de Salud con asesoramiento del INCUCAI, concretado en la Resolución 716/2019. Dicho protocolo puede variar, en atención a la necesidad de actualización técnica de los medios biotecnológicos utilizados para el diagnóstico.

35.3.4. Garantías y críticas al régimen vigente

Importante

Un sector de la doctrina ha criticado el sistema vigente por no establecer en el propio texto legal algunas garantías mínimas —como las que preveía la ley anterior—, delegando en una reglamentación un hecho tan decisivo como la certificación de la muerte. Esta cuestión ha merecido discusión doctrinaria; no obstante, la ley mantiene como criterio decisivo el del cese irreversible de las funciones.

Para la profundización de este debate cabe remitir a los trabajos del Dr. José Tobías y del Dr. Carlos Muñiz, quienes han escrito ampliamente sobre la determinación del momento de la muerte.

35.4. Conmoriencia y prueba supletoria del fallecimiento

35.4.1. Conmoriencia

Regla: Art. 95 CCyC — Conmoriencia

Se presume que las personas que fallecen en un desastre común mueren al mismo tiempo. Salvo prueba en contrario, es una presunción iuris tantum.

Nota

A lo largo del tiempo han existido distintas tesis sobre la preeminencia —es decir, sobre quién moría primero, si los más jóvenes, los más ancianos, o de acuerdo con el sexo—. Los códigos civiles argentinos, ya desde la época de Vélez Sarsfield, establecen que todas las personas que se encuentran en esas circunstancias mueren al mismo tiempo, admitiéndose prueba en contrario.

Ejemplo: Accidente de tránsito

Fallecen el padre y el hijo en un accidente de tránsito; sobrevive la madre. Se supone que no existen otros herederos.
Si el hijo fallece **después** del padre: hereda del padre y, al morir el propio hijo, lo hereda la madre.
Si el hijo fallece **antes** que el padre: el padre, al morir, no tendría herederos directos, y serían sus propios ascendientes quienes heredarían.
Solución legal (Art. 95 CCyC): se presume que ambos fallecieron al mismo tiempo. No hay transmisión de derechos entre ellos, lo cual evita discusiones sobre quién murió primero y alteraciones en los órdenes sucesorios.

35.4.2. Prueba supletoria del fallecimiento

El segundo supuesto especial que corresponde analizar es el previsto en el artículo 98, segunda parte, del CCyC, que no debe confundirse con la presunción de fallecimiento.

Regla: Art. 98 CCyC — Prueba supletoria del fallecimiento

Cuando el cadáver no es hallado o no puede ser identificado, y la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe tenerse por cierta, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la correspondiente inscripción en el registro.

Para inscribir una muerte se requiere, en principio, un certificado médico. Sin embargo, cuando el profesional de la salud no dispone de cadáver alguno, o no puede identificarlo, dicha vía resulta imposible. Ante la certeza de que la persona ha fallecido, se habilita entonces un trámite judicial.

El criterio decisivo para optar por este artículo, en lugar de la presunción de fallecimiento, es la certeza:

Cuadro 35.2: Prueba supletoria (Art. 98) frente a la presunción de fallecimiento

Prueba supletoria — Art. 98	**Presunción de fallecimiento**
Hay **certeza** de que la persona falleció	Hay **duda o incertidumbre** sobre si falleció
Cadáver no hallado o no identificado	Persona ausente sin noticias durante el tiempo fijado por ley
Procedimiento judicial más breve	Procedimiento judicial mucho más largo
El juez ordena la inscripción de la muerte	Se declara presuntamente fallecida a la persona

35.4.3. Ejemplos desarrollados

Ejemplo: Avión que se desintegra en el aire (Art. 98)

Un avión de Air France que se desintegró en el aire (vuelo AF 447), o el avión de LAPA en el Río Uruguay que se desintegró en el aire: no hubo sobrevivientes, y resulta imposible que los hubiera habido. Ante ese hecho, se aplica el artículo 98 —prueba supletoria— porque existe certeza de que las personas fallecieron.

Ejemplo: Los Andes (presunción de fallecimiento)

El caso del avión de la película «Viven», cuyos pasajeros —uruguayos— caen en la cordillera de los Andes: no solo no se los encontraba, sino que tampoco se sabía si estaban muertos o no. No podía afirmarse que esas personas habían fallecido; correspondía, por lo tanto, aplicar la presunción de fallecimiento y esperar los plazos propios de ese instituto. De hecho, fueron encontrados a los tres meses.

Ejemplo: Alpinista en precipicio inaccesible (Art. 98)

Un alpinista cae en un precipicio de acceso imposible, acompañado por compañeros de montañismo que certifican que la persona llegó a ese punto, tuvo un problema, se resbaló y cayó, resultando imposible que haya sobrevivido e imposible acceder al

lugar. Con esos testimonios y las constancias del viaje puede realizarse la prueba supletoria: no corresponde permanecer en la incertidumbre, pues la persona falleció. El juez, teniendo por comprobada la muerte, dispone la inscripción en el registro.

35.5. Efectos jurídicos de la muerte

35.5.1. Efectos extrapatrimoniales

La muerte produce, en el campo extrapatrimonial, la extinción de los atributos de la persona: el nombre y la capacidad. Del domicilio subsiste el domicilio convencional —aquel que se elige para un contrato— que se transmite a los sucesores conforme al artículo 1024 CCyC. Se extingue el estado civil, pero subsisten los vínculos a los fines sucesorios: si existía cónyuge, y respecto del padre, la madre y los hijos, el parentesco se mantiene a esos efectos.

35.5.2. Protección jurídica post mortem

Se extinguen los derechos personalísimos, pero subsiste una protección jurídica sobre el honor de la persona fallecida, su intimidad y la inviolabilidad de sus papeles privados. Existe, asimismo, una protección jurídica del cadáver, orientada a que este sea tratado con dignidad.

Nota

El cadáver posee un estatuto especial: no es la persona ni es el cuerpo, pero constituye una prolongación de la persona, y por ello existe un cuidado de esta y de su memoria. La protección de la memoria de los difuntos se vincula también con su intimidad y con la inviolabilidad de sus papeles privados.

35.5.3. Efectos patrimoniales

En el campo patrimonial, los derechos patrimoniales de la persona fallecida se transmiten a sus herederos conforme a las reglas dispuestas por el CCyC, que pueden ser de dos tipos: testamentarias —cuando la propia persona ha determinado quiénes son sus herederos, existiendo porciones legítimas correspondientes a herederos forzosos sobre las cuales no puede disponerse, y una parte disponible según existan descendientes o solo ascendientes— o, en su defecto, ab intestato.

35.5.4. Derechos no transmisibles

Regla: Art. 1024 CCyC — Efectos de los contratos: sucesores

Las obligaciones que son inherentes a las personas no son transmisibles por causa de muerte.

Regla: Art. 2280 CCyC — Situación de los herederos

No se transmiten por sucesión los derechos que la ley dispone que no sean transmisibles.

No se transmiten, por tanto, los derechos que la ley dispone como no transmisibles. Un ejemplo de ello son las obligaciones inherentes a las personas, que no son transmisibles por causa de muerte.

Ejemplo: El pintor famoso

Se contrata a un pintor famoso para que realice el retrato de un familiar por cinco mil dólares. El pintor fallece. Su hija, también pintora, ofrece realizar el retrato en su lugar. La obligación no se transmite, porque era inherente a la persona —se habían considerado las cualidades específicas del pintor contratado— y su transmisión resultaría incompatible con la naturaleza de la obligación pactada.

Los derechos reales de usufructo y de habitación constituyen otros ejemplos típicos de derechos que no se transmiten por causa de muerte: por su propia constitución, se extinguen con la muerte del beneficiario. La muerte produce, por regla general, la transmisión de los derechos patrimoniales, con excepción de aquellos que no se transmiten.

35.6. Síntesis del capítulo

El capítulo ha desarrollado las cuestiones relativas al fin de la existencia de la persona humana: la muerte, su comprobación, el caso de la conmoriencia, la prueba supletoria del fallecimiento y los efectos jurídicos de la muerte.

35.7. Cuadro Cornell: la muerte

Cuadro 35.3: Cuadro Cornell — Fin de la existencia de la persona humana

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuándo termina la existencia de la persona? (Art. 93)	Con la muerte. El CCyC simplifica la redacción anterior eliminando la referencia a la «muerte natural» y la figura de la muerte civil, ya inexistente en el derecho argentino desde el Código de Vélez.
¿Qué es la muerte?	El cese irreversible de las funciones corporales. El momento exacto en que ocurre permanece en el plano del misterio; lo que el derecho regula es su comprobación posterior mediante estándares médicos.
Art. 94 — ¿Cómo se comprueba la muerte?	La comprobación queda sujeta a los estándares médicos aceptados, que evolucionan con la ciencia. Para la ablación de órganos rige la legislación especial (Ley 27.447 y Protocolo 2019).

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
Certificado médico vs. partida de defunción	El certificado médico es expedido por un profesional de la salud, siempre ante la presencia del cadáver, y constituye el documento base. La partida de defunción es el instrumento público del Registro Civil donde consta la inscripción de la muerte (Ley 26.413).
Ley 27.447 — ¿Todos somos donantes de órganos?	Sí, por presunción legal. Quien no quiera serlo debe expresar una negativa ante los organismos designados. Se eliminó el rol de la familia que existía bajo la Ley 24.193 (Arts. 36 y 37).
¿Qué exigía la Ley 24.193 (1993–2018) para la muerte encefálica?	Ausencia irreversible de respuesta cerebral; ausencia de respiración espontánea; ausencia de reflejos cefálicos; pupilas fijas no reactivas; encefalograma plano y constante durante seis horas. El paro cardiorrespiratorio total e irreversible eximía de la prueba encefálica.
Ley 27.447 — ¿cuál es el criterio actual de muerte?	Cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas. Los signos específicos y los plazos se remiten al Protocolo del Ministerio de Salud (Res. 716/2019), elaborado con el INCUCAI. Debe certificarlo un equipo de dos médicos, uno de ellos neurólogo o neurocirujano ajeno al equipo de ablación.
¿Qué es la conmoriencia? (Art. 95)	Presunción iuris tantum de que dos personas que fallecen en un desastre común mueren al mismo tiempo. Evita discusiones sobre quién murió primero y posibles alteraciones en los órdenes sucesorios; admite prueba en contrario.
Prueba supletoria del fallecimiento (Art. 98, segunda parte)	Procede cuando el cadáver no es hallado o no puede identificarse, pero existe certeza de que la persona falleció. Un juez —no un médico— ordena la inscripción de la muerte en el registro. Ejemplos: aviones desintegrados, alpinistas en precipicios inaccesibles.
Diferencia entre el Art. 98 y la presunción de fallecimiento	Art. 98: hay certeza de la muerte, el procedimiento es más breve y el juez ordena la inscripción. Presunción de fallecimiento: hay duda o incertidumbre, el procedimiento es mucho más largo y se declara «presuntamente fallecida» a la persona.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
Efectos extrapatrimoniales de la muerte	Se extinguen el nombre, la capacidad, el estado civil y los derechos personalísimos. Subsisten el domicilio convencional (para contratos), los vínculos familiares a fines sucesorios y la protección jurídica del honor, la intimidad y la inviolabilidad del cadáver.
Efectos patrimoniales de la muerte	Se transmiten a los herederos los derechos patrimoniales, conforme a las reglas testamentarias o ab intestato del CCyC, respetando las porciones legítimas de los herederos forzosos.
Derechos NO transmisibles por causa de muerte	Las obligaciones inherentes a la persona (intuitu personae) y los derechos reales de usufructo y de habitación (Arts. 1024 y 2280 CCyC). Ejemplo: si se contrata a un pintor famoso y este fallece, su hija no está obligada a cumplir ni tiene derecho a exigir el pago.

Resumen: El fin de la existencia de la persona humana se produce con la muerte, cuya única definición jurídica en el CCyC es el cese irreversible de las funciones corporales (Art. 93). Como ese momento exacto es de difícil determinación, el derecho regula su comprobación: en el caso ordinario, mediante el certificado médico de defunción —que exige la presencia del cadáver— y la posterior partida de defunción en el Registro Civil, ambos regulados por la Ley 26.413. Para la ablación de órganos, los criterios son más rigurosos y están regulados por la Ley 27.447 (2018) y el Protocolo del INCUCAI de 2019: basta el cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas, certificado por dos médicos, uno de los cuales debe ser neurólogo o neurocirujano y ajeno al equipo de trasplante. Bajo esta ley, toda persona es donante presunta salvo negativa expresa. Cuando dos personas fallecen en un desastre común sin poder determinarse quién murió primero, la conmoriencia (Art. 95) presume que ambas murieron simultáneamente, evitando distorsiones en los órdenes sucesorios. Si el cadáver no es hallado pero hay certeza de la muerte, el juez puede tenerla por acreditada y ordenar su inscripción mediante la prueba supletoria del Art. 98, que se distingue de la presunción de fallecimiento por la ausencia de incertidumbre. Finalmente, la muerte produce efectos extrapatrimoniales —extinción del nombre, la capacidad y el estado civil, con subsistencia de los vínculos familiares a fines sucesorios y protección jurídica post mortem del honor y la intimidad— y patrimoniales: transmisión del patrimonio a los herederos según las reglas del CCyC, con excepción de los derechos inherentes a la persona (usufructo, habitación, obligaciones intuitu personae), que se extinguen con la muerte del titular.

Capítulo 36

Ausencia y presunción de fallecimiento: marco conceptual e histórico

El fin de la existencia de la persona admite, además de la muerte comprobada, una vertiente de incertidumbre sobre su vida o su muerte, regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) mediante dos institutos diferenciados: la **ausencia** (arts. 79 a 84) y la **presunción de fallecimiento** (arts. 85 a 92). Los capítulos de esta sección tratan, sucesivamente, el marco conceptual e histórico, la ausencia, los tres casos de presunción de fallecimiento, el procedimiento y la sentencia, y las garantías y efectos de la reaparición.

Nota

Tarde o temprano resulta habitual encontrarse con un cliente cuyo familiar desapareció: un accidente en ruta, una catástrofe natural, o una persona que simplemente dejó de dar señales de vida. Saber distinguir la ausencia de la presunción de fallecimiento no es un detalle académico: es la diferencia entre proteger el patrimonio familiar desde el primer mes o perderlo por falta de acción.

Estos institutos permiten: (1) asesorar a herederos sobre cuándo y cómo iniciar acciones judiciales; (2) gestionar la curatela de bienes de personas desaparecidas; (3) representar acreedores que necesitan cobrar deudas pendientes; (4) intervenir en procesos sucesorios abiertos tras una declaración de fallecimiento presunto; (5) proteger los derechos del ausente ante una eventual reaparición, gestionando la prenotación registral.

En síntesis, estas reglas existen para que el derecho privado pueda dar una respuesta ordenada, justa y temporalmente acotada a uno de los dramas más dolorosos de la vida real: no saber si un ser querido está vivo o muerto.

¿Cómo se relacionan los temas? Puede pensarse el proceso como una escalada progresiva: si no se tienen noticias de una persona y sus bienes quedan desprotegidos, corresponde solicitar primero la **declaración de ausencia** (arts. 79 a 84) para que un curador los cuide. Si transcurren tres años sin novedades, puede iniciarse la **presunción de fallecimiento** (arts. 85 a 92), que abre la sucesión pero con garantías por si la persona reaparece. Todo el proceso protege tanto a quienes esperan como a quien podría volver.

36.1. Introducción: ausencia y presunción de fallecimiento

El fin de la existencia de la persona está regulado en el Código Civil y Comercial a través de dos figuras: la **ausencia**, por un lado, y la **presunción de fallecimiento**, por el otro.

Ausencia y presunción de fallecimiento son dos figuras distintas. Es habitual que se confundan bajo la expresión «ausencia con presunción de fallecimiento», lo cual no resulta exacto:

se trata de institutos diferentes. Por supuesto, la presunción de fallecimiento supone que existe una ausencia de la persona, pero lo que corresponde estudiar es, específicamente, por un lado la **ausencia** y por el otro la **presunción de fallecimiento**.

36.2. El problema jurídico de fondo

El problema jurídico de fondo puede formularse como la pregunta: ¿cuál es la respuesta jurídica ante la ausencia prolongada de una persona de su domicilio?

Esta cuestión ya encontraba explicación en el contexto de las guerras: la persona que quedaba cautiva y de la que no se sabía nada. ¿Qué sucedía con sus bienes? ¿Quién podía tomar medidas conservatorias? También pueden pensarse situaciones catastróficas más recientes: la desaparición de un avión, el tsunami que hubo en Tailandia a comienzos del año 2002, un incendio, o cualquier catástrofe en la que una persona desaparece y no se sabe si está viva o no.

Se produce una **incertidumbre**, y esa incertidumbre no puede durar eternamente, porque para el derecho civil existe una cantidad de relaciones y situaciones jurídicas que ameritan respuesta y toma de decisiones.

No existe una institución estatal que actúe de oficio ante la mera falta de contacto de una persona: este es un **sistema de derecho civil, de derecho privado**, en el cual los particulares que tienen algún tipo de interés en los bienes o en las relaciones jurídicas acuden a un proceso judicial, ya sea para declarar la ausencia o para declarar la presunción de fallecimiento.

Esto supone preguntarse: ¿cuándo se considera que una persona ha fallecido? ¿Cuándo resulta razonable asumirlo así? ¿Quién puede pedirlo? ¿Qué sucede si la persona reaparece? ¿Qué resguardos jurídicos se toman en el camino por si reaparece? Ese es el tema de fondo que estructura ambos institutos.

Importante

No debe confundirse la ausencia con la presunción de fallecimiento. Si bien están ubicadas inmediatamente una al lado de la otra en el Código Civil y Comercial, y tienen elementos comunes, son institutos distintos.

36.3. Antecedentes históricos

Los antecedentes de esta institución provienen del **Código de Vélez Sarsfield**, que regulaba la ausencia con presunción de fallecimiento en los artículos 110 a 625. La doctrina señala con claridad cómo en Vélez Sarsfield se produce una **confusión de elementos**:

Por un lado, existen antecedentes del **derecho germánico**, donde existía claramente el instituto de la declaración de muerte, que Vélez recibe a través de Freitas. Por el otro lado, el **derecho francés**, que no conocía esa declaración de muerte y simplemente regulaba la ausencia, sin poner fin a la existencia de la persona. Vélez también reconoce esta figura de la ausencia, de modo que el instituto queda regulado con elementos mixtos.

Tal como fue regulado por Vélez, la institución finalmente recibió críticas. En 1984 una ley ómnibus —una ley que reunía muchos temas en su contenido—, la **Ley 14.394**, reguló por un lado la ausencia y por otro lado la presunción de fallecimiento: dos instituciones distintas, clarificando y resolviendo lo que Vélez había planteado. El régimen de Vélez, entonces, quedó reemplazado por el sistema de la Ley 14.394.

Importante

CCyC — Estructura normativa actual. El nuevo Código Civil y Comercial deroga la Ley 14.394 en estas partes, pero sigue sus lineamientos e incorpora tanto la ausencia como la presunción de fallecimiento al articulado del Título I, Libro I:

- **Ausencia** — Capítulo 6, Arts. 79-84 (no implica fin de la existencia de la persona).
- **Presunción de Fallecimiento** — Capítulo 7, Arts. 85-92 (implica inscripción en el Registro Civil y apertura de la sucesión).

Metodológicamente, el CCyC los incorpora con muy pocos cambios respecto de la ley anterior.

Capítulo 37

La ausencia (arts. 79 a 84 CCyC)

37.1. Concepto de ausencia

La ausencia es una institución relativamente sencilla. Si la persona desapareció de su domicilio sin tenerse noticias de ella y sin dejar apoderado, o si el apoderado no tiene atribuciones suficientes, puede asignarse un **curador a los bienes**.

Definición: Ausencia

La ausencia, en el proceso del Art. 79 CCyC, no busca declarar a la persona presuntamente fallecida. Simplemente busca **garantizar la adopción de medidas sobre los bienes** de una persona de la que no se tienen noticias.

Ejemplo: ¿Qué NO es ausencia?

Si alguien quedó varado en Qatar durante la pandemia, se tienen noticias de esa persona: se sabe que está varada y que no puede regresar a su domicilio. Eso no configura una ausencia. La ausencia es la situación de la persona que desaparece, no se conecta a internet, no usa su tarjeta de crédito, no pasa por migraciones, no tiene registro en su correo electrónico, no tiene ningún tipo de actividad, y por lo tanto nadie de las personas conocidas tiene noticias de ella.

37.2. Legitimación y juez competente

Regla: Art. 80 CCyC — Legitimación activa

El Art. 80 establece quiénes pueden iniciar la acción: el Ministerio Público y las personas que tengan interés legítimo en los bienes (por ejemplo, los acreedores o los sucesores).

Respecto del juez competente:

Situación	Juez competente
Persona con domicilio en Argentina	Juez del domicilio
Sin domicilio en el país o lugar desconocido	Juez del lugar donde están los bienes que hay que cuidar
Bienes en distintas jurisdicciones	El primero que intervenga (principio de prevención)

Cuadro 37.1: Juez competente en el proceso de ausencia

37.3. Procedimiento y curatela

Se cita al ausente por **cinco días por edictos**. Los edictos son los avisos que se publican en el Boletín Oficial y en diarios de circulación importante, mediante los cuales se convoca a la persona a que se haga presente. Si no comparece, se le da intervención al **defensor oficial**, que interviene en representación del ausente, y pueden tomarse medidas precautorias para los bienes.

La prueba se orienta a demostrar que no hay noticias de esta persona: se libran distintos oficios, se solicitan testigos, y se determina si existe o no ausencia. El Ministerio Público procura defender al presunto ausente, evaluando la verosimilitud de la situación alegada.

Determinada la ausencia, se nombra un curador. El procedimiento del curador comprende actos de **conservación y administración de los bienes**. No puede realizar actos extraordinarios: no puede vender ni hipotecar un inmueble, porque en ese caso estaría comprometiendo el patrimonio. Los actos extraordinarios que resulten de necesidad evidente e impostergable requieren **autorización judicial**.

Los frutos —por ejemplo, la renta de un inmueble que se alquila— se destinan al **sostenimiento de los familiares del ausente**.

37.4. Conclusión de la curatela

La curatela concluye:

(a) Porque reaparece el ausente, personalmente o por apoderado.

(b) Porque se constata su muerte: ya sea porque aparece el cadáver y se hace la inscripción del fallecimiento y la correspondiente partida, o bien porque se declara el fallecimiento presunto judicialmente, instituto que se analiza a continuación.

Capítulo 38

La presunción de fallecimiento (arts. 85 a 92 CCyC)

El sistema del Código es igual al sistema de la Ley 14.394 y se estructura en torno a **tres casos**: un caso ordinario y dos casos extraordinarios —el extraordinario genérico y el extraordinario específico—.

38.1. Caso ordinario (Art. 85 CCyC)

Regla: Art. 85 CCyC — Caso ordinario

La persona que se ausenta de su domicilio sin que se tengan noticias de ella por el término de **tres (3) años**. Los elementos son: la ausencia sin noticias durante tres años. No hay ningún elemento particular adicional.

El plazo es de **tres años**. Esto se vincula con situaciones como, por ejemplo, una persona que desaparece —quizás víctima de un homicidio no resuelto— y de la que no se sabe bien qué pasó. Al cabo de tres años de incertidumbre, los familiares pueden solicitar su fallecimiento presunto.

No es obligatorio: el cumplimiento del plazo de tres años no impone iniciar el proceso de manera obligatoria. Esto se relaciona con la certeza de las relaciones jurídicas. Dado que en la mayoría de los casos se trata de un familiar y todo está rodeado de afectos y conmociones, hay quienes siguen buscando y pueden dejar pasar cinco o seis años. Lo que debe demostrarse en el proceso es que los supuestos legales se han cumplido.

Importante

La última noticia. El plazo de tres años —o el que corresponda según el caso— se cuenta desde la **última noticia** que se tuvo de la persona. Por ejemplo: si alguien cruzó por migraciones en una fecha determinada por el paso fronterizo de Paso de los Libres, esa es la última noticia que se tuvo. A partir de allí se cuentan los plazos.

38.2. Caso extraordinario genérico (Art. 86, 1.er párr.)

El caso extraordinario se denomina así porque acontece algún hecho que marca una **mayor probabilidad** de que haya habido un deceso de la persona. El caso genérico comprende situaciones de incendio, terremoto, acción de guerra u *otro suceso semejante*, o bien la participación de la persona en una actividad que implique el mismo riesgo.

Regla: Art. 86, 1.er párr. — Caso extraordinario genérico

Si la persona hubiese estado en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante susceptible de ocasionar la muerte, o hubiese participado de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tuviese noticias de ella durante **dos (2) años** desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

Ejemplo: Casos de extraordinario genérico

- El alpinista que estaba escalando el Aconcagua o el Everest y dejó de dar señales.
- El tsunami de Tailandia.
- Un incendio, un terremoto, una acción bélica.
- Cualquier suceso que resulte muy probable que haya provocado la muerte.

En este caso, el plazo se adelanta a **dos años**, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Por ejemplo, si se trata de un alpinista y el último día que consta en un registro que estaba subiendo fue el 10 de mayo de 2020, desde allí se cuentan los dos años.

38.3. Caso extraordinario específico (Art. 86, 2.do párr.)

El caso extraordinario específico es el supuesto más detallado por el Código: el de un **buque naufragado o aeronave perdida**. Aquí el acontecimiento resulta mucho más probable como causa de muerte, y el plazo es de **seis meses** desde que el suceso ocurrió o pudo ocurrir.

Regla: Art. 86, 2.do párr. — Caso extraordinario específico

Si el presunto fallecido estuvo en un buque naufragado o aeronave siniestrada o perdida, y no se tuviese noticias de su suerte durante **seis (6) meses** desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

38.4. Tabla comparativa de los tres casos

Tipo de caso	Artículo	Plazo	Circunstancia
Ordinario	Art. 85	3 años	Sin noticias
Extraordinario genérico	Art. 86, 1.er párr.	2 años	Catástrofe / actividad de riesgo
Extraordinario específico	Art. 86, 2.do párr.	6 meses	Buque naufragado / aeronave perdida

Cuadro 38.1: Comparación de los tres casos de presunción de fallecimiento

38.5. Casos reales ilustrativos

Ejemplo: Caso «Los Andes» (1972) — Aeronave perdida

En 1972, un avión militar uruguayo iba rumbo a Chile y cayó en la mitad de la cordillera de los Andes. Durante 72 días se buscó a sus ocupantes hasta que dos supervivientes lograron cruzar hacia el lado chileno y dieron aviso. Esas personas estuvieron desaparecidas durante 72 días. Si hubiera existido necesidad de declarar su fallecimiento, habría correspondido el caso extraordinario específico (buque/aeronave), por lo que hubiera sido necesario esperar seis meses. Como los encontraron antes de los 62 días, ese plazo no llegó a cumplirse.

Ejemplo: Caso Malaysia Airlines MH370 (2014) — Aeronave perdida

En 2014 desapareció un avión de Malaysia Airlines y nunca se supo con certeza dónde terminó. El último contacto se toma como fecha para contar los seis meses. Quien tuviera un familiar en ese vuelo debía esperar, como mínimo, seis meses desde ese último contacto para poder iniciar el proceso de presunción de fallecimiento bajo el caso extraordinario específico.

Capítulo 39

Procedimiento y sentencia de presunción de fallecimiento

39.1. Legitimación y juez competente

Regla: Art. 87 CCyC — Legitimación activa

Cualquier persona que tenga un derecho subordinado a la muerte puede pedir la declaración del fallecimiento presunto y debe justificar los extremos legales: la ausencia, la falta de noticias y las diligencias realizadas para averiguar la existencia del ausente.

El **juez competente** es el juez del domicilio del ausente. Si bien las normas procesales corresponden a cada provincia, en este caso el Código Civil y Comercial las incorpora para dar una **regulación común a todo el país**, evitando diferencias en el tratamiento de una situación muy delicada, ya que se está declarando fallecida a una persona para iniciar su sucesión.

39.2. Diligencias probatorias

Para justificar los extremos legales deben realizarse diligencias tendientes a averiguar la existencia del ausente, entre ellas:

- Oficios a distintas entidades.
- Pedido de informes a su tarjeta de crédito.
- Pedido de informes a su cuenta bancaria.
- Pedido a la empresa de telefonía celular.
- Pedido al club si es socio.
- Pedido a Migraciones para verificar entradas o salidas del país.
- Pedido de informe sobre actividad de su celular.

Se le nombra un **defensor al ausente** (o el defensor oficial). Se lo cita por **edictos una vez por mes durante seis meses**: se publican seis edictos, uno por mes. Se le nombra, asimismo, un curador de los bienes si no hay quien los esté administrando.

Importante

Aclaración del Art. 79 (ausencia simple) frente a la presunción de fallecimiento. El Código aclara que el hecho de haber tramitado previamente la simple ausencia (Art. 79) **no** es presupuesto necesario ni suficiente para la presunción de fallecimiento. Es decir: (a) puede iniciarse directamente la presunción de fallecimiento sin haber tramitado la ausencia previa; y (b) haber tramitado la ausencia no exime de tener que probar nuevamente, en el juicio de presunción de fallecimiento, que se han realizado todas las diligencias para dar con el ausente. Ambos procesos son independientes, aunque puedan darse en forma sucesiva.

39.3. Sentencia y día presuntivo de fallecimiento

Pasados los seis meses de citación, recibida la prueba y oído el defensor, el juez debe dictar sentencia. La sentencia contiene tres elementos:

1. Declara el fallecimiento presunto, comprobados que estén los extremos legales.
2. Fija el día presuntivo de fallecimiento.
3. Dispone la inscripción de la sentencia en el Registro Civil.

¿Cómo se fija el día presuntivo?

Caso	Día presuntivo	Ejemplo
Ordinario (Art. 85)	Último día del 1.er año = mitad del plazo de 3 años	Última noticia: 31/12/2017 → día presuntivo: 30/06/2019
Extraordinario genérico (Art. 86, 1.er párr.)	El día en que ocurrió el suceso (o el término medio si se extendió en el tiempo)	Si el incendio duró varios días: el día del mediodía del período
Extraordinario específico (Art. 86, 2.do párr.)	El último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave	MH370: último contacto = 8 de marzo de 2014 → ese es el día presuntivo

Cuadro 39.1: Fijación del día presuntivo de fallecimiento según el caso

El día presuntivo es de gran relevancia porque determina **quiénes son los herederos** que entran en la sucesión del presuntamente fallecido, declarado judicialmente. Si es posible, la sentencia debe determinar en qué hora presuntiva se fijó el fallecimiento; si no, se toma al final de ese día.

Capítulo 40

Garantías y efectos de la reaparición

40.1. Las tres garantías adoptadas

Con la declaración de fallecimiento presunto se abre la sucesión y los herederos pueden tomar los bienes. Pero el Código adopta **tres garantías** por si el ausente reapareciera:

Garantía	Descripción
Inventario	Se hace un inventario detallado de todos los bienes del presuntamente fallecido (el acervo sucesorio / masa hereditaria). En base a ese inventario, si reaparece, los herederos deben rendir cuentas de todos esos bienes.
Prenotación registral	Al transferir los bienes a nombre de los herederos (por ejemplo, un departamento a nombre de dos hijos), se hace una prenotación: se deja constancia en el asiento registral de que el bien está sometido al régimen de declaración de fallecimiento presunto.
Restricción para enajenar/gravar	Para enajenar (vender) o gravar (hipotecar) los bienes heredados, los herederos necesitan autorización judicial. La prenotación avisa a terceros contratantes de que ese bien está sometido a este régimen.

Cuadro 40.1: Las tres garantías del sistema ante una eventual reaparición

40.2. Duración de la prenotación (Art. 91 CCyC)

Regla: Art. 91 CCyC — Prenotación

La prenotación caduca a los **cinco (5) años** desde el día presuntivo del fallecimiento, o cuando la persona hubiera cumplido **ochenta (80) años** de edad, lo que ocurra primero. Vencida la prenotación, los herederos pueden enajenar libremente los bienes.

Importante

Son cinco años desde el **día presuntivo del fallecimiento**, no desde el día en que la persona desapareció, y no desde la fecha de la sentencia. Por eso el día presuntivo es tan relevante: es el que pone en marcha el plazo de prenotación.

40.3. Efectos de la reaparición (Art. 91 CCyC)

Si el ausente reaparece **antes** de que venza la prenotación: se le devuelven todos los bienes, porque el inventario asegura que se sabe exactamente con qué se empezó, y la restricción de enajenación junto con el requisito de autorización judicial protegieron el patrimonio.

Si el ausente reaparece **después** de vencida la prenotación (cuando ya los bienes podían enajenarse libremente):

- Se le entregan los bienes que aún existen.
- Se le entregan los bienes adquiridos con el valor de los que faltaron (subrogación real: por ejemplo, si se vendió un departamento y se compraron cuatro cocheras, se entregan las cuatro cocheras).
- Se le entrega el precio pendiente de cobro si se vendió un bien con saldo impago.
- Se le entregan los frutos no consumidos.

Ejemplo: Caso real: Oberá, Misiones (2011)

Una persona se metió al río Uruguay y desapareció; la buscaron por tierra y aire con helicópteros. Tiempo después, publicó en una red social una foto desde Curitiba, en la playa. Se armó un escándalo: resultó que había decidido hacerse «desaparecer» voluntariamente y fue descubierto con una nueva familia. Si esa persona hubiera tenido bienes y se hubiera iniciado la declaración, podría haber reaparecido y reclamado la devolución de lo que le correspondía.

Ejemplo: Caso real: Inglaterra — reaparición tras cinco años

Se conoció un caso en Inglaterra (noticias de diciembre de 2007) de una persona que había desaparecido y reapareció cinco años después. Si durante ese tiempo se hubiera declarado su fallecimiento presunto en Argentina, al reaparecer tendría derecho a que se le restituyeran los bienes —o su equivalente— conforme las reglas del Art. 91 CCyC.

40.4. Cuadro Cornell: ausencia y presunción de fallecimiento

El siguiente cuadro reúne, en formato Cornell, las preguntas y conceptos centrales desarrollados a lo largo de los capítulos anteriores, con el propósito de facilitar el repaso activo del material.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es la diferencia entre ausencia y presunción de fallecimiento?	La ausencia (Arts. 79-84) es una medida conservatoria de bienes: nombra un curador sin declarar fallecida a la persona. La presunción de fallecimiento (Arts. 85-92) declara judicialmente el fallecimiento, inscribe la sentencia en el Registro Civil y abre la sucesión. La presunción supone ausencia, pero no es lo mismo.
¿Quién puede pedir la declaración de ausencia?	El Ministerio Público y las personas que tengan interés legítimo en los bienes (acreedores, sucesores). El juez competente es el del domicilio del ausente; si no tiene domicilio en el país o es desconocido, el juez del lugar donde están los bienes.
¿Cuáles son los tres casos de presunción de fallecimiento?	1) Ordinario: ausencia sin noticias por 3 años (Art. 85). 2) Extraordinario genérico: persona involucrada en catástrofe o actividad de riesgo, plazo de 2 años (Art. 86, 1.er párr.). 3) Extraordinario específico: buque naufragado o aeronave perdida, plazo de 6 meses (Art. 86, 2.do párr.).
¿Cómo se fija el día presuntivo de fallecimiento?	En el ordinario: mitad del plazo (1 año y medio después de la última noticia). En el extraordinario genérico: el día en que ocurrió el suceso (o término medio si se extendió). En el extraordinario específico: el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave.
¿Cuáles son las tres garantías que protegen al ausente por si reaparece?	1) Inventario detallado de todos los bienes. 2) Prenotación registral en los asientos de los bienes. 3) Prohibición de enajenar o gravar sin autorización judicial. La prenotación dura 5 años desde el día presuntivo o hasta que la persona hubiera cumplido 80 años.
¿Qué pasa si el ausente reaparece después de vencida la prenotación?	Se le restituyen los bienes existentes, los adquiridos con el valor de los que faltaron (subrogación real), el precio pendiente de cobro y los frutos no consumidos. No puede recuperar bienes ya enajenados libremente por los herederos una vez caduca la prenotación.

Continúa en la página siguiente

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Es necesario haber tramitado la ausencia antes de iniciar la presunción de fallecimiento?	No. Según el Código, la declaración de ausencia (Art. 79) no es presupuesto necesario ni suficiente para la presunción de fallecimiento. Pueden tramitarse en forma sucesiva, pero en el juicio de presunción hay que probar nuevamente las diligencias para dar con el ausente.
¿Qué regula el CCyC sobre el procedimiento?	El CCyC incorpora normas procesales comunes para todo el país (citación por edictos una vez por mes durante 6 meses, defensor oficial del ausente, curador de bienes), para evitar diferencias entre jurisdicciones en situaciones de gran sensibilidad jurídica y personal.

Resumen: El derecho civil argentino responde a la incertidumbre generada por la desaparición de una persona mediante dos institutos diferenciados que conviven en el CCyC (Arts. 79-92). La **ausencia** (Arts. 79-84) es una herramienta de protección patrimonial preventiva: permite nombrar un curador de bienes y adoptar medidas conservatorias sin declarar fallecida a la persona. La **presunción de fallecimiento** (Arts. 85-92) va más lejos: declara judicialmente el fallecimiento, inscribe la sentencia en el Registro Civil y habilita la apertura de la sucesión. Se estructura en tres casos según el grado de probabilidad de muerte: el ordinario (3 años), el extraordinario genérico —catástrofes o actividades de riesgo— (2 años) y el extraordinario específico —buque o aeronave— (6 meses). La sentencia fija el día presuntivo, que determina quiénes son los herederos y desde cuándo corre la prenotación registral de cinco años. Durante ese período, los bienes no pueden enajenarse sin autorización judicial, garantizando la restitución al ausente en caso de reaparición. El sistema, con sus antecedentes en Vélez Sarsfield y la Ley 14.394, busca equilibrar la certeza jurídica que exigen las relaciones patrimoniales y sucesorias con la protección de los derechos del ausente, a quien siempre se le reserva la posibilidad de recuperar su patrimonio si regresa.

Parte X

El sujeto de la relación jurídica: las personas jurídicas

Junto a la persona humana, el ordenamiento reconoce como sujetos de derecho a las personas jurídicas. Esta parte estudia su concepto y naturaleza, el régimen de las personas jurídicas privadas, su responsabilidad civil, el fin de su existencia, las fundaciones y las asociaciones civiles y simples asociaciones.

Capítulo 41

Introducción a las personas jurídicas

Todo abogado, trabaje en derecho de familia, comercial, laboral, notarial o administrativo, se encuentra permanentemente con personas jurídicas. Saber identificar su tipo, leer su estatuto, comprender sus órganos de gobierno y conocer las reglas de responsabilidad es una habilidad transversal y cotidiana: desde redactar el estatuto de una ONG, hasta asesorar sobre la responsabilidad de los directivos de una sociedad anónima, gestionar la disolución de un consorcio o defender a una asociación civil en un proceso disciplinario. Este conocimiento también resulta útil en la vida cotidiana, dado que las personas se relacionan constantemente con personas jurídicas: el consorcio del edificio, el club al que se pertenece, la empresa en la que se trabaja, el Estado que regula.

Ejemplo integrador que guía la exposición: un grupo de vecinos forma un club de fútbol. Para ello necesitan constituir una persona jurídica. ¿Qué tipo eligen? ¿Qué nombre pueden usar? ¿Quién representa al club? ¿Pueden sancionar a un socio? ¿Qué pasa si el club se disuelve? Cada capítulo de esta parte responde a una de estas preguntas: el primero trata el concepto, la naturaleza y la clasificación; el segundo, el régimen de las personas jurídicas privadas; el tercero, su responsabilidad civil; el cuarto, el fin de su existencia y las fundaciones; y el quinto, las asociaciones civiles y simples asociaciones.

41.1. Presentación del tema

El estudio del régimen de las personas jurídicas en el derecho civil y comercial se sitúa dentro de la Parte General del Código, que se ocupa de los elementos de la relación jurídica: el sujeto, el objeto y la causa. Habiendo estudiado a fondo la persona humana, corresponde ahora tratar la persona jurídica, es decir, los entes colectivos que entablan también relaciones jurídicas en el campo del derecho privado.

41.2. El problema de fondo: la asociatividad humana

El problema central que resuelve esta regulación es cómo dar tratamiento jurídico a la asociatividad, dado que el ser humano es un ser sociable por naturaleza que tiende a unirse con otros para fines útiles. Esa regulación jurídica es fundamental porque permite establecer con qué requisitos esos entes colectivos, morales o ideales pueden entablar relaciones jurídicas: qué tipos de personas jurídicas existen, cuándo hay personalidad, cuáles son sus atributos, cuándo empieza y cuándo finaliza su existencia, y qué consecuencias tiene.

Estas personas jurídicas apuntan muchas veces a facilitar la organización de la vida cotidiana: desde el Estado como organización política que trasciende a los ciudadanos y tiene

una personalidad distinta a la de estos, hasta las sociedades, las mutuales, las cooperativas y las iglesias.

Nota

Existe un tipo de persona jurídica de enorme trascendencia económica, las sociedades, que tiene su materia específica (el Derecho Societario); el Estado también tiene la suya (el Derecho Administrativo). En esta materia se estudian las grandes disposiciones generales del Código Civil y Comercial aplicables a todas las personas jurídicas.

41.3. Regulación en el Código de Vélez (Ley 340, 1871)

Nota

Código de Vélez — artículos relevantes.
Art. 30: «Todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones son personas».
Art. 31: Las personas se clasifican en personas físicas (o de existencia visible) y personas jurídicas (o de existencia ideal).
Art. 32: Las personas jurídicas son definidas por exclusión: son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no son personas de existencia visible.
Arts. 33 a 50: Régimen general de las personas jurídicas.

41.4. El nuevo Código Civil y Comercial: metodología

El nuevo Código regula la materia de forma más organizada y sistemática. El Libro Primero, la Parte General, comienza con un Título Primero sobre la persona humana, y el Título Segundo trata de las personas jurídicas.

Dentro de los seis libros del Código, en el Libro Primero:

- Persona humana: artículos 19 al 140.
- Personas jurídicas: a partir del artículo 141.

El Título Segundo sobre personas jurídicas se divide en:

- Capítulo 1: Parte general (personalidad, composición y clasificación).
- Capítulo 2: Asociaciones civiles y simples asociaciones.
- Capítulo 3: Fundaciones.

Nota

El nuevo Código adopta la denominación única de «persona jurídica», diferenciándose del Código anterior, que hablaba de «persona de existencia ideal» y «persona jurídica». Antes de la Ley 17.711 (1968) se discutía si el género era la persona de existencia ideal

y la persona jurídica una especie; con dicha reforma se tendió a equipararlos. Otras denominaciones usadas en doctrina son «personas morales» o «personas colectivas».

41.5. Definición del artículo 141 del CCyC

Definición: Persona jurídica (art. 141 CCyC)

Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

Esta definición presenta dos características destacables:

1. **Se define por la positiva**: se incorpora como elemento al ordenamiento jurídico, que es quien confiere la aptitud. Esto marca la diferencia con las personas humanas, cuya personalidad es un dato de la naturaleza reconocido —no concedido— por el legislador.
2. **Se incorpora el elemento finalista**: la aptitud está orientada al cumplimiento del objeto y los fines de la creación. Este es el fundamento del principio de especialidad.

41.6. Principio de especialidad

A diferencia de la persona humana, que puede dedicarse a cualquier actividad lícita, las personas jurídicas tienen un objeto y un fin propios. El **principio de especialidad** significa que la persona jurídica, dentro de su posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, está acotada a sus fines, a su especialidad, a su objeto, y a aquello para lo cual fue constituida.

Importante

Artículo 156 CCyC — Objeto. El objeto de la persona jurídica privada debe ser preciso y determinado.

Esto resulta especialmente relevante para la redacción de los estatutos: los constituyentes deben ser claros, explícitos y descriptivos sobre cómo piensan lograr sus fines y cuál es el objeto de la persona jurídica.

41.7. Teorías sobre la naturaleza jurídica

41.7.1. Teoría de la ficción (Savigny)

Savigny recoge elaboraciones que provenían del derecho canónico y desarrolla la idea de la ficción. Para esta teoría, la persona humana es la única dotada de voluntad; como para Savigny el derecho es una expresión de la voluntad, no existirían propiamente personas jurídicas, sino un artificio creado por el legislador, que puede ser ampliado o restringido, pero que carece de voluntad propia.

Importante

Consecuencia fundamental de la teoría de la ficción: la persona jurídica no respondería por los daños causados —responderían solo las personas humanas—, y como se trataría de una representación con mandato, este mandato nunca podría ser conferido para el ilícito. Esto dio lugar a situaciones injustas y, con el tiempo, se modificó esta posición. El artículo 43 del Código de Vélez, en su redacción original, sostenía esta posición: las personas jurídicas no respondían por los daños causados por quienes las dirigían o administraban.

41.7.2. Teorías negatorias de la personalidad

Niegan que existan propiamente personas jurídicas. Sostienen que lo que existe son patrimonios de afectación o bienes colectivos, pero no algo que pueda llamarse persona jurídica.

41.7.3. Teorías de la realidad

Buscan encontrar un sustrato real detrás de lo que se llama persona jurídica:

- **Teoría organicista**: la persona jurídica sería como un organismo vivo, con sus mecanismos de adopción de la voluntad (los órganos que la gobiernan). Existe una realidad que el legislador viene a tutelar, proteger y regular.
- **Teoría de la institución** (Hauriou, seguida en Argentina por Llambías): las personas jurídicas son instituciones. Una institución requiere tres elementos: (a) una idea, objeto o fines en torno a los cuales se nuclean personas; (b) un sustrato personal, es decir, las personas que se nuclean en torno a esa idea; y (c) un poder u organización que permite llevar adelante esos fines.

41.7.4. Teorías normativistas (Kelsen)

Las personas jurídicas son un centro de imputación de normas: una realidad a la que el derecho le asigna consecuencias jurídicas a través de normas dictadas por la autoridad competente.

Nota

En el Código Civil y Comercial vigente se percibe una fuerte presencia de las teorías normativistas —el ordenamiento jurídico es quien confiere la aptitud—, pero también existe una dimensión institucional, en tanto se reconocen realidades organizativas como las simples asociaciones.

41.8. Clasificación: personas jurídicas públicas y privadas

El Código Civil y Comercial simplifica la clasificación entre públicas y privadas.

41.8.1. Personas jurídicas públicas (arts. 146 y 147)

Definición: Personas jurídicas públicas (art. 146 CCyC)

Son personas jurídicas públicas:

a) El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones a las que el ordenamiento jurídico les atribuya ese carácter.

b) Los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica (como la ONU) y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable.

c) La Iglesia Católica.

La inclusión de la Iglesia Católica con personería jurídica pública se vincula con el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, en virtud de la preeminencia histórica de la Iglesia antes de la constitución del Estado argentino.

En cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento y organización, las personas jurídicas públicas se rigen por sus propias leyes y ordenamientos. Así, por ejemplo, si se litiga contra el Banco Central, habrá que revisar su Carta Orgánica y las leyes que lo regulan.

41.8.2. Personas jurídicas privadas (art. 148)

El artículo 148 enumera los tipos de personas jurídicas privadas.

Cuadro 41.1: Tipos de personas jurídicas privadas (art. 148 CCyC)

Tipo	Característica principal	Ley aplicable
Sociedades	Finalidad directa de lucro. Los socios participan en ganancias y pérdidas.	Ley 19.550
Asociaciones civiles	No tienen fin de lucro. Unión de personas para un fin común (cultural, deportivo, social, etc.).	Arts. 168–186 CCyC
Simples asociaciones	Similar a la asociación civil, pero sin autorización estatal para funcionar.	Arts. 187–192 CCyC
Fundaciones	Patrimonio afectado por uno o varios fundadores a un fin de bien común. Sin miembros.	Arts. 193–224 CCyC
Iglesias y comunidades religiosas (no católicas)	No tienen fin de lucro. Libertad de culto y conciencia.	Ley 21.745
Mutuales	Ayuda mutua entre sus miembros. Socorros recíprocos.	Ley 20.321
Cooperativas	Asociación de personas para fines comunes de producción, trabajo o consumo.	Ley 20.337
Consorcios de propiedad horizontal	Conjunto de propietarios de unidades funcionales de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal.	Art. 2044 CCyC

Nota

El artículo 149 establece que, si el Estado participa en una persona jurídica privada, ello no modifica el carácter privado de esta, aunque puede haber derechos y obligaciones diferenciadas en razón del interés público comprometido.

41.9. Ley aplicable (art. 150)

Regla: Ley aplicable a las personas jurídicas privadas (art. 150 CCyC)

Las personas jurídicas privadas se rigen:

1.°) Por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;

2.°) Por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia;

3.°) Por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este Título.

El estatuto tiene fuerza de norma jurídica. Por ello, siempre que se aborde una cuestión en la que interviene una persona jurídica, lo primero que corresponde hacer es leer su estatuto en su última versión, con todas las modificaciones, y también sus reglamentos.

41.10. Personalidad diferenciada e inoponibilidad (art. 144)

Un presupuesto fundamental es que la persona jurídica es distinta de sus miembros. Esto implica distintos patrimonios, distintas responsabilidades, y la posibilidad incluso de que el propio miembro demande a la persona jurídica o viceversa.

Importante

Regla general: los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica. Esta es una de las diferencias más importantes que debe considerar quien constituye una persona jurídica: responde con el capital que aporta, pero no con todo su patrimonio personal.

Definición: Inoponibilidad de la persona jurídica (art. 144 CCyC)

La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, que constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

Esta norma reconoce como antecedente el artículo 54 de la Ley de Sociedades (Ley 19.550), pero ahora se aplica a todo el sistema de personas jurídicas por estar ubicada en la Parte General.

La inoponibilidad significa que los efectos de la personería no pueden hacerse valer frente a quien ha sido dañado, quien puede accionar directamente contra los socios, asociados, miembros o controlantes que hicieron posible esa actuación dañina. Responden solidaria e ilimitadamente: todos responden por el todo y con todos sus patrimonios.

Capítulo 42

Régimen de las personas jurídicas privadas

El Código ofrece reglas generales sobre nombre, domicilio, capacidad, patrimonio, estatutos y comienzo de la existencia, que luego cada tipo de persona jurídica complementa con sus normas específicas.

42.1. Nombre (art. 151)

Definición: Nombre de la persona jurídica (art. 151 CCyC)

La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre. El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.
No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres, ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica.
Si se incluye el nombre de personas humanas, deben contar con la conformidad de estas, que se presume si son socios. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso si acreditan perjuicios materiales o morales.

Los requisitos pueden precisarse del siguiente modo:

- **Indicación de la forma jurídica**: debe agregarse el tipo de persona jurídica (por ejemplo, «El estudiante feliz S.A.»). Si está en liquidación, se agrega «en liquidación».
- **Veracidad**: concordancia entre el nombre y el objeto, para que no haya lugar a confusión. Esto se juega especialmente en ciertos ámbitos, como el de las universidades.
- **Novedad y aptitud distintiva**: el nombre debe distinguirse de otros nombres, marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes y servicios.

Ejemplo: Teatro Colón S.A.

No se puede fundar una sociedad anónima con el nombre «Teatro Colón S.A.» porque se confundiría con el Teatro Colón preexistente. El nombre no tendría novedad ni aptitud distintiva.

Ejemplo: Fundación Lionel Messi / Fundación Borges

Si se quiere usar el nombre de una persona humana, se necesita su conformidad. Si esa persona ya falleció, los herederos pueden oponerse si acreditan perjuicios materiales o morales. Así, si la Fundación Borges —supuestamente dedicada a las altas letras— organizara un concurso de letras de reggaetón, los herederos de Borges podrían oponerse alegando que ello afecta el buen nombre del escritor y resulta incompatible con los fines fundacionales.

42.2. Domicilio y sede social (arts. 152 y 153)

El domicilio es el asiento jurídico de la persona jurídica y permite ubicarla, determinar el juez competente y conocer su inscripción registral.

Cuadro 42.1: Domicilio y sede social

Domicilio	Sede social
Se fija en el estatuto. Puede expresarse simplemente con una ciudad (por ejemplo, «Buenos Aires»). Determina el juez competente y la jurisdicción registral.	Es la dirección física concreta donde tienen lugar la dirección y administración de la persona jurídica (por ejemplo, «Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA»). Generalmente se inscribe ante el organismo de contralor (IGJ). Si está en el estatuto, cambiarla requiere modificar el estatuto.

Importante

Artículo 153 CCyC — Efectos de la sede social. Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.

También existe el domicilio especial: cuando la persona jurídica posee establecimientos o sucursales, tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, pero solo para las obligaciones allí contraídas.

Ejemplo: Sucursal del Banco Santander en Mendoza

Si un contratista de pintura firmó un contrato con la sucursal mendocina del Banco Santander y este no le paga, puede litigar en Mendoza. No necesita ir a Buenos Aires a litigar contra la casa matriz, porque la obligación se contrajo localmente.

42.3. Capacidad y principio de especialidad (arts. 141, 156)

La persona jurídica es capaz de derecho; la capacidad de ejercicio se realiza a través de sus órganos representativos. Pero esa capacidad tiene límites:

1. **Principio de especialidad**: la capacidad está acotada al objeto y a los fines de la persona jurídica.
2. **Limitaciones legales**: la ley prohíbe a las personas jurídicas adquirir ciertos derechos o los limita. Por ejemplo, el usufructo en favor de personas jurídicas tiene un plazo determinado, mientras que para personas humanas puede extenderse hasta su muerte.
3. **Limitaciones por la naturaleza de las cosas**: las personas jurídicas no pueden adoptar niños, porque el derecho de familia se refiere a las personas humanas.

42.4. Patrimonio (arts. 143 y 154)

La persona jurídica debe tener un patrimonio distinto del de sus miembros. Esto es una consecuencia directa de la personalidad diferenciada.

La persona jurídica tiene bienes a su nombre; si se trata de información registrable, se pueden inscribir preventivamente. Por ejemplo, si alguien dona un inmueble a una fundación y esta tarda en inscribirse, puede realizarse una anotación preventiva en el registro para proteger el bien mientras se completan los trámites.

Nota

En cuanto a su duración, las personas jurídicas son en principio ilimitadas en el tiempo, excepto que el acto constitutivo disponga lo contrario. La prórroga está regulada en el artículo 165 y requiere decisión de los miembros o aprobación de la autoridad de contralor antes del vencimiento del plazo.

42.5. Comienzo de la existencia (art. 142)

Definición: Comienzo de la existencia (art. 142 CCyC)

La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.

En el Código anterior existía una discusión sobre si el comienzo de la existencia era el momento de la constitución o el de la autorización. El nuevo Código es claro: el comienzo es la constitución. Sin embargo, si la ley requiere autorización estatal para funcionar (como en el caso de las fundaciones), la persona jurídica no puede comenzar a operar hasta obtenerla.

Ejemplo: Fundación banco de alimentos

Si hoy se constituye una fundación con objeto de banco de alimentos y se aporta un capital de $100.000, la fundación existe desde ese momento. Pero no puede empezar a hacer compras, emitir facturas ni hacer donaciones hasta que se obtenga la autorización estatal. La constitución y la autorización son dos momentos distintos.

42.6. Estatutos y gobierno (arts. 150, 158, 159, 160)

El estatuto es una norma jurídica secundaria que emana de las partes que constituyen la persona jurídica y que la regula internamente. No debe confundirse con el acto constitutivo:

- El **acto constitutivo** es el acto jurídico por el cual las partes deciden dar inicio a la persona jurídica. Generalmente, en ese acto se redacta el estatuto.
- El **estatuto** cobra independencia porque puede sufrir sucesivas modificaciones a lo largo del tiempo.

Nota

Hay clubes que tienen más de cien años y cuyo estatuto ha cambiado muchísimas veces. Cuando se solicita el estatuto ante la Inspección de Justicia, se pide el actualizado con todos sus cambios.

42.6.1. Contenido del estatuto

El estatuto de una persona jurídica privada debe contener:

- Nombre y domicilio.
- Objeto preciso y determinado (art. 156).
- Derechos y deberes de los miembros.
- Forma de gobierno: composición de los órganos, cómo se toman las decisiones, quórum y mayorías necesarias (incluidas las agravadas para decisiones trascendentes, como reforma del estatuto, expulsión de miembros o disolución).
- Atribuciones de cada órgano y sus miembros.
- Administración de bienes.
- Destino de los bienes en caso de disolución.

42.6.2. Deber de lealtad y diligencia de los administradores (art. 159)

Importante

Artículo 159 CCyC — Deber de lealtad y diligencia. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación tuvieran un interés contrario al de ella, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o, en su caso, al órgano de gobierno, y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación.

Ser administrador de una persona jurídica implica una gran responsabilidad, porque se confían bienes económicos que no son propios.

Capítulo 43

Responsabilidad civil de las personas jurídicas

43.1. Evolución histórica: del artículo 43 de Vélez al nuevo Código

El Código de Vélez Sarsfield, adherente a la teoría de la ficción, establecía en el artículo 43 que las personas jurídicas no respondían por los daños que causaban quienes las dirigían o administraban: no se podía iniciar una acción de daños y perjuicios contra una persona jurídica.

La lógica era coherente con la teoría de la ficción: como la personería era solo ficción y el mandato nunca se confería para el ilícito, las actuaciones ilícitas se imputaban a las personas humanas, no a la persona jurídica. A lo largo del tiempo, esta solución fue generando la sensación de que constituía una injusticia.

Existieron distintas posturas doctrinarias para resolver el problema. Un profesor de apellido Rivarola acudió al diccionario que empleaba Vélez y encontró que, en el texto original de Freitas (en portugués), el término utilizado podía entenderse como «cuando» y no como «aunque», lo que cambiaría el sentido de la norma; sin embargo, esta interpretación no fue pacífica. El jurista Borda, en un fallo, llegó a declarar que el artículo 43 era de una injusticia intolerable.

Importante

Todo cambió en 1968 con la Ley 17.711, que reformó el artículo 43 y estableció que la persona jurídica responde por los daños que causen quienes la dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones. El nuevo Código recoge esta solución en el artículo 1763.

43.2. Tres supuestos de responsabilidad

43.2.1. Responsabilidad por actos de directivos y administradores (art. 1763)

Regla: Responsabilidad de la persona jurídica (art. 1763 CCyC)

La persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

La expresión «en ejercicio o con ocasión de sus funciones» resulta determinante: si un presidente de la empresa está de vacaciones y comete un daño, la empresa no responde, porque el acto no ocurre en ejercicio ni con ocasión de sus funciones.

43.2.2. Responsabilidad por cosas y actividades riesgosas (art. 1757)

Regla: Hecho de las cosas y actividades riesgosas (art. 1757 CCyC)

Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.

Esta norma se aplica a todas las personas, incluidas las jurídicas. Se trata de una responsabilidad objetiva: no depende de factores de atribución subjetivos (dolo o culpa); la responsabilidad se atribuye siempre.

Ejemplo: Sociedad anónima y accidente de tránsito

Una sociedad anónima tiene un automóvil. Ese auto causa un daño. La persona jurídica responde, aunque no estuviera manejando: se le imputa la responsabilidad porque es dueña de la cosa riesgosa.

43.2.3. Responsabilidad por los dependientes (art. 1753)

Regla: Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente (art. 1753 CCyC)

El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas.

También esta norma engloba a las personas jurídicas. El término «dependientes» es genérico: incluye a cualquier persona de la que la persona jurídica se sirve para cumplir sus obligaciones, más allá de la relación de empleo formal.

Ejemplo: Personal de seguridad que golpea a alguien

En una empresa, el personal de seguridad golpea a una persona de manera arbitraria y violenta. El daño causado se imputa tanto al empleado como a la persona jurídica. La empresa no puede escudarse en que «fue el empleado».

43.3. Responsabilidad de los administradores (art. 160)

Regla: Responsabilidad de los administradores (art. 160 CCyC)

Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus integrantes y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión.

Esta disposición es la contracara del artículo 1763: si el presidente causó un daño, frente al tercero dañado responden tanto el presidente como la persona jurídica. Pero la persona

jurídica, a su vez, puede iniciar acción contra el presidente por los daños que causó. Los administradores responden de forma ilimitada (con todos sus bienes) y solidaria (todos responden por el todo).

Capítulo 44

Fin de la existencia y fundaciones

44.1. Causales de disolución (art. 163)

Regla: Causales de disolución (art. 163 CCyC)

La persona jurídica se disuelve por:

a) La decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición especial;

b) El cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia;

c) La consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo;

d) El vencimiento del plazo;

e) La declaración de quiebra;

f) La fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la escisión respecto de la escindida;

g) La reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y esta no es restablecida dentro de los tres meses;

h) La denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando esta sea requerida;

i) El agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;

j) Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en disposiciones de este Título o de ley especial.

Entre las causales más relevantes cabe señalar:

- **Inciso a) — Decisión de los miembros**: por unanimidad si el estatuto no dice nada; si el estatuto establece una mayoría, se aplica esa mayoría.
- **Inciso b) — Condición resolutoria**: cuando la existencia estaba subordinada a un hecho futuro e incierto que se cumple.
- **Inciso c) — Consecución del objeto**: cuando la persona jurídica se creó para un fin específico y este se cumplió o se tornó imposible.

- **Inciso e) — Quiebra**: cuando el pasivo supera al activo y no hay propuesta de acuerdo preventivo viable. La quiebra está regulada por ley especial y tiene por objeto liquidar el activo para pagar a los acreedores; excepcionalmente, puede haber avenimiento o conversión.
- **Inciso h) — Revocación estatal**: el Estado puede revocar la autorización para funcionar, con las restricciones del artículo 164.

Ejemplo: Fundación condicionada a un programa estatal

Una fundación se crea para ayudar a personas en situación de calle «siempre y cuando no exista un programa especial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para esa problemática». Si el gobierno implementa tal programa, se cumple la condición y la fundación se disuelve.

Ejemplo: Fundación para los cien años de un club

Se constituye una fundación especial para organizar la celebración del centenario de un club. Pasada la celebración, el objeto se cumplió y la personería se disuelve.

44.2. Revocación estatal — garantías (art. 164)

Importante

Artículo 164 CCyC — Revocación de la autorización estatal. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en la comisión de actos graves que violen la ley, el estatuto o el reglamento. La resolución que la disponga debe ser fundada y contener la indicación de los actos que la justifican. Se debe dar a los interesados la posibilidad de ser escuchados antes de que la resolución se dicte. Es apelable judicialmente. La apelación puede tener efectos suspensivos.

Las garantías que protegen a la persona jurídica frente a una revocación arbitraria pueden sintetizarse así:

1. Solo procede por actos graves que violen la ley, el estatuto o el reglamento.
2. La resolución debe ser fundada (no puede ser arbitraria).
3. Se debe garantizar el derecho de defensa (descargo previo).
4. Es apelable judicialmente, y la apelación puede tener efecto suspensivo (la persona jurídica sigue funcionando mientras se tramita).

El fundamento constitucional de estas garantías es la libertad de asociación consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

44.3. Reconducción y liquidación

- **Reconducción**: si se decidió la disolución pero no terminó la liquidación, se puede revertir esa decisión siempre que la causa pueda ser removida. Por ejemplo, si se cumplió el plazo pero los miembros deciden ampliarlo y transformar la personería de tiempo limitado a indefinido.
- **Liquidación**: una vez dada la causal de disolución, se pagan las deudas y obligaciones pendientes con el activo, se abonan los gastos, y los bienes remanentes se destinan según lo establezca la ley o el estatuto. En asociaciones civiles y fundaciones generalmente se exige que los bienes vayan a otra institución de bien común, sin fin de lucro.

44.4. Las fundaciones (arts. 193–224)

Definición: Fundación (art. 193 CCyC)

Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, denominadas fundadores, destinando dicho aporte al cumplimiento de sus fines.

Características distintivas de las fundaciones:

- No tienen miembros: el fundador aporta un patrimonio, que queda afectado al cumplimiento de un fin de bien común.
- No tienen fin de lucro.
- Requieren autorización estatal para funcionar (art. 142).
- Pueden constituirse por acto entre vivos o por testamento.

Ejemplo: Fundación banco de alimentos (caso detallado)

En un contexto de crisis, un fundador con capital decide constituir una fundación con $100.000 para organizar un banco de alimentos. La fundación alquila un depósito, contrata empleados, establece convenios con instituciones que proveen alimentos y organiza campañas de donación. Todo eso es la fundación funcionando. No hay «socios»: hay un fundador que dotó el patrimonio y un Consejo de Administración que lo gestiona.
También puede constituirse por testamento: un deportista que practique hockey puede establecer en su testamento que su parte disponible de la herencia vaya a una fundación para que personas sin recursos puedan practicar ese deporte.

44.4.1. Patrimonio inicial suficiente

El Código exige que la fundación cuente con un patrimonio inicial que posibilite razonablemente el cumplimiento de sus fines (recaudo no exigido para las asociaciones civiles). La Inspección de Personas Jurídicas no otorgará la autorización si los fondos son insuficientes.

El plan de acción a tres años (plan trienal) que se presenta ante el organismo de contralor puede incluir tanto los aportes iniciales como los ingresos futuros proyectados (eventos benéficos, campañas de donación, etc.).

44.4.2. Órgano de gobierno: Consejo de Administración

El único órgano de gobierno es el Consejo de Administración, dotado de todas las atribuciones para el gobierno y la administración. Debe tener al menos tres personas humanas como integrantes.

Puede delegar funciones en un Comité Ejecutivo (art. 205), que ejerce esas funciones entre las reuniones del Consejo. Los miembros del Comité Ejecutivo pueden ser remunerados, mientras que los del Consejo de Administración no.

44.4.3. Control externo

Las fundaciones no tienen órgano de fiscalización interna: el control es exclusivamente externo, a cargo de la autoridad de contralor (IGJ u organismo provincial equivalente). Entre las atribuciones del organismo de contralor (art. 222) se encuentran:

- Aprobar estatutos y sus reformas.
- Fiscalizar el funcionamiento.
- Designar administradores interinos, suspender deliberaciones, remover administradores, convocar asambleas.
- Intervenir en la disolución y liquidación.

44.4.4. Inmutabilidad del objeto (art. 216)

No es posible reformar el objeto de la fundación, salvo que haya resultado de cumplimiento imposible. Esto se debe a que la fundación fue autorizada para ese objeto específico, y cambiarlo implicaría traicionar la voluntad inicial del fundador.

Capítulo 45

Asociaciones civiles y simples asociaciones

Las asociaciones civiles y las simples asociaciones son personas jurídicas privadas de enorme importancia social: clubes deportivos, ONG, asociaciones barriales, organizaciones de víctimas, entidades religiosas. La Constitución Nacional consagra la libertad de asociación como un derecho fundamental.

45.1. Asociaciones civiles (arts. 168–186)

45.1.1. Concepto y objeto

Definición: Objeto de las asociaciones civiles (art. 168 CCyC)

La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. El objeto no puede ser contrario a las disposiciones de este Código ni a la ley especial, ni referirse a cuestiones de interés particular de los asociados.

La definición es por la negativa: cualquier finalidad que no afecte al interés general puede ser objeto de una asociación civil. La asociación civil es una corporación: unión de personas en torno a un fin común (cultural, artístico, deportivo, religioso, social).

Importante

La asociación civil no tiene fin de lucro y no persigue el lucro como fin principal. Puede eventualmente generar ganancias si organiza un evento a beneficio, pero ese dinero se reinvierte en los fines de la asociación; no se distribuye entre los miembros.

45.1.2. Diferencia fundamental con las sociedades

En la sociedad, los socios aportan capital, participan de ganancias y pérdidas, y obtienen utilidades. En la asociación civil, los miembros aportan su cuota —fijada por el estatuto y las asambleas— que contribuye a los fines colectivos, sin distribuirse ganancias.

Nota

La Resolución de la IGJ 7/2015 entiende por «bien común» a las finalidades que contribuyen al bien de la comunidad en general o a la mejora de las condiciones de vida, en contraposición al bien individual.

45.1.3. Constitución y contenido del estatuto (art. 170)

El instrumento constitutivo debe hacerse en escritura pública. El artículo 170 establece que debe contener:

- Identificación de los constituyentes.
- Nombre, objeto y domicilio.
- Plazo de duración y causales de disolución.
- Composición del patrimonio inicial.
- Clases o categorías de socios (activos, cadetes, vitalicios, etc.).
- Régimen de admisión, renuncia y sanciones disciplinarias.
- Órganos de gobierno: composición, atribuciones, funcionamiento y duración de cargos.
- Cierre del ejercicio económico anual.
- Destino de los bienes en caso de liquidación: deben ir a otra entidad de bien común, pública o privada, sin fin de lucro, con domicilio en la República Argentina.

45.2. Órganos de gobierno

45.2.1. Comisión Directiva (art. 171)

Es el órgano de dirección y administración cotidiana de la asociación civil. Los cargos mínimos son Presidente, Secretario y Tesorero (los demás son Vocales). Cada estatuto puede agregar cargos adicionales: vicepresidentes primero y segundo, prosecretario, protesorero, etc.

Debe reunirse al menos una vez al mes. Sus atribuciones las fija el estatuto, y hay que distinguir entre las que tiene la Comisión como cuerpo colegiado y las que tiene el Presidente individualmente.

Importante

No hay que confundir el hecho de que alguien sea presidente con que pueda resolver todo por sí mismo. El presidente es quien preside un órgano que es la Comisión Directiva.

Ejemplo: Venta de un inmueble por una asociación civil

Si una asociación civil quiere vender un inmueble, hay que leer el estatuto para saber quién puede tomar esa decisión. A veces se exige que la asamblea autorice previamente la venta; otras veces basta con la Comisión Directiva. El abogado debe siempre revisar el estatuto antes de asesorar.

45.2.2. Asamblea

Es el órgano supremo: la reunión de todos los asociados. En asociaciones muy numerosas puede instrumentarse a través de representantes elegidos por los socios.

- **Asamblea ordinaria**: generalmente una vez al año; aprueba la memoria y el balance presentado por la Comisión Directiva con el dictamen del órgano de fiscalización.
- **Asamblea extraordinaria**: se convoca cuando es necesario modificar el estatuto, elegir autoridades, aprobar reglamentos o tomar decisiones que requieran mayorías especiales.

45.2.3. Órgano de fiscalización

Puede recaer en personas no asociadas. Si la asociación cuenta con más de cien socios, debe tener una Comisión Revisora de Cuentas. Si la asociación exige una profesión determinada para ser socio, los integrantes del órgano de fiscalización no necesariamente deben contar con ese título, pero debe contratarse a profesionales independientes para el asesoramiento correspondiente.

Además del control interno, existe también la fiscalización estatal del artículo 174.

45.3. Poder disciplinario

La asociación civil puede sancionar a sus miembros. En esto se evidencia la distinción entre la persona jurídica y sus miembros.

45.3.1. Principios que rigen el poder disciplinario

1. Debe estar regulado en el estatuto, con claridad sobre qué órgano interviene (asamblea, Comisión Directiva o Comisión de Disciplina).
2. Se debe garantizar el derecho de defensa del afectado: debe darse vista al sumariado y permitirle hacer sus descargos.
3. Gradualidad y proporcionalidad de la sanción: primero se amonesta, luego se suspende por períodos crecientes, y finalmente se expulsa. No se puede expulsar sin proceso.
4. La decisión es apelable ante los tribunales judiciales si no se respetó el derecho de defensa, si fue desproporcionada o si no hubo debido proceso.

Ejemplo: Destrucción de un vestuario

Un socio muy enojado, luego de un partido, destruye el vestuario del club un domingo. El lunes, la Comisión Directiva puede suspenderlo transitoriamente como medida cautelar. Pero no puede expulsarlo sin proceso: debe abrirse un sumario, recopilarse pruebas y testimonios, notificarse al imputado, permitirle hacer su descargo y luego resolver. La sanción debe ser proporcional a la falta.

45.3.2. Límites de la revisión judicial

El juez puede revisar la forma del proceso disciplinario (si se respetó el derecho de defensa, si la sanción fue proporcional). Pero no puede revisar el fondo de la decisión —salvo grave violación de derechos humanos—, porque ello implicaría alterar el objeto y la autonomía de la persona jurídica.

Ejemplo: Club vegano y el vendedor de panchos

Un club de personas veganas expulsa a un socio que insiste en vender panchos en las instalaciones. Si el juez le diera la razón al expulsado en cuanto al fondo, estaría alterando el objeto de la asociación y el derecho de todos sus miembros a mantener la identidad que los une. Por eso, el control judicial se centra en la forma, no en el fondo de la decisión disciplinaria.

45.4. Simples asociaciones (arts. 187–192)

Las simples asociaciones son personas jurídicas privadas que, a diferencia de las asociaciones civiles, no necesitan autorización estatal para funcionar. Existen muchísimas en la práctica.

45.4.1. Diferencias con las asociaciones civiles

Cuadro 45.1: Asociación civil frente a simple asociación

Aspecto	Asociación civil	Simple asociación
Instrumento constitutivo	Escritura pública	Instrumento público o privado con firma certificada
Autorización estatal	Requerida	No requerida
Comienzo de existencia	Desde la constitución (previa autorización para funcionar)	Desde la constitución
Órgano de fiscalización	Obligatorio (Comisión Revisora de Cuentas si hay más de 100 socios)	Prescindible si hay menos de 20 socios; se certifica con contador externo
Responsabilidad en insolvencia	Separación plena entre persona jurídica y miembros	Administradores y miembros que participaron responden solidariamente con sus bienes propios
Régimen supletorio	No aplica	Se aplica el régimen de asociaciones civiles

45.4.2. Responsabilidad en las simples asociaciones (art. 191)

Regla: Responsabilidad en simples asociaciones (art. 191 CCyC)

Si la simple asociación no puede pagar a sus acreedores, los administradores y todos los miembros que hubieren participado de hecho en la administración responden solidariamente con sus propios bienes por las deudas de la simple asociación.
Los demás miembros que no participaron en la administración solo responden hasta el límite de las cuotas y contribuciones prometidas o debidas.

En la simple asociación existe una menor diferencia entre la persona jurídica y sus miembros: quienes participaron de alguna forma en la administración y llevaron a un resultado de quebranto o insolvencia deben responder con sus propios bienes.

continúa en la página siguiente

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

45.5. Cuadro Cornell: repaso general de las personas jurídicas

El siguiente cuadro reúne, según el método Cornell, las preguntas centrales que atraviesan los cuatro bloques temáticos estudiados, con sus respuestas y una síntesis final para el repaso integral de la materia.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es una persona jurídica?	Son los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación (art. 141 CCyC). A diferencia de la persona humana, cuya personalidad es reconocida por el legislador, la de las personas jurídicas es conferida por él.
¿En qué consiste el principio de especialidad?	La capacidad de la persona jurídica está acotada a su objeto y sus fines específicos. No puede hacer cualquier cosa: solo aquello para lo que fue creada. De ahí la importancia de redactar el objeto con precisión y amplitud suficiente en el estatuto.
¿Cuál es la diferencia entre la teoría de la ficción y las teorías de la realidad?	La teoría de la ficción (Savigny) entiende que la persona jurídica es un artificio del legislador, sin voluntad real. Las teorías de la realidad (organicista, de la institución) buscan un sustrato real. Las teorías normativistas las conciben como centros de imputación de normas. El CCyC combina elementos normativistas e institucionales.
¿Cómo clasifica el Código a las personas jurídicas?	Públicas: Estado nacional, provincias, municipios, entidades autárquicas, estados extranjeros, organismos internacionales, Iglesia Católica. Privadas: sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal y otras previstas en leyes especiales.
¿Qué norma prevalece según el artículo 150?	Orden de prevalencia: (1) normas imperativas de la ley especial; (2) normas imperativas del CCyC; (3) estatuto y reglamentos; (4) normas supletorias. El estatuto tiene fuerza de norma jurídica en el ámbito de la persona jurídica.

continúa en la página siguiente

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuándo se aplica la inoponibilidad del artículo 144?	Cuando la persona jurídica es usada para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, la personería se vuelve inoponible y se puede accionar directamente contra los socios, miembros o controlantes que hicieron posible esa actuación. Responden solidaria e ilimitadamente.
¿Qué requisitos debe cumplir el nombre de una persona jurídica?	Debe indicar la forma jurídica adoptada; debe ser veraz, novedoso y con aptitud distintiva (diferenciarse de nombres, marcas y fantasías); no puede inducir a error sobre el objeto; no puede contener términos contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres. Si incluye el nombre de una persona humana, se necesita su conformidad.
¿Cuál es la diferencia entre domicilio y sede social?	Domicilio: ciudad indicada en el estatuto; determina jurisdicción y juez competente. Sede social: dirección física inscripta ante el organismo de contralor; las notificaciones allí enviadas se tienen por válidas. Domicilio especial: en el lugar de las sucursales, para las obligaciones allí contraídas.
¿Cómo responde civilmente la persona jurídica?	Tres supuestos: (1) daños causados por directivos/administradores en ejercicio o con ocasión de sus funciones (art. 1763); (2) daños por cosas o actividades riesgosas, responsabilidad objetiva (art. 1757); (3) daños causados por dependientes en ejercicio o con ocasión de funciones (art. 1753). Los administradores también responden ilimitada y solidariamente ante la propia persona jurídica (art. 160).
¿Cuáles son las causales de disolución del artículo 163?	Decisión de los miembros; condición resolutoria; consecución o imposibilidad del objeto; vencimiento del plazo; quiebra; fusión o escisión; reducción a uno del número de miembros; revocación o denegatoria de autorización estatal; agotamiento de bienes; otras causas estatutarias o legales.
¿Qué garantías protegen frente a la revocación estatal del artículo 164?	Solo procede por actos graves que violen la ley, el estatuto o el reglamento. Requiere resolución fundada, garantía del derecho de defensa, y es apelable judicialmente con posible efecto suspensivo. El fundamento es la libertad de asociación constitucional.

continúa en la página siguiente

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué caracteriza a las fundaciones?	Persona jurídica sin miembros, con fin de bien común y sin lucro, creada por el aporte patrimonial de uno o varios fundadores. Requiere autorización estatal para funcionar. Necesita patrimonio inicial suficiente (plan trienal). Órgano de gobierno: Consejo de Administración (mínimo tres personas). Solo fiscalización externa. El objeto es inmutable, salvo imposibilidad sobreviniente.
¿Qué caracteriza a las asociaciones civiles?	Corporación de personas con fin común no lucrativo. Instrumento constitutivo: escritura pública. Tres órganos: Comisión Directiva, Asamblea (suprema) y órgano de fiscalización (Comisión Revisora de Cuentas si hay más de 100 socios). Poder disciplinario: proceso con derecho de defensa, gradualidad y proporcionalidad. Apelación judicial solo sobre la forma, salvo grave violación de derechos humanos.
¿En qué se diferencian las simples asociaciones?	No requieren autorización estatal. Pueden constituirse por instrumento privado con firma certificada. Comienzan su existencia desde la constitución. Si hay menos de 20 socios, pueden prescindir del órgano de fiscalización. Principal diferencia: en caso de insolvencia, los administradores y miembros que participaron en la gestión responden solidariamente con sus propios bienes.

continúa en la página siguiente

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

Resumen: Las personas jurídicas son entes colectivos a los que el ordenamiento jurídico —no la naturaleza— otorga aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones, con el fin de cumplir el objeto para el que fueron creadas (principio de especialidad). El Código Civil y Comercial las clasifica en públicas —el Estado y sus organismos, los estados extranjeros, los organismos internacionales y la Iglesia Católica— y privadas —sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas y consorcios—. Su existencia comienza desde la constitución, aunque algunas requieren autorización estatal para funcionar. Son entidades con personalidad diferenciada de sus miembros (patrimonios y responsabilidades distintas), salvo los supuestos de inoponibilidad del artículo 144, donde la personería cede frente al uso abusivo o fraudulento. Responden civilmente por los daños que causen sus directivos en ejercicio de sus funciones (art. 1763), por las cosas y actividades riesgosas que posean (art. 1757) y por los hechos dañosos de sus dependientes (art. 1753); además, los propios administradores responden ilimitada y solidariamente frente a la persona jurídica (art. 160). Su disolución puede deberse a la voluntad de los miembros, al cumplimiento o imposibilidad del objeto, al vencimiento del plazo, a la quiebra o a la revocación estatal —esta última con estrictas garantías de fundamentación y defensa—. Entre los tipos especiales, las fundaciones se distinguen por la ausencia de miembros, la afectación de un patrimonio a un fin altruista y el control externo exclusivo de la autoridad de contralor; las asociaciones civiles, por su carácter corporativo, sus tres órganos de gobierno y el poder disciplinario sobre sus miembros con plenas garantías procesales; y las simples asociaciones, por no requerir autorización estatal y por la responsabilidad solidaria que recae sobre los administradores y miembros activos ante la insolvencia.

Parte XI

El objeto de la relación jurídica: patrimonio, derechos y bienes

Esta parte conecta dos preguntas fundamentales del derecho privado: ¿quién responde? y ¿con qué responde? El patrimonio es el puente entre ambas. Se estudia el patrimonio, la clasificación de los derechos, los bienes y las cosas que lo componen y, finalmente, la garantía patrimonial de los acreedores, los bienes que quedan excluidos de ella y las acciones destinadas a conservarla.

Capítulo 46

El patrimonio

46.1. Planteo general

Esta parte conecta dos preguntas fundamentales del Derecho Privado: **¿quién responde?** y **¿con qué responde?** El patrimonio es el puente entre ambas: es el atributo que le da contenido económico a la persona jurídica y, al mismo tiempo, la garantía sobre la que los acreedores ejecutarán sus créditos. Entender qué son los bienes y las cosas —y cómo se clasifican— es entender de qué está hecho ese patrimonio.

Nota

Relevancia práctica. Estas nociones constituyen la base de la práctica profesional jurídica cotidiana:

- Al redactar una escritura de compraventa, es necesario distinguir si el bien es mueble o inmueble para determinar la forma requerida (escritura pública o simple contrato).
- Al asesorar a un cliente endeudado, permite determinar qué bienes puede conservar por ser inembargables.
- En un litigio, permite identificar qué acciones utilizar para recuperar el patrimonio de un deudor que intenta eludir a sus acreedores.

El patrimonio como garantía es el concepto central del crédito: no se presta dinero ni se celebra un contrato sin entender sobre qué responde el deudor.

46.2. El patrimonio como atributo de la personalidad

En este capítulo confluyen dos aspectos distintos y complementarios. El primero es el estudio del **patrimonio como atributo de la personalidad**. Existen distintas posturas: algunas señalan que el patrimonio es un atributo de la personalidad y otras no lo entienden así. Se adopta aquí —junto con el profesor Lozano Roy— la posición que entiende el patrimonio como atributo de la personalidad.

La materia aborda el patrimonio desde dos planos:

Perspectiva	Qué estudia	Dónde se ubica
Atributo de la personalidad	El patrimonio como cualidad inherente al sujeto de derecho	Dentro del estudio del sujeto de la relación jurídica
Objeto de la relación jurídica	Los bienes y cosas que conforman el patrimonio	Dentro del estudio del objeto de la relación jurídica

La materia recorre tres grandes ejes: el **sujeto** (persona humana y jurídica), el **objeto** (bienes y cosas) y la **causa** de la relación jurídica. El patrimonio aparece en los dos primeros ejes: como atributo del sujeto y como continente de los objetos.

> **Artículo 15 CCyC — Titularidad de derechos individuales**
>
> *Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme a lo que se establece en este Código.*

46.3. El patrimonio como garantía común de los acreedores

El artículo 242 constituye el núcleo funcional del patrimonio:

> **Artículo 242 CCyC — Garantía común**
>
> *Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales declaran inembargables e inejecutables.*

Ejemplo: La deuda de un millón de pesos

Supóngase que una persona debe un millón de pesos. El acreedor la intima a pagar y el deudor no paga. El acreedor no puede limitarse a solicitar cortésmente el pago: en algún momento deberá ejecutar compulsivamente al deudor.
Si el deudor no entrega voluntariamente el dinero, no realiza una transferencia bancaria ni cumple de ninguna manera la obligación, el acreedor se cobra **ejecutando su patrimonio**. Si el deudor tiene un auto a su nombre y un departamento, el acreedor traba embargo sobre esos bienes y, si el deudor no paga, los ejecuta judicialmente; con el producido de los bienes se cobra.

46.4. El patrimonio como universalidad de derecho

Definición: Patrimonio (universalidad de derecho)

Según la teoría clásica —Llambías y otros autores—, el patrimonio es una **universalidad de derecho**: un conjunto de bienes y deudas que conforman una unidad porque la ley se la otorga, con independencia de su contenido concreto en cada momento.

Se destacan dos notas esenciales:

Nota	Descripción	Consecuencia práctica
Unicidad	Cada persona tiene un solo patrimonio	No puede fragmentarlo a voluntad, salvo casos legales
Mutabilidad del contenido	Los bienes entran y salen, pero el patrimonio subsiste	Los acreedores se cobran sobre los bienes actuales, no sobre los que existían al contraer la deuda

Los acreedores pueden cobrarse con los bienes actuales del deudor. El hecho de que el deudor haya vendido un departamento no implica que los acreedores hayan perdido su garantía: la garantía es el **patrimonio como tal**, con independencia de su contenido. Esto indica también que, si el contenido del patrimonio de la persona va cambiando con el tiempo, sigue siendo su patrimonio.

46.4.1. Los patrimonios especiales

El Código Civil y Comercial reconoce la existencia de patrimonios especiales, disipando la ambigüedad que existía en el código anterior. Son universalidades autónomas que conviven con el patrimonio general:

Tipo de patrimonio especial	Descripción
Fondo de comercio	Conjunto de bienes afectados a una explotación comercial
Masa de la quiebra	Bienes del fallido afectados al proceso concursal
Masa hereditaria	Bienes del causante antes de la partición
Herencia del presunto fallecido	Patrimonio sujeto a prenotación durante el período legal

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

46.5. Cuadro Cornell: el patrimonio

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el patrimonio y por qué se dice que es una universalidad de derecho?	Es una universalidad de derecho: el conjunto de bienes (activo) y deudas (pasivo) de una persona, al que el ordenamiento jurídico le otorga unidad. Es una unidad porque la ley se la otorga, con independencia de su contenido concreto en cada momento (teoría clásica: Llambías y otros autores). En la materia se lo entiende, junto con el profesor Lozano Roy, como atributo de la personalidad.
¿Cuáles son las notas esenciales del patrimonio?	**Unicidad:** cada persona tiene un solo patrimonio, que no puede fragmentar a voluntad salvo casos legales. **Mutabilidad del contenido:** los bienes entran y salen, pero el patrimonio subsiste; por eso los acreedores se cobran sobre los bienes actuales y no sobre los que existían al contraer la deuda.
¿Puede existir más de un patrimonio para una misma persona?	Cada persona tiene un solo patrimonio (unicidad), salvo casos legales. El CCyC reconoce patrimonios especiales, universalidades autónomas que conviven con el patrimonio general: fondo de comercio, masa de la quiebra, masa hereditaria y herencia del presunto fallecido.
¿Por qué se dice que el patrimonio es la garantía común de los acreedores?	Porque todos los bienes del deudor responden por sus obligaciones (Arts. 242 y 743 CCyC). Si el deudor no paga voluntariamente, el acreedor puede ejecutar compulsivamente los bienes que integran su patrimonio, con excepción de los declarados inembargables.
¿Desde qué perspectivas se estudia el patrimonio?	Como atributo de la personalidad (dentro del estudio del sujeto de la relación jurídica) y como conjunto de los bienes y cosas que lo conforman (dentro del estudio del objeto de la relación jurídica). Los tres ejes de la materia son el sujeto, el objeto y la causa; el patrimonio aparece en los dos primeros.
Resumen: El patrimonio es una universalidad de derecho —conjunto de bienes y deudas— y un atributo de la personalidad. Es único y de contenido cambiante, aunque el CCyC admite patrimonios especiales. Es la garantía común de los acreedores (Art. 242 CCyC): todos los bienes del deudor responden por sus obligaciones, salvo los declarados inembargables e inejecutables, y el acreedor puede cobrarse ejecutándolos cuando el deudor no paga voluntariamente.	

Capítulo 47

Clasificación de los derechos

47.1. Derechos patrimoniales y extrapatrimoniales

La gran clasificación de los derechos distingue los que componen el patrimonio de los que quedan fuera de él:

Categoría	Subcategorías	Caracteres
Extrapatrimoniales	Derechos personalísimos; derechos de familia	Sin contenido económico directo; ligados a la persona o al vínculo familiar
Patrimoniales — Reales	Dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, prenda	Relación directa entre la persona y la cosa; oponibles *erga omnes*
Patrimoniales — Personales	Obligaciones y contratos	Relación entre acreedor y deudor respecto de una prestación
Patrimoniales — Intelectuales	Obras científicas, literarias, artísticas, invenciones, software	Recaen sobre creaciones inmateriales

47.2. Los derechos reales

Definición: Derechos reales

Los derechos reales son aquellos que conceden un **señorío inmediato sobre una cosa**: existe una relación directa de la persona con la cosa.

El derecho real por antonomasia es el **dominio**, que es el derecho más perfecto y confiere el uso y goce de una cosa. Técnicamente, en el Código Civil y Comercial —cuya tradición proviene de los romanos—, el *dominus* es el señor de una *res*; por eso estos derechos son «reales»: el término viene del latín *res*, que significa «cosa».

Tipo	Ejemplos	Nota
Sobre cosa propia — plenos	Dominio	El más amplio: uso, goce y disposición
Sobre cosa propia — limitados	Condominio	Dos o más titulares sobre la misma cosa
Sobre cosa ajena — de disfrute	Usufructo, uso, habitación, servidumbre	El titular goza de la cosa de otro
Sobre cosa ajena — de garantía	Hipoteca (inmuebles), prenda (muebles)	Garantizan el cumplimiento de una obligación

47.3. Los derechos personales

Importante

No deben confundirse los derechos **personales** con los derechos **personalísimos**.

Los derechos se llaman «personales» porque confieren prerrogativas para exigir de **otro** una determinada prestación: la relación no es directa entre una cosa y su dueño, sino entre un acreedor y un deudor en torno a una prestación. Estos derechos se plasman fundamentalmente en obligaciones y contratos.

47.4. Los derechos intelectuales

Definición: Derechos intelectuales

Los derechos intelectuales confieren un **derecho de explotación, de uso y de goce sobre una obra intelectual**: una obra científica, la creación de una invención, la obra literaria o artística, el software.

Se trata de distintos tipos de creaciones que tienen un campo de inmaterialidad, porque no son una casa, un auto o una computadora, sino obras intelectuales.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

47.5. Cuadro Cornell: clasificación de los derechos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo se clasifican los derechos según su relación con el patrimonio?	**Extrapatrimoniales** (personalísimos y de familia): sin contenido económico directo, ligados a la persona o al vínculo familiar; quedan fuera del patrimonio. **Patrimoniales:** reales, personales e intelectuales.
¿Qué son los derechos reales y cuál es el derecho real por antonomasia?	Conceden un señorío inmediato sobre una cosa: hay una relación directa de la persona con la cosa, y son oponibles *erga omnes*. El derecho real por antonomasia es el dominio, el derecho más perfecto, que confiere el uso y goce de una cosa. Se los llama «reales» por el latín *res* (cosa).
¿Qué diferencia hay entre ser dueño de una cosa y tener un derecho sobre ella?	El dominio es un derecho real sobre cosa propia, pleno y el más amplio (uso, goce y disposición). Los derechos reales sobre cosa ajena son de disfrute (usufructo, uso, habitación, servidumbre: el titular goza de la cosa de otro) o de garantía (hipoteca sobre inmuebles, prenda sobre muebles). El condominio es un derecho sobre cosa propia limitado: dos o más titulares sobre la misma cosa.
¿Por qué se llaman «personales» los derechos personales si no son personalísimos?	Porque confieren prerrogativas para exigir de otro una determinada prestación: la relación no es entre una cosa y su dueño, sino entre un acreedor y un deudor en torno a una prestación. Se plasman en obligaciones y contratos. No deben confundirse con los derechos personalísimos, que son extrapatrimoniales.
¿Qué son los derechos intelectuales?	Derechos de explotación, de uso y de goce sobre una obra intelectual (obra científica, invención, obra literaria o artística, software). Recaen sobre creaciones con un campo de inmaterialidad.
Resumen: Los derechos se clasifican en extrapatrimoniales (personalísimos y de familia, sin contenido económico directo) y patrimoniales (reales, personales e intelectuales). Los derechos reales otorgan un señorío inmediato sobre una cosa y son oponibles *erga omnes*; el dominio es el derecho real por antonomasia. Los derechos personales confieren la facultad de exigir de otro una prestación y se plasman en obligaciones y contratos; no deben confundirse con los personalísimos. Los derechos intelectuales recaen sobre creaciones inmateriales.	

Capítulo 48

Bienes y cosas

48.1. Distinción entre bienes y cosas

> **Artículo 16 CCyC — Bienes y cosas**
>
> *Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.*

Concepto	Definición	Ejemplos
Bien (sentido amplio)	Todo objeto susceptible de valor económico, material o inmaterial	Un crédito, un derecho de autor, una casa, dinero
Cosa	Objeto material susceptible de valor económico	Casa, auto, computadora, ganado
Bien inmaterial	Bien sin corporalidad física	Un crédito, una marca, un derecho de usufructo

48.2. Muebles e inmuebles

La distinción entre cosas inmuebles y cosas muebles es la clasificación más importante de las cosas en el Código.

48.2.1. Inmuebles

Tipo de inmueble	Descripción	Ejemplos
Por naturaleza	Fijados al suelo de manera natural o que se encuentran bajo él sin hecho del hombre	El suelo, los minerales, los árboles arraigados
Por accesión	Cosas muebles inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable	Paredes, pisos, ventanas, puertas, techos de un edificio

Ejemplo: Límite de la accesión

Los pisos, las paredes, las ventanas, las puertas y los techos de una casa están compuestos por cosas que eran muebles pero que fueron incorporadas y fijadas al piso con carácter perdurable, por lo que se convierten en inmuebles. La ventana es separable, pero es parte del inmueble.
En cambio, una biblioteca colocada en un departamento no es parte del inmueble aunque esté puesta con carácter permanente, porque está afectada a la actividad de su titular: si se vende el departamento, se lo vende sin la biblioteca, salvo que se trate de un placar construido directamente e incorporado con las paredes.

48.2.2. Cosas muebles

Tipo de cosa mueble	Descripción	Ejemplos
Por desplazamiento propio (semovientes)	Se mueven por sí mismas	Ganado
Por fuerza externa	Se desplazan mediante fuerza humana o mecánica	Muebles del hogar, electrodomésticos
Locomóviles	Vehículos con propulsión propia	Automóviles, motos, camiones, aeronaves
Muebles registrables	Muebles que por su importancia la ley manda registrar	Automotores, buques, aeronaves
Muebles no registrables	Sin obligación de registro	La mayoría de los objetos cotidianos

48.2.3. Importancia práctica de la distinción entre muebles e inmuebles

Aspecto jurídico	Cosas inmuebles	Cosas muebles
Forma de transmisión	Escritura pública obligatoria	Mayor libertad de formas
Ley aplicable (DIPr)	Ley del territorio donde está el bien	Ley del domicilio del propietario
Prescripción adquisitiva	20 años (10 con justo título y buena fe)	Plazo más corto; sin registro: posesión vale título
Garantías reales	Hipoteca	Prenda

48.3. Cosas divisibles e indivisibles

Definición: Cosas divisibles

Son divisibles las cosas que pueden dividirse en porciones reales sin ser destruidas, y cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa original.

Ejemplo: División de una cosa

Si deben hacerse, a partir de diez quintales de soja, dos entregas de cinco quintales, la cosa es perfectamente divisible: cada parte es un todo homogéneo. En cambio, si se divide un auto, no quedan dos autos: queda un auto destruido.

La divisibilidad tiene un límite legal: la división no puede tornar antieconómico el uso y aprovechamiento de la cosa.

Ejemplo: División de un lote

Dividir un lote de diez metros por diez en pequeños lotes de un metro cuadrado sería absolutamente inconveniente y antieconómico.

Por eso la reglamentación en materia de inmuebles fija unidades mínimas —en algunos lugares, de 866 metros cuadrados—. Las autoridades locales (municipios o provincias) tienen las potestades para reglamentar las divisiones en materia de inmuebles.

48.4. Cosas principales y accesorias

Definición: Cosas principales y accesorias

Son **principales** las cosas que pueden existir por sí mismas; **accesorias**, aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra de la cual dependen o están adheridas.

El régimen jurídico de la cosa accesoria es el de la principal.

Ejemplo: El cuadro y su marco

Sea un cuadro compuesto por la tela, la pintura y un marco: el marco es accesorio con relación a la tela y a la pintura, y el régimen jurídico aplicable es el de la principal. Pero si se trata de una lámina que se compra en cualquier kiosco y se la coloca en un marco enormemente valioso de oro, lo principal pasa a ser el marco, y la lámina colocada en él resulta absolutamente accesoria.

> **Artículo 230 CCyC — Criterio residual**
>
> *Si no es posible determinar la relación de principalidad y accesoriedad entre las cosas, se considera principal la de mayor valor. Si los valores son iguales, no hay cosa principal ni accesoria.*

48.5. Cosas consumibles y no consumibles; fungibles y no fungibles

Clasificación	Definición	Ejemplos	Importancia
Consumibles	Su existencia termina con el primer uso	Alimentos, combustible	Relevante en obligaciones de restitución
No consumibles	No dejan de existir por el uso habitual	Muebles, ropa (se deterioran, pero subsisten)	Base de contratos de uso y préstamo
Fungibles	Un individuo equivale a otro de la misma especie; pueden sustituirse	Toneladas de trigo de igual calidad, billetes	Admite sustitución en el cumplimiento
No fungibles	No pueden sustituirse por otro individuo	Cuadro de artista reconocido, botella de vino numerada	Incumplimiento si se entrega cosa distinta

Las obras artísticas no son fungibles; las cosas producidas industrialmente, por lo general, sí lo son.

48.6. Frutos y productos

Categoría	Definición	Renovación	Ejemplos
Frutos naturales	Producidos espontáneamente por la naturaleza	Se renuevan periódicamente	Manzanas de un árbol
Frutos industriales	Producidos con intervención humana (agricultura, industria)	Se renuevan con la actividad	Cosechas, producción fabril
Frutos civiles	Rentas producidas por el bien a través de actos jurídicos	Se renuevan periódicamente	Alquileres, intereses del dinero prestado
Productos	Objetos no renovables que al separarse alteran o disminuyen la sustancia	No se renuevan	Minerales extraídos de una cantera

Ejemplo: Producto y fruto

Si se extrae cobre de una cantera, se trata de un **producto**: la cantera no volverá a producir ese mineral sino en dos millones de años, de modo que se extraen productos y se disminuye el valor de la cosa. En cambio, las manzanas de un árbol se renuevan: son un **fruto**.

Esta distinción adquiere importancia cuando debe restituirse algo con sus frutos y sus productos.

Ejemplo: Restitución de una casa por un poseedor de mala fe

Quien recibe una casa y es de mala fe debe restituirla con las rentas: si la casa producía un alquiler mensual de veinte mil pesos, debe devolver la casa con las rentas que hubiese producido durante esos años.

Los artículos 1935 y 1936 CCyC (y el artículo 234, sobre bienes fuera del comercio) regulan los deberes de restitución de frutos y productos según la buena o mala fe del poseedor.

48.7. Bienes según las personas

Categoría	Artículo CCyC	Caracteres	Ejemplos
Dominio público del Estado	Art. 235	Inalienables, inembargables, imprescriptibles; uso de todos	Ríos, lagos, playas, plazas, calles
Dominio privado del Estado	Art. 236	El Estado es titular como particular; pueden enajenarse	Inmueble fiscal no afectado a uso público
Bienes de los particulares	Art. 238	Todos los bienes no enumerados en los artículos anteriores	Cualquier bien en manos de un privado
Bienes fuera del comercio	Art. 234	Prohibida su enajenación por ley o por acto jurídico	Bienes de uso cultual, bienes embargados
Bienes de incidencia colectiva	Art. 240	Interés colectivo en su protección; no apropiables individualmente	Ecosistema, fauna, biodiversidad, agua, valores culturales

48.7.1. Bienes de incidencia colectiva

Definición: Bienes de incidencia colectiva

Son bienes que no son estrictamente individuales, sino que corresponden de forma homogénea a un conjunto de personas o a la comunidad como tal. Por ejemplo: el ecosistema, la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua y los valores culturales.

48.8. Cuadro Cornell: bienes y cosas

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué diferencia hay entre un bien y una cosa?	Todo bien es un objeto susceptible de valor económico (material o inmaterial). Una cosa es un bien material (objeto corporal). Todos los objetos inmateriales con valor económico son bienes, pero no cosas (Art. 16 CCyC).
¿Cuál es la clasificación más importante de las cosas?	Muebles e inmuebles. Los inmuebles pueden ser por naturaleza (el suelo y lo adherido orgánicamente) o por accesión (cosas muebles incorporadas con carácter perdurable). Los muebles pueden desplazarse por sí mismos (semovientes) o por fuerza externa; algunos son registrables (automotores).
¿Por qué importa distinguir muebles de inmuebles?	Define la ley aplicable (en DIPr), el plazo de prescripción adquisitiva (20/10 años para inmuebles *vs.* plazos menores para muebles), la forma de transmisión (escritura pública para inmuebles) y el tipo de garantía real (hipoteca *vs.* prenda).
¿Cuándo una cosa es divisible?	Cuando puede dividirse en porciones reales sin ser destruida y cada porción forma un todo homogéneo y análogo a las otras partes y a la cosa original (diez quintales de soja en dos entregas de cinco; un auto no es divisible: dividido queda destruido). Límite: la división no puede tornar antieconómico el uso y aprovechamiento; en inmuebles, las autoridades locales fijan unidades mínimas.
¿Cuándo una cosa es principal o accesoria?	Es principal la que puede existir por sí sola; accesoria, la que depende de otra. El régimen jurídico sigue a lo principal. Si no se puede determinar cuál es principal, prevalece la de mayor valor (Art. 230 CCyC); si los valores son iguales, no hay cosa principal ni accesoria.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué diferencia hay entre cosas consumibles y no consumibles, y entre fungibles y no fungibles?	**Consumibles:** su existencia termina con el primer uso (alimentos, combustible). **No consumibles:** no dejan de existir por el uso habitual. **Fungibles:** un individuo equivale a otro de la misma especie y pueden sustituirse, lo que admite sustitución en el cumplimiento (trigo de igual calidad, billetes). **No fungibles:** no pueden sustituirse; entregar una cosa distinta es incumplimiento (cuadro de artista reconocido).
¿Qué diferencia a un fruto de un producto?	El fruto se produce de modo renovable sin alterar ni disminuir la sustancia de la cosa (manzanas, intereses, alquileres). El producto es no renovable y su separación altera o disminuye la sustancia (minerales extraídos de una cantera).
¿Por qué importa distinguir entre frutos y productos?	Interesa cuando debe restituirse algo con sus frutos y productos: los Arts. 1935 y 1936 CCyC regulan los deberes de restitución según la buena o mala fe del poseedor. Quien recibe una casa de mala fe debe restituirla con las rentas que hubiese producido.
¿Cómo se clasifican los bienes según las personas?	▪ **Dominio público del Estado** (Art. 235): inalienables, inembargables, imprescriptibles; uso de todos. ▪ **Dominio privado del Estado** (Art. 236): el Estado es titular como particular; pueden enajenarse. ▪ **Bienes de los particulares** (Art. 238): los no enumerados en los artículos anteriores. ▪ **Bienes fuera del comercio** (Art. 234): prohibida su enajenación por ley o por acto jurídico. ▪ **Bienes de incidencia colectiva** (Art. 240): interés colectivo en su protección; no apropiables individualmente.
¿Qué son los bienes de incidencia colectiva?	Bienes no estrictamente individuales, que corresponden de forma homogénea a un conjunto de personas o a la comunidad como tal (ecosistema, flora, fauna, biodiversidad, agua, valores culturales).

Resumen: Todo bien es un objeto susceptible de valor económico; las cosas son los bienes materiales (Art. 16 CCyC). Las cosas se clasifican en muebles e inmuebles (la distinción más importante), divisibles e indivisibles, principales y accesorias, consumibles y no consumibles, fungibles y no fungibles, y se distingue entre frutos y productos. Según las personas, los bienes pueden ser del dominio público o privado del Estado, de los particulares, fuera del comercio o de incidencia colectiva. Cada clasificación tiene consecuencias jurídicas precisas.

Capítulo 49

Garantía patrimonial, acreedores y acciones

49.1. El patrimonio como garantía: repaso y profundización

El artículo 743 precisa cuáles son los bienes que constituyen la garantía:

> **Artículo 743 CCyC — Bienes que constituyen la garantía**
> *Son bienes del deudor sujetos a ejecución todos los que integran su patrimonio a la fecha de la sentencia o en el que se hubiese determinado, y los que adquiera hasta la extinción de la obligación. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia.*

49.2. Tipos de acreedores y preferencias de cobro

Cuando hay concurrencia de acreedores —especialmente en situaciones de insolvencia— el orden de cobro no es necesariamente igualitario.

Tipo de acreedor	Fuente de preferencia	Alcance	Ejemplo
Con privilegio especial	La ley	Sobre determinados bienes	Acreedor laboral sobre maquinarias del empleador en quiebra
Con privilegio general	La ley	Sobre la generalidad del patrimonio	Créditos del fisco en algunos supuestos
Con garantía real	Autonomía de la voluntad (contrato)	Sobre el bien gravado	Hipotecario que ejecuta el inmueble hipotecado
Quirografario (común)	Ninguna preferencia	Sobre el remanente, en igualdad	Acreedor sin ninguna garantía

Ejemplo: Concurrencia de acreedores

Supóngase que el deudor debe 10.000 dólares a un acreedor, 20.000 a otro y 30.000 a un tercero. Tiene un único bien: un departamento valuado en 50.000 dólares.

Escenario A (todos quirografarios). El pasivo total es de 60.000 y el activo de 50.000: hay insolvencia. Cada acreedor cobrará proporcionalmente sobre los 50.000.
Escenario B (uno tiene hipoteca por 50.000). El acreedor hipotecario ejecuta primero el departamento, cobra sus 50.000 y los otros dos no cobran nada, porque el bien con garantía real tiene preferencia.

49.3. Bienes inembargables (Art. 744 CCyC)

Razones humanitarias justifican la exclusión de ciertos bienes de la garantía común.

Bien inembargable	Fundamento
Ropa, muebles e inmuebles de uso indispensable del deudor, cónyuge, conviviente e hijos	Necesidades básicas del hogar
Instrumentos necesarios para ejercer la profesión, arte u oficio	Sin ellos, la persona no tendría manera de sobrevivir
Sepulcros afectados a su destino (salvo que la deuda sea por su construcción o reparación)	Respeto a la memoria de los difuntos
Bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado (templos, objetos de culto)	Libertad religiosa
Derechos de usufructo, uso y habitación (en los términos del Código)	Carácter personalísimo de estos derechos
Indemnizaciones por daño moral o lesiones a la integridad psicofísica	Compensación de daños personalísimos
Indemnizaciones por alimentos al cónyuge, conviviente e hijos en caso de homicidio	Protección de la familia del fallecido
Otros declarados inembargables por leyes especiales (por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil)	Sustento mínimo para la vida

Importante

El telón de fondo de todas estas exclusiones es proteger la dignidad humana en sus dimensiones más fundamentales.

49.4. La protección de la vivienda (Arts. 244 y ss. CCyC)

El Código Civil y Comercial reemplazó la denominación «bien de familia» (Ley 14.394) por el concepto de «protección de la vivienda».

Artículo 244 CCyC — Afectación

> *Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concurrencia de otros acreedores.*

Aspecto	Régimen
Requisito	Inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble (trámite sencillo)
Efecto	El inmueble queda inembargable frente a las deudas posteriores a la inscripción
Deudas anteriores	Los acreedores con deudas anteriores no se ven afectados
Límite cuantitativo	Puede afectarse la totalidad o solo parte del valor
Límite de unidades	No puede afectarse más de un inmueble

49.5. Acciones de los acreedores

49.5.1. Medidas preventivas

Antes de llegar a la ejecución, los acreedores disponen de medidas preventivas para conservar la garantía:

Medida	Descripción	Ejemplo
Embargo preventivo	Afecta un bien determinado para que no salga del patrimonio del deudor	Trabar embargo sobre la casa del deudor que está por venderla antes de obtener sentencia
Inhibición general de bienes	Impide al deudor enajenar cualquier bien cuando no se conocen bienes concretos	Anotar en el registro una inhibición general cuando el deudor no tiene bienes identificables

Los deudores pueden plantearse la estrategia de sacar bienes de su patrimonio y transformarlos en dinero en efectivo, de tal manera que los acreedores, cuando vengan a cobrar, no encuentren bienes a su nombre. Estas medidas sirven para contrarrestar esa estrategia.

49.5.2. Acción directa (Arts. 736 y 737 CCyC)

Definición: Acción directa

Es la acción que se le da al acreedor para **cobrar lo que un tercero debe a su deudor**, hasta el importe del propio crédito.

Sus caracteres son los siguientes:

Carácter	Descripción
Propia	El acreedor la ejerce por derecho propio
Exclusiva	En beneficio exclusivo del acreedor que la ejerce, no de todos
Excepcional	Solo procede en los casos expresamente previstos por la ley
Restrictiva	De interpretación restrictiva
Presupone homogeneidad	Los créditos deben ser de la misma naturaleza (por ejemplo, dinerarios)

Ejemplo: Acción directa con créditos homogéneos

Supóngase que se prestó dinero a una persona y que esta, a su vez, se lo prestó a una tercera. Los créditos son homogéneos, porque el propio dinero del acreedor pasó de uno a otro. El acreedor va directamente contra el deudor de su deudor y le ejecuta la deuda, pero solo hasta el importe de su crédito: si prestó doscientos mil pesos a su deudor y este le prestó a otro trescientos mil, puede reclamarle al tercero doscientos mil; los cien mil restantes se los reclamará su deudor.

Esta figura aparece también denominada en las fuentes originales «acción de delegación directa».

Regla: Art. 737 CCyC — Requisitos de la acción directa

- Existencia de un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor.
- Existencia de una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor.
- Homogeneidad de ambos créditos entre sí.
- Ninguno de los dos créditos debe estar embargado ni ser indisponible.
- El deudor debe ser notificado de la demanda.

49.5.3. Acción subrogatoria (Arts. 739 y 740 CCyC)

Definición: Acción subrogatoria

El acreedor ocupa el lugar de su deudor y ejerce un derecho que le es propio a este, cuando el deudor está inactivo y esa omisión perjudica el cobro del crédito.

Ejemplo: La cochera heredada

Supóngase que se prestaron doscientos mil pesos a una persona. Esta tiene un familiar que fallece y le deja en herencia una cochera que vale cuatrocientos mil pesos. El deudor, considerando que el acreedor se quedaría con la cochera apenas la tuviera, decide no iniciar la sucesión y permanece inactivo.

El acreedor, que advierte que su deudor está inactivo y tiene la posibilidad de exigir judicialmente un crédito, y que esa inactividad lo perjudica, se subroga: ocupa su lugar e inicia la sucesión. La cochera ingresa al patrimonio del deudor y el acreedor traba embargo sobre ese bien para cobrarse. Pero aquí no tiene ningún privilegio especial: cualquier otro acreedor embargante tendrá también preferencia.

Regla: Arts. 739 y 740 CCyC — Acción subrogatoria

Art. 739. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si este es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio.

Art. 740. Los derechos y acciones del deudor excluidos de la subrogación son los inherentes a su persona, los no patrimoniales, los patrimoniales no susceptibles de ejecución forzada y los excluidos por disposición legal.

El crédito o la acción recuperados ingresan al patrimonio del deudor; por eso la acción subrogatoria beneficia a todos los acreedores, mientras que en la acción directa resulta beneficiado únicamente el acreedor que actúa.

49.5.3.1. Comparación entre la acción directa y la acción subrogatoria

Criterio	Acción directa	Acción subrogatoria
Nombre en el que se actúa	Nombre propio del acreedor	Nombre del deudor (subrogación)
Beneficiario	Solo el acreedor que la ejerce	Todos los acreedores del deudor
Privilegio	Sí: cobra directamente hasta su crédito	No: el bien ingresa al patrimonio; todos pueden ejecutarlo
Presupuesto	Créditos homogéneos y caso legal expreso	Inactividad del deudor que perjudica la acreencia
Límite	Hasta el importe del propio crédito	Todo lo recuperado ingresa al patrimonio del deudor
Normas	Arts. 736 y 737 CCyC	Arts. 739 y 740 CCyC

Importante

La acción subrogatoria, a diferencia de la acción directa, no otorga ningún privilegio y beneficia a todos los acreedores.

49.5.3.2. Derechos excluidos de la acción subrogatoria

No se pueden subrogar derechos vinculados con la personalidad ni de ejercicio absolutamente discrecional por el titular (Arts. 741–742 CCyC). Como ejemplo se menciona el reconocimiento de un hijo o las cuestiones de puro ejercicio de la voluntad familiar. Según

otra de las fuentes, los derechos excluidos son los inherentes a la persona del deudor, los no patrimoniales, los patrimoniales no susceptibles de ejecución forzada y los excluidos por disposición legal (art. 740 CCyC).

49.5.4. Acción de simulación y acción revocatoria (inoponibilidad)

Acción	Denominación en el CCyC	Presupuesto	Efecto
De simulación	Nulidad por simulación	El deudor aparenta sacar bienes pero los conserva (por ejemplo, venta ficticia al hermano/a sin contraprestación)	Nulidad del acto; la cosa vuelve al patrimonio del deudor
Revocatoria / pauliana	Inoponibilidad (CCyC)	El deudor vende realmente su bien a un cómplice para defraudar a sus acreedores	El acto es válido entre partes pero inoponible al acreedor; puede ejecutar el bien

Ambas acciones se distinguen mediante casos paralelos.

Ejemplo: Simulación

El deudor llama a su hermana y le dice «simulemos que te vendo mi casa». La hermana no tiene dinero ni bienes, pero aparece como compradora. Cuando el acreedor va a ejecutar al deudor, la casa no está a su nombre. El acreedor alega que el acto fue simulado; el juez decreta la nulidad, las cosas vuelven al estado anterior y el acreedor puede cobrarse.

Ejemplo: Inoponibilidad

El deudor vende efectivamente su casa —el dinero ingresa a su patrimonio—, pero el acreedor demuestra que el comprador era cómplice del deudor. Al revocar la venta, esta no se anula: es inoponible al acreedor defraudado, que ejecuta el bien como si la venta no hubiera existido. El adquirente cómplice pierde el bien, pero tiene acción para cobrarse contra el deudor originario.

49.6. Cuadro Cornell: garantía, acreedores y acciones

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué bienes del deudor están sujetos a ejecución?	Según el Art. 743 CCyC, todos los que integran su patrimonio a la fecha de la sentencia (o en el que se hubiese determinado) y los que adquiera hasta la extinción de la obligación. El acreedor puede exigir la venta judicial solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito, y todos los acreedores ejecutan en posición igualitaria salvo causa legal de preferencia.
¿Qué tipos de acreedores existen y cómo afecta eso al cobro?	Con privilegio especial (sobre determinados bienes, por ejemplo el laboral), con privilegio general (sobre todo el patrimonio), con garantía real (hipoteca o prenda, elegida voluntariamente) y quirografarios (sin preferencia, cobran en igualdad sobre el remanente). En caso de insolvencia, cobran en ese orden.
¿Qué bienes son inembargables? (Art. 744 CCyC)	Ropa y muebles indispensables del hogar, instrumentos del oficio o profesión, sepulcros (salvo deuda de construcción), bienes de culto, ciertos derechos de usufructo, uso y habitación, indemnizaciones por lesiones o daño moral, alimentos por homicidio, y los declarados así por leyes especiales (salario mínimo). El fundamento común es proteger la dignidad humana en sus dimensiones más fundamentales.
¿Cómo se protege la vivienda frente a las deudas?	Inscribiendo el inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble (Arts. 244 y ss. CCyC). Desde la inscripción, las deudas posteriores no pueden ejecutarlo. Solo se protege un inmueble, en su totalidad o hasta una parte de su valor. Las deudas anteriores a la inscripción no se ven afectadas.
¿Qué medidas preventivas tienen los acreedores antes de la ejecución?	**Embargo preventivo:** afecta un bien determinado para que no salga del patrimonio del deudor. **Inhibición general de bienes:** impide al deudor enajenar cualquier bien cuando no se conocen bienes concretos. Sirven para contrarrestar la estrategia del deudor de convertir sus bienes en dinero en efectivo para que los acreedores no encuentren bienes a su nombre.
¿Qué es la acción directa?	Permite al acreedor cobrar directamente lo que un tercero le debe a su deudor (Art. 736 CCyC). La ejerce en nombre propio, solo lo beneficia a él y opera hasta el límite de su crédito. Requiere homogeneidad de créditos y un caso legal expreso.
¿Qué es la acción subrogatoria?	El acreedor ocupa el lugar de su deudor inactivo y ejerce los derechos patrimoniales de este en su nombre (Art. 739 CCyC). El bien recuperado ingresa al patrimonio del deudor y beneficia a todos los acreedores, no solo al subrogante.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué diferencias hay entre la acción directa y la acción subrogatoria?	▪ **Directa:** se actúa en nombre propio; beneficia solo al acreedor que la ejerce; con privilegio (cobra directamente hasta su crédito); requiere créditos homogéneos y caso legal expreso. ▪ **Subrogatoria:** se actúa en nombre del deudor; beneficia a todos los acreedores; sin privilegio (el bien ingresa al patrimonio y todos pueden ejecutarlo); requiere inactividad del deudor que perjudique la acreencia.
¿Qué derechos no pueden ejercerse mediante la acción subrogatoria?	Los derechos vinculados con la personalidad y los de ejercicio absolutamente discrecional por el titular (Arts. 741–742 CCyC); por ejemplo, el reconocimiento de un hijo o cuestiones de puro ejercicio de la voluntad familiar.
¿Qué diferencia hay entre la acción de simulación y la de inoponibilidad?	En la simulación el acto es ficticio (el deudor aparenta vender pero conserva el bien); el efecto es la nulidad. En la inoponibilidad (acción revocatoria o pauliana) el acto es real pero fraudulento: el acreedor lo hace inoponible a sí mismo y puede ejecutar el bien aunque el tercero lo haya adquirido realmente.
Resumen: Los bienes del deudor responden por sus obligaciones y los acreedores los ejecutan en posición igualitaria salvo causa legal de preferencia (Art. 743 CCyC). Los acreedores pueden tener privilegio especial, privilegio general, garantía real o ser quirografarios. La garantía tiene límites: los bienes inembargables (Art. 744) y la protección de la vivienda (Art. 244). Para conservar y recuperar la garantía, los acreedores cuentan con medidas preventivas (embargo preventivo, inhibición general de bienes) y con las acciones directa, subrogatoria, de simulación y de inoponibilidad.	

49.7. Síntesis de la parte

49.7.1. Recorrido de la parte

Esta parte recorrió el patrimonio, el patrimonio como garantía, los distintos tipos de acreedores y los distintos tipos de acciones de los acreedores. Desde el patrimonio como garantía existe la posibilidad de ejercer acciones; asimismo, hay bienes que quedan excluidos de ella, y que el Código enuncia en los artículos 744 y 244.

49.7.2. Síntesis final

Esta parte construyó la arquitectura conceptual sobre la que descansa buena parte del Derecho Privado argentino. El patrimonio es el puente entre la persona y el mercado: como atributo de la personalidad, le da contenido económico al sujeto; como garantía común (Art. 242 CCyC), le da sustento a todo el sistema crediticio.

Para entender de qué está hecho ese patrimonio, el Código clasifica los bienes y cosas según múltiples criterios —muebles e inmuebles, fungibles y no fungibles, divisibles e indivisibles, principales y accesorias, frutos y productos—, cada uno con consecuencias jurídicas precisas que atraviesan el Derecho Real, Obligacional, Contractual, de Familia y de Sucesiones.

El sistema de protección articula dos tensiones: la del acreedor, que necesita ejecutar el patrimonio para cobrar, y la del deudor, que no puede ser reducido a la indigencia. Esta tensión se resuelve mediante los bienes inembargables y la protección de la vivienda.

Finalmente, las acciones directa, subrogatoria, de simulación y de inoponibilidad son los instrumentos procesales que permiten al acreedor conservar y recuperar la garantía frente a estrategias de vaciamiento patrimonial.

Parte XII

La causa de la relación jurídica: hechos y actos jurídicos

Si el sujeto es quien entabla la relación y el objeto es la materia sobre la que recae, la causa explica cómo surgen las relaciones jurídicas. Esta parte estudia los hechos jurídicos y el acto voluntario, la imputabilidad, el acto jurídico y sus elementos (objeto, causa y forma), los instrumentos, la clasificación y las modalidades de los actos y, por último, los efectos de los actos jurídicos respecto de las partes, los representantes, los sucesores y los terceros.

Capítulo 50

Fundamentos de los hechos y actos jurídicos

Nota

Los primeros capítulos de esta parte abordan el tercer elemento de la relación jurídica: la causa, es decir, el origen del cual emergen las relaciones jurídicas. El recorrido conceptual parte de la clasificación general de los hechos jurídicos, avanza hacia la distinción entre hechos voluntarios e involuntarios (discernimiento, intención y libertad) y culmina con el estudio de la imputabilidad, es decir, de las consecuencias que se atribuyen a quien realiza un acto voluntario, así como del tratamiento excepcional que reciben los actos involuntarios a través del principio de equidad.

50.1. Introducción: la causa como tercer elemento de la relación jurídica

La teoría de los hechos y actos jurídicos constituye el tercer elemento de la relación jurídica, luego de haberse estudiado el sujeto y el objeto. Mientras el sujeto es quien entabla la relación y el objeto es la materia sobre la que ésta recae, la causa explica cómo surgen las relaciones jurídicas.

Cuadro 50.1: Elementos de la relación jurídica

Elemento	Definición	Contenido
Sujeto	Quien entabla la relación	Persona humana o jurídica
Objeto	Materia sobre la que recae la relación	Bienes y cosas
Causa	De dónde surge la relación jurídica	**Hechos y actos jurídicos**

Esta teoría proyecta efectos sobre el conjunto del derecho civil y comercial, en la medida en que toda disciplina jurídica se ocupa, en definitiva, de hechos que dan origen a relaciones y situaciones jurídicas.

50.2. Ubicación metodológica en el Código Civil y Comercial

En el Código de Vélez, los hechos y actos jurídicos se regulaban en el Libro Segundo, Sección Segunda, dedicada a los derechos personales. El artículo 896 marcaba el inicio de la regulación de los hechos jurídicos, distanciada de los derechos reales y de otras áreas del código.

Cuadro 50.2: Cambio metodológico: Código de Vélez frente al CCyC

Código de Vélez (anterior)	CCyC actual
Libro Segundo — Derechos personales	Libro Primero — Parte General (metodológicamente más correcto)
Art. 896: iniciaba los hechos jurídicos	Desarrolla la teoría en nueve capítulos integrados a la parte general
Distanciado de los derechos reales y otras áreas	Integra la Parte General y fue bien recibido por la doctrina

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) desarrolla la teoría en nueve capítulos: disposiciones generales, los vicios (error, dolo, violencia), los actos jurídicos propiamente dichos, los vicios de los actos, las modalidades, la representación y la ineficacia. Este cambio metodológico constituye un acierto del nuevo Código, en la medida en que integra la parte general del derecho civil. Concretamente, la regulación de los hechos y actos jurídicos se ubica en el Libro Primero, Título Cuarto del Código.

50.3. Definición de hecho jurídico en el CCyC

Definición: Art. 257 CCyC — Hecho jurídico

El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Cuadro 50.3: Comparación entre el art. 257 CCyC y el art. 896 del Código de Vélez

Aspecto	CCyC (Art. 257)	Código de Vélez (Art. 896)
Término clave	Produce (certeza)	Susceptible de producir (posibilidad)
Referencia al orden jurídico	Sí: «conforme al ordenamiento jurídico»	No hacía esta referencia expresa
Efectos abarcados	Relaciones o situaciones jurídicas	Derechos u obligaciones solamente

El CCyC incorpora la expresión «conforme al ordenamiento jurídico», señalando que es el ordenamiento jurídico el que genera estas consecuencias. Esta afirmación no debe entenderse exclusivamente desde una visión positivista, como si únicamente el ordenamiento jurídico las generase, pues existe al respecto un debate doctrinario abierto.

El reemplazo del término «susceptible de producir» por «produce» resulta más preciso, en tanto al derecho le interesan los acontecimientos que efectivamente producen consecuencias jurídicas.

Ejemplo: El hecho jurídico frente al acontecimiento cotidiano

Tomar un vaso de agua no constituye un hecho jurídico. Arrojarlo por la ventana y dañar a un transeúnte sí lo es, en tanto genera una consecuencia jurídica relevante para el ordenamiento.

50.4. Clasificación general de los hechos jurídicos

El cuadro general de clasificación de los hechos jurídicos resulta central para el desarrollo de la materia.

Cuadro 50.4: Hechos jurídicos: clasificación general

Hechos de la naturaleza	Hechos humanos
Granizo, terremoto, aluvión. Relevan por sus efectos, no por su origen.	**Involuntarios**: sin discernimiento, intención o libertad.
	Voluntarios (con discernimiento, intención y libertad): — **Lícitos**: simples actos lícitos / actos jurídicos — **Ilícitos**: delitos (con dolo) / cuasidelitos (con culpa)

50.5. Hechos voluntarios e involuntarios: importancia de la distinción

Ejemplo: Caso del ataque epiléptico en la estación de subte

Una persona sufre un ataque de epilepsia en una estación de subte y se desvanece, golpeando a otra persona, que a su vez golpea a una tercera que casi cae a las vías del tren.
Conclusión jurídica: el hecho se origina de manera involuntaria. No hubo voluntad de empujar; la persona sufrió un ataque de epilepsia y se desvaneció. Desde el punto de vista jurídico, este hecho es tratado de manera diferente al supuesto en que existe voluntad, pues quienes tienen dominio de sus actos se hacen cargo de ellos, existiendo mayor responsabilidad cuando media voluntad.

50.6. Actos ilícitos: dolo y culpa

Los actos ilícitos son los prohibidos por la ley que generan daños. A diferencia del derecho penal, donde los delitos se encuentran tipificados, en el derecho civil los ilícitos comprenden todos los actos que causan un daño, presumiéndose que dicho daño es siempre antijurídico.

Cuadro 50.5: Delito civil y cuasidelito civil

Figura	Definición
Delito civil	Acto ilícito cometido con dolo (intención de dañar o manifiesta indiferencia por los intereses ajenos)
Cuasidelito civil	Acto ilícito cometido con culpa (negligencia, imprudencia o impericia, sin intención de dañar)

Nota

Los términos «delito civil» y «cuasidelito civil» no aparecen literalmente en el texto del CCyC. Se trata de una clasificación histórica elaborada por la doctrina.
Cabe señalar, asimismo, una crítica metodológica: los actos ilícitos se encuentran regulados en el Libro Tercero del CCyC (Derechos Personales — Responsabilidad Civil), cuando, al menos en sus elementos centrales, deberían haberse tratado en el Libro Primero, junto a la teoría general de los hechos jurídicos.

Definición: Art. 1724 CCyC — Factores subjetivos de atribución (dolo y culpa)

El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.
La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión.

El CCyC amplía la noción clásica romanista del dolo (intención de dañar), incorporando también la «manifiesta indiferencia».

Ejemplo: Caso del conductor que ignora a la anciana

Un conductor circula a 120 km/h y advierte que una anciana cruza correctamente con el semáforo en verde para peatones. Pese a verla, no realiza ningún intento de esquivarla ni de frenar, y la mata.
Análisis: no puede determinarse con certeza que el conductor haya querido matarla con premeditación, pero sí mostró una «manifiesta indiferencia» ante los intereses ajenos. Por lo tanto, se configura el dolo por indiferencia, que el CCyC incorpora expresamente.

Cuadro 50.6: Formas de culpa

Forma de culpa	Definición
Negligencia	Torpeza, falta de cuidado o diligencia debida. Ej.: un médico que no se lava las manos antes de una intervención.
Imprudencia	Realizar algo osado que no correspondía, asumiendo un riesgo innecesario sin intención de dañar.
Impericia	Falta de conocimientos técnicos propios de la profesión u oficio. Ej.: un médico que interviene sin los conocimientos necesarios.

50.7. Actos lícitos: simples actos lícitos y actos jurídicos

Definición: Art. 258 CCyC — Simple acto lícito

La acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Definición: Art. 259 CCyC — Acto jurídico

El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Cuadro 50.7: Simple acto lícito frente a acto jurídico

Criterio	Simple acto lícito (Art. 258)	Acto jurídico (Art. 259)
Voluntad	Sí, voluntario	Sí, voluntario
Licitud	Sí, no prohibido por la ley	Sí, lícito
Fin inmediato	No busca producir consecuencias jurídicas directamente	Sí: fin inmediato de producir consecuencias jurídicas
Ejemplo	Pasear por la calle (puede derivar en consecuencias jurídicas imprevistas)	Contrato de mutuo (préstamo de dinero con plazo e interés pactados)

Ejemplo: El contrato de mutuo como acto jurídico

En un contrato de mutuo, una persona decide prestarle dinero a otra, fijando el plazo y, eventualmente, una tasa de interés. Todo ello se establece en un contrato firmado por personas humanas que resuelven voluntariamente realizar un acto lícito —prestarse dinero— con el fin inmediato de generar una relación jurídica.

Capítulo 51

La teoría del acto voluntario

51.1. Las condiciones del acto voluntario

Definición: Art. 260 CCyC — Acto voluntario

El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.

Cuadro 51.1: Condiciones del acto voluntario

Condición	Tipo	Descripción
Discernimiento	Interna	Aptitud para diferenciar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto y sus consecuencias
Intención	Interna	Propósito de llevar a cabo un acto determinado, de manera consciente y dirigida a ese fin
Libertad	Interna	Posibilidad de actuar de acuerdo a la propia conveniencia, deseo y convicción, sin coacción
Exteriorización	Externa	Manifestación visible del acto: expresa (oral, escrita, signos inequívocos) o tácita

51.2. El discernimiento

El discernimiento es la aptitud para diferenciar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto y sus consecuencias. Se trata de una comprensión genérica, una capacidad o aptitud para comprender lo que está sucediendo.

Cuadro 51.2: Causas obstativas del discernimiento (Art. 261 CCyC)

Causa	Detalle
Privación de razón (permanente o transitoria)	Ej.: golpe en la cabeza que genera un estado de inconsciencia durante el cual se realizó un acto perjudicial. No requiere sentencia judicial de incapacidad.
Menor de diez (10) años — para actos ilícitos	El código presume que antes de esa edad no hay discernimiento para comprender lo injusto y sus consecuencias.
Menor de trece (13) años — para actos lícitos	Para los actos lícitos se exige mayor madurez cognitiva; la edad mínima es superior.

Importante

El discernimiento no debe confundirse con la capacidad. La capacidad es un concepto jurídico integral que se refiere a la aptitud para entablar relaciones jurídicas, mientras que el discernimiento es un componente del acto voluntario. Puede haber discernimiento sin capacidad: es el caso de las personas menores de edad.

Ejemplo: Discernimiento sin capacidad jurídica

Un niño de diez años puede tener discernimiento suficiente para un acto lícito, pero no necesariamente capacidad jurídica para celebrar ese acto.

Cuadro 51.3: Discernimiento frente a capacidad jurídica

Discernimiento (Art. 261 CCyC)	Capacidad jurídica
Elemento del acto voluntario. Se evalúa en cada caso concreto. No depende de sentencia judicial.	Concepto jurídico integral. Puede requerir sentencia judicial. Se adquiere con la mayoría de edad (18 años).

51.3. La intención y sus vicios: error y dolo

La intención es el propósito de llevar a cabo un acto determinado con consciencia. Mientras el discernimiento es la característica general que puede estar presente o no en cada acto, la intención es el propósito de realizar ese acto concreto, preciso y específico.

Cuadro 51.4: Vicios de la intención

Vicio	Definición	Ejemplo
Error	Ignorancia o falso conocimiento de la realidad que vicia la voluntad	Creer que se vende una casa cuando la otra parte entiende que es una donación. Error sobre la naturaleza del acto.
Dolo (vicio de la voluntad)	Maniobra engañosa por la que se induce a la otra parte a celebrar el acto	Alquilar una propiedad mostrando fotos falsas; al llegar, la casa está en mal estado y lejos de la playa.

La palabra «dolo» posee al menos dos significados en el derecho civil: (1) como intención de dañar, elemento subjetivo de la responsabilidad civil, y (2) como maniobra engañosa que vicia la voluntad.

El error puede recaer sobre los objetos, las personas, las causas o las cualidades de la cosa, dando lugar a distintas circunstancias que se estudian en el capítulo 72.

Respecto del dolo como vicio, la cuestión central consiste en determinar cuándo el engaño tiene entidad suficiente para afectar la intención, es decir, cuándo puede afirmarse que el acto no se habría realizado de no mediar el engaño.

51.4. La libertad y el vicio de violencia

La libertad es la posibilidad de llevar a cabo el acto de acuerdo con la propia conveniencia, deseo y convicción.

Cuadro 51.5: Formas de violencia como causa obstativa de la libertad

Forma de violencia	Definición
Fuerza física irresistible	Uso de la fuerza física de manera irresistible sobre el sujeto para que realice el acto. Ej.: torturar a alguien para que firme.
Intimidación (violencia moral)	Amenaza de sufrir un mal grave e inminente que no puede contrarrestarse, y que lleva a la persona a realizar el acto sin libertad real.

Es posible comprender, querer y realizar un acto con esa intención, y sin embargo no ser suficientemente libre por encontrarse la persona bajo amenaza. Un acto realizado bajo amenaza no es, por tanto, un acto voluntario.

51.5. La exteriorización de la voluntad

La voluntad debe exteriorizarse para ser considerada tal. Esto puede ocurrir de manera expresa o tácita.

Cuadro 51.6: Modalidades de exteriorización de la voluntad

Modalidad	Descripción	Ejemplo
Expresa oral	La voluntad se comunica verbalmente	Pactar verbalmente un préstamo
Expresa escrita	Instrumentada en documento público o privado	Contrato firmado; escritura pública
Signos inequívocos	Gestos que no admiten otra interpretación	Hacer el gesto de pedir un café en un bar
Ejecución de hecho material	Realización de un acto que revela la voluntad	Girar dinero como pago de una deuda
Tácita	Se infiere de conductas que permiten conocer con certidumbre la voluntad	Serie de actos que evidencian aceptación de una oferta

Definición: Art. 264 CCyC — Límite a la voluntad tácita

Si la ley o la convención exigen que la voluntad sea expresa, no puede suplirse con una expresión tácita.

Un ejemplo de esta regla es el consentimiento exigido para los actos de disposición de derechos, respecto de los cuales la ley exige que sea expreso, no pudiendo interpretarse un consentimiento tácito en ese contexto.

51.6. El silencio como (no) manifestación de voluntad

Definición: Art. 263 CCyC — El silencio como manifestación de voluntad

El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley o de la voluntad de las partes.

En el derecho civil y comercial, el silencio no constituye, en principio, una manifestación de voluntad: quien calla no otorga.

Ejemplo: El silencio frente a una oferta no solicitada

Si una persona recibe un mensaje de texto que indica «te has ganado un auto; a partir de mañana se descuentan $20.000 de tu tarjeta de crédito durante 60 meses, salvo que contestes que no lo querés en 24 horas», y guarda silencio, ese silencio no puede

considerarse aceptación. De lo contrario, sería necesario responder permanentemente a las publicidades para aclarar que no se las desea.

Cuadro 51.7: Excepciones: cuándo el silencio sí es manifestación de voluntad

Excepción	**Descripción**
Deber legal de expedirse	La ley obliga a pronunciarse. Ej.: intimación para reconocer o desconocer la firma de un instrumento. Si se guarda silencio, se tiene por reconocida.
Deber convencional de expedirse	Las partes acordaron que el silencio implica determinada manifestación. Ej.: contrato que establece que se renueva automáticamente si la parte no comunica lo contrario con un mes de anticipación.
Relaciones entre declaraciones precedentes	Cuando una serie de declaraciones anteriores llevaron razonablemente a la otra parte a esperar una determinada respuesta, y el silencio posterior confirma esa dirección.

Capítulo 52

Imputabilidad de los actos voluntarios

52.1. El deber de reparar: fundamento y presupuestos

Quienes realizan un acto voluntario deben hacerse cargo de sus consecuencias, en virtud de la relación de causalidad existente entre la acción y el resultado. La cuestión central consiste en determinar hasta dónde se extiende esa responsabilidad.

Definición: Art. 1716 CCyC — Deber de reparar

La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código.

Definición: Art. 1717 CCyC — Antijuridicidad

Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.

Cuadro 52.1: Presupuestos de la responsabilidad civil

N.°	Presupuesto	Descripción
1	Daño	Debe existir un daño efectivo a una persona o a su patrimonio.
2	Antijuridicidad	El daño debe ser antijurídico (se presume siempre, salvo causa de justificación — Art. 1718).
3	Factor de atribución	Subjetivo: dolo o culpa (Art. 1724). Objetivo: la ley establece que se responde independientemente de dolo o culpa (ej.: art. 1757 — responsabilidad por cosas y actividades riesgosas).
4	Relación de causalidad	El acto voluntario debe ser la causa adecuada del daño producido (nexo causal adecuado).

Ejemplo: Concausalidad: auto que choca a motociclista sin casco

Un auto choca a una moto cuyo conductor no lleva casco. El accidente le provoca una lesión cerebral severa, agravada precisamente por la falta de casco.
Análisis: quien chocó a la moto tiene una parte fundamental en la causación del daño, pues sin el choque el motociclista no se habría caído. Pero la negligencia del conductor que no llevaba casco también incide en el resultado dañoso, ya que con casco se habrían

evitado o reducido las consecuencias. Esto no exime al conductor del auto de responder, pero obliga a analizar cómo incidió cada causa (concausalidad).

52.2. Tipos de consecuencias: inmediatas, mediatas y casuales

Cuadro 52.2: Clasificación de las consecuencias del acto

Tipo	Definición	Ejemplo (choque de auto)
Inmediatas	Las que acostumbran suceder según el curso normal y ordinario de las cosas (Art. 1726 CCyC).	Auto choca a persona → fractura de cadera. Resultado directo del impacto.
Mediatas	Resultan de la conexión del hecho con un acontecimiento distinto (Art. 1726 CCyC).	Internación → pérdida de ingresos como carpintero durante 20 días.
Casuales	No pueden ser previstas, o resultan de circunstancias extraordinarias (Art. 1727 CCyC).	Pérdida de ingresos → depresión → divorcio → hijos con adicciones. Imprevisibles.

Regla: Arts. 1726 y 1727 CCyC — ¿Por cuáles consecuencias se responde?

Se reparan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. No se responde por las consecuencias casuales (mediatas no previsibles).

52.3. El criterio de previsibilidad y la graduación de la responsabilidad

Definición: Art. 1725 CCyC — Valoración de la conducta

Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.

Cuanto mayor es lo que una persona conoce, y cuanto mayor es su deber de conocer y obrar con prudencia, mayor es la diligencia que se le exige y, en consecuencia, mayor es también la valoración de la previsibilidad de las consecuencias por las que deberá responder.

Cuadro 52.3: Graduación de la diligencia exigible según la situación

Situación	Exigencia de diligencia
Profesional de la salud tratando un paciente	Alta: se le exige la diligencia propia de su especialidad y el estándar de cuidado de la comunidad médica.
Trabajador en planta con material nuclear o contaminante	Muy alta: el riesgo elevado implica mayor previsibilidad exigida.
Trabajador en tareas de bajo riesgo	Estándar ordinario de diligencia.

La condición especial o la facultad intelectual particular del agente no se toma en cuenta a los fines de esta graduación, a menos que haya sido específicamente contemplada en un contrato.

52.4. El caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes

Definición: Art. 1730 CCyC — Caso fortuito y fuerza mayor

Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto, o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario.

Importante

Cuando algo no puede ser previsto, el supuesto excede el ámbito de lo voluntario y se enmarca dentro del caso fortuito o la fuerza mayor. Se trata de un principio clásico del derecho civil: cuando algo no es voluntario, no se responde.

Capítulo 53

Responsabilidad por actos involuntarios

53.1. Regla general: no responsabilidad por actos involuntarios

Los actos involuntarios, a diferencia de los voluntarios, no generan responsabilidad en principio. Ello obedece a que, si el agente no obró con discernimiento, intención y libertad, no puede imputársele el deber de responder por las consecuencias del hecho.

Importante

En principio, los actos involuntarios no generan responsabilidad, salvo las excepciones expresamente previstas por el ordenamiento.

El antiguo artículo 907 del Código de Vélez establecía que en ningún caso se respondía por los actos involuntarios.

53.2. La evolución: el principio de equidad

A partir, especialmente, de la jurisprudencia francesa, comenzó a abrirse camino la idea de que la regla de no responsabilidad por actos involuntarios podía resultar injusta en determinados casos.

Ejemplo: El caso que motivó la incorporación de la equidad

Una persona privada de la razón por una enfermedad mental, con un gran patrimonio, causa un daño enorme a una persona muy pobre con familia numerosa.
Dilema: desde el punto de vista teórico, el hecho es involuntario y no puede imputarse. Pero cabe preguntarse si es justo que una persona muy rica, cuya conducta involuntaria arruina a una familia pobre, no repare absolutamente nada. Aquí aparece el concepto de equidad.

Cuadro 53.1: Dos concepciones de equidad

Concepción	Contenido
Equidad romana / igualitaria	Buscar que las personas tengan lo indispensable para la vida; igualdad material o distributiva.
Epieikeia aristotélica (equidad correctiva)	Rectificación de lo justo legal en el caso concreto. Cuando la aplicación estricta de la ley conduce a un resultado manifiestamente injusto, el juez puede apartarse de ella y disponer algo distinto para ese caso. Esta es la concepción que opera en el artículo 1750 CCyC.

53.3. El artículo 1750 del CCyC: régimen vigente

Definición: Art. 1750 CCyC — Daños causados por actos involuntarios

El autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742. El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor, sin perjuicio de la que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza.

Cuadro 53.2: Evolución normativa: del art. 907 (mod. 1968) al art. 1750 CCyC

Aspecto	Anterior (Art. 907 mod. 1968)	CCyC (Art. 1750)
Regla general	Nunca se respondía	El autor responde por razones de equidad
Facultad judicial	«Los jueces podrán disponer»	Texto más imperativo; el autor «responde»
Quantum	Patrimonio del autor y situación de la víctima	Se remite al art. 1742 (atenuación)
Debate doctrinario	Incorporado en 1968, debatido desde entonces	Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe): ¿es posible una indemnización de cero?

Nota

Constituye una cuestión doctrinaria debatida si el juez podría considerar que la equidad implica no establecer ninguna indemnización, frente a la posición de otros autores que sostienen que siempre debe establecerse alguna. La mayoría de la doctrina se inclina

por esta última posición, aunque se trata de un debate abierto en el que se ha señalado que podría el juez, por razones de equidad, no fijar indemnización alguna.
Se menciona al Dr. Juan Carlos Palmero, jurista cordobés, como el autor que más ha profundizado este tema en Argentina, con una publicación específica sobre el daño involuntario.

53.4. Criterios de la equidad para la atenuación (Art. 1742 CCyC)

Definición: Art. 1742 CCyC — Atenuación de la responsabilidad

El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable.

Cuadro 53.3: Factores para la determinación de la indemnización equitativa

Factor	Descripción
Patrimonio del causante del daño	¿Cuánta capacidad económica tiene quien causó el daño involuntario?
Situación personal de la víctima	¿Cuáles son las circunstancias de la persona que sufrió el daño?
Circunstancias del hecho	El contexto particular del caso concreto que rodea al evento dañoso.

El juez debe considerar estos factores, pudiendo apartarse de la regla general por razones de equidad y disponer el monto de la indemnización, llegando incluso a la posibilidad de que no exista indemnización, según una posición doctrinaria minoritaria; la mayoría de los autores sostiene, en cambio, que siempre corresponde otorgar algún tipo de indemnización.

Con el desarrollo de la imputabilidad de los actos voluntarios y del régimen de los actos involuntarios queda cerrada la presentación general de la teoría de los hechos y actos jurídicos.

53.5. Cuadro Cornell: hechos jurídicos, acto voluntario e imputabilidad

Hechos y Actos Jurídicos · Actos Voluntarios · Imputabilidad

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es un hecho jurídico según el CCyC?	El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas (Art. 257 CCyC). El CCyC mejoró la redacción anterior: usa «produce» en lugar de «susceptible de producir», y habla de «relaciones o situaciones jurídicas» en lugar de solo «derechos u obligaciones».
¿Cómo se clasifican los hechos jurídicos?	Hechos de la naturaleza (sin intervención humana: granizo, terremoto, aluvión) y hechos humanos (con intervención de la voluntad). Los humanos se subclasifican en voluntarios (con discernimiento, intención y libertad) e involuntarios.
¿Cuándo un acto humano es voluntario?	Cuando reúne tres condiciones internas —discernimiento (aptitud para distinguir lo bueno de lo malo), intención (propósito dirigido al acto concreto) y libertad (ausencia de coacción)— y se exterioriza (Art. 260 CCyC).
¿Qué son las causas obstativas y cuáles corresponden a cada condición?	Son los vicios o impedimentos que eliminan cada condición. Discernimiento: privación de razón, minoría de edad (menor de 10 años para actos ilícitos; menor de 13 para actos lícitos). Intención: error y dolo. Libertad: violencia (fuerza o intimidación).
¿En qué se diferencia el acto jurídico del simple acto lícito?	Ambos son voluntarios y lícitos. La diferencia radica en el fin inmediato: el acto jurídico tiene por fin inmediato producir consecuencias jurídicas (Art. 259 CCyC); el simple acto lícito no busca ese resultado directamente, aunque puede producirlo (Art. 258 CCyC).
¿Cuáles son los dos significados del «dolo» en el Derecho Civil?	(1) Como factor de atribución: intención de dañar o manifiesta indiferencia por los intereses ajenos (Art. 1724 CCyC). (2) Como vicio de la voluntad: maniobra engañosa que induce a la otra parte a celebrar un acto que de otro modo no habría realizado.
¿Qué diferencia al dolo de la culpa como factores de atribución?	Dolo: el agente produce el daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia. Culpa: omisión de la diligencia debida, sin intención de dañar. Se subdivide en negligencia (torpeza), imprudencia (temeridad) e impericia (falta de conocimiento técnico).

Continúa en la página siguiente

Cuadro Cornell de Repaso General (continuación)

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Cuándo el silencio es manifestación de voluntad?	En principio no lo es (Art. 263 CCyC). Excepcionalmente sí, cuando: (a) la ley obliga a expedirse; (b) las partes pactaron que el silencio implica determinada consecuencia; o (c) existe una serie de declaraciones precedentes que permiten inferir el sentido del silencio.
¿Cuáles son los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil?	1) Daño (efectivo). 2) Antijuridicidad (se presume, salvo causa de justificación — Art. 1717). 3) Factor de atribución (subjetivo: dolo/culpa; objetivo: la ley). 4) Relación de causalidad adecuada entre el acto y el daño.
¿Por cuáles consecuencias responde el agente?	Por las consecuencias inmediatas (curso natural y ordinario — Art. 1726) y las mediatas previsibles. No se responde por las casuales (mediatas imprevisibles — Art. 1727). El caso fortuito —imprevisto o inevitable— exime de responsabilidad (Art. 1730).
¿Qué pasa con los actos involuntarios y el deber de reparar?	En principio no generan responsabilidad. Pero el Art. 1750 CCyC establece que el autor de un daño involuntario responde por razones de equidad. El juez pondera el patrimonio del causante, la situación de la víctima y las circunstancias del hecho (remisión al Art. 1742). Quien actúa bajo fuerza irresistible no responde; sí responde quien ejerció esa fuerza.
¿Qué es la equidad en este contexto?	En su sentido aristotélico (epieikeia): la rectificación de lo justo legal cuando la aplicación estricta de la norma conduce a un resultado manifiestamente injusto en el caso concreto. Permite al juez apartarse de la regla general de no responsabilidad por actos involuntarios para establecer (o no) una indemnización justa.

Continúa en la página siguiente

Cuadro Cornell de Repaso General (continuación)

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**

Resumen: La teoría de los hechos y actos jurídicos constituye el tercer elemento de la relación jurídica, es decir, la fuente de donde emergen derechos y obligaciones. El punto de partida es la clasificación general: hechos de la naturaleza y hechos humanos; dentro de los humanos, voluntarios e involuntarios según concurran discernimiento, intención y libertad. Los actos voluntarios se dividen en lícitos —simples actos lícitos y actos jurídicos (Art. 259 CCyC), cuyo elemento diferenciador es el fin inmediato de producir consecuencias jurídicas— e ilícitos —delitos (con dolo) y cuasidelitos (con culpa)—. La exteriorización de la voluntad puede ser expresa o tácita; el silencio, como regla general, no es manifestación de voluntad salvo excepciones legales o convencionales. La segunda parte abordó la imputabilidad: el deber de reparar (Arts. 1716-1717 CCyC) nace cuando confluyen cuatro presupuestos —daño, antijuridicidad, factor de atribución y nexo causal adecuado—. Las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles son reparables; las casuales no. El caso fortuito exime de responsabilidad (Art. 1730). Finalmente, los actos involuntarios, si bien no generan responsabilidad en principio, pueden dar lugar a una indemnización por equidad en virtud del Art. 1750 CCyC, aplicando los criterios de atenuación del Art. 1742: patrimonio del causante, situación personal de la víctima y circunstancias del hecho. Esta tensión entre la regla de la no responsabilidad y la equidad como válvula correctora constituye uno de los debates doctrinarios más actuales del derecho civil argentino.

Capítulo 54

El acto jurídico: concepto y elementos

El acto jurídico es, dentro de la clasificación general de los hechos jurídicos (sección 50.4), un hecho humano voluntario lícito que tiene por fin inmediato producir la adquisición, modificación o extinción de derechos, relaciones o situaciones jurídicas. Es la categoría central de esta parte.

54.1. Acto jurídico y contrato: alcance de la teoría general

El Código Civil y Comercial argentino contiene un sistema general de los actos jurídicos, a diferencia del Código francés, que no trata los actos jurídicos en general sino que se limita al contrato. **El acto jurídico es un concepto más amplio que el contrato**; el contrato es una especie dentro del género acto jurídico.

Definición: Contrato

El contrato es el acto jurídico en el cual hay acuerdo de voluntades para el surgimiento de obligaciones en el campo patrimonial.

Ejemplo: Contratos como especie de acto jurídico

- **Contrato de compraventa**: acuerdo de voluntades para transferir la propiedad de una cosa contra el pago de un precio.
- **Contrato de locación**: acuerdo para transferir la tenencia de un bien —mueble o inmueble— contra la entrega de una renta mensual (canon).

No todos los actos jurídicos son contratos. Existen actos jurídicos que no responden a esta estructura de acuerdo patrimonial de voluntades:

- **Testamento**: acto que tiene por finalidad disponer de los bienes para el supuesto de la propia muerte, asignándolos según la voluntad del testador. Produce efectos luego de la muerte, pero no constituye un contrato.
- **Matrimonio**: acto jurídico de carácter especial que crea relaciones jurídicas de naturaleza personal.

54.2. Definición y características del acto jurídico

Definición: Acto jurídico (Artículo 259, Código Civil y Comercial de la Nación)

Acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de derechos, relaciones o situaciones jurídicas.

De esta definición se desprenden tres elementos fundamentales: que el acto sea **voluntario**, que sea **lícito**, y que tenga por **fin inmediato** producir consecuencias jurídicas.

Importante

La idea de «fin inmediato» es crucial: significa que el acto jurídico busca de manera directa la producción de consecuencias jurídicas. Esto es lo que lo diferencia del simple acto lícito, que puede producir consecuencias jurídicas, pero sin que ello constituya su finalidad.

54.3. Acto jurídico frente al simple acto lícito

La distinción entre el acto jurídico y el simple acto lícito reside en la intención del sujeto respecto del efecto jurídico producido.

Ejemplo: El pescador

Un pescador que sale a pescar, al apropiarse de lo pescado, realiza un simple acto lícito. Se produce un efecto jurídico —el pescador pasa a ser dueño de lo que pescó—, pero su intención original al pescar no es adquirir propiedad, sino pescar. El efecto jurídico es una consecuencia accesoria o secundaria del acto, no su fin inmediato.
Por el contrario, cuando se celebra un contrato de compraventa, el fin inmediato del sujeto es adquirir la propiedad de una cosa. El efecto jurídico es precisamente el objetivo buscado, la intención directa. Por ello, se trata de un acto jurídico.

54.4. Los elementos del acto jurídico

El acto jurídico se compone de los siguientes elementos esenciales:

1. **Sujeto**: la persona que concurre al acto para su celebración.
2. **Objeto**: la materia sobre la que recae el acto, es decir, los bienes o hechos que constituyen su contenido.
3. **Forma**: la manera en que se exterioriza el acto.
4. **Causa**: la finalidad perseguida por las partes al realizar el acto.

El sujeto de los actos jurídicos se estudió en las Partes II y III. Los capítulos siguientes desarrollan el **objeto** y la **causa** del acto jurídico; la **forma** se estudia en el capítulo 57, y los elementos accidentales o modalidades (condición, plazo y cargo), que pueden estar o no presentes en un acto determinado, en el capítulo 65.

Capítulo 55

El objeto del acto jurídico

55.1. Fundamento normativo

El artículo 279 del Código Civil y Comercial es central en materia de objeto de los actos jurídicos. Este artículo reconoce como antecedente el artículo 953 del Código Civil de Vélez, disposición que tuvo enorme influencia a lo largo de toda la vigencia del código anterior, en tanto marcaba el contenido moral del acto.

Definición: Objeto del acto jurídico (Artículo 279, Código Civil y Comercial de la Nación)

El objeto del acto jurídico debe ser un hecho o un bien. Los hechos no pueden ser imposibles (ni jurídica ni prácticamente), prohibidos por la ley, o contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Los bienes que son objeto del acto no pueden ser prohibidos, ni ser de carácter extrapatrimonial a menos que exista una autorización legal.

55.2. Contenido moral y límite de la autonomía de la voluntad

Un acto jurídico debe ser conforme a la ley, a la moral y al orden público. No existe una libertad absoluta en la autonomía de la voluntad: esta se encuentra limitada y moldeada por razones de distinto tipo —la ley, el orden público, la moral y la dignidad de la persona.

Nota

A lo largo de la historia, la disposición del artículo 953 del Código de Vélez originó numerosas limitaciones y aplicaciones jurisprudenciales, entre ellas:

- Antes de la sanción de la Ley 17.711, dicha disposición dio lugar a la aplicación del vicio de **lesión**, que permitía anular un acto cuando existía una notable desproporción entre las prestaciones.
- Limitación en la aplicación de **cláusulas penales**, entendidas como la cláusula que se impone a quien incumple un contrato, obligándolo a pagar, por ejemplo, intereses punitorios.
- Limitación de los intereses cuando resultan **usurarios**: cobrar una tasa de interés excesiva o desproporcionada constituye usura, considerada inmoral. Aunque ello depende de la situación y el contexto (por ejemplo, en escenarios inflacionarios), cobrar tasas del 200 al 300 por ciento de interés es claramente inmoral.

Existe una tensión ideológica sobre este punto: una mirada más liberal sostiene que cada parte es libre de pactar las tasas de interés que desee. Sin embargo, en Argentina —y en la mayoría de las legislaciones modernas— aun cuando no exista un límite normativo expreso a los intereses, el objeto del acto jurídico debe ser conforme a la moral y a las buenas costumbres, principio que conserva plena vigencia en la actualidad.

55.3. Requisitos del objeto

El artículo 279 divide el objeto del acto jurídico en dos grandes categorías: los hechos y los bienes.

55.3.1. Los hechos como objeto del acto

Los hechos, en tanto acontecimientos, no pueden ser:

1. **Imposibles** (ni jurídica ni prácticamente): no puede pactarse lo imposible. Cruzar el océano Atlántico nadando, por ejemplo, no puede ser objeto de un acto jurídico por tratarse de un hecho prácticamente imposible.
2. **Prohibidos por la ley**: si la ley prohíbe determinado hecho, este no puede ser objeto de un acto jurídico.
3. **Contrarios a la moral y a las buenas costumbres**: constituye una exigencia fundamental que el acto jurídico se adecue a los principios morales básicos.

55.3.2. Los bienes como objeto del acto

El artículo 279 hace referencia genérica a prohibiciones que pueden surgir de la ley. Así, por ejemplo, ciertos bienes no pueden ser objeto de determinados contratos: los bienes de dominio público no pueden ser objeto de un acto jurídico de disposición.

55.4. Objeto ilícito: el caso de la venta de influencias

Ejemplo: Venta de influencias y acto de corrupción

Una persona se compromete a realizar tratativas para obtener un privilegio en sede administrativa. En el fondo, se trata de una venta de influencias, un acto de corrupción. Este acto tiene un objeto ilícito porque vender influencias es contrario a la ética pública y constituye un acto de corrupción que afecta el orden público.
Si posteriormente esa persona pretende hacer valer la obligación —por ejemplo, cobrar lo que le fue prometido—, la consecuencia es la **nulidad del acto**. La nulidad surge precisamente porque el objeto no responde a los requisitos del artículo 279. Se trata de una nulidad de tipo **absoluta**, regulada en el artículo 386 del Código Civil y Comercial.

Capítulo 56

La causa del acto jurídico

56.1. Causa fuente y causa fin

El concepto de causa admite varias acepciones en el derecho civil. En particular, se distingue entre la causa fuente y la causa fin.

Definición: Causa fuente

Es la fuente de las obligaciones, es decir, el origen del cual surgen. Las obligaciones surgen de los contratos, en general de los actos jurídicos, y también de los actos ilícitos. No puede haber una obligación sin una causa, sin un elemento que le dé origen.

Definición: Causa fin

Es el fin perseguido por las partes al momento de celebrar un acto: qué se propusieron las partes al celebrarlo y cuál es la finalidad que persiguen.

El desarrollo que sigue se concentra en el problema de la **causa fin**, y no en la causa fuente.

56.2. Evolución histórica de la teoría de la causa

El concepto de causa ha sido objeto de debate a lo largo de la historia del derecho, dando lugar a distintas posturas doctrinarias. Elementos vinculados a la valoración de los actos aparecen desde la antigüedad, especialmente con los canonistas y los glosadores.

56.2.1. Teoría causalista

Esta teoría, atribuida a un autor francés, sostiene que la causa fin de un contrato es la prestación de la otra parte. Se presenta como algo evidente que, al celebrar un contrato sinalagmático —perfectamente bilateral, en el que una parte tiene una prestación que la obliga y la otra, a su vez, otra prestación que también la obliga—, cada parte persigue como causa la prestación de la contraria.

Ejemplo: Compraventa bajo la teoría causalista

En una compraventa, la causa por la cual una parte celebra el contrato es adquirir la cosa, y para la otra parte, la causa es recibir el precio.

56.2.2. Crítica anticausalista

Un autor belga —mencionado posteriormente por otros autores, entre ellos Planiol— critica la tesis causalista. El argumento principal sostiene que, si la causa fin es la prestación de la otra parte, entonces la causa se identifica con el objeto mismo del contrato, sin ofrecer ninguna novedad explicativa.

La crítica anticausalista señala que la idea de causa fin no agrega nada que no esté ya detrás del objeto: si el objeto es la transferencia de la propiedad (en una compraventa) y la causa es adquirir esa propiedad, causa y objeto se superponen. La postura anticausalista afirma, en consecuencia, que la causa no constituye un elemento independiente.

56.2.3. Teoría moderna de la causa

Enrique Capitant, hacia comienzos del siglo XX, retoma la idea de la causa y la profundiza. Para Capitant, la causa relevante es la finalidad perseguida por las partes, una finalidad que estas incorporan y que buscan en el momento de celebrar el acto.

56.3. La causa en el Código de Vélez

El Código Civil de Vélez no menciona la causa entre los elementos del acto de manera explícita en la sección específica de actos jurídicos. Sin embargo, el tema de la causa aparecía en algunos artículos ubicados en la parte de obligaciones (artículos 499 a 502), en el Libro Segundo, que se abría con la sección de obligaciones.

Definición: Artículo 499, Código Civil de Vélez

No hay obligación sin causa. Se entiende por tal el hecho o acto lícito o ilícito en la relación de familia, o entre extraños, que es la causa generadora del derecho que faculta al acreedor a exigir del deudor la prestación debida.

Este artículo se refiere claramente a la **causa fuente** (el hecho o acto que genera la obligación). Sin embargo, en los artículos 500 y 502, y especialmente en las notas que Vélez Sarsfield colocaba al pie de la ley —donde se critica la confusión entre causa fuente y causa fin—, aparece la idea de causa fin vinculada a la finalidad perseguida.

Definición: Artículo 502, Código Civil de Vélez (principio de la causa ilícita)

De ningún efecto es el acto constituido con una causa ilícita, si esa causa es contraria a las leyes o al orden público.

Aunque la causa no estaba expresamente mencionada como elemento en el Código de Vélez, existía la presunción de que, si las partes no expresaban la causa, esta debía existir igualmente, y la obligación se mantenía válida aun cuando la causa expresada fuera falsa.

Importante

Una obligación con causa ilícita carece de todo efecto. Si la causa es ilícita, si contraviene las leyes o el orden público, el acto es nulo.

56.4. La causa en el Código Civil y Comercial

El nuevo Código Civil y Comercial incorpora expresamente la causa como elemento del acto jurídico. El artículo 281 es la disposición central de esta regulación.

Definición: Artículo 281, Código Civil y Comercial

La causa es el fin inmediato perseguido por las partes que ha sido determinante de la voluntad. Cuando las partes no la expresan, se presume que existe. Se presume también su licitud, a menos que resulte ilícita del acto mismo. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácita, y sean esenciales para ambas partes.

En rigor, lo que resulta relevante de esta definición es que la causa es el fin perseguido por las partes que ha sido determinante de la voluntad.

56.4.1. Dimensiones objetiva y subjetiva de la causa

El artículo 281 incorpora dos dimensiones de la causa:

1. **Dimensión objetiva**: el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico. Es la finalidad típica que el derecho reconoce como válida para ese tipo de acto. En una compraventa, la causa objetiva es transferir la propiedad de una cosa a cambio de un precio.
2. **Dimensión subjetiva**: los motivos o intenciones de las partes. Estos integran la causa cuando son exteriorizados (expresados o manifestados), lícitos, y esenciales para ambas partes; es decir, cuando ambas partes conocen y aceptan esos motivos como parte de la razón por la cual celebran el acto.

Ejemplo: El caso de la profesora de francés

Una profesora de francés contrata a un escritor para que redacte un ensayo que ella presentará, traducido, en un concurso destinado a obtener una beca para viajar a Francia. La profesora presentará el ensayo como propio.
En este caso se distingue con claridad entre objeto y causa:

- El **objeto** del acto es contratar a alguien para que realice un ensayo o un trabajo. Esto es, en sí mismo, perfectamente válido y lícito.
- La **causa** (finalidad perseguida) es presentar el ensayo como propio para engañar a un concurso y obtener una beca. Esto es ilícito.

Si una parte persigue una causa ilícita pero la otra parte lo ignora, esta última no resulta afectada: el motivo ilícito no integra el acto. Pero si se interpreta que ambas partes conocen la causa y esta es esencial para ambas, entonces dicha causa integra el acto y lo vicia.

56.4.2. Síntesis de las características de la causa

1. El Código Civil y Comercial incorpora la causa como elemento del acto jurídico en el artículo 281.
2. La causa comprende dos dimensiones: una **objetiva** (el fin inmediato autorizado por el ordenamiento, determinante de la voluntad) y una **subjetiva** (los motivos o intenciones de las partes).
3. Solo integran la causa los motivos o intenciones cuando: (a) son exteriorizados, (b) son lícitos, y (c) son esenciales para ambas partes.
4. Quedan excluidos de la causa los puros motivos o intenciones personales que no estén exteriorizados ni sean esenciales para ambas partes.

56.5. Régimen de la causa

Definición: Artículo 282, Código Civil y Comercial

Cuando la causa no está expresada, se presume que existe. Se presume también su licitud, a menos que resulte ilícita del acto mismo.

El artículo 282 retoma los principios ya contenidos en los artículos 500, 501 y 502 del Código de Vélez:

- Si la causa no está expresada, se presume que existe (presunción de causa).
- El acto vale aunque la causa expresada sea falsa. Si lo que se aparenta es falso pero existe una causa verdadera, se estará ante una simulación, aunque el acto siga siendo válido.
- Una causa ilícita vicia el acto: si la causa es ilícita —contraria a las leyes y al orden público—, el acto es nulo o de ningún efecto.

56.6. Actos abstractos

Definición: Artículo 1014, Código Civil y Comercial (en materia de contratos)

La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto.

Un **acto abstracto** es aquel que se independiza de su causa y recibe un tratamiento autónomo. El caso típico es el pagaré.

Ejemplo: El pagaré

Una persona firma un pagaré porque contrae una deuda con un hospital. Al ingresar al hospital, el pagaré adquiere autonomía propia: puede circular y transferirse a terceros. Si posteriormente esa persona ya pagó al hospital y alguien pretende ejecutar el pagaré, no puede discutirse la causa (el hecho de que ya se pagó). La causa por la cual se emitió el pagaré no se discute en los títulos abstractos.

56.7. Cuadro Cornell: el acto jurídico, su objeto y su causa

El siguiente cuadro reproduce, en formato de tabla Cornell, las preguntas y respuestas centrales para el repaso activo de los contenidos desarrollados en estos capítulos.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué es un acto jurídico?	Es el acto voluntario lícito con fin inmediato de producir la adquisición, modificación o extinción de derechos, relaciones o situaciones jurídicas (art. 259, Código Civil y Comercial). Lo fundamental es que la intención directa de generar consecuencias jurídicas distingue al acto jurídico del simple acto lícito.
¿Cuál es la diferencia entre acto jurídico y simple acto lícito?	En el acto jurídico, la producción de consecuencias jurídicas es el fin inmediato e intencional. En el simple acto lícito, las consecuencias jurídicas se producen, pero no son el fin buscado (por ejemplo, el pescador que se apropia de lo que pesca). Lo determinante es la intención o finalidad del sujeto respecto del efecto jurídico.
¿Cuáles son los elementos del acto jurídico?	1. Sujeto: la persona que realiza el acto. 2. Objeto: la materia o los bienes sobre los que recae el acto. 3. Forma: la manera de exteriorizar el acto. 4. Causa: la finalidad perseguida por las partes.
¿Qué requisitos debe cumplir el objeto?	Debe ser posible (física y jurídicamente); no debe estar prohibido por la ley; debe ser lícito, es decir, conforme a la moral, a las buenas costumbres y al orden público; y no debe ser de carácter extrapatrimonial, salvo autorización legal.

Continúa en la página siguiente

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la causa del acto?	Es el fin inmediato perseguido por las partes que ha sido determinante de la voluntad (art. 281, Código Civil y Comercial). Incorpora una dimensión objetiva (el fin autorizado por el derecho) y una dimensión subjetiva (los motivos lícitos, exteriorizados y esenciales para ambas partes). Se distingue de la causa fuente (origen de la obligación), que resulta menos relevante a estos efectos.
¿Qué diferencia hay entre objeto ilícito y causa ilícita?	En el objeto ilícito, la materia misma sobre la que recae el acto es ilícita (por ejemplo, vender un bien prohibido o contratar un acto ilegal). En la causa ilícita, el objeto es lícito, pero la finalidad o el motivo que persiguen las partes es ilícito (por ejemplo, contratar la redacción de un ensayo cuyo fin es el fraude académico). Ambas vician el acto, aunque por razones distintas.
¿Qué es un acto abstracto?	Es el acto que se independiza de su causa y recibe un tratamiento autónomo. El ejemplo típico es el pagaré: una vez emitido, puede circular sin vincularse a la causa original, y dicha causa no puede discutirse al momento de su ejecución. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto.

Resumen: Los actos jurídicos constituyen el fenómeno jurídico fundamental mediante el cual las personas, voluntariamente, crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Su estudio requiere comprender que un acto jurídico no es simplemente cualquier conducta lícita: su característica esencial es que su fin inmediato es la producción intencional de consecuencias jurídicas. Para que un acto sea válido debe reunir cuatro elementos: un sujeto (persona con capacidad), un objeto (materia lícita, posible y conforme a la moral), una forma (manera de exteriorización) y una causa (finalidad perseguida). El objeto y la causa constituyen los límites más importantes a la autonomía de la voluntad: no puede haber objeto imposible, prohibido o contrario a la moral, ni causa ilícita. La distinción entre objeto ilícito y causa ilícita es crucial, porque permite comprender que un acto puede tener un objeto perfectamente válido pero una finalidad viciada. El Código Civil y Comercial introduce innovaciones relevantes: incorpora la causa expresamente como elemento (art. 281), reconoce sus dimensiones objetiva y subjetiva, y establece presunciones de existencia y licitud de la causa. Salvo en los actos abstractos (como el pagaré), la causa es siempre discutible y determinante: una causa ilícita torna nulo el acto, sin importar cuán lícito sea su objeto.

Capítulo 57

La forma del acto jurídico

57.1. Concepto de forma

Definición: Forma del acto jurídico

La forma es la exteriorización de la voluntad de los sujetos respecto del objeto, en orden a conseguir el fin jurídico y su protección al celebrar el acto. Ningún acto puede carecer de forma; en este sentido, la forma es un elemento esencial de los actos jurídicos.

La forma del acto jurídico puede ser muy variada. El ordenamiento contempla desde formas simples —como un gesto que expresa la voluntad de adquirir algo— hasta actos de gran solemnidad, como el matrimonio y el testamento, para los cuales la ley establece formas determinadas. Entre estos extremos, existen los contratos verbales, los contratos electrónicos celebrados mediante formularios por internet y los instrumentos privados y públicos.

La forma se vincula con dos cuestiones centrales del derecho civil:

- La **validez** del acto: en ciertos casos, la forma es requisito de existencia del acto y su incumplimiento genera la nulidad.
- La **prueba** del acto: en otros casos, la forma es exigida por la ley con el único fin de facilitar la demostración de que el acto fue celebrado.

57.2. Regulación en el Código Civil y Comercial

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) regula la forma del acto jurídico dentro del Capítulo Quinto dedicado a los actos jurídicos, en las siguientes secciones del Libro Primero, Título Cuarto:

- **Sección Tercera:** Forma y prueba del acto jurídico.
- **Sección Cuarta:** Instrumento público.
- **Sección Quinta:** Escritura pública.
- **Sección Sexta:** Instrumentos privados y particulares.

57.3. El formalismo en el derecho: ventajas y desventajas

La regulación jurídica de las formas no es neutral. Exige ponderarse en función de sus ventajas y desventajas para el tráfico jurídico.

57.3.1. Ventajas del formalismo

Ventaja	Explicación
Facilita la prueba del acto	El acto queda documentado y puede acreditarse con mayor certeza.
Publicita el acto	El acto es conocido por los demás; ingresa al conocimiento público.
Colabora en la percepción de impuestos	Como ocurre con los contratos de alquiler que deben informarse a la AFIP.
Permite distinguir el acto concluido de los preparatorios	La forma cristaliza el acto jurídico. Los borradores de un testamento no son un testamento; éste queda concluido con la forma mandada por la ley.
Protege a terceros	Los derechos adquiridos respecto de terceros resultan tutelados cuando se cumple la forma. El tercero conoce su situación jurídica; esto es especialmente relevante en materia de inmuebles.

Ejemplo: Testamento — cristalización del acto

Una persona puede estar pensando en hacer un testamento, consultar a distintas personas y elaborar borradores. En un momento determinado, la forma cristaliza ese acto jurídico. Los borradores no sirven: no son un testamento. El testamento queda concluido con la forma mandada por la ley: por escritura pública o por instrumento ológrafo.

57.3.2. Desventajas del formalismo

Las formas más estrictas presentan también inconvenientes:

- Las formas son más costosas y engorrosas.
- Existe mayor riesgo de que el acto resulte inválido por algún defecto formal.
- Le dan **menor celeridad** a las transacciones.
- Generan incomodidades indudables en el tráfico jurídico cotidiano.

Por estas razones, el ordenamiento jurídico impone formas más exigentes únicamente a los actos más importantes o trascendentes, donde la mayor seguridad justifica la mayor incomodidad.

Capítulo 58

Clasificación de los actos jurídicos según la forma

58.1. Forma esencial y forma instrumental

Es necesario distinguir dos sentidos del concepto de forma:

- **Forma esencial:** es la manifestación de la voluntad que realizan las partes para celebrar el acto jurídico.
- **Forma instrumental:** es cuando la ley impone que algunos actos deben celebrarse mediante documentos escritos, ya sean públicos o privados.

El Código Civil y Comercial se concentra en la forma instrumental. Los instrumentos podrán ser públicos o privados.

58.2. Primera clasificación: actos formales y no formales

Definición: Actos formales

Son aquellos respecto a los cuales la ley impone el cumplimiento de ciertas formas o solemnidades que deben cumplirse para la validez del acto. Ejemplo: el testamento, el matrimonio.

Definición: Actos no formales

Son aquellos que no tienen ninguna solemnidad prescripta por la ley; las partes son libres de realizarlos con libertad de formas.

58.3. Segunda clasificación: actos solemnes y no solemnes

Los actos formales, a su vez, se clasifican en solemnes y no solemnes:

Definición: Actos formales solemnes

Son aquellos en los que el rigor formal impuesto por la ley se vincula con la validez misma del acto. Si no se cumple con la forma, el acto es inválido.

Definición: Actos formales no solemnes (ad probationem)

Son aquellos en los que la forma es prescripta por la ley únicamente para facilitar la prueba del acto, sin afectar su validez.

58.4. Solemnidad absoluta y solemnidad relativa

Dentro de los actos formales solemnes, el Código establece una distinción fundamental:

Solemnidad absoluta	Solemnidad relativa
La solemnidad es parte esencial del acto. Si no se cumple, el acto es ineficaz por nulidad de forma y no produce ningún efecto. *Ejemplo:* El testamento ológrafo que no está escrito y firmado de puño y letra por el testador.	El acto no es válido (no genera los efectos propios del acto), pero genera la obligación de otorgar la forma prescripta. *Ejemplo:* El boleto de compraventa de un inmueble. No produce el efecto de la transferencia de la propiedad, pero sí genera la obligación de escriturar.

58.4.1. Conversión del acto jurídico

Regla: Art. 285 CCyC — Conversión del acto jurídico

El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal, pero vale como acto en el que las partes se obligan a cumplir con la expresada formalidad, salvo que ella se exija bajo sanción de nulidad.

La **conversión del acto jurídico** opera en los supuestos de solemnidad relativa: el acto no produce los efectos propios del negocio jurídico que se procuraba celebrar, pero se convierte en otro acto —la obligación de otorgar el instrumento proyectado—. Cuando la forma es exigida bajo sanción de nulidad (solemnidad absoluta), el incumplimiento genera la nulidad y no produce ningún otro efecto.

Ejemplo: Boleto de compraventa de inmueble

Una compraventa de inmueble celebrada mediante boleto de compraventa (instrumento privado) no produce el efecto traslativo de dominio, ya que la ley exige escritura pública para ello. Sin embargo, en virtud de la conversión del artículo 285, genera la obligación de las partes de escriturar, es decir, de otorgar el instrumento proyectado.

58.5. Principio de Libertad de Formas

Regla: Art. 284 CCyC — Libertad de formas

Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.

El principio de libertad de formas es la regla general del sistema. Si la ley no designa una forma determinada, las partes son libres de elegir la que consideren conveniente. Esta libertad tiene dos dimensiones:

- **Libertad de elección:** ante el silencio de la ley sobre la forma, las partes determinan libremente el modo de exteriorizar su voluntad.
- **Autonomía para elevar la forma:** las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Por ejemplo, celebrar un contrato de locación por escritura pública, aunque la ley no lo requiera.

Ejemplo: Locación por escritura pública

Las partes de un contrato de alquiler pueden convenir celebrarlo por escritura pública, aunque la ley no exija esa forma para la locación. Ello implica costos adicionales (honorarios del escribano), pero resulta perfectamente válido.

Por supuesto, cuando la ley manda una forma determinada, las partes deben partir de la forma legalmente impuesta. El artículo 284 es el punto de partida para aquellos actos respecto de los cuales la ley no designa forma especial.

Capítulo 59

Los instrumentos: clasificación general

59.1. Concepto de instrumento

El concepto de instrumento refiere a la forma escrita. Es la expresión de la voluntad a través de un documento que da mayor seguridad y certeza acerca de los derechos y obligaciones asumidos por las partes.

Regla: Art. 286 CCyC — Expresión escrita

La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.

Importante

La referencia a medios técnicos contempla los soportes informáticos y electrónicos. El Código extiende la categoría de instrumento a todo soporte inteligible, independientemente del medio requerido para su lectura.

59.2. Clasificación de los instrumentos

Instrumentos públicos	Instrumentos privados	Particulares no firmados
Interviene un oficial público. Tienen validez y fuerza probatoria por sí mismos con los alcances que les concede el Código.	Surgen de las partes. Son instrumentos particulares firmados. La **firma** es un requisito esencial.	Todo escrito no firmado: impresos, registros visuales o auditivos de cosas o hechos, registros de la palabra y de la información, cualquiera sea el medio empleado.

Regla: Art. 287 CCyC — Instrumentos particulares

Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de la información.

El Código Civil y Comercial amplió el tratamiento jurídico de esta materia respecto del Código anterior, incorporando la categoría de instrumentos particulares no firmados para dar cobertura a la realidad del tráfico contemporáneo, caracterizado por la informatización: formularios web, constancias electrónicas, mensajes de texto, registros digitales.

Ejemplo: Constancia de compra por internet

Una constancia generada por una plataforma de comercio electrónico al completar un formulario de compra en línea —que registra los datos del contrato, el precio y el método de pago— es un instrumento particular no firmado. No tiene firma en sentido estricto, por lo que no es instrumento privado con su fuerza probatoria plena, pero puede tener valor como prueba en caso de conflicto.

59.3. La firma como disposición general

Regla: Art. 288 CCyC — Firma

La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. La firma consiste en el nombre del firmante o en un signo; en ambos casos se realiza con el trazo habitual y de tal manera que identifique a la persona.

En el Código Civil y Comercial, la regulación de la firma fue trasladada de la sección de instrumentos privados —donde se encontraba en el Código de Vélez— a las disposiciones generales sobre la forma, lo que significa que rige tanto para los instrumentos públicos (incluyendo la escritura pública) como para los privados. La firma:

- Prueba la **autoría** de la declaración de voluntad.
- Expresa la **conformidad** con el contenido del documento.
- Consiste en el nombre o en un signo habitual e identificatorio de la persona.

59.3.1. Firma digital y firma electrónica

El artículo 288 contempla también la cuestión de los instrumentos generados por medios electrónicos y remite a la normativa específica sobre firma digital.

Importante

La **firma digital** no debe confundirse con el agregado de datos personales al pie de un correo electrónico (nombre, cargo, teléfono). Este último no constituye firma digital en sentido jurídico.

Definición: Firma digital (Ley 25.506 — año 2001)

Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático (algoritmo) que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante y que se encuentra bajo su absoluto control. La firma digital debe haber

sido: (a) creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante; (b) verificada por referencia a los datos de verificación de firma; y (c) generada por un certificado emitido por un certificador licenciado.

Definición: Firma electrónica

Es un conjunto de datos electrónicos, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, que el signatario utiliza con fines de identificación, pero que no alcanza el estándar de la firma digital. No cuenta con certificación indubitable de autoría e integridad.

La diferencia entre ambas figuras es fundamental en materia probatoria:

Firma digital	**Firma electrónica**
Certificación digital indubitable de **autoría** e **integridad** mediante tercero certificador licenciado. El documento firmado digitalmente no puede ser modificado con posterioridad sin que ello resulte detectable.	Identificación electrónica sin certificación indubitable. Puede ser desconocida; quien la invoca debe acreditar su validez mediante prueba.
Mayor valor probatorio. Garantizadas la autoría y la integridad.	**Menor valor probatorio.** La autoría y la integridad no están garantizadas por estas certificaciones.

Capítulo 60

Los instrumentos públicos

60.1. Concepto y caracteres

Definición: Instrumento público

Son los documentos a los cuales la ley les asigna un valor de autenticidad por sí mismos y que, como tales, no requieren de un reconocimiento previo de la firma para hacer plena fe de su contenido. La autenticidad del instrumento público proviene de la ley, no de la voluntad de las partes.

En la mayoría de los instrumentos públicos interviene un oficial público —funcionario público o escribano— que certifica la validez del acto. Sin embargo, lo que otorga la fuerza probatoria propia al instrumento público es la ley: es ella la que, ante la intervención de determinado funcionario revestido de esa credibilidad social e institucional, concede al instrumento el carácter de auténtico.

Los caracteres esenciales del instrumento público son:

- **Autenticidad:** hace plena fe de su contenido sin necesidad de reconocimiento previo.
- **Fuerza probatoria propia:** su valor probatorio proviene de la ley.
- **Oponibilidad erga omnes:** tiene valor frente a todos, no sólo entre las partes.

60.2. Enumeración legal

Regla: Art. 289 CCyC — Enumeración de instrumentos públicos

Son instrumentos públicos: a) Las escrituras públicas y sus copias o testimonios; b) Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes; c) Los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.

Cada categoría comprende:

1. **Escrituras públicas y sus copias o testimonios:** instrumento matriz del protocolo notarial y sus reproducciones autenticadas.
2. **Instrumentos de escribanos o funcionarios públicos:** comprende, entre otros, las actas notariales, las sentencias judiciales homologadas, las actas celebradas en sede judicial, y los convenios celebrados ante funcionario competente (como un convenio de alimentos labrado en sede judicial).

3. **Títulos emitidos por el Estado:** títulos de deuda pública nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitidos conforme a las leyes que autorizan su emisión.

60.3. Requisitos de validez

Regla: Art. 290 CCyC — Requisitos de validez del instrumento público

Son requisitos de validez del instrumento público: a) La actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella; b) Las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma por sí o no puede hacerlo, otro de los intervinientes lo hará a su ruego, haciéndose constar esta circunstancia.

Los dos requisitos esenciales son:

- **Competencia del oficial público:** comprende la competencia *funcional* (atribuciones para celebrar ese tipo de acto) y la competencia *territorial* (actuación dentro de la jurisdicción asignada). La actuación fuera de estos límites invalida el instrumento.
- **Firmas:** deben firmar el oficial público, las partes y, en su caso, los representantes. La falta de firma de cualquiera de los intervinientes invalida el instrumento para todos.

Importante

Es presupuesto de validez que el oficial público se encuentre efectivamente en funciones. Los actos otorgados antes de la notificación de la suspensión o cesación de funciones son válidos. Si la persona ejercía efectivamente un cargo existente bajo apariencia de legitimidad, la falta de investidura no afecta al acto ni al instrumento dentro de los límites de la buena fe.

60.4. Defectos de forma

Los defectos de forma en el instrumento público —enmiendas, agregados, borraduras, entrelineados, alteraciones— deben ser salvados al final del instrumento antes de las firmas. Si no se salvan, el instrumento carece de validez en esa parte.

Ejemplo: Enmienda en número de DNI

Si en una escritura pública se consignó erróneamente el número del documento nacional de identidad de uno de los comparecientes y se corrigió mediante una enmienda manuscrita sobre el texto impreso, esa corrección debe ser salvada al final del instrumento antes de las firmas. De lo contrario, la enmienda no salvada afecta la validez del instrumento.

Nota

Si el instrumento contiene las firmas de las partes pero adolece de un defecto que le impide valer como instrumento público (por ejemplo, por incompetencia del escribano), puede igualmente valer como **instrumento privado**, en la medida en que el acto de que se trate no exija forma pública bajo sanción de nulidad.

60.5. Eficacia probatoria del instrumento público

Este es uno de los aspectos de mayor relevancia práctica. El instrumento público hace plena fe, pero el Código distingue dos situaciones según el tipo de contenido:

Regla: Art. 296 CCyC — Eficacia probatoria del instrumento público

El instrumento público hace plena fe: a) En cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal; b) En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.

60.5.1. Hechos percibidos directamente por el oficial público

Los **hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él** —la fecha, el lugar, la celebración del acto, los hechos ocurridos en su presencia— hacen plena fe y sólo pueden ser cuestionados mediante un **juicio de redargución de falsedad** (acción civil o criminal tendiente a demostrar la falsedad del instrumento). Quien pretenda impugnarlos debe acusar al oficial público de haber faltado a la verdad, lo que supone una acusación de suma gravedad dada la credibilidad que la sociedad deposita en la función notarial.

Ejemplo: Acta notarial — constancia de hechos ante el escribano

Si un escribano labra un acta en la que consigna: «En el día de la fecha me constituí en el domicilio de la calle X y constaté que se realizaba la actividad Y, en presencia de las personas Z», quien pretenda desacreditar ese hecho debe iniciar un juicio de redargución de falsedad, dado que estaría afirmando que el escribano mintió en su función oficial.

60.5.2. Declaraciones de las partes

En cuanto al **contenido de las declaraciones de las partes** —convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto del acto—, el instrumento hace plena fe pero **admite prueba en contrario**. En este caso, no es necesario iniciar un juicio de redargución de falsedad: basta con demostrar por otros medios que el contenido de esas declaraciones no es veraz.

Ejemplo: Reconocimiento de deuda simulado

Si en una escritura pública una de las partes reconoce adeudar una suma de dinero, ese reconocimiento es el contenido de su declaración de voluntad. Si posteriormente se pretende demostrar que ese reconocimiento fue simulado, no es necesaria la redargución de falsedad —el escribano no mintió: certificó que el compareciente hizo esa declaración—, sino que puede acreditarse la simulación por prueba en contrario.

Capítulo 61

La escritura pública y las actas notariales

61.1. Concepto y protocolo notarial

Regla: Art. 299 CCyC — Escritura pública. Definición

La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, que contiene uno o más actos jurídicos.

La escritura pública es el tipo de instrumento público más importante en la regulación civil y comercial. Sus características esenciales son:

- **Instrumento matriz:** la escritura original es aquella que queda integrada al protocolo del escribano. Lo que las partes conservan en sus domicilios es una **copia** o **testimonio**, que también tiene carácter de instrumento público y hace plena fe tanto como la escritura matriz.
- **Contenido:** la escritura contiene **actos jurídicos**. Esto la distingue del acta notarial, cuyo objeto es la comprobación de **hechos**.
- **Función notarial:** los escribanos son regulados en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Código Civil y Comercial establece reglas comunes para este instrumento con validez en todo el país.

Importante

Si existe discordancia entre el texto de la copia o testimonio y el de la escritura matriz, prevalece el contenido de la escritura matriz.

61.1.1. El protocolo notarial

El protocolo está conformado por folios numerados correlativamente. No pueden quedar hojas en blanco —lo que implicaría la posibilidad de antedatar documentos. Los asientos deben realizarse en orden cronológico. La reglamentación del libro del protocolo es de competencia local (provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

61.2. Requisitos de la escritura pública

La escritura pública debe ser recibida personalmente por el escribano, quien tiene el **deber de calificación** de todos los presupuestos y elementos del acto: verifica la identidad de los comparecientes, su capacidad, la legitimidad del acto y la regularidad de los títulos.

61.2.1. Estructura: encabezado, cuerpo y pie

El contenido de la escritura pública (artículo 305 CCyC) se organiza en tres grandes partes:

Parte	Contenido
Encabezado	Lugar y fecha de otorgamiento (con posibilidad de incluir la hora). Datos de los comparecientes: nombre, apellido, documento nacional de identidad, domicilio real, estado civil. En el caso de segundas nupcias, se hace constar. Nombre del cónyuge, relevante por cuestiones vinculadas a la vivienda y al régimen patrimonial. Si comparece una persona jurídica: denominación completa, domicilio y datos del representante y de su mandato.
Cuerpo	Naturaleza del acto e individualización de los bienes que constituyen su objeto. En las transmisiones de derechos reales sobre inmuebles, incluye el **«corresponde»**: la relación de antecedentes de titularidad del bien transmitido.
Pie / Cierre	Constancia de la lectura del instrumento por el escribano ante los comparecientes. Salvado de enmiendas, borrones o entrelineados realizados antes de las firmas. Firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos, si los hubiera. Si algún compareciente no puede firmar, otro firmará a su ruego, dejándose constancia del impedimento y de la impresión digital del otorgante.

61.2.2. El «corresponde» en las transmisiones de inmuebles

El **«corresponde»** es una cláusula obligatoria en las escrituras que instrumentan transmisiones de derechos reales sobre inmuebles. Contiene la relación de todos los antecedentes en virtud de los cuales el transmitente llegó a ser titular del derecho que transmite.

Ejemplo: Cadena de antecedentes

Si el transmitente adquirió el inmueble por herencia, el corresponde consigna: «Le corresponde por declaratoria de herederos de fecha X y partición de fecha Y. A su vez, el causante lo había adquirido por escritura de fecha Z, que obra en el folio N del Registro de Propiedad Inmueble.» Esta cláusula permite encadenar las distintas escrituras y verificar la titularidad del bien a lo largo del tiempo.

La omisión del «corresponde» no genera la invalidez de la escritura, pero puede acarrear sanciones para el escribano en el ejercicio de su función profesional.

61.3. Copias y testimonios

Las copias o testimonios de la escritura matriz deben entregarse a las partes. Pueden reproducirse por cualquier medio que asegure su permanencia. Si alguna de las partes requiere una nueva copia, debe entregársele, salvo que exista una obligación de dar dinero pendiente de cumplimiento.

61.4. Actas Notariales

Regla: Art. 310 CCyC — Actas notariales

Se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos.

Definición: Acta notarial

Es el documento expedido por un escribano a requerimiento de parte, cuyo objeto es la comprobación de **hechos**. A diferencia de la escritura pública —que contiene actos jurídicos (Art. 299)—, el acta sólo constata hechos, sin crear, modificar ni extinguir relaciones jurídicas.

El acta notarial implica la concurrencia del escribano a un lugar determinado para constatar un hecho y dejar constancia de él. Entre sus aplicaciones habituales se encuentran:

- Constatación del estado de un bien al momento de su restitución (locaciones).
- Intimaciones de pago al deudor.
- Comprobación de que un acreedor se negó a recibir un pago.
- Constancia de hechos relevantes para el ejercicio de derechos.

Ejemplo: Acta de constatación al recuperar un local comercial

Al recuperar la posesión de un local comercial después de una locación, el locador puede requerir al escribano que concurra al acto de entrega de llaves y labre un acta notarial que constate el estado en que se encuentra el inmueble. El escribano describe en el acta todo lo que constata, y ese documento tendrá valor probatorio en caso de reclamarse daños o el incumplimiento de las obligaciones de restitución.

Los requisitos del acta notarial están regulados en el artículo 311 CCyC. El acta tiene valor probatorio respecto de:

- Los **hechos** que el notario tuvo a la vista: su existencia, características y estado.
- Las **personas** que concurrieron, si quisieron identificarse.
- Las **declaraciones** efectuadas por los presentes.

Nota

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula el ejercicio de la función notarial mediante la Ley 404 (año 2000). El escribano puede ser titular o adscripto. El ingreso al notariado requiere la aprobación de un procedimiento de selección competitivo y una investidura formal.

Capítulo 62

Instrumentos particulares y fecha cierta

62.1. Clasificación y jerarquía

El Código Civil y Comercial sistematiza los instrumentos particulares en dos categorías:

- **Instrumentos particulares firmados** (instrumentos privados): requieren firma de las partes como requisito esencial.
- **Instrumentos particulares no firmados**: todo escrito no firmado, registro visual o auditivo, o cualquier otro soporte inteligible sin firma.

La categoría más importante es la de los instrumentos privados (particulares firmados). Los instrumentos particulares no firmados constituyen una categoría incorporada por el nuevo Código para dar cobertura jurídica a la realidad del tráfico contemporáneo de bienes y servicios.

62.2. Instrumentos privados: el requisito de la firma

Importante

El **requisito esencial** de los instrumentos privados es la **firma** de las partes (Art. 288). Sin firma, el documento es un instrumento particular no firmado, con menor fuerza probatoria.

El Código Civil y Comercial eliminó el requisito del **doble ejemplar** que imponía el Código anterior (Código de Vélez). En virtud de ello, ya no es jurídicamente exigible que los instrumentos se celebren en tantos ejemplares como partes intervinientes. No obstante, la buena práctica profesional recomienda mantener este recaudo, especialmente cuando una de las partes asume obligaciones relevantes.

62.3. Reconocimiento de la firma

El instrumento privado tiene una firma que prueba la declaración de voluntad, pero para que se produzca la plenitud de la fuerza probatoria entre las partes, la firma debe ser **reconocida**.

Regla: Art. 314 CCyC — Reconocimiento de la firma

Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestarse al respecto. El silencio se tendrá por reconocimiento de la firma.

Importante

El silencio frente a la intimación de reconocimiento de firma equivale al reconocimiento. Esto constituye un supuesto de silencio como manifestación de la voluntad (Art. 263 CCyC): ante la obligación legal de expedirse, el silencio importa aceptación tácita.

El reconocimiento de la firma puede ser:

- **Expreso:** la persona declara que la firma le pertenece.
- **Tácito:** guarda silencio ante la intimación, o realiza gestiones sin desconocer la autoría de la firma.
- **Forzoso:** se acredita mediante prueba, especialmente a través de la **pericia caligráfica** (cotejo de firmas realizado por un perito calígrafo designado judicialmente).

Ejemplo: Negación de contrato de locación

Si el locatario niega haber suscripto el contrato de alquiler, el locador puede exhibirle el instrumento en juicio e intimarlo a que reconozca la firma. Si la niega, podrá acreditarse la autoría mediante pericia caligráfica, que establecerá con alta probabilidad la autenticidad de la firma atribuida al demandado.

El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento de todo el cuerpo del instrumento: las cláusulas, disposiciones, convenciones y reconocimientos que contiene. Lo que el instrumento público tiene por sí, el instrumento privado lo adquiere con el reconocimiento de firma.

62.4. Firma a ruego e impresión digital

Regla: Art. 313 CCyC — Firma a ruego e impresión digital

Si alguno de los firmantes no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o bien de la firma de otra persona a ruego, en presencia de dos testigos que también lo suscriban.

Cuando una parte no sabe o no puede firmar, el Código prevé dos alternativas:

1. **Firma a ruego:** otra persona firma en nombre del que no puede hacerlo, en presencia de dos testigos que también suscriben el instrumento. Esta modalidad tiene pleno valor probatorio, similar a un mandato.
2. **Impresión digital:** la estampación de la huella dactilar del signatario. Sin embargo, conforme al artículo 314 CCyC, el documento signado con impresión digital vale

únicamente como **principio de prueba por escrito** y puede ser impugnado. Su menor valor probatorio obedece a que la impresión digital puede obtenerse sin el pleno consentimiento de la persona.

62.5. Documento firmado en blanco

Regla: Art. 315 CCyC — Documento firmado en blanco

El firmante de un documento en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento del documento no puede invocarse para afectar al tercero que de buena fe celebró un acto jurídico basándose en él.

El documento firmado en blanco implica una suerte de mandato implícito: quien firma en blanco autoriza al receptor del documento a completarlo dentro de las instrucciones acordadas. Si el documento fue completado en forma contraria a esas instrucciones, el firmante puede impugnar su contenido, pero con importantes limitaciones probatorias:

- No puede valerse exclusivamente de testigos si no existe principio de prueba por escrito.
- Si el instrumento fue utilizado de buena fe por un tercero que celebró un acto jurídico basándose en él, ese tercero queda protegido: el firmante no puede invocar el desconocimiento del documento en su perjuicio.

Importante

La firma de documentos en blanco es una práctica de alto riesgo, ya que quien tiene el documento puede completarlo con obligaciones enormemente perjudiciales para el patrimonio del firmante.

62.6. Enmiendas en instrumentos privados

Las enmiendas, raspaduras o entrelineados que afecten partes esenciales del instrumento privado deben ser salvadas al final, con la firma de las partes. Diferencia con la escritura pública: en los instrumentos privados, las enmiendas no salvadas no generan la nulidad del instrumento, sino que el juez determinará en qué medida el defecto excluye o reduce su fuerza probatoria.

62.7. Fecha Cierta y Oponibilidad a Terceros

62.7.1. El instrumento privado frente a terceros

El instrumento privado tiene fuerza probatoria entre las partes desde el reconocimiento de la firma. Frente a terceros, sin embargo, rige una regla diferente: el instrumento privado **no es oponible** a terceros mientras no adquiera **fecha cierta**.

Regla: Art. 317 CCyC — Fecha cierta

La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después.

Definición: Fecha cierta

No es la fecha consignada en el instrumento, sino el momento a partir del cual existe certeza objetiva de que ese instrumento ya estaba firmado o no pudo ser firmado con posterioridad. Sirve para hacer oponible el instrumento privado a terceros.

62.7.2. Medios para adquirir fecha cierta

El Código de Vélez (artículo 1035) enumeraba taxativamente los casos de adquisición de fecha cierta:

- Exhibición del instrumento en juicio o ante una repartición pública donde quedara archivado.
- Reconocimiento ante un escribano y testigos.
- Transcripción en cualquier registro público.
- Fallecimiento de la parte que lo firmó.

El Código Civil y Comercial **abandona la enumeración taxativa** y establece que la fecha cierta puede acreditarse por cualquier medio de prueba, que el juez apreciará de manera rigurosa.

Ejemplo: Fecha cierta por exhibición en juicio

Cuando un instrumento privado se incorpora a un expediente judicial, la mesa de entradas de tribunales le estampa un sello que acredita la fecha de presentación. Desde ese momento existe certeza de que el instrumento ya existía: puede oponerse a terceros como instrumento firmado con anterioridad a esa fecha.

Ejemplo: Fecha cierta por fallecimiento del firmante

Si uno de los firmantes de un instrumento privado fallece, desde ese momento se tiene certeza de que el instrumento fue firmado antes de la muerte: con posterioridad al fallecimiento, esa persona ya no pudo haberlo suscripto. El instrumento adquiere fecha cierta desde el día del fallecimiento.

Capítulo 63

Instrumentos particulares no firmados y correspondencia

63.1. Concepto y amplitud

Los instrumentos particulares no firmados comprenden todos los escritos no firmados, impresos, registros visuales o auditivos de cosas o hechos, cualquiera sea el medio empleado, y los registros de la palabra y de la información. Esta amplísima categoría abarca tanto los soportes en papel como los medios electrónicos: mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, tickets electrónicos, registros de plataformas web.

Nota

A diferencia de los instrumentos privados, los instrumentos particulares no firmados no cuentan con firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad; su ausencia implica que el instrumento tiene menor fuerza probatoria y que la valoración de su alcance queda librada a la apreciación judicial.

63.2. Fuerza probatoria — criterios del juez

Regla: Art. 319 CCyC — Valor probatorio del instrumento particular

El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.

Las pautas que el juez debe ponderar son:

1. **Congruencia entre lo sucedido y lo narrado:** correspondencia entre lo que dice el instrumento y los hechos ocurridos y acreditados por otros medios.
2. **Precisión y claridad técnica del texto:** un formulario web completo y preciso tendrá mayor valor que un mensaje informal con redacción ambigua.
3. **Usos y prácticas del tráfico:** la forma habitual en que se concluyen los actos jurídicos en ese sector de actividad o negocio.
4. **Relaciones precedentes entre las partes:** el historial de intercambios previos que contextualice el instrumento en cuestión.

5. **Confiabilidad de los soportes y procedimientos técnicos empleados:** la seguridad e integridad de los sistemas informáticos utilizados para generar o transmitir el instrumento.

Ejemplo: Ticket electrónico como prueba

En un conflicto sobre el pago del precio en una compraventa de bienes, el comprador presenta el ticket generado por la plataforma de comercio electrónico y el resumen de tarjeta de crédito que registra el débito correspondiente. La congruencia entre ambos elementos es un indicio de peso que el juez puede ponderar para tener por acreditado el pago.

63.3. La correspondencia

Regla: Art. 318 CCyC — Correspondencia

La correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente.

La correspondencia —cartas, correos electrónicos, mensajes— pertenece, una vez recibida, al destinatario. Éste puede utilizarla como prueba en juicio contra el remitente, con la excepción de la **correspondencia confidencial**: si la comunicación tiene carácter confidencial, no puede ser utilizada sin el consentimiento del remitente.

La confidencialidad puede surgir:

- De la manifestación expresa de las partes (por ejemplo, que el remitente la haya designado así).
- De la naturaleza misma de la comunicación (una carta dirigida a un amigo de confianza sobre asuntos personales).

Esta protección tiene fundamento constitucional: la **inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados** reconocida por la Constitución Nacional como garantía vinculada a la intimidad y privacidad de las personas.

Ejemplo: Uso de correspondencia confidencial

Si alguien envía una carta a un amigo en la que reconoce adeudar sumas de dinero a terceros, y ese amigo entrega la carta a los acreedores para que la usen en un juicio, el uso de esa correspondencia puede ser cuestionado por su carácter confidencial. Sin el consentimiento del remitente, los destinatarios originales no pueden utilizarla.

63.4. Cuadro Cornell: forma e instrumentos del acto jurídico

Pregunta / Concepto clave	Notas / Respuesta
¿Qué es la forma del acto jurídico? ¿Es un elemento esencial?	Es la exteriorización de la voluntad de los sujetos respecto del objeto, en orden a conseguir el fin jurídico. Ningún acto puede carecer de forma: en ese sentido, la forma es un elemento esencial.
¿Cuáles son las dos dimensiones de la forma?	La forma tiene incidencia sobre la **validez** del acto (en ciertos casos, su incumplimiento produce nulidad) y sobre la **prueba** del acto (en otros casos, la forma es exigida sólo para facilitar su demostración).
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del formalismo?	*Ventajas:* facilita la prueba, publicita el acto, colabora en la percepción impositiva, permite distinguir el acto concluido de los preparatorios y protege a los terceros. *Desventajas:* mayor costo, mayor riesgo de invalidez por defecto formal, menor celeridad en las transacciones, incomodidades prácticas.
¿Cuál es el principio general que rige la forma? (Art. 284)	El **principio de libertad de formas**: si la ley no designa una forma determinada, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las propias partes pueden pactar formas más exigentes que las legales.
¿Cómo se clasifican los actos según la forma?	Actos **formales** (con forma legal impuesta) y **no formales** (libertad de formas). Los formales se subdividen en **solemnes** (la forma es requisito de validez) y **no solemnes** o *ad probationem* (la forma es exigida sólo para la prueba).
¿Qué diferencia hay entre solemnidad absoluta y solemnidad relativa?	En la **solemnidad absoluta**, el incumplimiento produce la nulidad del acto, sin ningún otro efecto. En la **solemnidad relativa**, el acto no produce los efectos propios del negocio, pero genera la obligación de otorgar la forma prescripta (conversión del acto jurídico, Art. 285).
¿Qué es la conversión del acto jurídico? (Art. 285)	Es el efecto propio de la solemnidad relativa: el acto no concluido en la forma requerida por la ley no queda concluido como tal, pero vale como acto por el cual las partes se obligan a cumplir con la formalidad, siempre que ésta no sea exigida bajo sanción de nulidad. Ejemplo: el boleto de compraventa genera la obligación de escriturar.

¿Cuáles son las categorías de instrumentos en el CCyC? (Arts. 286–287)	(1) Instrumentos **públicos**: con autenticidad propia por ley. (2) Instrumentos **privados**: particulares firmados; requisito esencial: firma (Art. 288). (3) Instrumentos **particulares no firmados**: todo escrito, registro visual, auditivo o electrónico sin firma.
¿Qué prueba la firma? ¿Qué diferencia hay entre firma digital y firma electrónica? (Art. 288, Ley 25.506)	La firma prueba la **autoría** de la declaración de voluntad. La **firma digital** garantiza autoría e integridad mediante algoritmo matemático y certificado emitido por certificador licenciado. La **firma electrónica** es sólo un conjunto de datos identificatorios sin esa certificación; puede ser desconocida y su validez debe acreditarse.
¿Qué son los instrumentos públicos y cuáles son sus caracteres? (Art. 289)	Son los documentos a los que la ley les atribuye autenticidad propia, sin necesidad de reconocimiento previo. Hacen plena fe de su contenido. Enumeración: escrituras públicas y copias, instrumentos de escribanos o funcionarios públicos, y títulos emitidos por el Estado.
¿Cuáles son los requisitos de validez del instrumento público? (Art. 290)	(a) Actuación del oficial público dentro de sus **atribuciones** (competencia funcional) y **competencia territorial**. (b) **Firmas** del oficial, las partes y sus representantes. La falta de cualquier firma invalida el instrumento para todos.
¿Cómo funciona la eficacia probatoria del instrumento público? (Art. 296)	Distingue dos regímenes: (a) Los **hechos percibidos por el oficial** (fecha, lugar, actos cumplidos ante él) sólo pueden cuestionarse mediante **juicio de redargución de falsedad**. (b) El **contenido de las declaraciones de las partes** hace plena fe pero admite **prueba en contrario** sin necesidad de redargución.
¿Qué es la escritura pública y en qué se diferencia del acta notarial? (Arts. 299 y 310)	La **escritura pública** es el instrumento matriz extendido en el protocolo notarial que contiene **actos jurídicos**. El **acta notarial** es el documento notarial que tiene por objeto la comprobación de **hechos**. La distinción es esencial: la escritura crea, modifica o extingue derechos; el acta sólo constata hechos.
¿Qué estructura tiene la escritura pública? (Art. 305)	Tres partes: (1) **Encabezado**: lugar, fecha y datos de los comparecientes. (2) **Cuerpo**: naturaleza del acto, individualización de bienes y, en transmisiones de inmuebles, el «corresponde». (3) **Pie**: constancia de lectura, salvado de enmiendas, firmas.

¿Qué es el «corresponde» y para qué sirve?	Es la cláusula que, en las escrituras de transmisión de derechos reales sobre inmuebles, relaciona todos los antecedentes de titularidad del bien. Permite encadenar las sucesivas escrituras y verificar la historia dominial. Su omisión no invalida la escritura pero puede generar sanciones para el escribano.
¿Cuál es el requisito esencial del instrumento privado y cómo se reconoce la firma? (Arts. 288 y 314)	El requisito esencial es la **firma**. Para que el instrumento tenga plena fuerza probatoria entre las partes, la firma debe ser **reconocida**: expresa, tácita (el silencio frente a la intimación equivale a reconocimiento, Art. 314) o forzosa (pericia caligráfica). El reconocimiento de firma implica el reconocimiento de todo el contenido del instrumento.
¿Qué es la firma a ruego y cuál es la diferencia con la impresión digital? (Art. 313)	La **firma a ruego** es la firma de un tercero en nombre de quien no sabe o no puede firmar, en presencia de dos testigos. Equivale a la firma y otorga plena fuerza probatoria. La **impresión digital** sólo vale como *principio de prueba por escrito* (Art. 314) y puede ser impugnada, por su menor seguridad.
¿Qué es la fecha cierta y para qué sirve? (Art. 317)	Es el momento a partir del cual existe certeza objetiva de que el instrumento ya estaba firmado o no pudo firmarse después. Desde la fecha cierta, el instrumento privado es **oponible a terceros**. El CCyC abandona la enumeración taxativa del Código anterior: la fecha cierta puede acreditarse por cualquier medio, que el juez apreciará rigurosamente.
¿Cómo valora el juez un instrumento particular no firmado? (Art. 319)	Debe ponderar: congruencia entre lo narrado y lo ocurrido; precisión y claridad técnica del texto; usos y prácticas del tráfico; relaciones precedentes entre las partes; y confiabilidad de los soportes y procedimientos técnicos empleados.
¿Puede utilizarse la correspondencia como prueba en juicio? (Art. 318)	Sí: el destinatario puede presentarla como prueba contra el remitente. Sin embargo, si la correspondencia es **confidencial** —por manifestación expresa o por la naturaleza de la comunicación—, no puede utilizarse sin consentimiento del remitente. Esta protección tiene fundamento constitucional (inviolabilidad de la correspondencia).

Resumen: La forma del acto jurídico es el modo en que la voluntad de las partes se exterioriza y produce efectos jurídicos. El CCyC parte del principio de libertad de formas (Art. 284), pero impone formas determinadas para los actos más trascendentes, con distintas consecuencias según se trate de solemnidad absoluta (nulidad del acto) o relativa (conversión: obligación de otorgar la forma prescripta, Art. 285). En materia de instrumentos, el Código distingue tres grandes categorías: los **instrumentos públicos**, que gozan de autenticidad propia y hacen plena fe, con dos regímenes de impugnación según se trate de hechos percibidos por el oficial (redargución de falsedad) o de declaraciones de las partes (prueba en contrario); la **escritura pública**, instrumento matriz del protocolo notarial que contiene actos jurídicos y requiere una estructura formal precisa; y los **instrumentos particulares**, que incluyen los privados (requisito esencial: firma; fuerza probatoria plena tras el reconocimiento) y los particulares no firmados (fuerza probatoria sujeta a la apreciación judicial según las pautas del Art. 319). La **firma digital** (Ley 25.506) garantiza autoría e integridad en el mundo digital, con mayor valor probatorio que la firma electrónica. La **fecha cierta** (Art. 317) determina desde cuándo el instrumento privado puede oponerse a terceros, y puede acreditarse por cualquier medio apreciado rigurosamente por el juez. Estas reglas configuran un sistema orientado a dar seguridad jurídica al tráfico de bienes y servicios, equilibrando la certeza del formalismo con la agilidad que demanda la vida contemporánea.

Capítulo 64

Clasificación de los actos jurídicos

En el régimen del Código de Vélez se enunciaba expresamente una serie de clasificaciones de los actos jurídicos —unilaterales y bilaterales, entre otras—. El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) vigente, en cambio, optó metodológicamente por no incluir una clasificación sistematizada de los actos jurídicos: no existen artículos dedicados a definir de manera unificada las distintas clases de actos. Sin embargo, estas clasificaciones subsisten y se manifiestan a lo largo de todo el articulado, en la medida en que el Código atribuye consecuencias jurídicas distintas según el acto sea bilateral, entre vivos o de última voluntad, oneroso o gratuito, entre otras categorías.

Nota

Estas clasificaciones no son puramente teóricas, sino que tienen consecuencias prácticas concretas y se encuentran presentes en distintos lugares del Código. A lo largo de las distintas asignaturas del plan de estudios de abogacía es habitual encontrar aplicaciones de estas categorías.

Su relevancia práctica es amplia: saber si un acto es formal o no formal determina si se requiere escritura pública; saber si es oneroso o gratuito modifica las reglas de buena fe aplicables (art. 392, CCyC); y saber si el acto está sujeto a condición, plazo o cargo indica en qué momento nace, se suspende o se extingue la obligación asumida. Estas categorías atraviesan los contratos, las sucesiones, el derecho de familia, las obligaciones y los derechos reales, y constituyen el marco conceptual necesario para interpretar el Código en su conjunto.

Ejemplo: Aplicación integradora de las clasificaciones

En la redacción de una compraventa de un inmueble, dicho acto resulta simultáneamente bilateral, oneroso, formal (requiere escritura pública), patrimonial y de disposición. Si además las partes acuerdan que la entrega quede sujeta a que el banco apruebe el crédito del comprador, se configura una condición suspensiva; si se pacta que el contrato se resuelve en caso de que el banco no se expida dentro de los sesenta días, se configura un plazo resolutorio; y si el vendedor se compromete a pintar el departamento antes de la entrega, se configura un cargo. De este modo, las clasificaciones y las modalidades estudiadas en este capítulo convergen en un único documento cotidiano de la práctica profesional.

64.1. Actos Unilaterales y Bilaterales

El criterio de esta clasificación es el número de partes que concurren a la celebración del acto.

Definición: Actos unilaterales y bilaterales

El acto es **unilateral** cuando una sola parte concurre a su celebración. Es **bilateral** cuando dos o más partes concurren a su celebración.

Tipo de acto	Definición	Ejemplo típico
Unilateral	Una sola parte concurre a la celebración del acto.	El testamento
Bilateral	Dos o más partes concurren a la celebración del acto.	Un contrato; el matrimonio

Cuadro 64.1: Actos unilaterales y bilaterales

64.2. Actos entre Vivos y de Última Voluntad

Definición: Actos entre vivos y de última voluntad

Los actos **entre vivos** son otorgados por personas vivas para producir efectos en vida de los otorgantes. Los actos **de última voluntad** son aquellos que producen sus efectos luego de la muerte de quien los otorga.

Tipo de acto	Definición	Cuándo produce efectos
Entre vivos	Son otorgados por personas vivas para producir efectos en vida.	Desde el momento de su celebración
De última voluntad	Producen sus efectos luego de la muerte del otorgante.	Desde la muerte del otorgante

Cuadro 64.2: Actos entre vivos y de última voluntad

64.3. Actos a Título Oneroso y a Título Gratuito

Esta clasificación resulta especialmente relevante a lo largo de todo el Código, dado que el CCyC tiende a proteger de manera diferenciada a quienes adquieren a título oneroso y de buena fe frente a quienes adquieren a título gratuito.

Definición: Actos onerosos y gratuitos

El acto es **oneroso** cuando existen prestaciones recíprocas: cada parte entrega algo a cambio de lo que recibe. El acto es **gratuito** (o a título de liberalidad) cuando una de las partes recibe una prestación sin dar nada a cambio, lo cual enriquece a esa parte.

Tipo de acto	Definición	Ejemplo
Oneroso	Hay prestaciones recíprocas: cada parte da algo a cambio.	Compraventa
Gratuito (liberalidad)	Una de las partes recibe sin dar nada a cambio; enriquece a esa parte.	Donación; renuncia a un derecho

Cuadro 64.3: Actos a título oneroso y a título gratuito

El caso típico del título gratuito es la donación, pero también puede configurarse a título gratuito la renuncia a un derecho: quien tiene derecho a cobrar y renuncia a ese cobro está beneficiando a la otra parte sin recibir nada a cambio.

Regla: Art. 392, CCyC — Efectos respecto de terceros en cosas registrables

El Código diferencia la protección al subadquirente según haya adquirido a título oneroso o gratuito. El subadquirente de buena fe y a título oneroso goza de mayor protección.

64.4. Actos Principales y Accesorios

Definición: Actos principales y accesorios

Los actos **principales** son aquellos que no dependen, para su existencia, de otro acto. Los actos **accesorios** son aquellos que siguen la suerte del acto principal, del cual dependen para existir.

Tipo de acto	Definición	Ejemplo
Principal	No depende de otro acto para existir.	Contrato de alquiler
Accesorio	Sigue la suerte del principal; depende de él para existir.	La garantía del contrato de alquiler

Cuadro 64.4: Actos principales y accesorios

A modo de ejemplo, una garantía que acompaña a un contrato de alquiler constituye un acto accesorio respecto del principal y sigue su suerte, sin perjuicio de los matices particulares que se estudian en cada contrato en concreto.

64.5. Actos Formales y No Formales

Esta es una clasificación de particular importancia, que se desarrolla en profundidad en el capítulo 57.

Definición: Actos formales y no formales

Los actos **formales** son aquellos en los que la ley prescribe cierta solemnidad. Dentro de estos, la solemnidad puede hacer a la validez del acto (**formal solemne** o absolutamente formal) o hacer únicamente a su prueba (**formal no solemne** o relativamente formal). Los actos **no formales** son aquellos respecto de los cuales la ley no exige una forma determinada, quedando las partes en libertad de elegir la que prefieran.

Tipo de acto	Definición	Consecuencia del incumplimiento de la forma
Formal solemne (absolutamente formal)	La ley prescribe una solemnidad cuyo incumplimiento invalida el acto.	Nulidad del acto
Formal no solemne (relativamente formal)	La ley prescribe una forma, pero su incumplimiento afecta solo la prueba, no la validez.	Puede probarse por otro medio
No formal	La ley no manda ninguna forma determinada; las partes pueden elegir la que prefieran.	No hay consecuencia: el acto es válido

Cuadro 64.5: Actos formales y no formales

Ejemplo: Acto formal solemne

El matrimonio es un acto formal solemne: se encuentra rodeado de una serie de solemnidades marcadas por el Código Civil y no puede celebrarse sino de acuerdo con los rituales que este establece. Cualquier otra forma determina que el matrimonio no sea válido.

Ejemplo: Acto no formal

El alquiler de un inmueble es, en principio, un acto no formal: la ley no exige que se celebre por escritura pública. No obstante, las partes pueden optar por una forma más solemne que la exigida legalmente —por ejemplo, contratando a un escribano— por razones de seguridad jurídica, sin que ello sea un requisito legal.

64.6. Actos Patrimoniales y Extrapatrimoniales

Definición: Actos patrimoniales y extrapatrimoniales

Los actos **patrimoniales** tienen contenido económico y están vinculados con el patrimonio. Los actos **extrapatrimoniales** no tienen contenido económico directo y se vinculan con derechos personalísimos o con el derecho de familia.

Tipo de acto	Definición	Ejemplo
Patrimonial	Tiene contenido económico; está vinculado con el patrimonio.	Un contrato de compraventa
Extrapatrimonial	No tiene contenido económico directo; vinculado con derechos personalísimos o de familia.	El reconocimiento de un hijo

Cuadro 64.6: Actos patrimoniales y extrapatrimoniales

El reconocimiento de un hijo es un acto jurídico unilateral mediante el cual una persona expresa su voluntad de reconocerlo. Se trata de un acto típico del derecho de familia, extrapatrimonial en sí mismo, aun cuando pueda tener consecuencias patrimoniales indirectas, como el derecho a alimentos. Los actos vinculados con derechos personalísimos también son extrapatrimoniales.

64.7. Actos de Disposición, de Administración y de Conservación

Definición: Actos de disposición, administración y conservación

Los actos de **disposición** producen una variación sustancial en la composición del patrimonio. Los actos de **administración** no producen un cambio sustancial en el patrimonio. Los actos de **conservación** están dedicados al mantenimiento de los bienes.

Tipo de acto	Definición	Ejemplo
Disposición	Se produce una variación sustancial en la composición del patrimonio.	Venta de un inmueble: sale el bien, entra dinero
Administración	No produce un cambio sustancial en el patrimonio.	Cobrar un alquiler, recibir una renta
Conservación	Dedicados al mantenimiento de los bienes.	Reparaciones, actos de preservación

Cuadro 64.7: Actos de disposición, administración y conservación

Nota

Esta clasificación resulta especialmente relevante en el derecho de familia y de las personas, en materia de tutela, curatela y régimen de poderes. El representante legal de una persona incapaz, por ejemplo, necesita autorización judicial para los actos de disposición, pero no para los de administración ordinaria.

64.8. Actos Puros y Simples, y Actos Modales

Definición: Actos puros y simples, y actos modales

Los actos **puros y simples** no están sujetos a ninguna modalidad y producen sus efectos de inmediato. Los actos **modales** son aquellos en los cuales las partes eligen sujetarlo a alguno de los tres modos posibles: condición, plazo o cargo.

Tipo de acto	Definición
Puro y simple	No está sujeto a ninguna modalidad. Produce efectos de inmediato.
Modal	Las partes eligen sujetarlo a alguno de los tres modos: condición, plazo o cargo.

Cuadro 64.8: Actos puros y simples, y actos modales

64.9. Actos Causales y Abstractos

La noción de acto abstracto se desarrolla también al estudiar el régimen de la causa (capítulo 56).

Definición: Actos causales y abstractos

El acto **causal** permanece vinculado a su causa, la cual influye en su validez y en sus efectos. El acto **abstracto** se independiza de su causa.

Tipo de acto	Definición
Causal	El acto permanece vinculado a su causa; la causa influye en su validez y efectos.
Abstracto	El acto se independiza de su causa.

Cuadro 64.9: Actos causales y abstractos

64.10. Actos Positivos y Negativos

Definición: Actos positivos y negativos

El acto **positivo** involucra una acción, es decir, un hacer. El acto **negativo** involucra una omisión, es decir, un no hacer.

Tipo de acto	Definición	Ejemplo
Positivo	Involucra una acción (un hacer).	Entregar una cosa, pagar una suma
Negativo	Involucra una omisión (un no hacer).	Comprometerse a no competir en un rubro comercial

Cuadro 64.10: Actos positivos y negativos

Ejemplo: Acto negativo: cláusula de no competencia

Es habitual que quienes se dedican a una determinada actividad —por ejemplo, la producción de helados— al vender la marca y la empresa se comprometan a no generar una nueva empresa ni emprendimientos vinculados con ese rubro durante los próximos cinco años. Este acto jurídico se encuadra dentro de los actos negativos, en tanto las partes se obligan a un «no hacer», es decir, a una omisión.

Capítulo 65

Modalidades del acto jurídico

Las modalidades del acto jurídico son la condición, el plazo y el cargo. En el régimen del Código de Vélez, las modalidades estaban reguladas dentro de la sección de obligaciones del Libro Segundo. En el Código Civil y Comercial vigente, en cambio, se las incorporó al Libro Primero, Título Cuarto, dentro del capítulo de hechos y actos jurídicos, en un capítulo específico dedicado a las modalidades del acto jurídico.

65.1. La Condición

Regla: Art. 343, CCyC — Alcances

Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto.

Definición: Condición

La condición es una cláusula por la cual se subordina la adquisición o la resolución de un acto a un hecho futuro e incierto. Lo esencial de la noción es la incertidumbre: el hecho condicionante puede o no llegar a suceder.

Ejemplo: Condición suspensiva (1)

«Te voy a regalar un auto si Argentina sale campeón del mundo en el próximo mundial.» Se trata de un hecho futuro e incierto: puede ocurrir o no. El efecto —la donación del auto— queda suspendido hasta que ocurra, o no, el hecho condicionante.

Ejemplo: Condición suspensiva (2)

«Te voy a regalar mi biblioteca jurídica si te recibís de abogado/a.» El hecho es incierto: puede ocurrir o no. La obligación existe desde la constitución del acto, pero no es exigible —no tiene plena eficacia— hasta el momento en que ocurre el hecho condicionante.

Ejemplo: Condición resolutoria

«Te dono mi auto, pero siempre y cuando mi hermano no vuelva de España. Si mi hermano vuelve, tenés que devolverme el auto.» Aquí el acto ya produce efectos desde el principio; el hecho condicionante produce la resolución, es decir, la devolución de los efectos hacia atrás.

Tipo de condición	Punto de partida	Efecto del hecho condicionante
Suspensiva	El acto existe pero NO produce efectos todavía.	Si ocurre el hecho, el acto produce sus efectos; si no ocurre, el acto no produce efectos.
Resolutoria	El acto YA produce efectos desde su celebración.	Si ocurre el hecho, los efectos cesan (se resuelven), con retroactividad.

Cuadro 65.1: Diferencia entre condición suspensiva y resolutoria

65.1.1. La Condición Impropia o Suposición

El nuevo Código incorporó también la llamada «condición impropia» o «suposición»: aquella en la que las partes condicionan el acto a un hecho presente o pasado que, al momento del acto, es ignorado por ellas.

Regla: Art. 343, CCyC (segundo párrafo)

Se equipara a la condición la cláusula por la cual las partes sujetan la eficacia del acto a la existencia de cierto estado de cosas al tiempo de celebrarlo.

Ejemplo: Condición impropia o suposición

Una persona ignora la situación patrimonial de un familiar que vive lejos y, sin saberlo, celebra un acto sujeto a que ese familiar no haya caído en quiebra: por ejemplo, «te presto la plata en la medida en que tal familiar mío no haya terminado en quiebra». Aunque el hecho ya ocurrió o no ocurrió al momento de celebrar el acto, la incertidumbre subjetiva de las partes —que lo ignoran— hace que este supuesto también valga como condición.

65.1.2. Clasificación de las Condiciones

Criterio	Tipo	Descripción
Según el hecho	Positiva	Implica una acción (que algo ocurra).
Según el hecho	Negativa	Implica una omisión (que algo no ocurra).
Según el efecto	Suspensiva	Subordina la eficacia del acto a un hecho futuro e incierto.
Según el efecto	Resolutoria	Subordina la extinción del acto a un hecho futuro e incierto.
Según la fuente	Causal	El hecho no depende de las partes; depende del azar o de un tercero.
Según la fuente	Potestativa	Depende de la voluntad del deudor o del acreedor.
Según la fuente	Mixta	Depende en parte del deudor y en parte de un tercero o del azar.

Cuadro 65.2: Clasificación de las condiciones

La condición **causal** no depende de las partes, sino del azar o de un tercero —por ejemplo, que la selección nacional resulte campeona—. La condición **potestativa** depende del acreedor o del deudor —por ejemplo, «te voy a regalar mi biblioteca si te recibís de abogado/a» es potestativa del acreedor—. La condición **mixta** depende en parte del deudor y en parte de un hecho ajeno a él.

Importante

La condición puramente potestativa del deudor está prohibida: «te comprometo a entregarte algo si yo decido hacerlo» no puede depender completamente de la voluntad del obligado.

65.1.3. Condiciones Prohibidas

Regla: Art. 344, CCyC — Condiciones prohibidas

Es nula la condición que: (1) sea un hecho imposible, (2) sea contraria a las buenas costumbres, (3) esté prohibida por el ordenamiento jurídico, (4) dependa exclusivamente de la voluntad del obligado (puramente potestativa). La condición de no hacer algo imposible no perjudica la validez de la obligación.

Regla: Art. 345, CCyC — Condiciones que gravan libertades fundamentales

Las condiciones cuyo cumplimiento depende de que el beneficiario cambie de domicilio, religión u otras libertades fundamentales se tienen por no escritas.

Ejemplo: Condición que grava una libertad fundamental

«Te dono la casa si cambiás de religión» constituye una condición prohibida, en tanto grava la libertad fundamental de profesar la religión que la persona elija.

Tipo de condición prohibida	Consecuencia jurídica
Hecho imposible / contraria a buenas costumbres / puramente potestativa (art. 344, párr. 1)	Nulidad absoluta del acto
Que grava libertades fundamentales (art. 345, párr. 3)	Se tiene por no escrita (la obligación principal podría subsistir)
Imposible en testamentos (excepción)	La condición se tiene por no puesta; la disposición vale

Cuadro 65.3: Condiciones prohibidas y sus consecuencias

Existe una diferencia entre el primer y el tercer párrafo del artículo 344: las condiciones ilícitas del primer párrafo producen la nulidad absoluta del acto, mientras que las condiciones comprendidas en el tercer párrafo se tienen por no escritas, discutiéndose en la doctrina si la obligación principal subsiste o no. La excepción se presenta en los testamentos: las condiciones prohibidas incorporadas en un testamento no afectan la validez de las disposiciones testamentarias de las que forman parte.

65.2. El Plazo

A diferencia de la condición, el plazo es la modalidad que posterga o limita temporalmente los efectos del acto. En el plazo hay un hecho futuro pero **cierto**: se sabe que va a ocurrir, aunque no siempre se sepa exactamente cuándo.

Ejemplo: Plazo suspensivo y plazo resolutorio

Plazo suspensivo: «Te voy a donar estas casas dentro de un año.» No hay incertidumbre sobre si llegará el día, aunque pueda haberla sobre el momento exacto en el caso del plazo incierto. Plazo resolutorio: «Te presto el uso de la casa por un año.» Los efectos comienzan de inmediato, pero cesan cuando vence el plazo.

Tipo de plazo	Definición	Ejemplo
Suspensivo	Posterga los efectos del acto hasta el vencimiento del plazo.	«Te dono la casa dentro de un año.»
Resolutorio	Los efectos del acto cesan al vencimiento del plazo.	«Te presto la casa por un año.»
Cierto	Se conoce la fecha exacta del vencimiento.	«En 30 días», «el 31 de diciembre»
Incierto	No se sabe exactamente cuándo vencerá, pero es seguro que ocurrirá.	«Cuando muera tal persona»
Determinado	Las partes, la ley o el juez fijaron la fecha o el momento.	La ley o el contrato establece una fecha
Indeterminado	No se precisó fecha, pero existe un plazo posible.	Cláusula «a mejor fortuna» (art. 889, CCyC)
Esencial	El cumplimiento fuera de término no satisface el interés del acreedor.	Catering para una fiesta: si llega dos semanas tarde, ya no sirve
Accidental	El cumplimiento tardío puede igualmente satisfacer el interés del acreedor.	Entrega de materiales de construcción con demora

Cuadro 65.4: Clasificación del plazo

Ejemplo: Plazo esencial

Una persona contrata un servicio de catering para una fiesta y, por un error, el servicio se entrega dos semanas después del evento. El plazo era esencial —la fiesta misma— por lo que la prestación tardía no satisface el interés del acreedor y el incumplimiento es total.

El plazo puede surgir de la convención de las partes, de la ley, puede ser judicial, o bien indeterminado, cuando se establece la fecha de inicio pero no la de finalización.

Regla: Art. 889, CCyC — Cláusula «a mejor fortuna»

El Código admite la cláusula «a mejor fortuna»: «yo te presto plata y me devolvés cuando estés bien económicamente.» Se trata de un plazo indeterminado. El juez, a solicitud del acreedor, puede fijar un plazo y hacer cumplir la obligación.

65.3. El Cargo

Definición: Cargo

El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho, que no impide los efectos del acto pero que, sin embargo, puede exigirse.

Ejemplo: Cargo simple

Una persona dona un campo a otra con el cargo de que mantenga en la casa a los caseros. Si el donatario no cumple, los caseros podrán exigir el cumplimiento del cargo o reclamar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento; sin embargo, en principio, el acto de donación no se cae.

Ejemplo: Cargo con finalidad benéfica

Se dona a una fundación un terreno con el cargo de que el producto de la explotación económica de ese terreno se destine a obras para los barrios vulnerables. La fundación que recibe la donación debe administrar el bien conforme a ese cargo.

Característica	Condición	Cargo
Suspende efectos del acto	SÍ (si es suspensiva)	NO
Coercible (exigible)	Cuando se cumple el hecho: sí	Sí, siempre
Si falla en cumplirlo, revoca el acto	Sí (si es resolutoria)	Solo si fue impuesto como cargo condicional
Quién puede exigirlo	Las partes	Los beneficiarios y quien constituyó el derecho

Cuadro 65.5: Diferencias entre condición y cargo

El cargo es coercitivo pero no suspensivo, a diferencia de la condición suspensiva, que sí suspende los efectos. El cargo siempre se impone al adquirente como una obligación que debe cumplir y, en tanto obligación, debe reunir los requisitos propios de las obligaciones: ser lícito, posible, determinado y de contenido patrimonial. Surge de la autonomía de la voluntad, es excepcional y accidental —puede o no estar presente—, constituye una obligación accesoria del derecho transmitido, debe ser expreso y es restrictivo del derecho adquirido, en la medida en que recibir algo con el cargo de cumplir una obligación restringe el derecho de quien lo recibe.

65.3.1. Cargo Simple y Cargo Condicional

Tipo de cargo	Definición	Consecuencia del incumplimiento
Cargo simple	Obligación accesoria que no condiciona la adquisición del derecho.	Se exige el cumplimiento o se reclaman daños. El acto no se revoca.
Cargo condicional	El cumplimiento del cargo fue puesto como condición del acto.	Si no se cumple, se puede revertir la adquisición del derecho. Opera como condición resolutoria.

Cuadro 65.6: Cargo simple y cargo condicional

El cargo simple no tiene efecto resolutorio sobre el derecho principal. El cargo condicional, en cambio, opera como una condición resolutoria (o suspensiva), de modo que su incumplimiento afecta a la propia adquisición del derecho: si el cargo fue puesto como condicional, la adquisición puede revertirse en caso de incumplimiento.

65.3.2. Cargos Prohibidos

Regla: Art. 357, CCyC — Cargos prohibidos

Son de aplicación a los cargos las normas establecidas para las condiciones prohibidas (art. 344, CCyC). Sin embargo, cuando se impone un cargo prohibido, no se produce la nulidad del acto, sino que el cargo se tiene por no escrito.

Los cargos prohibidos son, en su contenido, los mismos supuestos previstos para las condiciones prohibidas: el artículo 357 remite al artículo 344. La diferencia radica en la consecuencia: cuando se impone un cargo prohibido, este se tiene por no escrito, sin que ello acarree la nulidad del acto principal.

65.4. Cierre y Síntesis

Al finalizar el desarrollo de las clasificaciones y las modalidades del acto jurídico —condición, plazo y cargo— corresponde una aclaración fundamental sobre la naturaleza de estas últimas.

Importante

Las modalidades —condición, plazo y cargo— **no** son una clasificación de los actos jurídicos. Son modos, cláusulas, elementos accidentales de un acto jurídico: pueden o no estar presentes. Si las partes las pactan, rigen las reglas de su regulación civil; si no las incorporan, el acto es puro y simple y produce efectos de inmediato.

Los actos jurídicos son manifestaciones de voluntad orientadas a producir efectos jurídicos. El Código Civil y Comercial no los clasifica en un artículo único, sino que sus categorías atraviesan todo el texto legal. Estas clasificaciones —unilateral/bilateral, entre vivos/última voluntad, oneroso/gratuito, principal/accesorio, formal/no formal, patrimonial/extrapatrimonial, disposición/administración/conservación, puro/modal, causal/abstracto, positivo/negativo— no son puramente teóricas: determinan las reglas aplicables en cada situación jurídica concreta. Sobre esa base, el acto puede quedar sujeto a modalidades accidentales: la condición (hecho futuro e incierto que suspende o resuelve los efectos), el plazo (hecho futuro cierto que posterga o limita los efectos en el tiempo) y el cargo (obligación accesoria que no suspende el acto, pero que es coercitiva). Cada modalidad presenta variantes propias, reglas de validez específicas y artículos particulares dentro del CCyC (arts. 343 a 357).

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

65.5. Cuadro Cornell: clasificación y modalidades de los actos jurídicos

El siguiente cuadro reúne, según el método Cornell, las preguntas centrales que permiten repasar activamente el contenido desarrollado en los capítulos anteriores, junto con sus respuestas y una síntesis final integradora.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué son las clasificaciones de los actos jurídicos y para qué sirven?	Son categorías doctrinarias —y en gran parte también legales— que agrupan los actos según criterios como el número de partes, el momento de producción de efectos, la existencia de prestaciones recíprocas, la dependencia respecto de otro acto, la forma, el contenido patrimonial o el nivel de variación del patrimonio. No son puramente teóricas: determinan las reglas aplicables al acto en cada situación concreta del Código y de la práctica profesional.
Diferencia entre acto unilateral y bilateral. Ejemplos.	Unilateral: una sola parte (el testamento). Bilateral: dos o más partes (el contrato, el matrimonio). Esta diferencia resulta clave porque el régimen de perfeccionamiento, revocación y efectos es distinto en cada caso.
¿Por qué importa si un acto es oneroso o gratuito?	El CCyC protege de manera distinta a los subadquirentes según hayan adquirido a título oneroso o gratuito. Conforme el art. 392, CCyC, quien adquiere de buena fe y a título oneroso goza de mayor protección frente a la evicción y otras acciones de terceros que quien adquirió gratuitamente.
Acto formal solemne vs. formal no solemne vs. no formal.	Formal solemne: la forma es requerida para la validez; si no se cumple, el acto es nulo (testamento, matrimonio). Formal no solemne: la forma prescrita afecta solo la prueba; el acto igual es válido. No formal: la ley no exige ninguna forma; las partes eligen cómo exteriorizar su voluntad.
¿Qué es la condición? Definición legal.	Cláusula por la cual se subordina la adquisición o la resolución de un acto a un hecho futuro e incierto (art. 343, CCyC). Lo esencial es la incertidumbre: el hecho puede o no ocurrir. Si el hecho es cierto, se trata de un plazo, no de una condición.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
Condición suspensiva vs. resolutoria.	Suspensiva: los efectos del acto no se producen hasta que ocurra el hecho condicionante; el acto existe, pero no es exigible. Resolutoria: el acto ya produce efectos; si ocurre el hecho, los efectos cesan y se resuelven retroactivamente. Ejemplo de suspensiva: «te dono la biblioteca si te recibís». Ejemplo de resolutoria: «te dono el auto, pero si vuelve mi hermano, me lo devolvés».
¿Qué condiciones están prohibidas? Consecuencias.	Son nulas las condiciones que: (1) son imposibles, (2) son contrarias a las buenas costumbres, (3) son puramente potestativas del deudor (art. 344, CCyC). Se tienen por no escritas las que gravan libertades fundamentales, como la religión o el domicilio (art. 345). En los testamentos, las condiciones prohibidas no afectan la validez de la disposición testamentaria.
Diferencia entre condición y plazo.	En ambos casos el hecho es futuro. La diferencia clave es la certeza: en la condición el hecho es incierto (puede no ocurrir); en el plazo el hecho es cierto (se sabe que ocurrirá, aunque no siempre se sepa exactamente cuándo, como en el plazo incierto: «cuando muera tal persona»).
Tipos de plazo según su certeza y determinación.	Cierto: se conoce la fecha exacta. Incierto: no se sabe cuándo, pero es seguro que ocurrirá. Determinado: fijado por las partes, la ley o el juez. Indeterminado: sin fecha precisada (por ejemplo, la cláusula «a mejor fortuna», art. 889, CCyC). Esencial: el cumplimiento tardío no satisface el interés del acreedor (catering para una fiesta). Accidental: el cumplimiento tardío igualmente puede satisfacer el interés del acreedor.
¿Qué es el cargo? ¿Suspende los efectos del acto?	El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho que NO suspende los efectos del acto: el acto produce efectos de inmediato. Sin embargo, el cargo es coercitivo: puede exigirse su cumplimiento. Si fue impuesto como condición (cargo condicional), su incumplimiento puede revertir la adquisición del derecho. Los cargos prohibidos se tienen por no escritos (art. 357, que remite al art. 344, CCyC), sin que ello invalide el acto principal.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Son las modalidades una clasificación de los actos jurídicos?	No. Las modalidades (condición, plazo, cargo) son elementos accidentales del acto jurídico: pueden o no estar presentes. Si las partes las incorporan, el acto queda sujeto a esas reglas; si no las incorporan, el acto es puro y simple y produce efectos de inmediato, sin condicionamiento alguno.

Resumen: Los actos jurídicos admiten múltiples clasificaciones —según el número de partes, el momento de sus efectos, la existencia de contraprestación, su dependencia de otro acto, su forma, su contenido patrimonial y su incidencia en el patrimonio— que determinan las reglas aplicables en cada caso concreto del Código Civil y Comercial. Además de estas clasificaciones, el acto jurídico puede quedar sujeto a modalidades accidentales: la condición (hecho futuro e incierto), el plazo (hecho futuro cierto) y el cargo (obligación accesoria y coercitiva que no suspende el acto). Cada modalidad tiene reglas propias de validez, variantes específicas y condiciones o cargos expresamente prohibidos por la ley (arts. 343 a 357, CCyC). Comprender estas categorías es la base del razonamiento jurídico: permiten leer el Código, redactar documentos, asesorar a clientes y resolver casos con precisión técnica en cualquier rama del derecho privado.

Capítulo 66

Principios generales de los efectos del acto jurídico

66.1. Introducción: los efectos del acto jurídico

El estudio de los efectos del acto jurídico se organiza como un sistema concéntrico. El núcleo es el principio ***nemo plus iuris*** (nadie transmite más de lo que tiene), que luego se proyecta hacia las partes, sus representantes, los sucesores y, finalmente, los terceros. Puede pensarse como las ondas que produce una piedra en el agua: el acto jurídico es la piedra, y cada onda alcanza a un grupo diferente de personas con reglas propias.

Definición: Acto jurídico

Acto **voluntario lícito** que tiene por fin inmediato producir el **nacimiento, la modificación, la transferencia o la extinción** de relaciones e instituciones jurídicas.

Por definición, entonces, el acto jurídico busca producir efectos jurídicos. La cuestión central consiste en determinar **a quiénes abarcan esos efectos**. Los interrogantes que estructuran el tema son los siguientes:

- ¿Los efectos abarcan a las partes?
- ¿Cómo están abarcados los sucesores?
- ¿Cómo están abarcados los acreedores?
- ¿Quiénes son representantes?
- ¿Qué reglas rigen estos efectos de los actos jurídicos?

66.1.1. Importancia práctica

Estos conceptos constituyen el fundamento de cada operación jurídica que realiza un abogado o una abogada. Se proyectan, por ejemplo, en las siguientes situaciones:

- **Redacción de un contrato de compraventa:** es necesario saber si el cliente puede transmitir válidamente el derecho que pretende vender (*nemo plus iuris*).
- **Otorgamiento o recepción de un poder notarial:** debe determinarse si el representante actuó dentro de sus facultades.
- **Asesoramiento a herederos:** se distingue qué obligaciones del causante los alcanzan y cuáles se extinguen.

- **Cobro de un crédito impago:** se elige entre la acción directa —para cobrar directamente— y la acción subrogatoria —para ingresar bienes al patrimonio del deudor—.

No se trata de temas abstractos: son herramientas cotidianas de la abogacía en materia contractual, sucesoria y ejecutiva.

66.2. Nemo plus iuris (Art. 399 CCyC)

66.2.1. La transmisibilidad de los derechos como regla general

Los derechos son **transmisibles**, salvo estipulación válida de las partes o prohibición legal. Sobre esta base se establece la regla central que organiza todo el tema: **nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene**.

Esta regla ya se encontraba en el Código anterior, en el art. 3270: nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, salvo las excepciones legalmente dispuestas. Proviene del Derecho Romano y en algunos libros se la designa como *nemo plus iuris*, por sus primeras palabras. Ya estaba presente en el Digesto.

Regla: Art. 399 CCyC — Regla general (*nemo plus iuris*)

Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas.

Nota

El *nemo plus iuris* se encuentra en el art. 399, hacia el final del Libro Primero del Código Civil y Comercial de la Nación, dentro del Título Quinto, denominado «Transmisión de los derechos». Esto se relaciona con el estudio de los efectos del acto: quien transmite derechos no puede transmitirlos de un modo mejor que el que tiene.

Ejemplo: el inquilino que no puede vender

Quien es inquilino de un inmueble no puede venderlo, porque no puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. Su derecho sobre el inmueble es simplemente el uso y goce en los términos de un contrato de locación, y no el derecho en los términos del dominio del dueño de la cosa. Esto constituye claramente un **límite a la transmisibilidad de los derechos**.

66.2.2. Caso práctico: Juan, Verónica y Daniela

El principio se ilustra con un caso que involucra a tres personas.

Ejemplo: transmisión de propiedad viciada por intimidación

Juan ejerce violencia (intimidación) sobre Verónica y logra que ella le transfiera su propiedad bajo amenazas. Juan aparece como propietario, pero su título está viciado por intimidación. Luego, Juan le vende el inmueble a Daniela.

Pregunta: ¿Daniela recibió la propiedad con el vicio o sin él?

Conforme al *nemo plus iuris*, Juan transmite el derecho con el mismo alcance que lo tiene, es decir, con el vicio. Por lo tanto, Daniela, como sucesora, recibiría un derecho afectado por ese vicio de intimidación.

66.3. Excepciones al *nemo plus iuris*

El mismo caso plantea una **excepción crucial** al principio general: es necesario determinar si Daniela es o no de buena fe. Pueden presentarse, así, excepciones al *nemo plus iuris*.

66.3.1. Adquirente de buena fe y a título oneroso (Art. 392 CCyC)

Una de esas excepciones se encuentra en el art. 392. Si Daniela es de **buena fe** y a **título oneroso**, adquiere la propiedad, y quien sale perdiendo es Verónica —quien transmitió bajo intimidación—, porque Daniela se convierte en adquirente de buena fe a título oneroso. **Quien es de buena fe queda protegido.**

Regla: Art. 392 CCyC — Efectos respecto de terceros en casos de nulidad

El subadquirente de buena fe y a título oneroso queda a salvo de cualquier acción de nulidad que afecte el antecedente de su título, así como de los actos de los que fueran parte terceros de buena fe, con anterioridad a la inscripción de la sentencia que no fueren supuestos de restricciones a la capacidad, simulación o fraude.

66.3.2. Otros supuestos de protección de terceros

Los supuestos en que los terceros quedan protegidos frente al principio general son los siguientes:

- los **cambios en los poderes que no son oponibles**, según dependa de la posibilidad o no de hacerlos conocer a los terceros (cuestión vinculada con la protección de los terceros y la confirmación);
- el **poseedor de buena fe de cosas muebles**, que queda protegido;
- los supuestos de **simulación** (Art. 337);
- los supuestos de **fraude** (Art. 340).

66.4. Cuadro Cornell: principios generales

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué busca producir el acto jurídico y cuál es la cuestión central sobre sus efectos?	El acto jurídico es un acto voluntario lícito cuyo fin inmediato es producir el nacimiento, la modificación, la transferencia o la extinción de relaciones e instituciones jurídicas; por definición, busca producir efectos jurídicos. La cuestión central es a quiénes abarcan esos efectos: las partes, los sucesores, los acreedores y los representantes, y qué reglas los rigen.
¿Qué es el *nemo plus iuris*?	Regla del art. 399 CCyC: nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Proviene del Derecho Romano (estaba ya en el Digesto) y se encontraba en el Código anterior (art. 3270). Se ubica en el Título Quinto del Libro Primero, «Transmisión de los derechos». Es un principio cardinal del derecho privado. Los derechos son transmisibles, salvo estipulación válida de las partes o prohibición legal.
¿Cómo opera el *nemo plus iuris* en el caso de Juan, Verónica y Daniela?	Juan obtuvo la propiedad de Verónica mediante intimidación y luego se la vendió a Daniela. Juan transmite el derecho con el mismo alcance que lo tiene, es decir, con el vicio; por lo tanto, Daniela, como sucesora, recibe un derecho afectado por ese vicio, salvo que sea adquirente de buena fe y a título oneroso (art. 392 CCyC).
¿Cuándo queda protegido el adquirente frente al *nemo plus iuris*?	Según el art. 392 CCyC, el subadquirente de buena fe y a título oneroso queda a salvo de cualquier acción de nulidad que afecte el antecedente de su título; en el caso, Daniela adquiere y quien pierde es Verónica. También quedan protegidos el poseedor de buena fe de cosas muebles, los terceros en los supuestos de simulación (art. 337) y de fraude (art. 340), y los cambios en los poderes que no son oponibles a terceros.
¿Por qué un inquilino no puede vender el inmueble que alquila?	Porque no puede transmitir un derecho mejor que el que tiene: su derecho es solo al uso y goce en los términos de un contrato de locación, y no en los términos del dominio del dueño de la cosa. Es un límite a la transmisibilidad de los derechos.
Resumen: El acto jurídico busca producir efectos, y el primer principio para determinar su alcance es el *nemo plus iuris* (art. 399 CCyC): nadie transmite un derecho mejor o más extenso que el que tiene, de modo que el adquirente recibe el derecho con sus vicios. La excepción estudiada es la del adquirente de buena fe y a título oneroso (art. 392 CCyC), a la que se suman otros supuestos de protección de terceros.	

Capítulo 67

Las partes y el efecto relativo de los actos jurídicos

67.1. Efecto relativo de los actos jurídicos (Art. 1021 CCyC)

El segundo gran marco teórico es el efecto relativo. Los actos jurídicos producen efectos entre las partes que los celebran; es decir, tienen un **efecto relativo**: sus efectos afectan a las partes que celebran el acto.

Regla: Art. 1021 CCyC — Regla general (efecto relativo)

El contrato solo tiene efectos entre las partes contratantes; no lo tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.

Nadie puede verse afectado ni beneficiado por un acto del que no fue parte. Los actos jurídicos tienen valor entre las partes; como regla general, así lo establece el art. 1021.

67.2. Definición de parte (Art. 1023 CCyC)

La noción de «parte» resulta decisiva para determinar quién queda alcanzado por los efectos del acto. Esto conduce a considerar cuál es la definición de «parte», que se encuentra en el art. 1023.

Definición: Parte

Parte es quien concurre a un acto ejerciendo prerrogativas jurídicas propias.

Art. 1023 CCyC — Parte del contrato. Se considera parte del contrato a quien:

a) lo otorga a nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno;

b) es representado por un otorgante que actúa en su nombre o en su interés;

c) manifiesta la voluntad contractual, aunque sea transmitida por un corredor o por un agente sin representación.

67.2.1. Distinción entre parte y representante

Quien actúa en nombre propio, o por medio de un representante que actúa en su nombre, es la parte, aunque en el acto conste que concurre el señor Fulanito de Tal en representación de Menganito de Tal. En ese caso, la parte es el **representado** (Menganito de Tal). El **representante** no ejerce una prerrogativa jurídica propia, sino la de otro.

67.3. Cuadro Cornell: partes y efecto relativo

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es el efecto relativo de los actos jurídicos?	Los contratos solo producen efectos entre las partes (art. 1021 CCyC); no los producen respecto de terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Un tercero ni puede beneficiarse ni perjudicarse por un acto en el que no intervino, salvo excepciones legales (estipulación a favor de tercero, acciones directa y subrogatoria).
¿Quién es «parte» en un acto jurídico?	Quien concurre al acto ejerciendo prerrogativas jurídicas propias (art. 1023 CCyC). Se considera parte a quien: a) otorga el contrato a nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno; b) es representado por un otorgante que actúa en su nombre o en su interés; c) manifiesta la voluntad contractual, aunque sea transmitida por un corredor o por un agente sin representación.
¿Es parte el representante?	No. El representante no ejerce una prerrogativa jurídica propia, sino la de otro: actúa en nombre del representado, quien sí es la parte, aunque en el acto conste que concurre otra persona en su representación. El mandante de un poder, por ejemplo, es la parte aunque no esté presente.

Resumen: Los actos jurídicos tienen efecto relativo: producen efectos entre las partes y, como regla, no alcanzan a terceros (art. 1021 CCyC). Es parte quien concurre ejerciendo prerrogativas jurídicas propias (art. 1023 CCyC); por eso, cuando hay representación, la parte es el representado y no el representante.

Capítulo 68

La representación

El Código regula, en el Título Cuarto del Libro Primero, todo lo relativo a la representación. Esta materia es muy importante para la vida de los abogados, ya que generalmente quienes ejercen la profesión cumplen funciones de representación, dadas por poderes o por distintos mecanismos.

68.1. Tipos de representación (Art. 358 CCyC)

El art. 358 del CCyC clasifica la representación en tres tipos:

Tipo	Origen	Ejemplo
Voluntaria	Acto jurídico (poder notarial)	Juana le otorga poder a Daniela para celebrar un contrato de mutuo en su nombre.
Legal	Regla de derecho (la ley)	Padres que representan a sus hijos menores (Art. 101 CCyC); tutores; curadores.
Orgánica	Estatuto de persona jurídica	El presidente de una sociedad que firma contratos porque el estatuto le atribuye esa función.

68.2. Representación voluntaria (Arts. 362–381 CCyC)

Los arts. 362 a 381 regulan la forma, la capacidad, los vicios, la actuación y la extinción de la representación voluntaria. En cuanto a la capacidad:

- **Representante:** basta con el **discernimiento**. Puede serlo desde que tiene discernimiento para los actos lícitos, a los trece años.
- **Representado:** se requiere capacidad para otorgar el poder; debe ser una persona capaz.

68.3. Facultades expresas (Art. 375 CCyC)

El art. 375 es de máxima relevancia práctica: regula los casos en que se requieren **facultades expresas**. Quien, como abogado, vaya a realizar alguno de estos actos de mayor relevancia necesita lo que se denomina un **poder especial** de su representado.

Regla: Art. 375 CCyC — Facultades expresas

Las facultades para ciertos actos deben ser expresas. Entre ellos:

- reconocer hijos;
- aceptar herencias;
- contraer matrimonio;
- hacer donaciones;
- avalar;
- constituir hipotecas;
- otorgar testamentos;
- transar;
- comprometer en árbitros;
- y otros actos de especial trascendencia.

68.4. Cuadro Cornell: representación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué tipos de representación existen y cuál es el origen de cada una?	Arts. 358 y ss. CCyC. 1) **Voluntaria**: surge de un acto jurídico (poder notarial). 2) **Legal**: surge de la ley (padres respecto de hijos menores, tutores, curadores). 3) **Orgánica**: surge del estatuto de una persona jurídica (presidente de una sociedad).
¿Qué capacidad se requiere en la representación voluntaria?	Arts. 362 a 381 CCyC. Para el representante basta con el discernimiento, que se tiene desde los trece años para los actos lícitos. Para otorgar el poder se requiere capacidad en el representado, que debe ser una persona capaz.
¿Cuándo se requieren facultades expresas y qué se necesita en esos casos?	Art. 375 CCyC: las facultades para ciertos actos deben ser expresas, y para ellos se necesita un poder especial del representado. Entre esos actos: reconocer hijos, aceptar herencias, contraer matrimonio, hacer donaciones, avalar, constituir hipotecas, otorgar testamentos, transar, comprometer en árbitros y otros actos de especial trascendencia.
Resumen: La representación puede ser voluntaria (nace de un acto jurídico), legal (nace de la ley) u orgánica (nace del estatuto de una persona jurídica). En la representación voluntaria basta el discernimiento para el representante, mientras que el representado debe ser capaz para otorgar el poder. Para los actos de mayor relevancia enumerados en el art. 375 CCyC se requieren facultades expresas, es decir, un poder especial.	

Capítulo 69

Los sucesores

A un acto concurren las partes con sus representantes. Después se encuentran los **sucesores**, que son aquellos que reciben un derecho. El sucesor puede ser **universal** o **singular**.

69.1. Sucesor universal

Definición: Sucesor universal

Es quien recibe **todo o una parte indivisa del patrimonio** de otro.

Quien sucede a su padre porque este falleció se convierte en su sucesor universal. Y aunque sean dos herederos, ambos son universales porque tienen **vocación al todo**.

Ejemplo: sucesión entre dos hermanos

Supongamos que el padre tiene un departamento, una cochera, un auto y dinero en efectivo. Los dos hermanos tienen vocación al todo: sin testamento, cada uno al 50 %. No es que cada uno tenga el 50 % del dinero más el 50 % del auto: cada uno tiene vocación al todo.

Después, en la partición, si uno se queda con el departamento y el otro con todos los demás bienes, en ese momento cada uno se convierte en sucesor singular de lo que recibió.

Regla: Art. 1024 CCyC — Efectos respecto de los sucesores universales

Los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley.

Los límites de la transmisión a los sucesores universales se ilustran con el siguiente ejemplo.

Ejemplo: obligación inherente a la persona (pintor famoso)

Supongamos que se contrata a un pintor famoso —con nombre propio, por sus condiciones artísticas— para que realice un retrato. Si el pintor fallece, su sucesor no puede venir a cumplir el contrato, porque se trata de una obligación inherente a la persona del artista.

Tampoco se transmiten las obligaciones de derecho de familia, ni se transmite el usufructo o el contrato de uso y habitación.

69.2. Sucesor singular

Definición: Sucesor singular

Es quien recibe un **derecho determinado** (por ejemplo, un inmueble o un auto); es decir, quien sigue un bien determinado.

Importante

Los sucesores singulares, por regla, **no se ven afectados** por los actos jurídicos de la parte de quien reciben el bien, y se asimilan a los terceros completamente extraños. La excepción está dada por:

- los actos jurídicos que son **antecedentes del derecho transmitido**;
- las **obligaciones que pesan sobre la cosa**;
- los **derechos accesorios del objeto**.

Ejemplo: inmueble con contrato de locación

Quien hereda un inmueble sujeto a un contrato de locación recibe el inmueble con el contrato de locación, aunque sea sucesor singular, porque sigue un bien determinado.

Ejemplo: auto con prenda

Quien hereda un auto sujeto a una prenda hereda el auto con la prenda: la prenda lo afecta. Esa es la consecuencia de ser sucesor singular.

69.3. Cuadro Cornell: sucesores

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué son los sucesores universales?	Quienes reciben la totalidad o una parte indivisa del patrimonio de otra persona (art. 1024 CCyC): herederos *ab intestato* o testamentarios. Aunque sean varios herederos, todos son universales porque tienen vocación al todo.
¿Se extienden los efectos del contrato a los sucesores universales y cuáles son los límites?	Sí: los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales (art. 1024 CCyC), salvo que las obligaciones sean inherentes a la persona, que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o que esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley.
¿Qué ejemplos de obligaciones o derechos no se transmiten a los sucesores universales?	La obligación de un pintor famoso contratado por sus condiciones artísticas para realizar un retrato (obligación inherente a la persona: si fallece, su sucesor no puede cumplir el contrato); las obligaciones de derecho de familia; el usufructo o el contrato de uso y habitación.
¿Qué son los sucesores singulares y qué los afecta?	Quienes reciben un derecho determinado (un inmueble, un auto). Se asimilan a terceros respecto de los actos del causante, pero los afectan: los antecedentes del derecho transmitido, las obligaciones y cargas que pesan sobre la cosa y los derechos accesorios del objeto (por ejemplo, la prenda sobre un auto heredado, o la locación de un inmueble heredado).
¿Cuándo un sucesor universal se convierte en singular?	En la partición: si, por ejemplo, de los bienes del padre un hermano se queda con el departamento y el otro con los demás bienes, cada uno se convierte en sucesor singular de lo que recibió.

Resumen: Los sucesores universales reciben todo o una parte indivisa del patrimonio y ocupan el lugar del causante: los efectos del contrato se les extienden activa y pasivamente, salvo obligaciones inherentes a la persona, incompatibles con la naturaleza de la obligación o vedadas por el contrato o la ley (art. 1024 CCyC). Los sucesores singulares siguen un bien determinado: por regla no se ven afectados por los actos de la parte de quien lo reciben, salvo por los antecedentes del derecho transmitido, las obligaciones que pesan sobre la cosa y los derechos accesorios del objeto.

Capítulo 70

Los terceros y las acciones a su disposición

70.1. Situación de los terceros

Los terceros no pueden ni beneficiarse ni perjudicarse por los contratos, salvo que exista disposición legal o que así se haya convenido entre las partes. Por regla, los terceros son **ajenos** y no pueden verse afectados por las disposiciones de un acto en el que no fueron parte.

Ejemplo: estipulación a favor de un tercero

Supongamos que se establece una estipulación a favor de un tercero: «yo le voy a dar plata para que vos le des a Fulanito de Tal tanto en tales asistencias». Esto es una estipulación a favor de un tercero y es perfectamente válido.

70.2. Las acciones de los acreedores frente a terceros

Cuando un acreedor debe actuar frente a quien no es parte en el vínculo que lo une con su deudor, el ordenamiento le concede, excepcionalmente, la **acción directa** (arts. 736 y 737 CCyC) contra el deudor de su deudor y la **acción subrogatoria** (arts. 739 y 740 CCyC) para ejercer los derechos de un deudor inactivo. Ambas se desarrollan y se comparan en el capítulo 49, junto con la acción de simulación y la acción de inoponibilidad, estudiadas en la Parte VI.

70.3. Cuadro Cornell: terceros y acciones

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Puede un contrato obligar o beneficiar a un tercero?	Por regla, no: los terceros son ajenos y no pueden ni beneficiarse ni perjudicarse por los contratos, salvo disposición legal o que se haya convenido entre las partes. Por ejemplo, es perfectamente válida una estipulación a favor de un tercero.
¿Qué es la acción directa y qué requisitos tiene?	Permite al acreedor cobrar lo que un tercero debe a su deudor, actuando directamente contra el deudor de su deudor, hasta el importe de su propio crédito (arts. 736–737 CCyC). La ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio; es excepcional y de interpretación restrictiva. Requisitos: crédito exigible del acreedor contra su deudor; deuda correlativa exigible del tercero a favor del deudor; homogeneidad de ambos créditos; ningún crédito embargado ni indisponible; notificación de la demanda al deudor.
¿Qué es la acción subrogatoria y qué derechos quedan excluidos?	El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, ocupa el lugar de su deudor remiso y ejerce judicialmente los derechos patrimoniales que este no ejerce, cuando esa omisión afecta el cobro de su acreencia (arts. 739–740 CCyC). El acreedor no goza de preferencia sobre los bienes obtenidos. Quedan excluidos los derechos inherentes a la persona del deudor, los no patrimoniales, los patrimoniales no susceptibles de ejecución forzada y los excluidos por disposición legal.
¿En qué se diferencian la acción directa y la subrogatoria?	Directa: exige créditos homogéneos; el acreedor actúa por derecho propio, en su nombre; beneficia solo al acreedor que la ejerce; se limita al importe de su crédito. Subrogatoria: exige la inacción del deudor que perjudica al acreedor; el acreedor actúa en nombre del deudor; lo recuperado ingresa al patrimonio del deudor y beneficia a todos los acreedores.
Resumen: Los terceros, por regla, son ajenos al acto y no pueden beneficiarse ni perjudicarse por él, salvo disposición legal o convenio. Excepcionalmente, un acreedor puede actuar mediante la acción directa, que cobra contra el deudor del deudor y solo beneficia a quien la ejerce (arts. 736–737 CCyC), o mediante la acción subrogatoria, que ejerce en nombre del deudor inactivo y beneficia a todos los acreedores (arts. 739–740 CCyC).	

70.4. Síntesis general de los efectos del acto jurídico

Los efectos del acto jurídico se rigen por dos principios estructurantes: el ***nemo plus iuris*** (nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene, Art. 399 CCyC) y el **efecto relativo** (los actos solo producen efectos entre las partes, Art. 1021 CCyC).

A partir de estos ejes, el sistema regula quiénes resultan alcanzados:

- las **partes**;
- sus **representantes** (voluntarios, legales u orgánicos);
- los **sucesores universales**, que ocupan el mismo lugar que el causante en todos los derechos y obligaciones transmisibles;
- los **sucesores singulares**, que solo reciben los antecedentes del derecho transmitido, las cargas sobre la cosa y sus accesorios.

Los **terceros**, en principio ajenos, pueden excepcionalmente actuar mediante la **acción directa** (Arts. 736–737 CCyC) o la **acción subrogatoria** (Arts. 739–740 CCyC).

Estas instituciones son herramientas cotidianas de la práctica jurídica: delimitan quiénes quedan obligados por los contratos, cómo se transmiten los bienes en una sucesión y de qué modo un acreedor puede cobrar su crédito cuando el deudor es negligente.

Parte XIII

Vicios de los actos jurídicos: voluntad, equilibrio y sinceridad

Un acto jurídico puede existir y, sin embargo, presentar defectos que impiden que produzca todos sus efectos normales. Esta parte estudia los vicios de la voluntad (error, dolo y violencia), el vicio de lesión, que afecta el equilibrio de las prestaciones, y los vicios de simulación y de fraude, que afectan la sinceridad del acto y la garantía de los acreedores.

Capítulo 71

Los vicios de los actos jurídicos: denominación y clasificación

71.1. Introducción: ¿vicios de la voluntad o del consentimiento?

La doctrina ha discutido si estos institutos debían denominarse **vicios de la voluntad** o **vicios del consentimiento**. La mayoría de los juristas argentinos, al igual que el propio Código, se inclina por la primera denominación, señalando que es conceptualmente más amplia que la segunda.

La razón es de fondo: hablar de vicios del consentimiento los reduciría a defectos propios de los contratos —un tipo específico de acto jurídico—, mientras que los vicios de la voluntad afectan a todo acto voluntario.

> **Art. 260 CCyC — Acto voluntario.** *Son requisitos del acto voluntario: discernimiento, intención y libertad (condiciones internas) y manifestación de la voluntad (condición externa). Los vicios afectan a alguno de esos elementos.*

> **Art. 261 CCyC — Acto involuntario.** *Determina cuándo falta el discernimiento como condición interna del acto voluntario.*

Los actos voluntarios son aquellos que presentan tres condiciones internas: **discernimiento, intención y libertad**, y una condición externa que es la **manifestación de la voluntad**. Los vicios afectan alguno de estos elementos. El estudio de los vicios constituye una introducción al régimen de las **ineficacias**: la posibilidad de que el acto no produzca efectos jurídicos por la presencia de un defecto en su celebración.

Las preguntas centrales que guían este estudio son:

- Bajo qué circunstancias un acto voluntario puede ser anulado por la presencia de un defecto en su celebración.
- Cómo se afecta la intención y cómo se afecta la libertad como elementos internos.
- Qué requisitos deben reunir los vicios para que pueda declararse la nulidad.
- Qué consecuencias jurídicas se siguen de la presencia de un vicio.

71.2. Método del Código Civil y Comercial

Desde el punto de vista metodológico, los capítulos 2 a 4 del Título Cuarto del CCyC organizan los vicios comenzando en el artículo 265 con el error. El Código distingue dos grandes grupos bajo el término común de «vicios»:

Vicios de la voluntad	**Vicios propios de los actos jurídicos**
Error (Arts. 265–270)	Lesión
Dolo (Arts. 271–275)	Simulación
Violencia (Arts. 276–278)	Fraude

Cuadro 71.1: Clasificación de los vicios en el CCyC

Los primeros —error, dolo y violencia— afectan los elementos internos del acto voluntario. Los segundos —lesión, simulación y fraude— tienen un tratamiento posterior en el Código y son propios de los actos jurídicos.

Capítulo 72

El error como vicio de la voluntad (arts. 265 a 270 CCyC)

72.1. Concepto y clasificación del error de hecho

El error afecta la **intención** como elemento interno del acto voluntario. La doctrina trata conjuntamente dos supuestos: la **ignorancia** —la falta de conocimiento sobre algún elemento del acto— y el **error propiamente dicho** —un falso conocimiento—. Jurídicamente ambos se tratan como un único supuesto.

La primera gran distinción es entre el error de derecho y el error de hecho:

Error de derecho	Error de hecho
Falso conocimiento de la normativa legal aplicable a una relación o situación jurídica.	Recae sobre los elementos fácticos del acto o circunstancias del mismo.
Regulado en el Art. 8 CCyC: la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento.	Regulado en los Arts. 265 a 270 CCyC.
No puede invocarse como vicio. La ley se presume conocida por todos.	Es el que puede dar lugar a la nulidad del acto, con los requisitos del caso.

Cuadro 72.1: Error de derecho versus error de hecho

> **Art. 8 CCyC — Principio de inexcusabilidad.** *La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.*

Dentro del error de hecho, la clasificación fundamental es:

- **Error esencial**: recae sobre un elemento esencial del acto. Puede causar la nulidad si además es reconocible.
- **Error incidental**: recae sobre elementos secundarios que no son determinantes de la voluntad. No causa nulidad.

La fórmula es: cuando el error es **esencial Y reconocible**, causa la nulidad del acto (si es bilateral o unilateral de aceptación).

72.2. El error reconocible — Art. 266

El CCyC introduce un requisito que no estaba en el Código de Vélez: la **reconocibilidad**. En el Código anterior se exigía que el error fuera esencial y **excusable**. El nuevo Código reemplaza la excusabilidad por la reconocibilidad.

> **Art. 266 CCyC — Error reconocible.** *El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar.*

Código de Vélez	CCyC (vigente)
Error esencial + excusable.	Error esencial + reconocible.
Miraba al sujeto que erraba: ¿tenía razón para equivocarse?	Mira al destinatario: ¿pudo darse cuenta del error ajeno?
Requisito subjetivo centrado en quien declara.	Requisito objetivo centrado en quien recibe la declaración.

Cuadro 72.2: Cambio de requisito: Código de Vélez versus CCyC

La excusabilidad del Código de Vélez miraba al sujeto que emitía la declaración: que hubiera tenido alguna razón objetiva para errar. Ese criterio fue abandonado por el nuevo Código, siguiendo el modelo del derecho italiano.

El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración no pudo *no conocer* el error, según la naturaleza del acto o las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Existe así una expectativa de que la declaración viciada por un error esencial debió haber sido advertida por la parte destinataria.

Si el destinatario no advierte el error siendo que cualquiera lo hubiera advertido —pero tampoco actúa con malicia (porque si actúa con malicia incurriría en dolo)—, debe admitir que el acto sea anulado. La consecuencia de que el error sea reconocible es la nulidad relativa del acto.

72.3. El error esencial — supuestos del Art. 267

> **Art. 267 CCyC — Supuestos de error esencial.** *El error de hecho es esencial cuando recae sobre: (a) la naturaleza del acto; (b) el objeto sobre un bien o un hecho diverso o de distinta especie, o una calidad, extensión o suma diversa; (c) la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad; (d) los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente al acto; (e) la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante para su celebración.*

72.3.1. Inciso a) — Error sobre la naturaleza del acto

Es el error sobre el **tipo de acto** que, conforme al ordenamiento jurídico, cada parte cree celebrar.

Ejemplo: Error sobre la naturaleza del acto

A le dice a B: «Me das ese cuadro». A interpreta que B está haciendo una donación; B interpreta que está realizando un comodato (préstamo gratuito). Hay un error sobre la naturaleza del acto: uno pensó que era una donación y el otro que era un préstamo. Consecuencia: nulidad relativa, si el error es reconocible y esencial.

72.3.2. Inciso b) — Error sobre el objeto

Es el error sobre un **bien o un hecho diverso o de distinta especie**, o sobre una calidad, extensión o suma diversa.

Ejemplo: Error sobre el objeto — distintas especies

A cree estar comprando un caballo pura sangre para competencias; B interpreta que A está comprando un caballo de carga para trabajo en el campo. El objeto del acto —el caballo— no es el mismo en la mente de ambas partes. Si el error es reconocible, da lugar a la nulidad.

Ejemplo: Error sobre el objeto — calidad

A cree estar comprando un vino de excelente calidad y en realidad es un vino de calidad inferior. Si la otra parte debería haberse dado cuenta del error (reconocibilidad), el acto puede ser anulado.

72.3.3. Inciso c) — Error sobre la cualidad sustancial del bien

Este supuesto presenta un factor **objetivo** y uno **subjetivo**: por un lado, la cualidad debe ser sustancial al bien (factor objetivo); por otro lado, debe haber sido determinante de la voluntad según la apreciación común a las circunstancias del caso (factor subjetivo).

Código de Vélez	CCyC (vigente)
Utilizaba el criterio de la cualidad sustancial sin la palabra «sustancial» en ciertos pasajes, generando debate. Discusión entre criterio objetivo y subjetivo de la cualidad.	Incorpora la palabra «sustancial» y la conjuga con el requisito de que haya sido «determinante de la voluntad». Combina ambos factores: objetivo (cualidad sustancial del bien) + subjetivo (determinante de la voluntad según apreciación común).

Cuadro 72.3: Debate histórico sobre la cualidad sustancial

Ejemplo: Error sobre la cualidad sustancial

A está comprando una notebook y necesita que tenga buena memoria RAM porque va a trabajar con edición de videos. Esto es una cualidad sustancial de la computadora (factor objetivo), y además ha sido determinante para su voluntad de contratar (factor subjetivo). Si se le entrega una computadora sin esa capacidad y el error era reconocible, puede dar lugar a la anulabilidad del acto.

72.3.4. Inciso d) — Error sobre los motivos

Este inciso se vincula con la causa de los actos jurídicos (Art. 281 CCyC). El error puede recaer sobre los **motivos personales relevantes** que hayan sido incorporados expresa o tácitamente al acto.

Ejemplo: Error sobre los motivos

A quiere hacer una donación a una persona pensando que esa persona le salvó la vida. En realidad no es la misma persona. El motivo —la gratitud hacia quien le salvó la vida— fue incorporado al acto y es esencial. Si el error es reconocible, puede anularse la donación.

72.3.5. Inciso e) — Error sobre la persona

El error sobre la persona solo causa nulidad cuando la identidad de la persona fue **determinante para la celebración del acto**. Si no es determinante, es un error incidental y no produce nulidad.

Ejemplo: Error sobre la persona

A quiere contratar a un pintor famoso para que le haga un retrato de su madre. Existe un homónimo —alguien con el mismo nombre— y A contrata al homónimo creyendo que es el pintor famoso. Hay un error esencial sobre la persona: era determinante quién era el pintor, el homónimo debería haberse dado cuenta de que no era el artista buscado, y el acto puede anularse.

72.4. Error de cálculo — Art. 268

> **Art. 268 CCyC — Error de cálculo.** *El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento.*

El error de cálculo no da lugar a la nulidad sino únicamente a una **rectificación**, dado que se trata de un error aritmético que no fue determinante del consentimiento.

Ejemplo: Error de cálculo

Las partes pactan vender 40 kg de mercadería a $100 por kg. Queda claro el valor unitario y la cantidad. Al realizar la multiplicación en el contrato, escriben mal el precio total. Eso es simplemente un error aritmético que se corrige (rectifica) pero no da lugar a la nulidad.

72.5. Subsistencia del acto y nulidad relativa — Art. 269

> **Art. 269 CCyC — Subsistencia del acto.** *La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar.*

El artículo 269 le concede a la parte destinataria de la declaración la posibilidad de **ofrecer ejecutar el acto con las modalidades y el contenido que la parte en error pretendió** que se celebrara.

Ejemplo: Subsistencia del acto

A le dice a B: «Me das tu auto». B lo interpreta como préstamo; A como donación. A alega error y busca anular el acto. B puede decir: «Bueno, celebremos el acto bajo la modalidad del préstamo (comodato): te presto el auto». Si eso le conviene a A, se salva la nulidad. Esto responde al principio general de conservación de los actos.

Importante

El principio de conservación de los actos es un principio general del derecho civil: se tiende a interpretar que los actos deben ser conservados, preservando el valor de los negocios jurídicos.

72.6. Error en la declaración — Art. 270

Las disposiciones sobre el error se aplican tanto a la declaración de voluntad en sí como a su **transmisión**. Pueden presentarse problemas cuando quien transmite la voluntad es un **mandatario** (con representación) o simplemente un **mensajero**. En general, se aplican todas las disposiciones sobre error esencial y reconocible.

72.7. Consecuencias del error: nulidad relativa y prescripción

La sanción que se sigue de la presencia del error es la **nulidad relativa** del acto, regulada en el Art. 388 CCyC y susceptible de confirmación.

> **Arts. 2562 y 2563 CCyC — Prescripción.** *El plazo de prescripción para la acción de nulidad por vicios del consentimiento es de **dos años**. Comienza a correr desde que el error se conoció o pudo ser conocido.*

Capítulo 73

El dolo como vicio de la voluntad (arts. 271 a 275 CCyC)

73.1. Las acepciones del dolo en el derecho civil

La palabra «dolo» tiene múltiples significados en el CCyC. Es fundamental no confundirlos:

Acepción	Definición y referencia
1) Elemento del acto ilícito	Intención de dañar o manifiesta indiferencia por los intereses ajenos (Art. 1724 CCyC). Componente del factor subjetivo de atribución de responsabilidad.
2) Inejecución deliberada de obligación	Incumplimiento voluntario de una obligación. Figuraba en el Código de Vélez; el nuevo CCyC no lo define con la misma fórmula.
3) Vicio de la voluntad *(el que se estudia aquí)*	Maniobra engañosa realizada para determinar a una persona a celebrar un acto que no tenía intención de celebrar, o a celebrarlo en condiciones más desventajosas.

Cuadro 73.1: Las tres acepciones del dolo en el CCyC

Lo que tienen en común todas estas acepciones es una suerte de **conciencia de antijuridicidad**: el dolo siempre expresa una cierta conciencia de que se está actuando de modo contrario al derecho, intencionadamente causando un perjuicio o una situación prohibida.

73.2. Concepto: acción y omisión dolosa — Art. 271

> **Art. 271 CCyC — Acción y omisión dolosa.** *Acción dolosa es toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.*

La incorporación de la **omisión dolosa** es una novedad bien recibida por la doctrina. Significa que la maniobra engañosa puede realizarse tanto a través de acciones como de omisiones: ocultar información o ser reticente al proporcionarla puede inducir a la otra parte a celebrar un acto que afecta sus intereses y configura, por tanto, el concepto de engaño.

Las formas que puede tomar la maniobra engañosa son:

- **Aseverar lo falso**: afirmar algo que se sabe incorrecto.
- **Disimular lo verdadero**: ocultar la realidad.
- **Cualquier artificio, astucia o maquinación**: no es una mentira casual; tiene que ser una maniobra con entidad engañosa.
- **Omisión dolosa**: silencio o reticencia que induce al otro a celebrar el acto en condiciones perjudiciales.

Nota

En el fondo de estas conductas hay un **deber de buena fe** entre las partes: un deber de lealtad y de informar. En el derecho del consumidor estos principios son especialmente relevantes: la publicidad engañosa y la omisión de información relevante son manifestaciones colaterales del problema del dolo que pueden tener regulación específica.

73.3. Dolo esencial — requisitos del Art. 272

> **Art. 272 CCyC — Dolo esencial.** *El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, si es determinante de la voluntad, si causa un daño importante y si no ha habido dolo por ambas partes.*

Para que el dolo cause la nulidad del acto deben reunirse los cuatro requisitos siguientes:

a) Gravedad

La gravedad es una característica de la maniobra engañosa en sí misma. Para que el dolo sea grave debe tener **entidad para engañar**: no debe ser una maniobra burda que cualquier persona advertiría a primera vista. El parámetro es el de la persona razonablemente precavida que toma las precauciones comunes. La gravedad de la maniobra es un requisito distinto del daño importante.

b) Determinante de la voluntad

El dolo debe haber sido **determinante de la voluntad**. Este requisito es fundamental para distinguirlo del dolo incidental: si sin el engaño la persona igualmente hubiera celebrado el acto, no se configura dolo esencial.

c) Daño importante

Debe haberse causado un daño: una afectación de un interés o de un derecho de la parte que es víctima del acto.

d) No dolo de ambas partes

No debe haber habido dolo recíproco, es decir, de ambas partes. Un principio fundamental del derecho es que **nadie puede alegar su propia torpeza**: si ambas partes se engañaban mutuamente, ninguna puede pedir la nulidad.

73.4. Dolo incidental — Art. 273

> **Art. 273 CCyC — Dolo incidental.** *El dolo incidental no es determinante de la voluntad: la parte igualmente habría celebrado el acto, aunque en condiciones distintas. No causa la nulidad del acto, pero sí puede generar una indemnización de daños y perjuicios.*

Ejemplo: Dolo incidental

A está comprando un terreno. La otra parte realiza una maniobra para hacerle creer que el terreno tiene cierta habilitación que en realidad no tiene. Pero A de todos modos iba a comprar ese terreno. El engaño le ha provocado un perjuicio —por ejemplo, pagó más de lo que debía—, pero no fue determinante de que celebrara el acto. En ese caso, el dolo incidental solo puede dar lugar a una acción de daños y perjuicios, pero no a la nulidad.

Dolo esencial	Dolo incidental
Es determinante de la voluntad: sin el engaño, el acto no se hubiera celebrado.	No es determinante: la parte igualmente hubiera celebrado el acto.
Reúne los requisitos del Art. 272: grave, determinante, daño importante, sin dolo recíproco.	El engaño existe pero no alcanza los requisitos del Art. 272 en cuanto a su incidencia en la voluntad.
Consecuencia: nulidad relativa del acto + daños y perjuicios.	Consecuencia: solo daños y perjuicios (si se prueban). Sin nulidad.

Cuadro 73.2: Dolo esencial versus dolo incidental

73.5. Dolo de tercero — Art. 274

> **Art. 274 CCyC — Dolo de tercero.** *El dolo de un tercero causa la nulidad del acto si es esencial. Si el dolo de un tercero es incidental, solo da lugar a daños y perjuicios. La parte que conoció o debió conocer el dolo del tercero responde solidariamente con éste por los daños causados.*

El dolo de tercero es aquel cometido por alguien distinto de la parte con la cual se está contratando. Las reglas son simétricas al dolo de la propia parte:

- Si el tercero reúne los requisitos del Art. 272 (dolo esencial): causa la nulidad.

- Si el dolo del tercero reúne los requisitos del Art. 273 (dolo incidental): solo genera responsabilidad por daños y perjuicios.

Si la parte contratante tuvo **conocimiento del dolo del tercero** y no lo comunicó, responde **solidariamente** por todos los daños causados. La responsabilidad solidaria implica que responde por el total de la deuda, no solo por su parte proporcional.

73.6. Consecuencias del dolo: nulidad y daños — Art. 275

> **Art. 275 CCyC — Responsabilidad por daños.** *El autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado. Cuando el dolo sea del tercero, también responde la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero.*

Las consecuencias del dolo esencial son:

1. **Nulidad relativa del acto** (Art. 388 CCyC). Al ser relativa, está dispuesta en beneficio de la parte afectada y es susceptible de confirmación.
2. **Acción de daños y perjuicios** en virtud del Art. 275.
3. **Prescripción de dos años** desde el momento en que se conoció o pudo ser conocido el dolo (Arts. 2562 y 2563 CCyC).

Capítulo 74

La violencia como vicio de la voluntad (arts. 276 a 278 CCyC)

74.1. Concepto de violencia: fuerza e intimidación

La violencia es una **coerción grave de tipo físico o moral** que se ejerce sobre una persona para determinarla a realizar un acto en contra de su voluntad. Es un vicio que afecta la **libertad** como elemento interno del acto voluntario: la posibilidad de autodeterminarse y tomar decisiones sin coerciones injustas.

La violencia adopta dos grandes formas:

Fuerza (Art. 276, primera parte)	**Intimidación (Art. 276, segunda parte)**
Violencia física irresistible.	Amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente.
Ejemplo: torturas físicas para que alguien firme un contrato.	Ejemplo: «Si no me vendés tu casa, voy a hacerte daño a vos o a tu familia».
La coerción es de tipo corporal y directa.	La coerción opera a través del temor generado por las amenazas.

Cuadro 74.1: Formas de la violencia

Ejemplo: Fuerza física irresistible

A es torturado físicamente para que firme la escritura de venta de su casa. Aparece todo en regla: hay una escritura firmada, inscripta en el Registro de la Propiedad. Pero ese acto está viciado por fuerza física irresistible. Se inicia un juicio de nulidad para volver la situación al estado anterior a la celebración del acto. Este hecho también puede configurar delitos penales, pero aquí se analiza la dimensión civil.

74.2. Requisitos de la intimidación — Art. 276

> **Art. 276 CCyC — Fuerza e intimidación.** *La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.*

a) Las amenazas deben ser injustas

Las amenazas que configuran el vicio son **amenazas injustas**. El ejercicio legítimo de un derecho no constituye una amenaza en este sentido. Si una persona le debe dinero a otra y le dice «si no me pagás, voy a iniciar un juicio», no le está amenazando en el sentido jurídicamente relevante: está ejerciendo su derecho. Una amenaza ilícita sería, en cambio: «si no me vendés tu casa, te voy a romper la tuya».

b) El temor se mide según las circunstancias del amenazado

La relevancia de las amenazas ha de ser juzgada teniendo en cuenta la **situación del amenazado y las demás circunstancias del caso**. No hay un estándar único: la misma amenaza puede configurar intimidación para una persona pero no para otra, según sus capacidades y contexto.

Ejemplo: Medición del temor según las circunstancias

Si alguien con millones de seguidores en redes sociales amenaza con publicar que una persona es delincuente, eso puede generar un temor fundado a sufrir un daño grave a la reputación. El contexto (quién amenaza, con qué medios, a quién) determina la relevancia de la amenaza.

c) El mal debe ser grave e inminente

Grave: el mal debe tener entidad suficiente. Puede ser un mal sobre la persona (integridad física, moral o espiritual) o sobre los bienes.

Inminente: significa que el mal va a ocurrir y que no puede ser contrarrestado ni evitado. El término «evitar» fue agregado por el nuevo Código; no figuraba en el anterior.

d) El mal puede recaer sobre la parte o un tercero

En el Código de Vélez se enumeraban taxativamente las personas sobre quienes podía recaer la amenaza: cónyuge, ascendientes o descendientes. Esta enumeración generó una disputa: ¿era taxativa o ejemplificativa? La doctrina mayoritaria la interpretaba como ejemplificativa.

El nuevo Código resuelve el problema directamente indicando: **sobre la parte o un tercero**. Puede ser un familiar, un amigo, o incluso alguien que no se conoce tanto, pero cuya situación genera el temor suficiente.

74.3. Violencia de tercero y responsabilidad solidaria — Art. 278

Al igual que en el dolo, la violencia puede provenir de la propia parte o de un tercero. En ambos casos da lugar a la nulidad del acto. La diferencia relevante es la **responsabilidad de la parte cómplice**.

> **Art. 278 CCyC — Responsabilidad por daños causados por violencia.** *El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas debe reparar los daños causados. La parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza o de las amenazas responde solidariamente con el autor por los daños.*

Ejemplo: Violencia de tercero — complicidad de la parte

Un tercero amenaza a A para que le venda su casa a B. A le vende la casa a B (que es la parte contratante), pero la amenaza vino del tercero. Si B tuvo conocimiento de la fuerza o de la intimidación ejercida por el tercero, responde solidariamente por todos los daños y perjuicios: responde por el total, no solo por su parte proporcional.

74.4. El temor reverencial

El **temor reverencial** es el respeto o sumisión de una persona hacia sus superiores (por ejemplo, de un militar hacia un oficial superior). El temor reverencial **no es causa de nulidad**.

Para configurar el vicio de violencia deben existir amenazas concretas: la sola presencia de personas con autoridad no produce una situación de afectación de la libertad. El temor a una figura de autoridad, por sí solo, es temor reverencial y no causa nulidad. Este criterio se mantiene tanto en el Código de Vélez como en el nuevo CCyC.

Nota

Si el superior jerárquico realiza amenazas concretas que reúnen los requisitos de los Arts. 276 y siguientes, sí puede configurarse el vicio de violencia y dar lugar tanto a la nulidad como a los daños y perjuicios.

74.5. Consecuencias de la violencia: nulidad y prescripción

Las consecuencias de la violencia son análogas a las del dolo y el error:

1. **Nulidad relativa del acto**. Al ser relativa, la parte afectada puede confirmar el acto si así lo desea.
2. **Acción de daños y perjuicios** (Art. 278 CCyC).

La prescripción también es de **dos años** (Arts. 2562 y 2563 CCyC), pero existe una diferencia crucial respecto del error y el dolo: el plazo comienza a correr desde el momento en que **cesa la violencia**, no desde que se conoció el vicio.

> **Diferencia en el inicio del plazo de prescripción.** *Error: desde que se conoció o pudo ser conocido el error.*
> *Dolo: desde que se conoció o pudo ser conocido el dolo.*
> *Violencia: desde que cesa la violencia (Arts. 2562 y 2563 CCyC).*

Ejemplo: Inicio del plazo desde el cese de la violencia

A es secuestrado durante un año y medio. Durante ese tiempo, bajo torturas, firma un contrato vendiendo su casa. Después lo liberan. Desde el momento en que cesa la violencia —desde que recobra la libertad— comienza a correr el plazo de dos años para iniciar la acción de nulidad. Mientras dura la coerción, la persona no puede libremente ejercer su derecho a pedir la nulidad.

74.6. Cuadro Cornell: vicios de la voluntad: error, dolo y violencia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué se prefiere hablar de «vicios de la voluntad» y no de «vicios del consentimiento»?	Porque hablar de vicios del consentimiento los limitaría a los contratos (un tipo específico de acto jurídico). Los vicios de la voluntad, en cambio, afectan a todo acto voluntario. El CCyC adopta esta denominación más amplia.
¿Cuáles son los elementos internos del acto voluntario y qué vicio afecta a cada uno?	Los tres elementos internos son discernimiento, intención y libertad (Art. 260 CCyC). La **intención** es afectada por el error y el dolo; la **libertad** es afectada por la violencia (fuerza o intimidación).
¿Qué diferencia hay entre error esencial y error incidental?	El error esencial recae sobre un elemento esencial del acto (naturaleza, objeto, cualidad sustancial, motivos determinantes, persona). El error incidental recae sobre elementos secundarios no determinantes de la voluntad. Solo el error esencial —y reconocible— puede causar la nulidad.
¿Qué significa que un error sea «reconocible» (Art. 266)?	Que el destinatario de la declaración pudo conocer el error según la naturaleza del acto y las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Es un criterio objetivo centrado en el destinatario, que reemplaza la «excusabilidad» del Código de Vélez (criterio subjetivo centrado en quien erraba).
¿Qué sucede si el destinatario ofrece cumplir el acto según lo que el otro quiso? (Art. 269)	Se evita la nulidad del acto. La parte en error no puede solicitar la nulidad si el destinatario ofrece ejecutar el acto con las modalidades y el contenido que aquella pretendió celebrar. Esto responde al principio de conservación de los actos.

¿Qué es el dolo como vicio de la voluntad? (Art. 271)	Una maniobra engañosa: toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación para inducir a una persona a celebrar un acto. La omisión dolosa (reticencia u ocultación) tiene los mismos efectos que la acción dolosa cuando el acto no se habría realizado sin ella.
¿Cuáles son los requisitos del dolo esencial? (Art. 272)	Para causar la nulidad, el dolo debe ser: (1) **grave** —con entidad para engañar—; (2) **determinante de la voluntad** —sin el engaño, el acto no se hubiera celebrado—; (3) causante de un **daño importante**; (4) **unilateral** —no haber habido dolo de ambas partes—.
¿Qué diferencia al dolo incidental del dolo esencial? (Art. 273)	El dolo incidental no es determinante de la voluntad: la parte igualmente hubiera celebrado el acto. No causa la nulidad, pero sí puede dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios si se prueban.
¿Puede el dolo cometido por un tercero causar la nulidad? (Art. 274)	Sí. El dolo de tercero causa la nulidad si es esencial, y solo daños y perjuicios si es incidental. Si la parte contratante tuvo conocimiento del dolo del tercero, responde solidariamente por todos los daños.
¿Cuáles son las dos formas de la violencia? (Art. 276)	**Fuerza**: coerción física irresistible. **Intimidación**: amenazas injustas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no puede contrarrestarse ni evitarse, sobre la persona o bienes de la parte o de un tercero.
¿Cómo se mide si las amenazas son relevantes como intimidación?	Se juzga teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. No hay un estándar único: la misma amenaza puede configurar intimidación para una persona pero no para otra, según sus capacidades y contexto.
¿Qué es el temor reverencial y tiene efectos jurídicos?	Es el respeto o sumisión de una persona hacia su superior jerárquico (por ejemplo, un militar ante un oficial superior). El temor reverencial solo, sin amenazas concretas, no es causa de nulidad. Solo cuando se suman amenazas reales que reúnen los requisitos del Art. 276 puede configurarse el vicio de violencia.
¿Desde cuándo corre el plazo de prescripción para cada vicio?	En todos los casos el plazo es de dos años (Arts. 2562 y 2563 CCyC). La diferencia está en el punto de inicio: **error y dolo**: desde que se conoció o pudo ser conocido el vicio. **Violencia**: desde que cesa la violencia.

¿Cuál es el tipo de nulidad que producen los vicios de la voluntad?	Todos los vicios de la voluntad (error, dolo, violencia) producen **nulidad relativa** (Art. 388 CCyC). Eso significa que está dispuesta en beneficio de la parte afectada, puede ser confirmada por ella y prescribe a los dos años.

Resumen: Los vicios de la voluntad son defectos que afectan los elementos internos del acto voluntario —intención y libertad— y que, cuando reúnen los requisitos que establece el CCyC, producen la nulidad relativa del acto. El **error** (Arts. 265–270) afecta la intención por una falsa o errónea representación de la realidad: para causar la nulidad debe ser esencial —recaer sobre la naturaleza del acto, el objeto, la cualidad sustancial, los motivos determinantes o la persona— y reconocible por el destinatario, criterio que el nuevo Código tomó del derecho italiano en reemplazo de la excusabilidad del Código de Vélez. El **dolo** (Arts. 271–275) afecta la intención mediante una maniobra engañosa —acción u omisión— que para producir la nulidad debe ser grave, determinante de la voluntad, causante de un daño importante y unilateral; si no es determinante, solo genera daños y perjuicios (dolo incidental). La **violencia** (Arts. 276–278) afecta la libertad mediante fuerza física irresistible o intimidación a través de amenazas injustas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente; la relevancia de las amenazas se mide según las circunstancias del amenazado. En los tres vicios, la consecuencia es la nulidad relativa del acto —confirmable por la parte afectada— y la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. El plazo de prescripción es de dos años en todos los casos: para el error y el dolo, desde que se conoció o pudo conocerse el vicio; para la violencia, desde que cesa la coerción.

Capítulo 75

Antecedentes históricos y derecho comparado de la lesión

75.1. Los vicios de los actos jurídicos según el Código Civil y Comercial

El estudio de la lesión se inserta dentro del análisis general de los vicios propios de los actos jurídicos. En el ordenamiento argentino vigente, estos vicios son tres: la **lesión**, la **simulación** y el **fraude**.

A diferencia del tratamiento que recibían los vicios de la voluntad —cada uno regulado en un capítulo propio—, en el Código Civil y Comercial (CCC) la lesión, la simulación y el fraude están tratados dentro del capítulo sexto del título cuarto, distribuidos en tres secciones.

Nota

La lesión no estaba incluida originariamente en el Código de Vélez Sarsfield. Se trata de un instituto que resulta central para comprender el funcionamiento concreto de la justicia conmutativa en el derecho privado patrimonial, razón por la cual merece un desarrollo extenso y diferenciado, con antecedentes históricos propios.

75.2. Concepto de lesión: una distinción necesaria

Definición: Lesión como vicio de los actos jurídicos

Cuando se habla de lesión como vicio de los actos jurídicos, **no** se hace referencia a la lesión física —como en el derecho penal, donde el delito de lesiones se clasifica en graves, levísimas y leves—. Se trata de un concepto jurídico distinto, vinculado a la existencia de una **desproporción entre las prestaciones** de un acto jurídico.

En todo acto jurídico —especialmente en la compraventa— existe la expectativa de que las prestaciones sean equivalentes. Este principio se vincula con la denominada **justicia conmutativa**, entendida como la justicia entre particulares que busca una igualdad aritmética: que lo que una parte da sea igual a lo que recibe.

La pregunta central que atraviesa la construcción histórica del instituto es la siguiente: en principio, se supone que las partes son libres y pactan voluntariamente los términos de su acuerdo, de modo que no habría razón para invalidarlo si no existió error, dolo ni violencia. Sin embargo, cuando aparece una desproporción notable entre las prestaciones,

surge el interrogante de en qué punto esa desproporción se vuelve tan grave como para dar lugar a la lesión.

A este elemento objetivo —la desproporción— se suma un segundo elemento, de naturaleza subjetiva: la explotación, por una de las partes, de la inferioridad de la otra, con el fin de obtener una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada.

75.3. El derecho romano y el Código Justinianeo

En el derecho romano existen dos rescriptos atribuidos a los emperadores Diocleciano y Maximino que habrían instituido la figura, aunque se ha discutido si se trata de textos insertados con posterioridad. Lo indudable es que el instituto de la lesión aparece recogido en el Código Justinianeo, la recopilación del ordenamiento jurídico romano elaborada bajo el Emperador Justiniano.

Regla: Código Justinianeo (Corpus Iuris Civilis)

«Si tú o tu padre hubiera vendido por menor precio una cosa, es humano que, restituyendo todo el precio a los compradores, recobres el fondo vendido mediando la autoridad del juez, aunque si el comprador lo prefiere, reciban lo que les falta al justo precio. Pero se considera que el precio es menor si no se hubiera recibido ni la mitad del verdadero precio.»

Este instituto recibió el nombre de **lesión enorme**. Era concedida al vendedor en la compraventa de inmuebles, y exigía que la desproporción alcanzara una medida determinada: más de la mitad del valor real de la cosa.

La lesión enorme daba lugar a dos acciones posibles:

- una acción para recuperar el inmueble (el «fundo»); o bien
- una acción para que el comprador tuviera la opción de pagar el complemento del precio faltante, es decir, un reajuste.

Ejemplo: Reajuste del precio en el derecho romano

Si la cosa vale 100 y se pagó 40, el comprador —a quien le interesa conservar la cosa— puede optar por pagar los 60 que faltan, en lugar de restituir el fondo.

75.4. La Edad Media y el precio justo

Los glosadores, que continuaron comentando y ampliando el derecho romano, extendieron la aplicación de la lesión a la mayoría de los contratos durante la Edad Media. Los canonistas, por su parte, pusieron especial énfasis en la inmoralidad del desequilibrio entre las prestaciones.

Este factor moral resulta históricamente relevante, porque en torno a la lesión siempre ha oscilado la tensión entre una mirada objetiva —centrada en la desproporción del objeto— y un reproche dirigido a quien explota una situación ajena.

En este contexto adquiere especial relevancia el aporte de **Tomás de Aquino** y su idea del **precio justo**, un concepto de difícil determinación pero de gran influencia doctrinal: cuando el precio resulta manifiestamente injusto, se configura una posible lesión.

Regla: Tomás de Aquino — El precio justo

Aun la ley humana —en referencia al derecho romano— considera ilícito que el vendedor venda una cosa por más de lo que vale, o que el comprador la adquiera por menos de su valor, aunque no lo tiene por ilícito si la diferencia no es excesiva. Se reputa ilícito cuando el engaño supera la mitad del valor de la cosa, en clara referencia a la métrica del Código Justinianeo.

75.5. La legislación española como antecedente del derecho argentino

La evolución de la figura en las fuentes españolas —antecedente directo del derecho argentino— puede sintetizarse del siguiente modo:

Cuadro 75.1: Tratamiento de la lesión en la legislación española

Fuente española	Tratamiento de la lesión
Fuero Juzgo	Rigió durante la dominación visigoda. No admite la lesión, pero combate seriamente la usura, instituto muy cercano.
Fuero Real	Concede la acción al vendedor cuando lo engañan en más de la mitad del valor, si el comprador no acepta pagar la diferencia.
Las Leyes de Partidas	Consolidan la acción tanto para el vendedor como para el comprador.
Novísima Recopilación	Acepta la acción en compraventa, permuta, rentas y otros contratos semejantes.

75.6. El derecho comparado moderno

75.6.1. El Código Civil Francés (1804): la lesión objetiva

El Código Napoleónico constituye el ejemplo por excelencia de lo que se ha denominado **lesión objetiva**: aquella que contempla únicamente los elementos objetivos —es decir, la desproporción— sin tomar en consideración, en la configuración de la norma, el elemento subjetivo de la explotación de la inferioridad de la otra parte.

Regla: Código Civil Francés — art. 1.674 (1804)

Cuando el vendedor resulte lesionado en más de siete doceavos del precio del inmueble, tendrá derecho a solicitar la rescisión de la venta, aunque en el contrato haya renunciado expresamente a solicitar dicha rescisión y aunque haya declarado donar las plusvalías.

La medida establecida —más de 7/12— representa un poco más que la mitad (que serían 6/12). El código francés sigue así la métrica del derecho romano, pero la precisa mediante un porcentaje específico, tomando el valor al momento de la venta.

Ejemplo: Complemento del precio en el código francés

Se concede al comprador —lesionante— la posibilidad de ofrecer el complemento del precio con la deducción de la décima parte. Si la cosa vale 100 y se pagaron 40, el comprador puede ofrecer el complemento hasta 90, pagando los 50 restantes, y de esa manera conservar la propiedad.

En el derecho argentino, esta acción de complemento recibe el nombre de **reajuste equitativo** y es fijada por el juez. En el código francés, la prescripción de la acción era de dos años.

75.6.2. El Código Civil Alemán — BGB (1900): la lesión subjetiva

En 1900, la reforma del código civil alemán incorpora por primera vez la fórmula de la denominada **lesión subjetiva**, estrechamente vinculada al combate de la usura. La doctrina coincide en señalar este momento como el surgimiento de dicha categoría.

Regla: Código Civil Alemán — BGB (síntesis, 1900)

Un acto jurídico contrario a las buenas costumbres por el cual alguien, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otro, obtiene para sí o para un tercero que a cambio de una prestación le prometa o entregue ventajas patrimoniales que exceden de tal forma el valor de la prestación que, teniendo en cuenta las circunstancias, existe una desproporción chocante con ella.

Aparecen aquí los elementos subjetivos del lesionante —que explota la necesidad, la ligereza o la inexperiencia— y se hace prometer o entregar ventajas patrimoniales. Existe, entonces, una acción activa: el lesionante toma la iniciativa para explotar una inferioridad. Del lado del lesionado, la inferioridad se define como necesidad, ligereza o inexperiencia, términos que luego reproducirá casi textualmente el art. 954 argentino y, con alguna variante, el código vigente.

Importante

El código alemán declaraba el acto nulo en su totalidad, sin admitir nulidades parciales ni reajuste de precios, por tratarse de un acto contrario a las buenas costumbres. Existía un deber de restituir; la acción no era confirmable, era imprescriptible y podía ser declarada de oficio.

75.6.3. El Código Suizo (1912) y el Código Italiano (1942)

En 1912, el Código Suizo de las Obligaciones sigue al modelo alemán con variantes propias: coloca la prescripción en un año, torna la acción anulable y permite la confirmación del acto, acercándose así a la idea de un vicio que da lugar a una nulidad relativa susceptible de confirmación.

En 1942 se sanciona el Código Civil Italiano, que ejercerá una influencia decisiva sobre la reforma del art. 954 argentino en 1968.

Regla: Código Civil Italiano — art. 1.448 (1942, síntesis)

Si hubiera desproporción en las prestaciones de una de las partes, y esa desproporción dependiese del estado de una de ellas, del cual se aprovechara la otra para obtener ventajas, la parte damnificada podrá demandar la rescisión del contrato. La acción no es admisible si la lesión es inferior a la mitad del valor que la prestación ejecutada o prometida por la parte perjudicada tenía en el momento del contrato. La lesión debe perdurar hasta el momento en que se proponga la demanda.

Nota

La exigencia de que la lesión perdure hasta el momento de la demanda no estaba presente en los códigos anteriores, y será recogida tanto por la ley 17.711 como por el CCC vigente. En el código italiano, además, los contratos aleatorios no pueden ser rescindidos por esta vía.

75.7. Cuadro Cornell: antecedentes históricos y derecho comparado de la lesión

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué son los vicios propios de los actos jurídicos en el CCC?	Son tres: lesión, simulación y fraude. Están regulados en el capítulo sexto del título cuarto del Código Civil y Comercial, distribuidos en tres secciones.
¿Qué es la lesión como vicio jurídico?	No es la lesión física, sino una desproporción entre las prestaciones de un acto jurídico, combinada con la explotación, por una de las partes, de la inferioridad de la otra. Se vincula con la idea de justicia conmutativa (igualdad aritmética entre lo que se da y lo que se recibe).
¿Cuál es el origen histórico del instituto?	El Código Justinianeo (siglo VI) consagró la «lesión enorme» en la compraventa de inmuebles: si el precio era inferior a la mitad del valor real, el vendedor podía pedir la nulidad o el complemento del precio.
¿Qué distinción clave introduce el BGB alemán de 1900?	Introduce la lesión subjetiva: ya no basta la desproporción objetiva, sino que se requiere además la explotación de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra parte. Esta fórmula fue luego adoptada por Argentina en 1968 y rige, con variantes, en el art. 332 del CCC.

Resumen: La lesión, desde la lesión enorme del Código Justinianeo (más de la mitad del valor en la compraventa de inmuebles), pasando por el énfasis moral de la Edad Media y el precio justo de Tomás de Aquino, evolucionó hacia dos grandes modelos de derecho comparado: la **lesión objetiva** del código francés (que exige únicamente la desproporción) y la **lesión subjetiva** del BGB alemán (que agrega la explotación de la inferioridad de la otra parte), modelo este último que —junto con el código italiano de 1942— influirá decisivamente en la incorporación de la figura al derecho argentino.

Capítulo 76

La lesión en el derecho argentino

76.1. El Código de Vélez (1869): la exclusión de la lesión

Vélez Sarsfield no incluyó la lesión entre los vicios de los actos jurídicos. Al tratar los actos jurídicos en el art. 944, y luego de referirse a la simulación, el codificador dedicó una extensa nota —ubicada luego del art. 943— para explicar por qué no adoptaba la figura.

Nota

Técnicamente, la nota no se refiere al contenido del art. 943 —que trataba sobre la violencia—, sino que Vélez la ubicó allí, antes del comienzo del tratamiento de los actos jurídicos, con el propósito de explicar en algún lugar del código por qué no incorporaba la lesión. Años más tarde, Borda señaló en un fallo de 1958 que una nota al pie no constituye ley.

Vélez ofrece dos grandes razones para no reconocer la lesión:

Regla: Nota de Vélez al art. 943 — Primer argumento

«Para sostener nosotros que la lesión enorme, menor o mínima vicia los actos y obtenernos por tanto de proyectar disposiciones de la materia, basta comparar las diversas legislaciones y de las diferencias entre ellas resultados que no han tenido un principio uniforme al establecer esta ley.»

El codificador observa que la legislación comparada presenta numerosas diferencias: unas la conceden al vendedor, otras al comprador; unas la aplican a la compraventa, otras a distintos actos; unas imponen una medida de más de la mitad, otras no. Ante esta disparidad de criterios, Vélez concluye que no encuentra un principio uniforme y que, por lo tanto, no se siente obligado a incorporar la figura.

Regla: Nota de Vélez al art. 943 — Segundo argumento

«Dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores o todas las consecuencias de ellos. El consentimiento libre prestado sin error, dolo y violencia y con la solemnidad requerida por las leyes debe hacer irrevocables los contratos.»

Este segundo argumento expresa que lo pactado sin error, dolo ni violencia es válido, y que quien se equivoca debe hacerse cargo de las consecuencias de su propio error. Se advierte aquí una visión marcadamente individualista y liberal, coincidente con otras opciones adoptadas por Vélez a lo largo de todo el código.

76.2. La jurisprudencia anterior a la ley 17.711

Durante el siglo XX, distintos fallos judiciales fueron invalidando actos manifiestamente desproporcionados, invocando generalmente el art. 953 —referido al objeto del acto—, que disponía que el objeto no podía consistir en cosas o hechos contrarios a la moral. Cuando se pactaba algo contrario a la moral, ello podía dar lugar a la nulidad, de modo que el vicio de lesión se introducía por vía del art. 953.

La nota de Vélez al art. 943 seguía vigente, pero algunos jueces —entre ellos, Borda, en un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de 1958 conocido como el caso «Orlando»— sostuvieron que las notas no constituyen texto legal y que la lesión resulta incompatible con las buenas costumbres.

Ejemplo: Casos de aplicación jurisprudencial de la lesión (antes de 1968)

Préstamos usurarios, honorarios exorbitantes del administrador de una sucesión, venta a precio vil (muy bajo) de un terreno, y moderación de cláusulas penales excesivas.

En 1961, el Tercer Congreso de Derecho Civil tuvo una importancia decisiva para la reforma de la ley 17.711, al formular recomendaciones que constituyeron, en gran medida, la base de la reforma de 1968.

76.3. La ley 17.711 y la reforma al art. 954 (1968)

La ley 17.711 incorporó diversas figuras al Código Civil —entre ellas, el abuso del derecho y modificaciones en los efectos de la declaración de voluntad en el tiempo— y también la lesión, incorporada en el art. 954.

Regla: Art. 954 — Ley 17.711 (1968, texto incorporado)

«También podrá demandarse la nulidad o modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir al momento de la demanda. Solo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción operará a los cinco años. El accionante tiene opción para demandar la nulidad o el reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuera ofrecido por el demandado.»

En este texto se incorporan claramente un elemento objetivo —la desproporción— y un elemento subjetivo —la explotación de la necesidad, ligereza o inexperiencia—. El nuevo código sustituirá luego la palabra «ligereza» por «debilidad psíquica». Cabe destacar que el texto del art. 954 no establece una métrica fija para medir el elemento objetivo.

76.4. El art. 332 del CCC: texto y diferencias con el art. 954

El Código Civil y Comercial vigente sigue, en lo sustancial, al art. 954 para regular la lesión, en un único artículo ubicado en la sección primera del capítulo sexto del título cuarto.

Importante

Aunque se trate de un único artículo, el art. 332 contiene un desarrollo normativo extenso, que exige un análisis detenido de cada uno de sus elementos.

Regla: Art. 332 — Código Civil y Comercial de la Nación (vigente)

«Puede demandarse la nulidad o modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en casos de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir al momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transforma en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Solo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción.»

Las diferencias del CCC respecto del art. 954 pueden sintetizarse así:

Cuadro 76.1: Diferencias entre el art. 954 (ley 17.711) y el art. 332 (CCC)

Modificación	Explicación
Cambio 1	La palabra «ligereza» es reemplazada por «debilidad psíquica». El nuevo código clarifica así un punto que había dado lugar a un problema interpretativo, entre quienes ubicaban la ligereza como un obrar irreflexivo sin mayores requisitos y quienes la entendían como expresión de una cierta debilidad psíquica; el CCC se pronuncia por esta última postura.
Cambio 2	El plazo de prescripción se reduce de cinco a dos años. Metodológicamente resulta correcto tratar el plazo en el libro dedicado a las prescripciones, y no dentro del propio artículo.

76.5. Ámbito de aplicación del art. 332

El art. 332 recoge, en principio, todos los actos jurídicos en general. Sin embargo, el acto debe ser bilateral y no a título gratuito, puesto que en los actos a título gratuito siempre existe una desproporción entre las prestaciones que resulta ajena a la lógica de la lesión.

76.6. El elemento objetivo: la desproporción de las prestaciones

El primer elemento exigido por la norma es el elemento objetivo: la desproporción de las prestaciones. A diferencia del código francés, que establece un criterio fijo (7/12 partes), el CCC habla de «ventaja evidentemente desproporcionada» y de «notable desproporción», sin fijar un criterio numérico. No obstante, se exige que la diferencia sea muy notable: no bastaría, por ejemplo, una diferencia del veinte por ciento.

Un requisito adicional es que la desproporción debe ser **sin justificación**.

Ejemplo: Desproporción con justificación

Un tío que va a asistir al casamiento de un sobrino le vende un departamento que vale 100.000 dólares en 40.000, como regalo de casamiento. Tras su muerte, otros herederos —primos del beneficiado— demandan por lesión, invocando la diferencia entre el valor real y el precio pagado. El demandado se defenderá alegando que existió una justificación: la intención de realizar una liberalidad. Podrá discutirse si ese regalo excede o no la porción disponible —cuestión de legítima—, pero no podrá hablarse de lesión en sentido propio, porque no hubo explotación sino una justificación para la desproporción.

Los cálculos deben realizarse tomando en cuenta los valores al momento del acto, puesto que todo vicio afecta al acto desde su origen. Sin embargo, la desproporción debe además subsistir al momento de la demanda, exigencia que proviene del código italiano.

Ejemplo: Desproporción que no subsiste

Una persona compra muy barato un inmueble en un barrio cotizado. La desproporción existe al momento del acto, pero luego el valor de la propiedad desciende notablemente porque el barrio se deteriora y se vuelve inhabitable. Como la desproporción no subsiste al momento de la demanda, no existe acción por lesión, aun cuando el vicio se hubiera configurado al momento del acto.

76.7. Los elementos subjetivos

El art. 332 exige, además del elemento objetivo, la **explotación** por parte del lesionante. Se trata de algo más intenso que un simple «aprovechar» —entendido como que la otra parte no advierte la desproporción y el lesionante simplemente continúa adelante—: existe aquí una acción más activa, consistente en «hacerse dar o prometer» aprovechando la inferioridad de la otra parte. Este elemento resulta, en la práctica, de difícil prueba.

Del lado del lesionado, el CCC exige que se configure alguno de los siguientes tres estados de inferioridad:

Cuadro 76.2: Estados de inferioridad del lesionado (art. 332 CCC)

Estado de inferioridad	Definición y aclaración
Necesidad	Falta de lo indispensable para la vida. No basta con alegar, por ejemplo, que se tenía necesidad de asistir a la final de un mundial y por ello se vendió una propiedad muy barata. La necesidad exige una situación urgente, vital e indispensable —como cubrir una operación médica de un familiar—, no un deseo o conveniencia.
Debilidad psíquica	Presencia de alguna alteración mental. Reemplaza a la palabra «ligereza» del código anterior, que había generado dos posturas doctrinarias: obrar irreflexivo sin mayores requisitos, o expresión de una cierta debilidad psíquica. El nuevo código se pronuncia por esta última.
Inexperiencia	Falta del conocimiento que otorgan la vida y las relaciones. Quien se dedica profesionalmente al mercado inmobiliario durante treinta años no puede alegar inexperiencia en esa materia; distinta es la situación de una persona que se traslada de otro lugar, desconoce el ambiente y carece de formación en la materia del acto.

Importante

En general se interpreta que estos tres supuestos de inferioridad constituyen una enumeración taxativa: no puede invocarse otro distinto. El proyecto de reforma del CCC del año 2018 proponía ampliar estos supuestos, pero en el derecho vigente son únicamente tres: necesidad, debilidad psíquica e inexperiencia.

76.8. La presunción legal del art. 332

El art. 332, al igual que su antecedente el art. 954, establece que se presume —salvo prueba en contrario— la existencia de explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.

Importante

Esta presunción constituye una inversión de la carga de la prueba: si el lesionado prueba la notable desproporción de las prestaciones, se presume que hubo explotación, y corresponderá entonces al lesionante —demandado— probar que no existió tal explotación. Existe así una preponderancia práctica del elemento objetivo dentro de una norma que, en su configuración, es de lesión subjetiva.

Parte de la doctrina discute si el término «notable» equivale a «evidentemente desproporcionada». En general, se considera que lo notable es aquello que salta a la vista sin necesidad de una investigación mayor.

Existe además una discusión acerca del alcance de la presunción: una postura sostiene que solo alcanza al elemento subjetivo del lesionante, debiendo probarse por separado la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia del lesionado; otra postura entiende que, probada la desproporción, ambos elementos subjetivos se presumen.

Nota

Esta presunción legal constituye una novedad propia del derecho argentino, sin equivalente en el código italiano, el código suizo ni el código alemán, y es la que otorga al elemento objetivo su especial preponderancia práctica.

76.9. Las acciones, la legitimación y la prescripción

La lesión da lugar a dos acciones:

1. **Acción de nulidad**, de carácter relativo —susceptible de confirmación—, en tanto está establecida para la protección de la parte lesionada, al igual que ocurre con los restantes vicios.
2. **Reajuste equitativo**, mediante el cual el juez corrige la desproporción en el caso concreto, determinando lo que resulte justo. A diferencia del esquema del código francés, que deducía una décima parte para el pago del complemento del precio, en el derecho argentino el reajuste queda librado a la valoración judicial, sin que la ley fije una pauta.

Importante

El reajuste equitativo prima sobre la acción de nulidad cuando es ofrecido por el demandado al contestar la demanda, en virtud del principio de conservación de los actos jurídicos.

La legitimación para iniciar la acción corresponde exclusivamente al lesionado o a sus herederos, tal como establecía ya el art. 954. El plazo de prescripción es de **dos años**, contado desde la fecha en que la obligación debía cumplirse —plazo que la ley 17.711 fijaba en cinco años.

76.10. Figuras afines: cláusula penal y usura

El art. 794, relativo a la cláusula penal, guarda semejanza con la lesión: los jueces pueden reducir las penas establecidas en una cláusula penal —cláusula contractual que fija sanciones para el caso de incumplimiento— cuando resulten excesivas. Se trata de una figura próxima a la lesión, en cuanto también existe desproporción susceptible de reducción judicial, aunque con una diferencia relevante: no produce nulidad, sino únicamente reajuste.

La **usura**, en cambio, constituye un delito en el derecho penal, regulado por el art. 175 bis del Código Penal.

Regla: Art. 175 bis — Código Penal (síntesis) — Usura

Quien, aprovechando la necesidad, ligereza o inexperiencia de otro, se hiciera dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para un tercero, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgare a sabiendas un crédito usurario, será reprimido.

En la figura penal se requiere dolo. Debe notarse que esta norma no utiliza el término «explotación» sino «aprovechar», y exige que el autor se haga dar o prometer las ventajas: existe una acción activa dirigida a lograr esa entrega o promesa, que constituye el núcleo del delito.

76.11. Debate doctrinario: la esencia de la lesión

Existe un debate doctrinario acerca de cuál es la esencia de la lesión. Tobías, en su Tratado de Derecho Civil, identifica tres posturas posibles:

Cuadro 76.3: Posturas doctrinarias sobre la naturaleza jurídica de la lesión

Postura	Contenido
Vicio del objeto	Enfatiza el elemento objetivo: existe un problema en el objeto del acto, que resulta desproporcionado. Para Tobías, esta postura ignora la presencia de la explotación de la inferioridad.
Vicio de la voluntad	Enfatiza el elemento subjetivo del lesionado: por su inferioridad —necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia— estaría viciada su voluntad. Tobías objeta que, de seguirse este criterio, resultaría irrelevante la existencia de desproporción.
Comportamiento reprochable (Tobías)	Es una respuesta del ordenamiento frente a un comportamiento reprochable, vinculado a la buena fe. Se reprocha la explotación. Esta postura se encuentra más cerca del antecedente alemán.

En definitiva, los tres elementos —objeto, voluntad y conducta— están en juego a la hora de determinar la esencia de la lesión, y de fondo siempre se encuentra la justicia conmutativa. El elemento objetivo resulta indudable: el objeto del acto debe ser proporcionado, y si existe desproporción, el acto no realiza plenamente la justicia. Al mismo tiempo, existe una valoración desde las buenas costumbres, que fundamenta el reproche jurídico cuya consecuencia es la nulidad.

Nota

En síntesis: el vicio de lesión en el ordenamiento argentino se recorrió desde el Código de Vélez —que no lo contempló, por las razones expuestas en su nota al art. 943— pasando por la jurisprudencia posterior y la reforma introducida por la ley 17.711 en el art. 954,

cuyo texto es sustancialmente reproducido por el art. 332 del CCC vigente. Dentro de esta figura se analizaron su fuente, su método, su ámbito de aplicación, sus elementos, las acciones a las que da lugar, la legitimación activa, el plazo de prescripción, su comparación con otras figuras afines y el problema de su esencia jurídica.

76.12. Cuadro Cornell: la lesión en el derecho argentino

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué Vélez no incluyó la lesión?	Por dos razones: (1) la disparidad de criterios en el derecho comparado, que le impedía identificar un principio uniforme; (2) su visión liberal-individualista, según la cual, si no hubo error, dolo ni violencia, el contrato es válido y cada parte debe hacerse cargo de sus propias decisiones.
¿Cómo incorporó Argentina la lesión antes de 1968?	La jurisprudencia —especialmente el fallo de Borda en el caso «Orlando» (1958)— la aplicó por vía del art. 953 (objeto contrario a la moral). El Tercer Congreso de Derecho Civil (1961) recomendó luego su incorporación expresa.
¿Qué exige el art. 332 del CCC para configurar la lesión?	Un elemento objetivo: desproporción evidente y sin justificación, que exista al momento del acto y subsista al momento de la demanda. Dos elementos subjetivos: explotación por parte del lesionante, y necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia del lesionado.
¿Cómo opera la presunción del art. 332?	Si se prueba la notable desproporción de las prestaciones, se presume —salvo prueba en contrario— la explotación. Esto invierte la carga probatoria: es el demandado quien debe demostrar que no explotó.
¿Qué acciones otorga la lesión?	Nulidad relativa (confirmable) o reajuste equitativo (fijado por el juez). El reajuste prima sobre la nulidad cuando es ofrecido por el demandado al contestar la demanda, en virtud del principio de conservación del acto.
¿Cuál es el plazo de prescripción?	Dos años, contados desde que la obligación debía ser cumplida. El CCC redujo el plazo de cinco años que establecía la ley 17.711.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la lesión según la doctrina?	Existe debate entre tres posturas: (1) vicio del objeto; (2) vicio de la voluntad; (3) conducta reprochable, contraria a la buena fe y a las buenas costumbres. Tobías se inclina por esta tercera postura, más próxima al modelo alemán.

Resumen: Argentina, luego de que Vélez la excluyera por razones liberales y por la falta de un criterio uniforme en el derecho comparado, incorporó la lesión en 1968 mediante la ley 17.711, siguiendo el modelo alemán e italiano. El CCC vigente la regula en el art. 332 con tres elementos: uno objetivo (desproporción evidente, sin justificación, que subsista al tiempo de la demanda), uno subjetivo del lesionante (explotación activa) y uno subjetivo del lesionado (necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia). La presunción legal de explotación ante la notable desproporción —novedad argentina sin equivalente en los códigos extranjeros— otorga preponderancia práctica al elemento objetivo. Las acciones disponibles son la nulidad relativa y el reajuste equitativo, prevaleciendo este último por el principio de conservación del acto. El plazo de prescripción es de dos años.

Capítulo 77

La simulación como vicio de los actos jurídicos

Tanto la simulación como el fraude son vicios de los actos jurídicos que hacen que un acto, pese a existir, no produzca todos sus efectos normales. La diferencia entre ambos puede describirse como la que existe entre una fachada falsa y una casa vaciada por dentro: en la simulación se construye una fachada —un acto aparente— que oculta o no oculta nada real, y por eso se ataca con la nulidad; en el fraude la casa es real, pero el deudor la vació de bienes para no pagarles a sus acreedores, y por eso se ataca con la inoponibilidad y no con la nulidad. Este capítulo trata la simulación; el siguiente, el fraude, y al final se comparan ambas figuras.

Nota

Estos dos vicios explican por qué un acto que parece perfecto en el papel puede terminar siendo anulado o simplemente ignorado por la ley frente a ciertas personas. Para cualquier abogado —litigante, asesor de empresas, escribano o juez— identificar una simulación (por ejemplo, una venta que en realidad esconde una donación para perjudicar herederos) o un fraude (un deudor que vacía su patrimonio para no pagar) constituye una herramienta central de la práctica profesional: de estos institutos depende poder recuperar un bien familiar, cobrar una deuda, defender a un cliente acusado de haber «prestado su nombre», o asesorar correctamente antes de firmar un contrato para no quedar involucrado, sin saberlo, en un acto simulado o fraudulento. También resulta útil en la vida personal: son temas que aparecen en sucesiones familiares, en préstamos entre parientes, en la compra de bienes a nombre de terceros o en cualquier situación donde alguien pueda intentar aprovecharse de un acuerdo informal. Entender la diferencia entre lo lícito y lo ilícito, y saber qué prueba se necesita para desarmar un acto aparente, protege el propio patrimonio y el de la familia.

77.1. Concepto y noción general

La simulación es un vicio especial de los actos jurídicos, porque supone una situación en la que las partes acuerdan una declaración de voluntad o un acto jurídico que, o bien no es real, o bien es aparente y encubre otro acto verdadero.

La simulación puede tener fines lícitos o ilícitos, según las circunstancias en las que las personas involucradas la lleven a cabo.

Ejemplo: Simulación ilícita entre herederos

Un padre o una madre —viudo o viuda— tiene tres hijos y quiere beneficiar en realidad a uno de ellos, su hijo favorito, simulando venderle su única casa. Los otros dos hijos no se enteran del verdadero propósito del acto.
Cuando fallece la persona y los herederos inician la sucesión, se encuentran con que la casa figura vendida, pero el hijo que aparece como comprador en realidad no tenía fondos, pues atravesaba una situación económica muy mala. Ante la pregunta de los demás hermanos, queda claro que el acto tuvo que haber sido simulado: en apariencia se le vendió la casa, pero en realidad se la estaban regalando, de modo que se trató de una donación.
Frente a esto, se ataca el acto para que se declare su nulidad y se lo considere una donación, de modo que la porción de la legítima hereditaria que corresponde a los demás herederos reingrese al acervo hereditario. Este es un ejemplo de simulación **ilícita**, porque perjudica a terceros —en este caso, a los otros coherederos.

Ejemplo: Simulación lícita: el auto a nombre del hermano

Una persona que se muda al exterior por tiempo indeterminado acuerda con su hermano poner el automóvil a su nombre, simulando una venta, para que este lo utilice mientras dure la ausencia, con el compromiso de restituirlo a su regreso.
La titularidad del auto queda simulada: el hermano actúa todo el tiempo como si el auto fuera suyo, y cuando la persona regresa y lo reclama, se produce la necesidad de volver las cosas al estado anterior.

77.2. Definición doctrinaria y ubicación metodológica

La doctrina define la simulación como la situación en la que dos personas, o una de ellas y un tercero que aparentemente no interviene en el acto, se ponen de acuerdo para declarar que celebran actos jurídicos que en realidad no se han propuesto llevar a cabo, o para aparentar un acto distinto, ocultando el acto verdadero bajo la apariencia de otro que declaran haber realizado.

Definición: Simulación

Habrá simulación cuando dos personas, o una de ellas y un tercero que aparentemente no interviene en el acto, se ponen de acuerdo para declarar que celebran actos jurídicos que en realidad no se han propuesto llevar a cabo, o para aparentar un acto distinto, ocultando el acto verdadero bajo la apariencia de otro que declaran haber realizado.

A partir de esta definición surgen los dos grandes tipos de simulación: la **absoluta**, cuando no hay nada de real, y la **relativa**, cuando la simulación encubre otro acto.

Metodológicamente, el tema se ubica en la Sección Segunda del Capítulo 6, «De los vicios de los actos jurídicos», del Título Cuarto («Hechos y actos jurídicos») del Libro Primero, Parte General, del Código Civil y Comercial (CCyC).

77.3. Definición legal de la simulación

La definición legal que trae el Código Civil y Comercial viene prácticamente igual a la que traía el código anterior en su artículo 955.

Regla: Definición legal de la simulación

«La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto con la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por el acto se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.»

77.4. Simulación absoluta y simulación relativa

Dentro de esta clasificación se distingue, por un lado, la simulación absoluta y, por otro, la simulación relativa.

77.4.1. Simulación absoluta

Es absoluta cuando el acto nada tiene de verdadero.

Ejemplo: Simulación absoluta

Una madre simula venderle un bien a un hijo para eludir a sus acreedores. Lo «vende», pero sigue viviendo allí: no hay ninguna transferencia de dinero, no hay nada real. El bien sigue siendo de ella; lo único que hace es aparentar haberlo puesto a nombre de su hijo. Esto constituye una simulación absoluta.

77.4.2. Simulación relativa

Es relativa aquella en que el acto aparente encubre a otro real y verdadero.

Regla: Art. 334 CCyC

«Si el acto simulado encubre a otro real, este es plenamente eficaz, siempre que concurran los requisitos propios de esa categoría de acto, y no sea ilícito ni perjudique a un tercero.»

Ejemplo: Simulación relativa

Se simula una compraventa, pero en realidad se trata de una donación, sin que esto perjudique a terceros ni sea ilícito. Será una donación hecha por determinados fines, que aparentemente se hizo como compraventa, pero en realidad es una donación.

El artículo 334 deja a salvo el acto encubierto: el acto aparente se anula y queda subsistente el acto encubierto, plenamente eficaz.

77.5. Simulación lícita e ilícita

La otra clasificación relevante distingue entre simulación lícita e ilícita: la simulación **lícita** es aquella que no perjudica a terceros ni viola la ley; la simulación **ilícita** es aquella que perjudica a terceros o viola la ley.

Retomando los ejemplos ya expuestos: el caso del deudor que simula vender un bien para que sus acreedores no puedan ejecutarlo es ilícito, porque los perjudica. En cambio, el caso de la persona que pone el auto a nombre de su hermano, sin perjudicar a nadie ni hacer nada contrario a la ley —simplemente porque resulta más práctico, ya que el hermano lo va a usar y asume todas las responsabilidades del caso, con el compromiso de devolverlo—, constituye una simulación lícita.

77.6. Naturaleza de la sanción: nulidad relativa

La simulación da lugar a la nulidad, y se trata de una nulidad de tipo **relativa**, porque está establecida en beneficio de las partes.

Entre los vicios que se tratan en el Título Cuarto del Código —error, dolo, violencia (vicios de la voluntad), vicios de los actos voluntarios, lesión y simulación— todos dan lugar a la nulidad. El fraude es el único vicio de ese título que da lugar a la inoponibilidad.

Algunos autores sostenían que, ante una simulación, se estaba frente a un acto inexistente, pero esta postura no encuentra eco en el Código Civil y Comercial, que siempre refiere a la nulidad del acto.

Importante

Si al leer algún texto o algún autor se encuentra una referencia a la inexistencia del acto simulado, en realidad esto no tiene asidero: la inexistencia es una categoría de ineficacia reconocida en otros países, pero en el derecho argentino no está reconocida, salvo en algún supuesto muy específico. Por lo tanto, al hablar de simulación siempre corresponde hablar de nulidad.

77.7. La acción de simulación entre las partes

La acción de simulación puede ser ejercida por las partes entre sí, o por terceros.

Ejemplo: Acción entre las partes

Una persona regresa de un viaje y reclama a su hermano la restitución del auto que le había puesto a su nombre de manera simulada, comprometiéndose este a devolvérselo a su regreso. El hermano desconoce que el acto haya sido simulado y sostiene que el auto es suyo.
Frente a ese desconocimiento, la persona debe iniciar una acción de simulación contra su hermano ante el juez, solicitando que se declare la nulidad del acto simulado, para

que las cosas vuelvan al estado anterior. Este es un ejemplo de acción entre las propias partes.

77.7.1. Procedencia de la acción entre partes

Regla: Art. 335 CCyC (primer párrafo)

«Los que otorgan un acto simulado ilícito, o que perjudica a terceros, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del acto practicado con la simulación.»

Si la simulación es ilícita, la acción entre las partes no procede, por regla, salvo que ninguna de ellas pueda obtener un beneficio de la simulación. En cambio, en la simulación lícita no está presente este requisito, y la acción procede siempre.

Ejemplo: Excepción a la regla

Una persona simuló vender su casa para eludir a sus acreedores y, luego, gracias a una herencia de un pariente lejano, obtiene dinero suficiente para pagarles. Con esa disponibilidad, inicia una acción de simulación contra el adquirente simulado de su casa, para recuperar la propiedad. Aunque la simulación fue ilícita, al dejar sin efecto el acto simulado no obtiene ningún beneficio indebido, porque ya pagó a los acreedores: estos no perdieron nada, no fueron perjudicados. Por eso, en este caso, la acción entre partes puede proceder.

77.7.2. La prueba entre las partes: el contradocumento

Entre las partes, la simulación debe probarse a través del **contradocumento**. El contradocumento es el instrumento donde consta la verdadera intención de las partes: si la simulación es una declaración de voluntad aparente que encubre otro acto real, o que no tenía nada de real, en el contradocumento se plasma la voluntad real, y las partes dejan en claro que se trató de un acto simulado. Durante la simulación se redacta también un contradocumento, justamente para que, ante la necesidad de probar que el acto es simulado, la parte interesada pueda exhibirlo.

En la redacción originaria de Vélez, de 1871 (vigente desde 1869), no había posibilidad de eximirse de presentar el contradocumento. Luego, la jurisprudencia fue incorporando excepciones, y en el período 1968/1969 la Ley 17.711 incorporó un párrafo al código anterior que estableció la posibilidad de prescindir del contradocumento. Esta solución fue receptada por el nuevo Código en el artículo 335, que agrega, respecto del código anterior, la exigencia de justificar las razones por las cuales el contradocumento no existe o no puede ser presentado.

Regla: Art. 335 CCyC (segundo párrafo)

«La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él cuando la parte justifica las razones por las cuales

no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.»

Ejemplo: Prescindencia del contradocumento

Dos hermanos, por la cercanía y confianza entre ellos, no consideraron necesario escribir un contradocumento, o bien este se destruyó —por ejemplo, en un incendio— y no puede ser presentado. En ese caso deben acreditarse circunstancias que hagan inequívoca la simulación: por ejemplo, demostrar que el hermano titular registral tenía bienes que en realidad seguía usando el otro hermano —el departamento, el automóvil—, de modo de dar al juez la convicción inequívoca de que efectivamente se está ante un acto simulado.

Complementariamente, el artículo 1028 del código anterior establecía que el contradocumento particular que altere lo expresado en un instrumento público puede invocarse entre las partes, pero no es oponible respecto de terceros.

Importante

Si el acto simulado se instrumentó por escritura pública, puede utilizarse un contradocumento simplemente particular, es decir, que no sea escritura pública. Aunque la escritura pública tiene mayor fuerza probatoria que el instrumento particular, el contradocumento particular puede ser invocado entre las partes si tiene firma, ya que esta le da mayor certeza. Frente a terceros, en cambio, es inoponible. Si no tiene firma, habrá que probar las circunstancias que hacen inequívoca la simulación.

77.8. La acción de simulación ejercida por terceros

77.8.1. Procedencia

La acción ejercida por terceros procede cuando la simulación es ilícita. El tercero no tendría ningún interés en atacar una simulación lícita; la razón de su acción reside, precisamente, en la existencia de una simulación ilícita.

Regla: Art. 336 CCyC

«Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad.»

Esta norma habilita a los terceros a iniciar una demanda de nulidad; se trata, nuevamente, de una demanda de nulidad, y no de inexistencia ni de inoponibilidad.

77.8.2. La prueba por indicios

Según el artículo 336, el tercero puede acreditar la simulación por cualquier medio de prueba: no se le exige el contradocumento, ya que este lo tienen las partes que hicieron el acto simulado, y no el tercero.

Ante la imposibilidad de recurrir al contradocumento, el tercero recurre a indicios. La doctrina, con aportes de distintos autores especializados en el tema, reúne una enumeración de indicios:

- Carencia de medios económicos del adquirente para haber podido pagar el precio.
- El parentesco muy próximo, o la amistad íntima, entre las partes del acto.
- La ausencia de ejecución material del acto o contrato (por ejemplo, el vendedor que sigue viviendo en el inmueble «vendido»).
- La venta de la cosa a una sociedad anónima en la que el propio enajenante o sus parientes son accionistas.
- La venta de un bien que el vendedor necesita para su sustento (por ejemplo, el auto con el cual trabaja y se traslada).
- El precio vil, es decir, un precio muy bajo en relación con el valor real de la cosa.
- La ausencia de incorporación del bien en las declaraciones impositivas (no haberlo denunciado ante la AFIP).
- Los pagos anticipados: pagar por anticipado todo el precio antes de la escrituración resulta sospechoso.
- La retroventa: es poco habitual que alguien compre algo con la posibilidad de que se lo revendan a él mismo.
- Que la enajenación no sea útil ni necesaria: no había ninguna necesidad real de vender.

Estos son indicios surgidos de la jurisprudencia, que el tercero que alega una simulación debe reunir para convencer a un juez de que lo sucedido no es real, sino que encubre otro acto, o que directamente no tiene nada de real.

77.9. Efectos de la simulación frente a terceros

La simulación ilícita que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto; si el acto simulado encubre a otro real, este es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría, y no es ilícito ni perjudica a terceros. En las simulaciones relativas por cláusulas simuladas, si es posible distinguir y separar la cláusula falsa de las demás, esta pierde valor, pero el acto sigue siendo válido en lo restante, por el principio de conservación de los actos.

Regla: Art. 337 CCyC

«La simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. La acción del tercero contra los subadquirentes solo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en la simulación. El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al tercero que ejerció la acción, si los

derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se hizo imposible su recaudo.»

Ejemplo: Efectos frente a terceros y subadquirentes

Una persona simula venderle el auto a su hermano; este, a su vez, tiene sus propios acreedores, que ejecutan el auto de buena fe, sin saber nada de la simulación. En ese caso quedan protegidos, pues la lógica siempre es proteger al de buena fe y a título oneroso.

Si el hermano, a su vez, transmitió el auto a un subadquirente, la acción contra este solo procede si adquirió a título gratuito, o si fue cómplice de la simulación. Si el subadquirente es de buena fe y a título oneroso —por ejemplo, compró el vehículo mediante un aviso, sin conocer la simulación— queda protegido. Si, en cambio, el hermano se puso de acuerdo con esa otra persona y le vendió el auto sabiendo todo, la acción procede, aunque la complicidad resulta muy difícil de demostrar.

El subadquirente de mala fe y el deudor responden por los daños: procede una acción de daños junto con la nulidad, dirigida contra el subadquirente de mala fe. En cambio, si el subadquirente es de buena fe pero a título gratuito —por ejemplo, si el bien fue donado a una institución de beneficencia— no responde por los daños, sino en la medida en que se haya enriquecido, debiendo restituir en esa medida.

La regla general que atraviesa este tema es que siempre se protege a quien actuó de buena fe y a título oneroso; quien actuó de mala fe responde por los daños, y quien actuó de buena fe pero a título gratuito responde solo en la medida de su enriquecimiento. Se trata de un principio fundamental en todo el tema de los actos jurídicos dentro del sistema de derecho civil argentino.

77.10. Prescripción de la acción de simulación

Regla: Art. 2563, inc. b, CCyC

El plazo de prescripción de dos años se computa, en la acción de simulación ejercida por parte, «desde que, requerida una de ellas, se negó a dejar sin efecto el acto simulado»; y en la acción de simulación que ejerce un tercero, desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico.

La acción entre partes no comienza a correr desde que se celebró el acto simulado, sino desde que una de ellas desconoce, en los hechos, la simulación.

Ejemplo: Cómputo del plazo entre partes

Una persona regresa de España, reclama el auto y su hermano le dice que el auto es suyo. Aunque hayan pasado varios años desde su partida, el plazo de prescripción empieza a correr recién cuando regresa y el hermano se niega a devolvérselo, y no desde el momento de la partida.

La acción ejercida por un tercero prescribe a los dos años desde que este conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico.

77.11. Cuadro Cornell: la simulación como vicio de los actos jurídicos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la simulación?	Un vicio en el que las partes acuerdan una declaración de voluntad que no es real, o que es aparente y encubre otro acto. Puede tener fines lícitos (por ejemplo, poner un auto a nombre de un hermano) o ilícitos (por ejemplo, simular una venta para perjudicar a coherederos).
¿Simulación absoluta o relativa?	Absoluta: el acto no tiene nada de real (por ejemplo, una madre que «vende» un bien pero sigue siendo suya). Relativa: el acto aparente encubre a otro real y válido (art. 334 CCyC), que subsiste plenamente eficaz si no es ilícito ni perjudica a terceros.
¿Simulación lícita o ilícita?	Lícita: no perjudica a terceros ni viola la ley. Ilícita: perjudica a terceros o viola la ley (por ejemplo, vender bienes para eludir acreedores).
¿Qué sanción tiene la simulación?	La nulidad, de carácter relativo (no la inexistencia, categoría que el Código Civil y Comercial no reconoce para estos casos).
¿Cómo se prueba entre las partes?	Mediante el contradocumento (art. 335 CCyC); puede prescindirse de él si se justifican las razones de su ausencia y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.
¿Cómo prueba un tercero?	Por cualquier medio de prueba (art. 336 CCyC), típicamente a través de indicios: falta de medios económicos del comprador, parentesco cercano, precio vil, ausencia de ejecución material del contrato, pagos anticipados, retroventa, entre otros.
¿Quién queda protegido frente a terceros?	Los acreedores de buena fe del adquirente simulado que hayan ejecutado bienes (art. 337 CCyC). Los subadquirentes de mala fe o a título gratuito responden; los de buena fe y título oneroso quedan protegidos.
¿Cuándo prescribe la acción de simulación?	A los dos años (art. 2563 inc. b CCyC): entre partes, desde que una de ellas se negó a dejar sin efecto el acto; por terceros, desde que conocieron o pudieron conocer el vicio.

Resumen: La simulación y el fraude son los dos últimos vicios de los actos jurídicos estudiados en esta parte, y ambos responden a la misma preocupación: qué hacer cuando un acto jurídico, sin ser lo que aparenta, afecta a personas ajenas a él. En la simulación, las partes se ponen de acuerdo para declarar algo que no es real o que oculta otro acto; según perjudique o no a terceros o viole la ley, será ilícita o lícita, y siempre se sanciona con la nulidad relativa del acto ostensible, probándose entre las partes mediante contradocumento y, por los terceros, mediante cualquier indicio idóneo.

Capítulo 78

El fraude como vicio de los actos jurídicos

78.1. Introducción y distinción con el fraude penal

La palabra «fraude» no debe confundirse con el delito de fraude, si bien puede darse que la misma conducta configure, a la vez, un fraude civil y un delito. En este capítulo se consideran los aspectos civiles del fraude, vinculados con la garantía del patrimonio a favor de los acreedores.

En la concepción integral del derecho civil y del Código Civil y Comercial, el patrimonio opera como garantía de los acreedores. Por eso, si un deudor enajena bienes para sustraerlos de sus acreedores, comete un fraude: elude, por así decirlo, la acción de sus acreedores. El código da una respuesta a esta conducta a través de determinadas disposiciones.

78.2. Definición doctrinaria

Definición: Fraude

El fraude tiene lugar cuando una persona, en forma intencional, se desapodera de bienes o poderes para colocarse en una situación de insolvencia y eludir de esta manera la acción de sus acreedores.

La insolvencia expresa una situación en la que el pasivo supera al activo, y en la que, por lo tanto, el deudor no tiene bienes suficientes para hacer frente a sus deudas.

Ejemplo: Insolvencia y dinero en efectivo

Un deudor vende su casa para evitar que se la ejecuten. Si conserva el dinero de la venta en efectivo —en una caja fuerte, en un bolso, o de cualquier otra forma— resulta muy difícil de embargar, salvo que en algún mandamiento se logre identificarlo. Así, la persona aparece como sin bienes, pero los acreedores pueden descubrir que hubo un acto de enajenación y atacarlo.

78.3. La inoponibilidad como consecuencia del fraude

El fraude no da lugar a una nulidad, sino a la **inoponibilidad**. La acción que corresponde al fraude se denomina acción de inoponibilidad en el nuevo Código; históricamente se la conocía como acción pauliana o acción revocatoria, nombre que usaba el código de Vélez. El nuevo Código, siguiendo lo que ya aceptaba la mayoría de la doctrina antes de su entrada en vigencia, habla directamente de inoponibilidad.

El acto es válido entre las partes, pero inoponible: tiene una ineficacia relativa. Esta ineficacia consiste en que el acto no produce efectos respecto de ciertas personas determinadas, que son los acreedores defraudados que inician la acción. Frente a ellos, el acto se comporta como si no se hubiera celebrado, es decir, es inoponible; pero frente a las propias partes, y frente a cualquier otra persona que no sea el acreedor accionante, el acto sigue siendo válido.

Importante

El concepto de inoponibilidad —y no de nulidad— es fundamental para diferenciar al fraude de los demás vicios de los actos jurídicos.

78.4. La acción de inoponibilidad

Metodológicamente, el fraude está tratado en la Sección Tercera del Capítulo 6 («De los vicios de los actos jurídicos»), del Título Cuarto, del Libro Primero, Parte General.

Regla: Art. 338 CCyC

«Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.»

El acreedor puede pedir la declaración de inoponibilidad tanto de los actos hechos en fraude, como de las renuncias hechas para eludir la acción de los acreedores.

Ejemplo: Renuncia en fraude a los acreedores

Quien renuncia a cobrar una indemnización o un crédito perjudica a sus acreedores, porque estos se ven afectados por esa renuncia. Los acreedores pueden alegar que esa renuncia fue hecha en fraude a sus derechos.

Nota

Esta inoponibilidad, como supuesto de ineficacia relativa, debe complementarse con los artículos 396 y 397 del Código, que regulan la inoponibilidad en general y que se estudian al abordar las ineficacias.

78.5. Requisitos de procedencia de la acción

78.5.1. Crédito de causa anterior al acto impugnado

El primer requisito es que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, salvo que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores.

Ejemplo: Crédito anterior al acto impugnado

Un deudor tiene una deuda desde el 1 de enero de 2018; a partir de esa fecha, su acreedor tiene la expectativa de que todo su patrimonio constituye la garantía del crédito. El acreedor no podría impugnar un acto realizado en 2017, porque en ese momento no existía la deuda. Si al 1 de enero de 2018 el deudor tenía un departamento y un auto, y durante 2018 enajena el departamento y se vuelve insolvente —porque además el auto se destruye en un choque—, el acreedor puede atacar la venta del departamento, porque su crédito es anterior (enero de 2018) y la venta es posterior (mayo). En cambio, si antes tenía además una cochera que vendió durante 2017, el acreedor no puede atacar esa venta, porque su crédito es posterior a ella, salvo que demuestre que la venta se hizo a sabiendas, para defraudar a los futuros acreedores.
Este sería el caso de un deudor que tiene varios inmuebles y, mientras un acreedor tramita un crédito que tarda varios meses en salir, vende todos sus inmuebles; cuando el crédito finalmente se otorga, el deudor ya no tiene nada, pero lo hizo a sabiendas, en fraude de los futuros acreedores.

78.5.2. Que el acto haya causado o agravado la insolvencia

El segundo requisito es que el acto haya causado o agravado la insolvencia.

Ejemplo: Insolvencia causada o agravada

Un deudor que tiene cinco departamentos y vende uno, conservando otros cuatro con los cuales puede responder perfectamente, no incurre en fraude: este supone una situación de incapacidad e impotencia para atender los créditos.

78.5.3. La complicidad del adquirente a título oneroso

El tercer requisito exige distinguir según el acto haya sido a título oneroso o a título gratuito. Si es a título oneroso, debe probarse que quien contrató con el deudor conocía, o debía conocer, que el acto provocaba o agravaba la insolvencia, es decir, que fue cómplice porque conocía la situación. Si el acto fue a título gratuito, no se exige este requisito de complicidad, y la acción procede siempre, porque no hay nadie que se haya enriquecido en perjuicio de acreedores que quedaron desprovistos del bien.

Ejemplo: Complicidad del adquirente

Un contador que conoce perfectamente la situación contable de su cliente le compra un departamento: en ese caso corresponde analizar si conocía o debía conocer el estado de insolvencia del vendedor. La complicidad es, en la práctica, difícil de probar.

78.6. Efectos de la acción de inoponibilidad

El acto es válido entre las partes, pero sus efectos son inoponibles al acreedor defraudado que obtiene la sentencia a su favor. A diferencia de la nulidad, que vuelve las cosas al estado anterior, en el fraude el acto sigue siendo válido entre las partes; lo único que ocurre es

que, al ejecutarse la cosa, el acreedor cobra su crédito, y el excedente queda para quien había adquirido el bien.

Ejemplo: Efectos de la inoponibilidad

Una persona vende un departamento a un pariente cercano en fraude de sus acreedores. Se prueba el fraude; la deuda era de 40.000 dólares y el departamento vale 100.000. Se ejecuta el bien, se obtienen 100.000 dólares: los acreedores cobran su parte, que son 40.000, y los 60.000 restantes no son de ellos, sino de quien había adquirido el inmueble, que se queda con ese excedente. El adquirente tiene, a su vez, un reclamo contra el deudor por lo que pagó, aunque probablemente no tenga de dónde cobrarse. Esta es una diferencia importante entre el fraude y la simulación: en la simulación, si se declara la nulidad, las cosas vuelven al estado anterior; en el fraude, si al ejecutar la cosa hay un excedente, este se entrega a quien había adquirido la cosa, porque el acto vale entre las partes.

78.7. El desinterés del adquirente

Regla: Art. 341 CCyC

El adquirente puede desinteresar a los acreedores que promovieron la acción, ofreciendo una garantía suficiente, o pagando directamente el crédito de quienes se hubiesen presentado.

Ejemplo: Desinterés del adquirente

Un adquirente que se encuentra muy conforme con el departamento adquirido —por su cercanía al trabajo y al colegio de sus hijos— y a quien se le inicia la acción por haber sido cómplice, ofrece una garantía o paga directamente a los acreedores. En ese caso, la acción de inoponibilidad se detiene, porque los acreedores quedan desinteresados.

78.8. Extensión de la inoponibilidad

Regla: Art. 342 CCyC

La declaración de inoponibilidad beneficia solo a los acreedores que promovieron la acción, y hasta el importe de sus respectivos créditos.

Solo el acreedor que promueve la acción se beneficia con ella; si existen otros acreedores que no la iniciaron, no pueden beneficiarse. Retomando el ejemplo anterior: si el acreedor accionante tiene un crédito de 40.000 dólares y el departamento vale 100.000, se beneficia solo con los 40.000; los 60.000 restantes quedan para quien hubiera adquirido la cosa.

78.9. Efectos frente a subadquirentes

Este punto resulta muy similar al analizado para la simulación. Si el adquirente tiene, a su vez, sus propios acreedores, que embargan y ejecutan de buena fe, estos quedan protegidos: en el fraude, tampoco puede oponérsele al acreedor de buena fe que haya ejecutado los bienes comprendidos en el acto.

Si existe un subadquirente, corresponde analizar si es o no cómplice del fraude, y si adquirió a título oneroso o gratuito. Si es de mala fe, o si adquirió a título gratuito, en cualquiera de los dos casos procede la acción. Si el subadquirente es de buena fe y a título oneroso, queda protegido, y la acción se dirige, en forma de daños y perjuicios, contra el cómplice y el deudor que celebró el acto en fraude.

El criterio para determinar la complicidad es si el sujeto conocía el estado de insolvencia y que el acto lo agravaba. Se aplica también la regla de la responsabilidad solidaria por daños y perjuicios para quien actuó de mala fe, mientras que quien actuó de buena fe y a título gratuito responde solo en la medida de su enriquecimiento, es decir, de lo que deba restituir al acreedor defraudado.

78.10. Prescripción de la acción de inoponibilidad

El plazo de prescripción es de dos años, y se cuenta desde que el acreedor conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico.

Importante

Con el Código de Vélez, la lesión prescribía a los cinco años y el fraude al año; el nuevo Código bajó el plazo de la lesión a dos años y elevó el del fraude también a dos años, unificando así el plazo de prescripción de todos los vicios: error, dolo, violencia, lesión, simulación y fraude prescriben, todos, a los dos años, aunque cambia el momento desde el cual comienza a correr ese plazo en cada caso.

A diferencia de la simulación y de los demás vicios, en el caso del fraude no se trata de una acción de nulidad, sino de una acción de inoponibilidad.

78.11. Cuadro Cornell: el fraude como vicio de los actos jurídicos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el fraude como vicio civil?	El acto por el cual el deudor, en forma intencional, se desapodera de bienes para colocarse en insolvencia y eludir a sus acreedores. No debe confundirse con el delito penal de fraude.
¿Qué sanción tiene el fraude?	La inoponibilidad (ineficacia relativa), no la nulidad: el acto es válido entre las partes, pero no produce efectos frente al acreedor defraudado que obtuvo la sentencia a su favor (art. 338 CCyC).
¿Qué requisitos exige la acción de inoponibilidad?	1) Crédito de causa anterior al acto (salvo fraude a futuros acreedores); 2) que el acto haya causado o agravado la insolvencia; 3) si es a título oneroso, que el adquirente conociera o debiera conocer ese estado (complicidad).
¿Qué ocurre si hay un excedente al ejecutar el bien?	El excedente queda para el adquirente, no para el acreedor: a diferencia de la nulidad, el fraude no retrotrae el acto por completo, solo lo hace inoponible en la medida del crédito (arts. 341 y 342 CCyC).
¿Cómo se desinteresa el adquirente?	Ofreciendo garantía suficiente o pagando directamente a los acreedores que promovieron la acción (art. 341 CCyC), lo que detiene la acción.
¿Cuándo prescribe la acción de inoponibilidad?	A los dos años desde que el acreedor conoció o pudo conocer el vicio del acto (antes, con el Código de Vélez, era un año).

Resumen: En el fraude, a diferencia de la simulación, el acto es plenamente real: el deudor efectivamente enajena un bien, pero lo hace para colocarse en insolvencia y eludir a sus acreedores; por eso la sanción no es la nulidad, sino la inoponibilidad, que deja vigente el acto entre las partes y solo lo desconoce frente al acreedor que promovió la acción, protegiendo siempre al adquirente de buena fe y a título oneroso.

78.12. Comparación entre simulación, fraude y acción subrogatoria

Para cerrar el estudio de los vicios de los actos jurídicos, corresponde comparar la acción de simulación, la acción por fraude y la acción subrogatoria (esta última no es, en rigor, un vicio, pero guarda cierto parentesco con las anteriores).

Cuadro 78.2: Simulación, fraude y acción subrogatoria

Criterio	Simulación	Fraude	Acción subrogatoria
¿A quién beneficia?	A todos los acreedores (vuelve el bien al patrimonio del deudor)	Solo al acreedor que la ejerce	A todos los acreedores
¿En nombre de quién se ejerce?	En derecho propio del acreedor	En derecho propio del acreedor	Por el derecho del deudor (por ejemplo, cobrar una herencia)
¿Requiere insolvencia del deudor?	No la requiere	Sí la requiere	No la requiere; requiere inacción del deudor
Acción que persigue	La nulidad del acto	La inoponibilidad del acto	El fin propio del derecho que se ejerce (por ejemplo, la herencia)
¿Quién puede ejercerla?	Cualquier persona con interés (por ejemplo, herederos entre sí)	El acreedor con interés	El acreedor con interés

Con esta comparación se cierra el estudio de los vicios de los actos jurídicos. Lo que sigue en las próximas unidades son los supuestos de ineficacia y, sobre todo, el estudio de la nulidad como el gran supuesto de ineficacia civil.

Cuadro Cornell: simulación y fraude, síntesis comparativa

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿En qué se diferencian simulación, fraude y acción subrogatoria?	La simulación persigue la nulidad y beneficia a todos los acreedores; el fraude persigue la inoponibilidad, beneficia solo al acreedor accionante y requiere insolvencia; la acción subrogatoria no es un vicio, se ejerce por el derecho del deudor, no requiere insolvencia sino inacción, y beneficia a todos los acreedores.

Resumen: Ambas figuras, junto con la acción subrogatoria, integran el sistema de protección del patrimonio como garantía común de los acreedores, y sientan las bases conceptuales —nulidad, inoponibilidad, buena y mala fe, título oneroso y gratuito— aplicables a la ineficacia de los actos jurídicos.

Parte XIV

La extinción de las relaciones jurídicas

Así como existen hechos y actos que dan nacimiento a una relación jurídica, existen también hechos y actos que la extinguen. Esta parte estudia el cierre del ciclo de la relación jurídica por tres vías: los hechos ajenos a la voluntad de las partes, los actos jurídicos extintivos y el transcurso del tiempo (prescripción y caducidad).

Capítulo 79

Introducción: el cierre del ciclo de la relación jurídica

79.1. Objeto del tema

El estudio de la parte general del derecho civil comprende el sujeto, el objeto y la causa de las relaciones jurídicas. Dentro de la causa se ubican los **hechos jurídicos**, que dan inicio a las relaciones y producen consecuencias jurídicas. Del mismo modo en que existen hechos y actos que dan nacimiento a una relación jurídica, existen también hechos y actos que, en algún momento, la **extinguen**. Ese es el objeto de esta parte.

Nota

El desarrollo del tema es introductorio: la extinción de las obligaciones se trata con mayor profundidad en **Obligaciones**, y la extinción de los contratos, en **Contratos**.

En materia de hechos jurídicos extintivos se sigue la doctrina de Antonio Aguiar Anzorena.

79.2. Relevancia práctica

La prescripción y la caducidad suelen tratarse al final del estudio de la materia y no siempre se estudian con detenimiento. Sin embargo, tienen una relevancia decisiva en el ejercicio profesional: todo abogado recibirá clientes con una deuda para cobrar, y lo primero que deberá verificar es si la acción sigue vigente o ya prescribió, porque de ello depende toda la estrategia del caso.

Conocer cuándo un contrato puede resolverse, rescindirse o revocarse permite asesorar con precisión en negociaciones, redactar cláusulas de salida seguras y anticipar riesgos. Esta lógica es útil también en la vida cotidiana: saber que las deudas y los reclamos tienen plazos permite tomar decisiones a tiempo (enviar un reclamo antes de que se pierda el derecho, comprender por qué una obligación antigua ya no puede exigirse judicialmente, o entender los efectos de un arrepentimiento en una seña).

79.3. Las tres vías de extinción

Un contrato de alquiler ilustra los tres bloques temáticos.

Ejemplo: El contrato de alquiler

El contrato nace como relación jurídica. Mientras existe, puede extinguirse:

- por un **hecho ajeno a la voluntad** de las partes, por ejemplo si fallece el inquilino y era el único con derecho a habitar el inmueble (**hechos extintivos**);
- por un **acto de voluntad** de las partes, como cuando el inquilino paga todos los meses hasta el final o decide rescindir el contrato antes de tiempo (**actos extintivos**);
- por el **transcurso del tiempo**: si el propietario nunca reclama una deuda de alquileres atrasados, la acción para cobrarla puede prescribir, y si no ejerce ciertos derechos puntuales dentro del plazo que fija la ley, esos derechos caducan (**prescripción y caducidad**).

Los tres bloques constituyen las tres formas en que el derecho explica el final de una misma historia: la de una relación jurídica que nace, vive y en algún momento se apaga.

79.4. Enumeración de la doctrina seguida

Hechos jurídicos extintivos:

- la muerte;
- la imposibilidad (sobrevenida);
- la confusión;
- la compensación;
- la caducidad.

Actos jurídicos extintivos:

- el pago;
- la dación en pago;
- la novación;
- la transacción;
- la renuncia a los derechos;
- la remisión de deuda;
- y, como los tres principales: la resolución, la rescisión y la revocación.

Capítulo 80

Hechos jurídicos extintivos

80.1. La muerte como hecho extintivo

Los efectos jurídicos de la muerte se desarrollan en el capítulo 35; aquí interesa su carácter de hecho que extingue relaciones jurídicas.

La muerte produce la extinción de la persona: finaliza la existencia de la persona humana. Como consecuencia, muchas relaciones jurídicas se extinguen, especialmente los **derechos extrapatrimoniales**.

También se extinguen con la muerte algunos derechos patrimoniales, como el **usufructo**: es un derecho que se constituye de por vida y, por lo tanto, se extingue con la muerte de su titular, sin transmitirse a los herederos.

Importante

El usufructo como excepción a la regla. En materia de derechos patrimoniales, la regla general es que, a la muerte de una persona, su patrimonio se transmite a los herederos, quienes pueden ser instituidos por testamento o por disposición de la ley, existiendo algunos herederos forzosos con derecho a una porción legítima. Sin embargo, esta regla de la transmisión no rige en todos los casos: en algunos supuestos la muerte extingue directamente la relación jurídica, sin transmitirla a nadie. Uno de ellos es el usufructo.

80.2. La imposibilidad sobrevenida

El segundo hecho extintivo es la **imposibilidad**. Debe tratarse de una imposibilidad **sobreviniente** y no inicial: si la imposibilidad existiera desde el comienzo, el acto jurídico no podría formarse válidamente, porque su objeto sería imposible.

> **Artículo 279 del Código Civil y Comercial.** *Los actos jurídicos no pueden tener por objeto un hecho imposible.*

El fundamento de esta regla se expresa en el adagio latino según el cual *a lo imposible nadie está obligado*: lo imposible no puede exigirse.

La imposibilidad sobrevenida, en cambio, se produce una vez que la relación jurídica ya comenzó. Se ubica en el título de las obligaciones del Código Civil y Comercial, en el Libro Tercero.

> **Artículo 955 del Código Civil y Comercial.** *La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad.*

Se trata, entonces, de una extinción **sin responsabilidad**, siempre que la imposibilidad sea absolutamente imprevisible (caso fortuito o fuerza mayor). En cambio, si la obligación se vuelve imposible de cumplir por causas imputables al deudor (por ejemplo, si el deudor no pagó por su propia culpa), el deudor debe responder igualmente.

80.3. La confusión

Definición: Confusión

Hecho extintivo que consiste en que la calidad de **acreedor** y la de **deudor** se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio.

> **Artículos 931 y 932 del Código Civil y Comercial.** *Regulan la extinción de la obligación por confusión, cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio.*

Ejemplo: Juana y su tía

Juana le presta 20.000 dólares a su tía. La tía fallece y Juana es su única heredera. Al heredar, Juana ocupa el lugar de su tía y se convierte, al mismo tiempo, en acreedora y deudora de la misma deuda, porque la tía le debía a ella. La obligación queda confundida y se extingue por confusión.

La confusión extingue la obligación en la proporción en que efectivamente se produce.

80.4. La compensación

Definición: Compensación

Tiene lugar cuando dos personas reúnen, recíprocamente, la calidad de acreedor y de deudor la una de la otra. Sus créditos se compensan hasta el monto de la menor deuda.

Ejemplo: Compensación de créditos recíprocos

Si yo te debo 10.000 y vos me debés 20.000, a partir de ese momento se compensan: vos me debés 10.000, porque 20.000 menos 10.000 es 10.000. Se extinguen ambas deudas, con fuerza de pago, hasta el monto de la menor, y desde el momento en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables.

Se trata de un *hecho* extintivo y no de un acto porque esta situación puede producirse automáticamente, sin que medie una declaración de voluntad expresa de las partes: en ese caso, la compensación opera **de pleno derecho**.

80.5. La caducidad (introducción)

Definición: Caducidad

Pérdida de un derecho por no ejercitarlo en el plazo fijado por la ley. Siempre tiene **fuente legal**.

Este instituto se desarrolla en profundidad junto con la prescripción (véase el capítulo 82). Desde ahora cabe señalar que la caducidad extingue el derecho no ejercido y que, a diferencia de la prescripción, **no se suspende ni se interrumpe**. Existen algunos supuestos, establecidos por la ley, en los que no corre la caducidad.

Importante

No debe confundirse la **caducidad**, que extingue el derecho no ejercido, con la **prescripción liberatoria o extintiva**, que extingue la acción.

La caducidad rige para algunos derechos muy puntuales respecto de los cuales el Código o las leyes especiales establecen que, transcurrido cierto tiempo (generalmente plazos cortos) sin que se ejerza el derecho, este caduca.

Ejemplo: La compensación económica en el divorcio

El derecho a exigir la compensación económica luego de un divorcio está regulado en los artículos 441 y 442 del Código Civil y Comercial. Conforme al artículo 442, la acción para reclamarla caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.

> **Artículo 442 del Código Civil y Comercial.** *La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.*

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

80.6. Cuadro Cornell: hechos jurídicos extintivos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué hechos extinguen relaciones jurídicas sin mediar un acto de voluntad?	La muerte, la imposibilidad sobrevenida, la confusión, la compensación y la caducidad.
¿Por qué el usufructo se extingue con la muerte de su titular?	Porque es un derecho constituido de por vida y no se transmite a los herederos, aunque la regla general sea que el patrimonio sí se transmite.
¿Qué distingue a la imposibilidad sobrevenida de la imposibilidad inicial?	La inicial impide que el acto se forme válidamente, porque el objeto sería imposible (art. 279 CCyC). La sobrevenida ocurre luego de nacida la obligación; si es objetiva, absoluta y definitiva, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad del deudor (art. 955 CCyC). Si se debe a causas imputables al deudor, este responde igualmente.
¿Qué es la confusión?	La reunión de las calidades de acreedor y deudor en una misma persona y en un mismo patrimonio (arts. 931 y 932 CCyC), como en el caso de Juana, que hereda a su tía acreedora.
¿Qué es la compensación y por qué es un hecho extintivo?	La extinción recíproca de créditos entre dos personas que son acreedoras y deudoras entre sí, hasta el monto de la menor deuda. Es un hecho porque puede operar de pleno derecho, sin declaración de voluntad de las partes.
¿Qué es la caducidad y en qué se diferencia de la prescripción?	La pérdida de un derecho por no ejercerlo dentro del plazo fijado por la ley; siempre tiene fuente legal. Extingue el derecho no ejercido, mientras que la prescripción extintiva extingue la acción. No se suspende ni se interrumpe. Ejemplo: art. 442 CCyC (seis meses desde la sentencia de divorcio).

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**

Resumen: los hechos extintivos operan sin necesidad de un acto de voluntad: la muerte (que extingue derechos extrapatrimoniales y algunos patrimoniales, como el usufructo), la imposibilidad sobrevenida (sin responsabilidad si obedece a caso fortuito o fuerza mayor), la confusión (acreedor y deudor en una misma persona), la compensación (créditos recíprocos hasta el monto de la menor deuda) y la caducidad (pérdida del derecho no ejercido en el plazo legal).

Capítulo 81

Actos jurídicos extintivos

Los actos jurídicos extintivos son aquellos que suponen una **declaración de voluntad** dirigida a poner fin a la relación jurídica.

81.1. El pago

El acto extintivo de una obligación por excelencia es el pago.

Definición: Pago

Cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación.

Importante

No debe asociarse el pago sólo con la entrega de dinero en efectivo: **pagar es cumplir con la obligación**.

Ejemplo: El pago no es sólo entregar dinero

Si yo te presto una cosa mueble y vos te comprometés a darme plata a cambio, cuando yo te entrego la cosa pactada estoy pagando, porque cumplo mi obligación; y cuando vos me entregás el dinero, vos también estás pagando. Del mismo modo, si a una persona la contratan para hacer una asesoría de servicios jurídicos, esa persona paga cuando cumple con la prestación de hacer esa asesoría.

81.2. La dación en pago

Definición: Dación en pago

Acto extintivo en el cual el acreedor acepta voluntariamente, en pago, una prestación diversa de la debida.

Ejemplo: Cambiar un servicio por dinero

Me comprometo a prestar servicios jurídicos pero, por un problema, no puedo hacerlo. En lugar de esa prestación, ofrezco dinero al acreedor y este lo acepta en pago de la deuda original. Eso es una dación en pago.

81.3. La novación

Definición: Novación

Extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla. Aparece una cierta modificación y la nueva obligación sustituye a la anterior.

Ejemplo: Reemplazo del objeto de la obligación

Yo debía entregar una cosa determinada y, mediante novación, pactamos que ahora debo entregar otra cosa distinta. Se extingue la primera obligación y aparece la segunda en su reemplazo.

81.4. La transacción

La transacción es un **contrato**. Con ella ya se sale de los artículos ubicados en la parte de las obligaciones (en torno al número 900) para pasar a la parte de contratos especiales, dentro del mismo Libro Tercero, en torno al artículo 1641. Su ubicación como contrato es una novedad del Código actual.

La palabra «transar» tiene en derecho civil y comercial un alcance muy específico: significa poner fin a obligaciones dudosas o litigiosas.

Definición: Transacción

Contrato por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas.

Ejemplo: El accidente de tránsito

Ante un litigio (por ejemplo, un accidente de tránsito) una de las partes reclama una indemnización de 200.000 pesos y la otra ofrece una suma sensiblemente menor. Quien le pone fin a ese litigio, habitualmente, es un juez, que determina qué es lo justo. Pero si las partes desean ponerle fin anticipadamente y llegan a un acuerdo (una de ellas dice «yo reconozco mi responsabilidad, te voy a pagar cien mil pesos» y la otra acepta), están haciendo una transacción. La transacción implica ceder en parte el propio derecho: quien reclamaba 200.000 termina recibiendo 100.000.

En la práctica profesional, un abogado necesita contar con **poder especial** de su cliente para hacer una transacción en su nombre, y existen ciertos contratos que no admiten transacción. Estas cuestiones están reguladas en detalle en el Código y se profundizan en Obligaciones y en Contratos.

81.5. La renuncia

Definición: Renuncia

Acto jurídico extintivo que consiste en la abdicación de un derecho.

> **Artículo 944 del Código Civil y Comercial.** *Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y sólo afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que pueden hacerse valer en juicio.*

Ejemplo: Renunciar a cobrar una deuda

«Te renuncio a cobrarte esa deuda que tengo». Es una liberalidad: en el fondo se está regalando algo, y sigue siendo un acto a título gratuito. Por ello puede ser eventualmente impugnado si hubiera acreedores interesados en que esa deuda sí se cobre.

81.6. La remisión de deuda

Definición: Remisión de deuda

Acto jurídico que se produce cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título en el que consta la deuda (por ejemplo, un pagaré).

81.7. La resolución

La resolución, la rescisión y la revocación son los tres institutos principales con los que se cierra el estudio de los actos jurídicos extintivos.

Definición: Resolución

Extinción de los efectos de la relación jurídica que se produce cuando ocurre un acontecimiento que, conforme a previsiones legales precisas o a pactos de las partes, provoca dicha extinción.

Importante

En derecho civil, «resolución» tiene un alcance técnico: no significa resolver un problema en el sentido de encontrarle una solución, sino **ponerle fin**. En general, la resolución pone fin de manera **retroactiva**: opera hacia atrás, hacia el momento de origen de las actuaciones. Este efecto se denomina, en latín, *ex tunc*.

81.7.1. La cláusula resolutoria (o pacto comisorio)

Es una cláusula de un contrato por la cual las partes tienen la potestad de resolverlo, es decir, de ponerle fin, en caso de que la otra parte no cumpla. Puede ser **expresa** (pactada explícitamente) o **implícita** (presente en todos los contratos bilaterales, aunque nada se haya pactado). También se la conoce como **pacto comisorio**, expreso o implícito.

> **Artículo 1087 del Código Civil y Comercial.** *Todo contrato bilateral tiene implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de él en caso de incumplimiento de una de las partes.*

Los artículos 1086, 1088 y 1089 del Código precisan los requisitos y el modo en que debe ejercerse esta facultad.

Ejemplo: El pintor que no cumplió el día pactado

Se pacta que un pintor venga a pintar una casa el primero de enero. El pintor se toma diez días de vacaciones y recién el diez de enero pretende que se lo acepte igual. El dueño de la casa le dice «usted incumplió porque no vino el día que habíamos pactado» y resuelve el contrato, debiendo notificarlo conforme a los requisitos correspondientes.

Ejemplo: El catering que llega tarde

Se contrata un servicio de catering para un casamiento el día viernes y el proveedor pretende entregar las cosas recién el domingo. El cliente responde: «usted incumplió, yo no le voy a pagar». El proveedor incumplió su parte y, por lo tanto, el cliente tampoco cumple la suya: se resuelve el contrato.

81.7.2. La señal o arras

La señal (también llamada arras) es una suma de dinero que se entrega al inicio de un contrato y que puede tener dos alcances distintos:

- **Facultad de arrepentirse:** debe pactarse expresamente. Quien entregó la señal puede luego arrepentirse y poner fin al contrato (cláusula de arrepentimiento).
- **Función confirmatoria del acto:** es el alcance que se le atribuye si no se pactó nada distinto. Quien entregó la señal debe cumplir todo el contrato igualmente.

Importante

Es muy importante ver cómo se pactó la entrega de la seña, porque de ello depende si el contrato queda firme o si existe la posibilidad de arrepentirse.

> **Artículo 1059 del Código Civil y Comercial.** *Regula la señal o arras: su función confirmatoria y, si así fue pactado expresamente, la facultad de arrepentimiento.*

81.7.3. La condición resolutoria

Es una cláusula que subordina la resolución (es decir, la extinción) de una relación jurídica a un **hecho futuro e incierto**.

81.7.4. La frustración de la finalidad

El Código Civil y Comercial incorpora, como causal de resolución, la frustración definitiva de la finalidad del contrato: cuando el contrato se frustra en su finalidad, la parte perjudicada puede declarar su resolución, siempre que medie una causa extraordinaria en las circunstancias.

> **Artículo 1090 del Código Civil y Comercial.** *Regula la frustración definitiva de la finalidad del contrato como causal de resolución, cuando obedece a una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de su celebración.*

Ejemplo: La pandemia y el casamiento frustrado

Alguien debía entregar algo el diez de abril porque iba a celebrarse un casamiento, y este finalmente no se realizó porque se prohibieron todas las reuniones de personas. Se frustró la finalidad del contrato y la parte perjudicada puede poner fin al acto invocando esa frustración.

81.7.5. La teoría de la imprevisión

La teoría de la imprevisión tiene como antecedente el artículo 1198 del Código de Vélez, que no contenía originalmente este instituto: fue incorporado por la reforma de la ley 17.711. Se aplica cuando la prestación a cargo de una de las partes se torna **excesivamente onerosa** por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato, producida por una causa sobreviniente.

Esta figura se compara con la lesión, que también supone una desproporción entre las prestaciones, aunque se trata de institutos distintos: en la imprevisión, la alteración de las bases del contrato produce una desproporción que torna excesivamente onerosa la posición de una de las partes.

> **Artículo 1091 del Código Civil y Comercial.** *Autoriza, ante la excesiva onerosidad sobreviniente de la prestación, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación.*

Nota

La figura tuvo su apogeo periódicamente en Argentina con los cambios en el dólar y la hiperinflación. Sin embargo, se advierte que la inflación en Argentina «ya no es algo previsible», por lo que el instituto va teniendo, con el tiempo, situaciones de aplicación cada vez más acotadas, porque siempre debe tratarse de algo realmente imprevisible.

81.7.6. Efectos generales de la resolución

La resolución opera, generalmente, en forma **retroactiva** (*ex tunc*).

> **Artículo 1079 del Código Civil y Comercial.** *Salvo disposición legal en contrario, la resolución produce efectos retroactivos, con excepción de las prestaciones cumplidas que quedan firmes en cuanto resulten equivalentes.*

Si ya se han cumplido determinadas prestaciones y quedaron firmes, la resolución no las alcanza. En esto se diferencia de las dos figuras siguientes (rescisión y revocación), que operan hacia el futuro.

81.8. La rescisión

Definición: Rescisión

Forma de extinción que opera a futuro: no tiene efectos retroactivos. Puede ser bilateral o unilateral, en los casos autorizados por la ley.

> **Artículo 1079 del Código Civil y Comercial (efectos de la extinción por declaración de una de las partes).** *La rescisión opera a futuro. Excepto estipulación en contrario, sólo produce efectos para el futuro y no afecta el derecho de terceros.*

Ejemplo: Rescisión bilateral: un contrato de servicios jurídicos

Se trata, generalmente, de contratos de tracto sucesivo: por ejemplo, un contrato de servicios jurídicos que se viene pagando todos los meses. Un día, ambas partes deciden rescindirlo de común acuerdo. Eso es una rescisión bilateral.

Ejemplo: Rescisión unilateral: el contrato de alquiler

El contrato puede extinguirse total o parcialmente por la sola declaración de una de las partes, en los casos en que el propio contrato o la ley le otorgan esa facultad. El ejemplo típico es el contrato de alquiler, que puede ser rescindido por el inquilino con cierto preaviso, a partir de los seis meses de celebrado el contrato: la ley concede unilateralmente al locatario la potestad de rescindir.

81.9. La revocación

Definición: Revocación

Acto jurídico unilateral mediante el cual una de las partes deja sin efecto la relación por su exclusiva voluntad. Al igual que la rescisión, es unilateral y produce efectos a futuro: no es retroactiva.

Ejemplo: El mandato revocado

Se contrata a un abogado para que actúe en nombre de una persona (mandato). En un momento se produce un quiebre de la confianza, o simplemente existe la voluntad de no continuar con esa representación, y se revoca el mandato. Todo lo que el abogado hizo

en nombre del mandante hasta ese momento es válido, porque tenía mandato vigente; pero desde el día en que se revoca, ya no tiene mandato para actuar en su nombre.

Ejemplo: El testamento revocado

Una persona otorga un testamento válido. Mientras vive, puede revocarlo y otorgar otro nuevo, quedando revocado el anterior.

81.9.1. Cuadro comparativo: resolución, rescisión y revocación

Criterio	**Resolución**	**Rescisión / Revocación**
Efectos en el tiempo	Retroactivos (*ex tunc*)	Hacia el futuro (*ex nunc*)
Origen típico	Incumplimiento, condición, frustración de la finalidad, imprevisión	Acuerdo de partes o facultad legal / contractual unilateral
Partes involucradas	Puede requerir declaración de la parte cumplidora	Rescisión: bilateral o unilateral. Revocación: unilateral
Prestaciones ya cumplidas	En principio quedan sin efecto, salvo equivalencia	Quedan firmes; no se retrotraen

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

81.10. Cuadro Cornell: actos jurídicos extintivos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es el acto extintivo por excelencia?	El pago: el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. No se limita a la entrega de dinero: pagar es cumplir con la obligación.
¿Qué diferencia a la dación en pago de la novación?	En la dación en pago el acreedor acepta voluntariamente una prestación distinta de la debida. En la novación nace una obligación nueva que reemplaza y extingue a la anterior.
¿Qué es la transacción?	Un contrato (ubicado en torno al art. 1641 CCyC) por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas, evitando o poniendo fin a un litigio. El abogado necesita poder especial de su cliente para transar.
¿Qué diferencia a la renuncia de la remisión de deuda?	La renuncia es la abdicación de un derecho conferido por la ley, cuando no está prohibida y sólo afecta intereses privados (art. 944 CCyC); puede ser una liberalidad a título gratuito. La remisión de deuda es la entrega voluntaria, por el acreedor, del título en el que consta la deuda.
¿Qué efecto tiene la resolución sobre la relación jurídica?	Un efecto retroactivo (*ex tunc*), salvo las prestaciones ya cumplidas que resulten equivalentes y queden firmes (art. 1079 CCyC).
¿Qué formas o causas puede adoptar la resolución?	La cláusula resolutoria o pacto comisorio (expreso o implícito, art. 1087 CCyC), la señal o arras (art. 1059 CCyC), la condición resolutoria, la frustración de la finalidad (art. 1090 CCyC) y la teoría de la imprevisión (art. 1091 CCyC).
¿Cómo influye la forma en que se pactó la señal?	Si se pactó expresamente como facultad de arrepentirse, quien la entregó puede poner fin al contrato. Si no se pactó nada distinto, es confirmatoria del acto y quien la entregó debe cumplir todo el contrato.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Cuándo se aplica la teoría de la imprevisión?	Cuando la prestación de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al celebrarse el contrato, producida por una causa sobreviniente e imprevisible.
¿Qué diferencia a la rescisión y a la revocación de la resolución?	Ambas operan hacia el futuro (*ex nunc*), sin efecto retroactivo. La rescisión puede ser bilateral o unilateral; la revocación es unilateral (ejemplos: mandato, testamento).

Resumen: los actos extintivos requieren una declaración de voluntad. El pago cumple la obligación; la dación en pago la satisface con una prestación distinta; la novación la reemplaza por otra nueva; la transacción pone fin a obligaciones dudosas o litigiosas mediante concesiones recíprocas; la renuncia abdica un derecho y la remisión entrega el título de la deuda. La resolución opera hacia atrás (*ex tunc*); la rescisión y la revocación, hacia el futuro.

Capítulo 82

Prescripción y caducidad

82.1. Importancia de la prescripción en la práctica

La prescripción es un instituto de enorme importancia que, por tratarse generalmente al final de la materia, no siempre se estudia con detenimiento; sin embargo, tiene una relevancia decisiva en la vida profesional del abogado.

Ejemplo: El cliente que llega con una deuda vieja

Un cliente llega con una deuda y pregunta: «¿yo tengo derecho a cobrar esto? Hace tiempo que pasó, alguna vez le mandé un mensajito para reclamarla». El abogado pregunta cuánto tiempo pasó y a veces la respuesta es «como cinco años». Ahí hay que advertir que pueden quedar apenas tres días antes de que la deuda prescriba, y actuar con urgencia. Por eso, lo primero que hay que revisar al recibir a un cliente son las **fechas**.

El fundamento de la prescripción es que existe la expectativa de que los derechos se ejerzan en un tiempo oportuno: no se puede vivir con la indeterminación de que en cualquier momento alguien venga a reclamar algo pasado un tiempo indefinido. La inacción hace presumir, por ley, que decayó el interés en ejercer el derecho. Si una persona tiene una deuda a su favor y pasan veinte años sin reclamarla, ya no parece tener tanto interés en cobrarla, y esto hace que la deuda (más precisamente, la acción para reclamarla) prescriba.

82.2. Prescripción adquisitiva y prescripción extintiva

Definición: Prescripción

Instituto jurídico en virtud del cual el transcurso del tiempo opera la adquisición de un derecho, o la extinción de la acción por la inacción del titular del derecho.

La prescripción está tratada en el Libro Sexto, Título Primero del Código Civil y Comercial, que reúne las disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Tiene dos grandes formas, la **adquisitiva** y la **extintiva o liberatoria**, que comparten algunos elementos comunes (sobre todo, la idea del transcurso del tiempo unida a una cierta inacción) pero presentan muchas diferencias entre sí y persiguen finalidades distintas. El énfasis de esta parte está en la prescripción extintiva o liberatoria.

82.2.1. La prescripción adquisitiva (usucapión)

Definición: Prescripción adquisitiva (usucapión)

Modo por el cual, mediante la posesión de una cosa reunidas ciertas condiciones, se puede adquirir el dominio, ante el manifiesto desinterés del propietario en la atención, cuidado y vigilancia del bien.

Está regulada en el Libro Cuarto, sobre Derechos Reales, y se profundiza en esa materia.

Definición: Posesión

Relación real: la que se tiene directamente con la cosa en los hechos, es decir, el *corpus* (la detentación material de algo), unida al *animus domini* (el ánimo de comportarse como dueño de la cosa, sin reconocer en ningún otro un derecho superior).

> **Artículos 1898 y 1899 del Código Civil y Comercial.** *Para la prescripción adquisitiva de inmuebles, el plazo común es de veinte años de posesión continua e ininterrumpida, sea de buena o de mala fe. Existe un plazo más corto de diez años cuando el poseedor cuenta con justo título y buena fe.*

Para las cosas muebles rigen plazos distintos: si la cosa fue hurtada o perdida, el plazo de prescripción adquisitiva es de dos años; si se trata de una cosa mueble registrable, el plazo es de diez años.

Ejemplo: El automóvil poseído por más de diez años

Una persona recibió un automóvil del titular registral o de un funcionario autorizado, de buena fe, y lo posee durante más de diez años sin que conste a su nombre en el registro de la propiedad. Esa persona pasa a tener la propiedad del bien; para ello debe promover un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión), que es un modo de adquirir el dominio.

82.2.2. La prescripción extintiva o liberatoria

Definición: Prescripción extintiva o liberatoria

Extingue la acción por la cual una persona puede reclamar un derecho, por el transcurso del tiempo fijado por la ley y la inacción del titular. Consiste en la falta de ejercicio, en el tiempo, de las acciones tendientes a reclamar los derechos, lo que determina la imposibilidad práctica de ejercerlos en el futuro por el transcurso de los plazos legales.

Importante

La prescripción extintiva extingue la **acción**, y no el derecho, porque puede ocurrir que finalmente se pague una deuda ya prescripta.

Ejemplo: El amigo que paga una deuda de veinte años

Una persona le prestó dinero a un amigo hace mucho tiempo y nunca se lo reclamó; pasaron veinte años. Un día se encuentran y el amigo le cuenta que está pasando una mala situación económica. El otro le dice: «hace veinte años me prestaste esta plata, tomá, te pago lo que te debía», y le paga. Tiempo después, ese amigo fallece y sus herederos preguntan si, por haber pagado una deuda prescripta, corresponde la devolución. La respuesta es que no: no se pagó algo que no se debía. La deuda existía; lo que se había extinguido era solamente la acción para reclamarla judicialmente.

> **Artículo 2538 del Código Civil y Comercial.** *El pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible.*

«Repetible» significa que puede pedirse el reembolso de lo pagado; por lo tanto, lo pagado espontáneamente no puede reclamarse. En el Código Civil anterior, esta situación se llamaba «obligación natural». El nuevo Código evita expresamente ese nombre y utiliza la expresión «pago espontáneo», pero en los hechos sigue siendo la misma idea: una obligación que tiene fundamento en la idea natural de justicia (dar a cada uno lo suyo). La deuda existe; lo que ocurre es que prescribió y ya no es exigible judicialmente. La acción que acompaña al derecho se extingue y el derecho queda desprovisto de acción, pero sigue siendo un derecho que existía.

Consecuencia práctica: cuando la contraparte intenta hacer valer un derecho ya prescripto, el abogado debe oponer la **excepción de prescripción**, defensa procesal por la cual se señala al juez que esa acción está prescripta y por qué motivos.

82.2.3. Reglas generales sobre la prescripción

Las normas de prescripción son **imperativas**: no pueden ser modificadas por las partes. No se puede pactar, por ejemplo, que una deuda sea imprescriptible.

> **Artículo 2533 del Código Civil y Comercial.** *Las normas relativas a la prescripción no pueden ser modificadas por convención de las partes.*

La prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, salvo disposición legal en contrario. En las obligaciones con sujetos múltiples (varios acreedores o varios deudores) cualquier acreedor puede oponer la prescripción, aunque el obligado no la invoque, y esta puede también renunciarse.

La renuncia a la prescripción sólo puede hacerse una vez que la prescripción ya se ganó: la persona a cuyo favor corrió el plazo puede renunciar a invocarla, de modo similar a la renuncia como acto extintivo. La prescripción puede ser invocada en todos los casos, salvo en los supuestos en que la ley indique expresamente lo contrario.

82.3. Suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción

Es muy importante distinguir dos categorías de hechos que pueden incidir sobre el cómputo del plazo de prescripción: los **hechos suspensivos** y los **hechos interruptivos**.

82.3.1. La suspensión

Definición: Suspensión del cómputo

Detiene el conteo del tiempo mientras dura la causa suspensiva, pero aprovecha (conserva) el período ya transcurrido antes de que la suspensión comenzara.

> **Artículo 2539 del Código Civil y Comercial.** *La suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el período transcurrido hasta que ella comenzó.*

Ejemplo: Cómo se cuenta un plazo suspendido

El plazo de prescripción empieza a correr el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017 ocurre un hecho suspensivo que dura un año: el cómputo se detiene ese día. El tramo ya corrido (del 1 de enero al 30 de junio de 2017) es válido y se conserva. Cuando, un año después, el 30 de junio de 2018, se reanuda el cómputo, se sigue contando desde el sexto mes en adelante, sin perder el tiempo ya corrido.

Supuestos de suspensión

- **Interpelación fehaciente.** Es el acto típico del abogado que recibe un caso y reclama la deuda al deudor (o al poseedor) de manera extrajudicial, mediante carta documento o acta notarial, con fuerza probatoria hacia terceros. Suspende el cómputo **por una sola vez y por seis meses**.

> **Artículo 2541 del Código Civil y Comercial.** *La interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor suspende la prescripción por seis meses, por una sola vez.*

- **Pedido de mediación.** Suspende el cómputo durante todo el tiempo que dura el trámite de mediación y hasta veinte días después de que se labra el acta de cierre, momento en el cual se reanuda el cómputo del plazo.

> **Artículo 2542 del Código Civil y Comercial.** *El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la solicitud de mediación, hasta veinte días contados desde el momento en que el acta que da por concluido el procedimiento se encuentre a disposición de las partes.*

- **Otros supuestos especiales.** Se trata de vínculos de confianza en los que los conflictos de interés dificultan ejercer acciones entre sí. Están suspendidas las acciones:

- entre cónyuges, mientras dura el matrimonio, para no sumar un motivo más a las disputas conyugales;
- entre convivientes en unión convivencial;
- entre las personas con capacidad restringida y sus representantes, apoyos o tutores, mientras dura la responsabilidad parental, la tutela o la curatela;
- entre las personas jurídicas y sus administradores;
- a favor y en contra de los herederos, mientras dure la respectiva situación.

> **Artículo 2543 del Código Civil y Comercial.** *Enumera los supuestos especiales de suspensión de la prescripción entre cónyuges, convivientes, personas con capacidad restringida y sus representantes o apoyos, personas jurídicas y sus administradores, y a favor y en contra de los herederos.*

82.3.2. La interrupción

Definición: Interrupción del cómputo

A diferencia de la suspensión, tiene por no sucedido el lapso que la precede e inicia un nuevo plazo. Es decir, invalida todo el tiempo ya transcurrido.

Ejemplo: Cómo se cuenta un plazo interrumpido

La prescripción empezó a correr el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017 ocurre un hecho interruptivo que dura un año. Cuando finaliza ese hecho, el cómputo empieza de cero: no se aprovecha nada del tiempo ya transcurrido. Esto es lo que distingue, en la práctica, a la interrupción de la suspensión.

Supuestos de interrupción

- **Reconocimiento de deuda.** Cuando la persona obligada firma un documento en el que reconoce la deuda.

> **Artículo 2545 del Código Civil y Comercial.** *El curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento que el deudor o poseedor efectúa del derecho de aquel contra quien prescribe.*

- **Petición judicial.** Se interrumpe la prescripción por toda petición del titular del derecho ante la autoridad judicial que traduzca la intención de no abandonar el derecho.

> **Artículo 2546 del Código Civil y Comercial.** *La petición judicial interrumpe la prescripción, aunque sea defectuosa, realizada por quien no es capaz o ante un tribunal incompetente, y aunque se presente dentro del plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal.*

La redacción del nuevo Código es muy amplia para describir este supuesto: **no se exige necesariamente una demanda** en sentido estricto, sino cualquier petición que traduzca

la intención de no abandonar el derecho; puede bastar, por ejemplo, una verificación de crédito en un proceso sucesorio. Interrumpir resulta más beneficioso para el acreedor que suspender, porque invalida todo el tiempo transcurrido y hace que se cuente todo de nuevo.

Sobre el plazo de gracia: los plazos procesales vencen a las 24 horas, pero como los tribunales dejan de funcionar antes, se habilitan las dos primeras horas hábiles del día siguiente para presentar el escrito dentro de ese plazo, lo que se conoce habitualmente como «las dos primeras».

- **Solicitud de arbitraje.** Equivale, en los hechos, a interponer una demanda o a un reconocimiento de deuda, y también interrumpe el cómputo de la prescripción.

> **Artículo 2548 del Código Civil y Comercial.** *La solicitud de arbitraje interrumpe la prescripción.*

82.3.3. Cuadro comparativo: suspensión e interrupción

Criterio	Suspensión	Interrupción
Tiempo ya transcurrido	Se conserva (se aprovecha)	Se invalida por completo
Reinicio del cómputo	Continúa sumando desde donde se detuvo	Empieza de cero
Supuestos	Interpelación fehaciente, mediación, causas entre cónyuges y convivientes, entre otras	Reconocimiento de deuda, petición judicial, solicitud de arbitraje

82.4. La dispensa y los plazos de prescripción

82.4.1. La dispensa

Definición: Dispensa

Tercer supuesto, distinto de la suspensión y de la interrupción. A diferencia de ambas, ocurre una vez que la prescripción ya se cumplió, cuando por alguna circunstancia extraordinaria era imposible ejercer la acción en el momento en que finalizaba el plazo.

En el Código anterior este supuesto se trataba como un caso de suspensión. El nuevo Código lo clarifica y lo llama **dispensa**: la doctrina ya interpretaba que se trataba de un supuesto de dispensa, y ahora se lo ubica claramente como tal.

> **Artículo 2550 del Código Civil y Comercial.** *El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras*

> *dolosas le obstaculizaron temporalmente el ejercicio de la acción, y si el titular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos.*

Ejemplo: La persona postrada en un hospital

Se debe recurrir ante un juez y explicarle, por ejemplo: «yo estaba en cama, totalmente postrado, al momento en que prescribía esta acción, y me era imposible ejercerla». Si el juez entiende que existieron esas circunstancias extraordinarias, concede una dispensa que permite iniciar la acción dentro de los seis meses siguientes. Apenas la persona sale del hospital, inicia la demanda y pide la dispensa de la prescripción.

La dispensa se aplica también a personas incapaces sin representante: por ejemplo, un niño de cinco años, sin representantes, que tenía que cobrar ciertas deudas; en ese caso se espera a que existan representantes que puedan actuar en su nombre.

Importante

La diferencia central con la suspensión y la interrupción es que la dispensa se **tramita ante un juez** y recae sobre una prescripción ya cumplida.

82.4.2. Los plazos de prescripción

Se han visto distintos plazos de prescripción a lo largo de las clases. Por ejemplo, la acción por vicios tiene un plazo de prescripción de dos años. El plazo genérico es de cinco años.

> **Artículo 2560 del Código Civil y Comercial.** *El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.*

A partir de los artículos siguientes, el Código regula distintos plazos especiales, desde más largos hasta más cortos, según el tipo de acción de que se trate.

En general, el cómputo del plazo corre desde el día en que la prestación es **exigible**, salvo distintas excepciones:

- en el caso de la violencia, el plazo comienza a correr desde que cesa la violencia;
- en la simulación entre las partes, el plazo corre desde que una de ellas desconoce el carácter simulado del acto.

Importante

Es un tema importantísimo, porque es la fecha a partir de la cual se cuenta todo.

82.5. La caducidad en profundidad

La caducidad es también una forma de operar del transcurso del tiempo, pero produce la extinción de un **derecho no ejercido**, no de la acción, como ocurre en la prescripción.

Los plazos de caducidad están fijados específicamente por la ley: no todos los derechos tienen un plazo de caducidad, sino solamente aquellos respecto de los cuales la ley expre-

samente lo determina. Un ejemplo es el del artículo 442 sobre la compensación económica en materia de divorcio, cuya acción caduca a los seis meses de dictada la sentencia.

> **Artículo 2567 del Código Civil y Comercial (régimen general de caducidad).** *Los plazos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen, excepto disposición legal en contrario.*

La caducidad no admite suspensión ni interrupción y, en general, sus plazos son más cortos que los de la prescripción.

Hay actos que impiden que se produzca la caducidad: el cumplimiento del acto previsto por la ley, la realización del acto jurídico correspondiente, o el reconocimiento del derecho por parte de quien podría beneficiarse de la caducidad.

Al igual que la prescripción, las normas sobre caducidad establecidas por la ley son, en general, **imperativas**: las partes no pueden renunciarla ni alterarla por disposición contractual cuando la caducidad proviene de la ley (sí es disponible cuando surge de la voluntad de las partes).

Cuando concurren, sobre un mismo supuesto, normas de caducidad y de prescripción, **priman las de caducidad**, y para lo no regulado se aplican, supletoriamente, las normas relativas a la prescripción.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

82.6. Cuadro Cornell: prescripción y caducidad

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la prescripción?	El instituto por el cual el transcurso del tiempo opera la adquisición de un derecho (prescripción adquisitiva) o la extinción de la acción por inacción del titular (prescripción extintiva o liberatoria). Se trata en el Libro Sexto, Título Primero del CCyC.
¿Qué diferencia hay entre prescripción adquisitiva y extintiva?	La adquisitiva otorga el dominio por la posesión de una cosa (para inmuebles: veinte años, o diez con justo título y buena fe). La extintiva extingue la acción para reclamar un derecho, no el derecho en sí mismo.
¿Puede pagarse válidamente una deuda ya prescripta?	Sí. El pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible (art. 2538 CCyC): el derecho existía y sólo se había extinguido la acción para exigirlo judicialmente. Si se intenta reclamar un derecho prescripto, debe oponerse la excepción de prescripción.
¿Pueden las partes modificar las normas de prescripción?	No. Son imperativas y no pueden modificarse por convención de las partes (art. 2533 CCyC). La renuncia a la prescripción sólo puede hacerse una vez que esta ya se ganó.
¿Qué diferencia a la suspensión de la interrupción del cómputo?	La suspensión detiene el cómputo pero conserva el tiempo ya transcurrido (art. 2539 CCyC); la interrupción invalida todo lo transcurrido y reinicia el plazo desde cero.
¿Qué hechos suspenden la prescripción?	La interpelación fehaciente (seis meses, una sola vez, art. 2541 CCyC), el pedido de mediación (hasta veinte días después del acta de cierre, art. 2542 CCyC) y ciertas situaciones entre cónyuges, convivientes, personas con capacidad restringida y sus representantes, personas jurídicas y sus administradores, y herederos (art. 2543 CCyC).

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué hechos interrumpen la prescripción?	El reconocimiento de deuda (art. 2545 CCyC), la petición judicial, interpretada en sentido amplio y aun si es defectuosa (art. 2546 CCyC), y la solicitud de arbitraje (art. 2548 CCyC).
¿Qué es la dispensa de la prescripción?	Una autorización judicial para ejercer la acción dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos, pese a que el plazo de prescripción ya se cumplió, cuando existió una imposibilidad de hecho justificada (por ejemplo, una internación) (art. 2550 CCyC).
¿Cuál es el plazo genérico de prescripción y desde cuándo se cuenta?	Cinco años (art. 2560 CCyC), salvo que esté previsto uno diferente; existen plazos especiales, más largos y más cortos. En general se cuenta desde que la prestación es exigible, con excepciones (violencia, simulación entre las partes).
¿Por qué la caducidad es más rígida que la prescripción?	Porque no admite suspensión ni interrupción (art. 2567 CCyC), sus plazos suelen ser más breves y extingue el derecho no ejercido, no sólo la acción. Cuando concurren normas de caducidad y de prescripción, priman las de caducidad.

Resumen: el transcurso del tiempo puede hacer adquirir un derecho (prescripción adquisitiva) o extinguir la acción por la inacción del titular (prescripción extintiva), que deja subsistente un derecho sin acción. El cómputo puede detenerse (suspensión, que conserva el tiempo corrido), reiniciarse (interrupción, que lo invalida) o ser habilitado judicialmente una vez cumplido el plazo (dispensa). La caducidad extingue el derecho no ejercido en el plazo legal, de manera más rígida e imperativa.

82.7. Síntesis de la extinción de las relaciones jurídicas

El tema recorre el cierre del ciclo de vida de las relaciones jurídicas: cómo terminan, después de haber nacido y desarrollado sus efectos. Ese final puede producirse:

- por **hechos ajenos a la voluntad** de las partes: la muerte, la imposibilidad sobrevenida, la confusión o la compensación;
- por **actos jurídicos** mediante los cuales las partes deciden ponerle fin a la relación: el pago y la dación en pago, que la cumplen; la novación, que la reemplaza; la transacción y la renuncia, que ceden derechos; la remisión, que perdona una deuda; y la resolución,

la rescisión y la revocación, que la dejan sin efecto, hacia atrás o hacia adelante según el caso;

- por el simple **transcurso del tiempo**, que castiga la inacción del titular de un derecho a través de la prescripción (que extingue la acción, pero no siempre el derecho) y de la caducidad (que extingue directamente el derecho no ejercido, de manera más rígida e imperativa).

El hilo conductor es la idea de que ningún derecho puede sostenerse en una incertidumbre indefinida: el ordenamiento jurídico necesita fijar, tarde o temprano, un punto final, ya sea porque los hechos de la vida lo imponen, porque las partes lo deciden o porque el tiempo, por sí solo, se encarga de hacerlo. Comprender estas reglas, y sobre todo los plazos y las causales de suspensión, interrupción y dispensa de la prescripción, es una de las herramientas de mayor relevancia práctica en el ejercicio cotidiano de la abogacía.

Apéndice A

Normativa citada en las fuentes

Las fuentes de estos apuntes no incluyen bibliografía doctrinal en forma de lista; se conservan únicamente las referencias normativas y de autores efectivamente mencionadas en el texto. Se agrupan aquí las principales normas citadas. Los artículos del Código Civil y Comercial que se citan en cada tema se indican en el capítulo correspondiente.

- Constitución Nacional: arts. 19, 75 inc. 22 y 75 inc. 23.
- Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994): Título Preliminar (arts. 1 a 18) y, entre otros, los arts. 19 a 21, 22 a 32, 33 a 48, 51, 57, 62 a 72, 73 a 78, 98, 101, 103, 332, 344, 386, 423, 574, 584, 591, 592, 597, 639, 641, 644, 684, 958, 960, 1002, 1004, 1014, 1742, 2279 y 2600.
- Código Civil de Vélez Sarsfield (Ley 340) y sus reformas: arts. 3, 4, 5, 30, 51, 63, 70, 141, 152 bis, 152 ter, 954, 4044 y 4045.
- Leyes: 11.723, 14.394, 17.711, 18.248, 19.550, 20.321, 20.337, 21.173, 21.541, 21.745, 23.264, 23.515, 23.849, 24.193, 25.326, 25.506, 26.061, 26.378, 26.390, 26.413, 26.529, 26.579, 26.657, 26.742, 26.743, 26.994, 27.077, 27.364 y 27.447.
- Otras disposiciones: Decreto 1089/2012; Resolución 716/2019 (Ministerio de Salud); Resolución IGJ 7/2015.
- Instrumentos internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Jurisprudencia citada: *Artavia Murillo y otros c. Costa Rica* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012); fallo *Reina* (Corte Suprema, 1956).